

스터디파이터

2차 보상법규

행정법

제1판 2024.12.24

01

PART

행정법 개관

제1장 행정과 행정법

제1절	행정법 개념 및 분류	001
제2절	행정법의 특성	002

제2장 행정의 법원

003

제3장 행정의 법 원칙

제1절	법치행정의 원칙	004
제2절	평등의 원칙	006
제3절	비례의 원칙	008
제4절	성실의무 및 권한남용금지의 원칙	009
제5절	신뢰보호의 원칙	009
제6절	부당결부금지의 원칙	012

제4장 행정법 관계

제1절	공법관계와 사법관계	013
제2절	행정법 관계의 당사자	014
제3절	공권	015
제4절	사인의 공법행위	017

02

PART

행정작용법

제1장 행정입법

제1절	일반론	021
제2절	법규명령	021
제3절	행정규칙	026
제4절	형식과 실질의 불일치 (형식 ≠ 실질)	027

제2장 행정행위

제1절	개념	031
제2절	행정행위의 요건과 효력	038
제3절	행정행위의 하자	043
제4절	행정행위의 폐지 및 실효	052
제5절	행정행위의 부관	057
제6절	확약	065

제3장 행정계획

제1절	개념	067
제2절	법적성질	067
제3절	계획재량	069
제4절	계획보장청구권	071

제4장 인·허가의의제 제도

제1절	의의 및 취지	073
제2절	법적근거	073
제3절	행정계획의 집중효와 구별	074
제4절	집중효의 정도	074
제5절	인·허가 의제의 효과	076

03

PART

행정절차와 실효성 확보

제1장 행정절차법

제1절	일반론	079
제2절	사전통지	079
제3절	의견청취	081
제4절	이유제시	083
제5절	절차상 하자	085

제2장 행정의 실효성 확보수단

제1절	행정의 실효성 확보수단	087
제2절	대집행	090
제3절	과징금	097
제4절	명단의 공표	099
제5절	행정조사	101

04

PART

행정구제법

제1장 개설

제1절	행정구제의 개념	105
제2절	행정구제의 종류	105

제2장 행정심판

제1절	개념	016
제2절	이의신청과 행정심판	016
제3절	행정심판의 종류	109
제4절	행정심판의 청구기간	111
제5절	행정심판의 재결	113
제6절	재결의 효력	115
제7절	재결의 불복	119
제8절	행정심판법상 가구제	120
제9절	고지제도	121

제3장 행정소송

제1절	개관	123
제2절	취소소송	124
제3절	무효등확인소송	162
제4절	부작위위법확인소송	165
제5절	당사자소송	169
제6절	기타	170

제4장 행정상 손해전보

1절	행정상 손해배상	173
2절	행정상 손실보상	180
3절	행정상 결과제거청구	180

05

PART

도시 및 주거환경정비법

제1장 개설

제1절	의의 및 종류	183
제2절	재개발사업과 재건축사업의 차이	183
제3절	정비사업의 절차	184
제4절	조합설립인가	185
제5절	사업시행계획인가	187
제6절	관리처분인가	189
제7절	현금청산	191
제8절	이전고시 관련 판례	194

PART 01

행정법 개관

Chapter 01 행정과 행정법

Chapter 02 행정의 법원

Chapter 03 행정의 법 원칙

Chapter 04 행정법 관계

제1절

행정법의 개념 및 분류

행정법이란 행정에 관한 법이자 공법이며, 국내법이다. 여기서 행정이란 정부가 하는 모든 작용을 말하는데, 행정법은 이러한 행정을 대상으로 한 법이다. 행정법은 프랑스, 독일 등의 대륙법계 국가와 영미법계 국가가 서로 다르게 성립·발전하여 왔으며, 우리나라는 특히 대륙법계인 독일법의 영향을 많이 받았다. 행정법은 다양하게 분류할 수 있는데, 적용분야와 그 내용을 기준으로 다음과 같이 분류할 수 있다.

01 일반행정법과 특별행정법

- ① 일반행정법은 모든 행정분야에 공통적으로 적용되는 표준적인 법규와 법 원칙을 말한다.
예로는 행정기본법, 행정절차법 등이 있다.
- ② 특별행정법은 공무원법, 도로법 등 공행정의 개별적인 분야에 적용되는 법을 말한다.

02 행정조직법, 행정작용법, 행정구제법

- ① 행정조직법은 행정을 위한 전제로 필요한 행정의 조직 구성과 조직의 권한을 정하는 법을 말한다.
- ② 행정작용법은 행정주체가 행정의 상대방에게 행정작용을 함에 있어 필요한 권리와 의무를 정하는 법을 말한다.
- ③ 행정구제법은 행정작용으로 인한 개인의 권리침해에 대한 구제에 관한 법을 말한다.
예로는 국가배상법, 행정소송법, 행정심판법 등이 있다.

※ 행정작용이란?

행정주체가 행정목적 달성을 위해 행하는 일체의 법률적, 사실적 작용을 의미한다.

예 행정입법, 행정행위, 행정계획, 공법상 계약, 사실행위 등

※ 개별적·구체적이란? (비교개념을 통한 이해)

일반과 개별 : 사람을 기준 → 일반은 불특정 다수인을, 개별은 특정인을 말한다.

추상과 구체 : 사건을 기준 → 추상은 불특정 다수의 사건을, 구체는 특정 사건을 말한다.

행정법은 행정에 관한 법으로, 행정이라는 행위의 성격상 공익성이 크고 국민의 권리·의무와 관련성이 높다. 이러한 성격으로 인해 행정법이 갖는 몇 가지 특성이 있는데 이를 살펴보자.

01 규정의 성문성

국민의 예측 가능성의 보장과 법적 안정성의 도모를 위해 규정이 성문화 된다.

02 형식의 다양성

행정법을 구성하는 법의 형식은 헌법, 법률, 조례 등 다양하다.

03 내용의 공익성

행정법은 공익 실현을 기본적인 목적과 내용으로 한다.

04 행정주체의 우월성

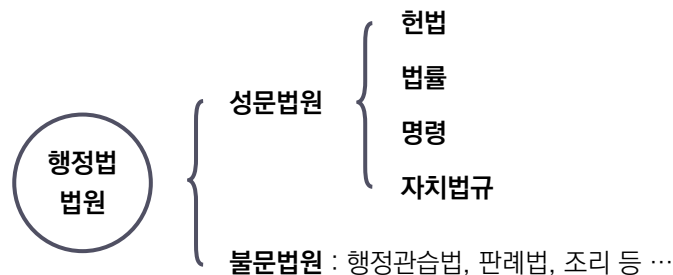
행정주체는 행정권 발동에 있어 우월한 법적 지위를 가진다.

05 행위규범성

행정법은 국가와 국민 사이의 권리·의무를 설정하고 국가기관의 활동에 근거를 제공한다.
(이에 반해 사법(私法)은 재판규범으로서의 성격이 강하다)

법원(法源)이란 법의 존재 형식 또는 인식근거를 의미하며, 법원은 조문의 형태로 존재하는 성문법원과 관습법 등의 형태로 존재하는 불문법원이 있다. 행정을 함에 있어서는 국민의 예측가능성과 법적 안정성이 중요하고, 공정한 행정권의 행사와 국민의 권리구제의 실효적 보장을 위해 명확한 기준이 필요하게 된다. 이에 행정법은 성문법으로 규율되어야 하나, 행정의 규율대상이 복잡·다양하여 내용상 불문법에 의해 보완되어 진다.

행정법의 성문법원에는 헌법, 법률, 명령, 자치법규 등이 있으며, 이들은 헌법을 최고 정점으로 하여 통일적, 단계적 구조를 이루고 있다. 하위법은 상위법에 맞게 해석하여야 하며, 법령 사이에 상호 모순이 있을 때는 상위법이 우선한다. 불문법에는 행정관습법, 판례법, 조리를 들 수 있으며, 이는 중요한 보충적 법원이 된다.



01 헌법

국가의 기본법으로서 최고규범이다.

02 법률

국회가 제정한 법률로서, 법률이 충돌할 경우 특별법이 일반법보다 우선하고, 신법이 구법보다 우선한다.

03 명령

행정권에 의해 제정되는 법형식을 말한다. 행정입법이라고 하며, 법규성의 유무를 기준으로 법규명령(법규성 긍정)과 행정규칙(법규성 부정)으로 구분할 수 있다.

04 자치법규

지방자치단체가 법령안에서 제정하는 법규로서, 지방의회가 제정하는 조례와 지방자치단체 장이 정하는 규칙이 있다.

제1절

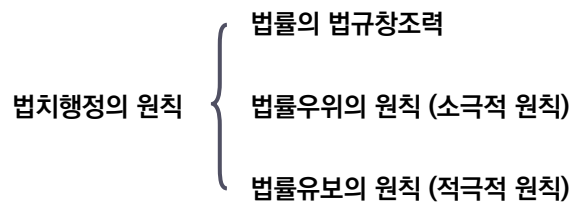
법치행정의 원칙 (「행정기본법」제8조)

01 일반론

법치주의란 행정이 법률의 범위 내에서 이루어져야 한다는 원칙으로 **정당한 법에 의한 통치**를 하여야 한다는 통치 원리를 말한다. 법치주의는 협의로는 지배자의 자의 배제를 목적으로 공권력의 행사는 의회가 제정한 법률에 따라야 한다는 형식적 법치주의를 의미하고, 광의로는 법률의 제정과 그 적용에 있어서도 국민의 권리·의무를 최대한 보장할 수 있어야 한다는 실질적 법치주의를 의미한다. 법치행정의 원칙의 내용으로 법률의 법규창조력, 법률우위의 원칙, 법률유보의 원칙이 있다.

[행정기본법] 제8조 (법치행정의 원칙)

행정작용은 법률에 위반되어서는 아니 되며, 국민의 권리를 제한하거나 의무를 부과하는 경우와 그 밖에 국민생활에 중요한 영향을 미치는 경우에는 법률에 근거하여야 한다.



02 법률의 법규창조력

법률의 법규창조력이란 적법한 절차에 따라 **의회에서 제정된 법률만이** 국민의 권리·의무에 영향을 줄 수 있다는 것을 말한다. 헌법 제40조에 따라 법규는 의회에 의해 만들어지고 이러한 법률만이 국민의 권리·의무에 영향을 줄 수 있다. 법률의 법규창조력에 의해 법률이 아닌 관습법, 행정명령, 일반원칙 등으로는 국민의 권리·의무에 영향을 줄 수 없다. 그러나, 오늘날에는 긴급명령처럼 법률적 효력을 갖는 명령을 행정권이 할 수 있는 경우도 있다.

03 법률우위의 원칙

1) 의의 및 근거

법률우위의 원칙이란 모든 행정작용은 **법률에 위반되어서는 안 된다**는 것을 의미한다. 행정의 법률에의 구속성으로 위반시 이는 위법이 되어 무효(법규명령, 조례)나 취소사유(행정행위)가 된다. 실질적 법치주의에 따라 법률의 내용 자체도 헌법에 합치되어야 한다. 근거로는 헌법 제107조 제2항이 있다.

2) 법률의 범위와 적용범위

법률우위의 원칙에서 말하는 법률은 헌법과 국회가 제정한 법률을 말한다. 또한, 헌법 제75조 및 95조에 근거한 법규명령(대통령령·총리령·부령)도 포함되고, 행정법의 일반원칙 등 불문법을 포함한 모든 법규를 의미한다.

행정기본법 제8조에서 적용범위에 대한 제한을 두고 있지 않으므로, 법률우위의 원칙은 모든 행정 영역에 적용된다. 따라서 수익적 행위인지, 침익적 행위인지를 불문하며, 사법형식의 국가작용 및 사실행위에도 적용된다.

3) 위반의 효과

행정작용이 법률우위의 원칙을 위반하면 위법한 행정작용이 된다. 위법한 행정작용의 효력은 행정의 행위형식에 따라 다르게 나타난다. 즉, 행정행위의 경우 중대·명백설에 따라 무효 또는 취소의 대상이 되고 행정입법, 공법상 계약은 특별한 사정이 없는 한 무효가 된다. 또한, 위법한 행정작용으로 손해가 발생한 경우 손해배상책임이 인정될 수도 있다.

04 법률유보의 원칙

1) 의의 및 근거

법률유보의 원칙이란 행정작용은 법률에 근거하여야 한다는 원칙을 의미한다. 법률우위의 원칙은 소극적으로 기존 법률의 침해를 금지하는 것이지만, 법률유보의 원칙은 적극적으로 법률제정을 요구하는 것이다. 행정부는 법률이 존재하지 않을 경우에는 행정작용을 하여서는 안 되고, 제정된 법률이 있을 때에만 그에 근거하여 행정을 할 수 있다는 원칙으로 적극적 원칙이라 할 수 있다.

2) 법률의 범위

법률의 유보에 있어서 법률은 원칙적으로 국회에서 법률제정의 절차에 따라 만들어진 형식적 의미의 법률을 의미한다. 따라서 국회의 의결을 거치지 않은 불문법·관습법·판례법은 포함되지 않는다. 그러나 헌법 제75조 및 제95조에 따라 상위법령의 위임을 받아 제정된 법규명령(대통령령·총리령·부령)은 '법률'에 포함된다.

3) 적용범위

(1) 문제점

행정은 복잡성·다양성을 가지고 있어 신속하고 효율적인 대응이 필요하다. 이에 모든 행정에서 법률상 근거를 요하는 것이 필요한지와 그것이 가능한지에 대한 현실적 문제로 법률유보의 원칙의 적용범위에 대한 견해가 대립하고 있다.

(2) 확설

① 침해유보설

국민의 자유나 재산을 침해하거나 제한 또는 의무를 부과하는 등 침해적 행정작용에 대해서만 법적 근거가 필요하다고 보는 견해이다.

② 급부유보설

침해적 행정작용 외에 사회보장행정, 자금지원행정 등 급부행정작용에 대해서도 법적 근거가 필요하다고 보는 견해이다.

③ 중요사항유보설

공동체나 개인의 중요한 부분에 영향을 미치는 행정작용은 법률의 근거가 필요하다고 보는 견해이다.

④ 전부유보설

모든 행정작용에는 법률에 근거가 필요하다고 보는 견해이다.

(3) 판례

헌법재판소는 “입법자가 형식적 법률로 스스로 규율하여야 하는 사항이 어떤 것인가는 일률적으로 확정할 수 없고 구체적인 사례에서 관련된 이익 내지 가치의 중요성, 규제 내지 침해의 정도와 방법 등을 고려하여 개별적으로 결정할 수 있을 뿐이나, 적어도 헌법상 보장된 국민의 자유나 권리를 제한하는 때에는 그 제한의 본질적인 사항에 관한 한 입법자가 법률로써 스스로 규율하여야 할 것이다”(헌재 2012헌바54)고 하여 중요사항 유보설의 태도를 취하고 있다.

(4) 소결

행정기본법 제8조 2문에서 ‘국민생활에 중요한 영향을 미치는 경우에는 법률에 근거하여야 한다’고 규정하고 있고, 국민의 기본권 보장과 행정의 단력적 운영의 조화가 중요하므로, 그 내용이 공동체나 개인에게 중요한 사항인 경우에 법률에 근거하는 중요사항유보설이 타당하다. 중요한 부분인지와 관련하여서는 침해의 정도와 관련 이익 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

4) 위반의 효과

행정작용이 법률유보의 원칙을 위반하면 위법한 행정작용이 된다. 위법한 행정작용의 효력은 행정의 행위형식에 따라 다르게 나타난다. 즉, 행정행위의 경우 중대·명백설에 따라 무효 또는 취소의 대상이 되고 상위법령의 위임 없이 발령된 위임명령은 무효이며, 위법한 행정작용으로 손해가 발생한 경우 손해배상책임이 인정될 수 있다.

제2절

평등의 원칙 (「행정기본법」제9조) [★]

01 의의 및 근거

평등의 원칙이란 행정기관은 행정작용을 함에 있어 특별히 합리적인 사유가 존재하지 않는 한, 그 상대방인 국민을 공정하게 대우해야 한다는 것을 의미한다. 자의금지의 원칙이라고도 하며, 재량권 행사의 한계원리로서 중요한 의미를 갖는다. 근거로는 헌법 제11조 및 행정기본법 제9조가 있다.

[헌법] 제11조

- ① 모든 국민은 법 앞에 평등하다. 누구든지 성별·종교 또는 사회적 신분에 의하여 정치적·경제적·사회적·문화적 생활의 모든 영역에 있어서 차별을 받지 아니한다.

[행정기본법] 제9조 (평등의 원칙)

행정청은 합리적 이유 없이 국민을 차별하여서는 아니 된다.

02 요건 및 한계

평등의 원칙은

① 모든 행정작용에 적용되며, ② 차별에 합리적 이유가 없을 것을 요건으로 한다.

한계로서 평등의 원칙은 불법에는 적용되지 않는다.

평등의 원칙은 모든 공권력 행사를 통제하는 법원칙으로 행정청의 재량권 행사의 한계원리로서 중요한 기능을 수행하지만, 불법 앞의 평등은 인정될 수 없다.

03 자기구속의 원칙(파생법리) [★]

1) 의의 및 근거

자기구속의 원칙이란 재량행위에 있어서 행정청은 동일한 사안에 대하여 이전에 한 처분과 동일한 처분을 하여야 한다는 원칙을 말한다. 즉, 행정청은 자기 스스로 정하여 시행하고 있는 결정기준을 합리적 이유 없이 변경할 수 없다. 재량행위에 있어 행정권의 자의를 방지하는 기능을 수행하며, 평등의 원칙이나 신뢰보호의 원칙을 근거로 자기구속의 원칙을 인정하는 것이 일반적이다.

2) 적용요건

기속행위의 경우 행정청에게 인정되는 선택의 자유가 없으므로 자기구속의 원칙이 적용되지 않으며, 행정청의 재량이 인정되는 경우에 한하여 적용된다. 따라서, 적용요건으로는 ① 재량행위의 영역일 것, ② 동종의 사안일 것, ③ 동일한 행정청일 것, ④ 행정선례가 존재할 것을 들 수 있다.

행정선례와 관련하여서는 견해가 대립하는데, ① 반복적인 행정선례가 필요하다는 견해(행정관행설), ② 1회의 행정선례로 족하다는 견해(1회 선례 충분설), ③ 재량준칙의 존재만으로 자기구속을 인정할 수 있다는 견해(선례 불요설)가 있다. 판례는 재량준칙이 되풀이 시행되어 행정관행이 이루어진 경우 자기구속의 원칙이 적용된다고 보고 있다. 생각건대, 1회 선례 충분설은 행정을 경직화시킬 우려가 있고, 선례불요설은 행정규칙의 법규성을 인정하는 결과를 초래한다는 점에서 문제가 있으므로 반복적인 선례가 되풀이되어 행정관행이 있어야 한다고 보는 판례의 입장과 같이 <행정관행설>이 타당하다.

3) 적용한계

자기구속의 원칙은 재량준칙이 적용되는 경우 인정되는 것으로서 ① 기속행위에는 인정될 수 없고, 성문의 법규를 보충하는 것으로서 ② 위법한 처분에 대하여는 인정되지 않는다. 또한 ③ 행정관행이 성립되었다 하더라도, 행정청이 행정선례와 다른 결정을 하여야 할 공익상 필요 등 특별한 사정이 있는 경우에는 자기구속의 원칙이 배제될 수 있다.

대법원 2009. 6. 25. 선고 2008두13132

위법한 행정처분이 수차례에 걸쳐 반복적으로 행하여졌다 하더라도 그러한 처분이 위법한 것인 때에는 행정청에 대하여 자기구속력을 갖게 된다고 할 수 없다.

01 의의 및 근거

비례의 원칙이란 행정목적과 행정수단 사이에 합리적 비례관계가 있어야 한다는 원칙을 말한다.

행정목적이 공익을 위해 정당하고 합리적이라 할 지라도 그 수단이 자의적이거나 무제한적이어서는 안 됨을 의미한다. 헌법 제37조 제2항, 행정기본법 제10조 및 행정절차법 제48조 제1항과 개별법 등에 근거가 있다.

[행정기본법] 제10조 (비례의 원칙)

행정작용은 다음 각 호의 원칙에 따라야 한다.

1. 행정목적 달성에 데 유효하고 적절할 것
2. 행정목적 달성에 데 필요한 최소한도에 그칠 것
3. 행정작용으로 인한 국민의 이익 침해가 그 행정작용이 의도하는 공익보다 크지 아니할 것

02 내용 (요건)

1) 적합성의 원칙 (수단의 적정성)

적합성의 원칙이란 행정기관은 행정목적 달성에 데 유효하고 적절한 수단을 선정하여야 한다는 것을 의미한다. 목적 달성을 위해 가능한 수단이 여러 개가 있는 경우 모든 수단이 법령상 허용되는 것이라면 이들 중 어떤 것을 취하더라도 적합성원칙에는 위반되지 않는다.

2) 필요성의 원칙 (최소침해의 원칙)

필요성의 원칙이란 적합한 수단이 여러 가지라면 그 중에서 국민의 권리나 자유에 대한 침해가 가장 적은 수단을 선택해야 하는 것을 의미한다. 이를 최소침해의 원칙이라고도 하며, 개인이나 공중에 최소한의 침해를 주는 수단을 선택할 것을 요구하는 원칙이다.

3) 상당성의 원칙 (협약의 비례원칙)

상당성의 원칙이란 행정작용을 함에 있어 달성되는 공익보다 침해되는 국민의 권익이 더 크다면 그러한 행정조치를 취해서는 안 된다는 원칙을 말한다. 이는 협약의 비례원칙이라고도 하며, 공익과 사익 간의 이익형량을 통해 판단한다.

4) 상호관계

적합성의 원칙, 필요성의 원칙과 상당성의 원칙은 단계적 구조를 이루고, 적합의 원칙부터 상당성의 원칙까지 단계적으로 심사를 하여 비례의 원칙의 위반 여부를 판단한다. 즉 적합한 여러 개의 수단 중에서 최소한의 침해를 가져오는 수단을 선택하여야 하고 그러한 행정조치로 인해 달성되는 공익이 침해되는 사익보다 더 커야 한다.

03 판례 (사업인정의 공익성에 대한 판단 : 비례의 원칙)

대법원 2011. 1. 27. 선고 2009두1051 판결

사업인정이란 공익사업을 토지 등을 수용 또는 사용할 사업으로 결정하는 것으로서 공익사업의 시행자에게 그 후 일정한 절차를 거칠 것을 조건으로 일정한 내용의 수용권을 설정하여 주는 형성행위이므로, 해당 사업이 외형상 토지 등을 수용 또는 사용할 수 있는 사업에 해당한다고 하더라도 사업인정기관으로서 그 사업이 공용수용을 할 만한 공익성이 있는지의 여부와 공익성이 있는 경우에도 그 사업의 내용과 방법에 관하여 **사업인정에 관련된 자들의 이익을 공익과 사익 사이에서는 물론, 공익 상호간 및 사익 상호간에도 정당하게 비교·교량**하여야 하고, 그 비교·교량은 비례의 원칙에 적합하도록 하여야 한다. 그뿐만 아니라 해당 공익사업을 수행하여 공익을 실현할 의사나 능력이 없는 자에게 타인의 재산권을 공권력적·강제적으로 박탈할 수 있는 수용권을 설정하여 줄 수는 없으므로, 사업시행자에게 해당 공익사업을 수행할 의사와 능력이 있어야 한다는 것도 사업인정의 한 요건이라고 보아야 한다.

제4절

성실의무 및 권한남용금지의 원칙 (『행정기본법』제11조)

01 의미 및 근거 [★]

성실의무의 원칙이란 행정청이 법령등에 따른 의무를 성실히 수행하여야 한다는 원칙을 말하고, 권한남용금지의 원칙이란 행정청이 주어진 행정권한을 남용하거나 그 권한의 범위를 넘어서는 안된다는 원칙을 말한다. 행정기본법 제11조에 규정되어 있으며, 행정청의 의무와 권한의 범위에 관해 명문화한 것이다.

[행정기본법] 제11조 (성실의무 및 권한남용금지의 원칙)

- ① 행정청은 법령등에 따른 의무를 성실히 수행하여야 한다.
- ② 행정청은 행정권한을 남용하거나 그 권한의 범위를 넘어서는 아니 된다.

02 적용범위

성실의무 및 권한남용금지의 원칙은 모든 행정작용에 적용되는 것으로 수익적 행정, 침해적 행정 및 급부행정 등 모든 분야에서 적용된다.

제5절

신뢰보호의 원칙 (『행정기본법』제12조) [★★]

01 의미 및 근거

신뢰보호원칙이란 행정기관이 공익 또는 제3자의 이익을 현저히 해칠 우려가 있는 경우를 제외하고는 행정에 대한 국민의 정당하고 합리적인 신뢰를 보호하여야 한다는 원칙을 말한다. 법적 안정성, 신의칙 및 사회국가원리에서 이론적 근거를 찾을 수 있고, 실정법으로는 행정기본법 제12조, 행정절차법 제4조 제2항 등을 근거로 들 수 있다.

[행정기본법] 제12조 (신뢰보호의 원칙)

- ① 행정청은 공익 또는 제3자의 이익을 현저히 해칠 우려가 있는 경우를 제외하고는 행정에 대한 국민의 정당하고 합리적인 신뢰를 보호하여야 한다.
- ② 행정청은 권한 행사의 기회가 있음에도 불구하고 장기간 권한을 행사하지 아니하여 국민이 그 권한이 행사되지 아니할 것으로 믿을 만한 정당한 사유가 있는 경우에는 그 권한을 행사해서는 아니 된다. 다만, 공익 또는 제3자의 이익을 현저히 해칠 우려가 있는 경우는 예외로 한다.

[행정절차법] 제4조 (신의성실 및 신뢰보호)

- ② 행정청은 법령등의 해석 또는 행정청의 관행이 일반적으로 국민들에게 받아들여졌을 때에는 공익 또는 제3자의 정당한 이익을 현저히 해칠 우려가 있는 경우를 제외하고는 새로운 해석 또는 관행에 따라 소급하여 불리하게 처리하여서는 아니 된다.

02 요건

1) 행정기관의 선행조치

행정기관의 상대방인 국민에 대한 신뢰를 주는 어떠한 **선행조치**가 있어야 한다. 선행조치는 법령, 행정행위, 약속, 행정계획, 행정지도 등 국민이 신뢰를 가질 수 있는 일체의 조치를 말하는데, 적극적인 행위뿐만 아니라 소극적인 행위와 묵시적인 **행위도 포함된다**. 이러한 선행조치는 반드시 적법할 필요는 없으나 무효인 행위의 경우에는 신뢰의 대상으로서의 선행조치가 될 수 없고, 입증책임은 신뢰보호 원칙의 위반을 주장하는 원고에게 있다고 본다.

2) 보호가치 있는 신뢰 (상대방의 무귀책)

선행조치에 대한 상대방의 신뢰가 **보호가치 있는 것**이어야 한다. 즉, 상대방 등에게 귀책사유가 있어서는 안 되는데, 상대방의 귀책사유란 사기 등 부정행위에 의한 것뿐만 아니라 행정청의 견해표명에 하자가 있음을 알았거나 중대한 과실로 알지 못한 경우까지 포함한다.

3) 상대방의 조치 및 인과관계

상대방이 행정기관의 선행조치에 대한 **신뢰에 입각하여** 어떠한 **조치**를 취하여야 한다. 신뢰보호의 원칙의 목적은 선행조치를 믿고 어떠한 행위를 한 사인을 보호하기 위한 것이므로 단순히 선행조치를 신뢰한 것만으로는 부족하고, 사인의 후행 조치가 필요하다. 또한 이러한 행정기관의 선행조치와 이를 신뢰하고 행한 국민의 조치 사이에는 상당한 인과관계가 있어야 한다.

4) 선행조치에 반하는 후행행위와 권익침해

행정기관이 선행조치를 하였고 이를 신뢰한 상대방이 일정한 조치를 하였는데, **행정기관이 상대방의 신뢰에 반하는 행정권의 행사를 하여 상대방의 권익이 침해**되어야 한다. 즉, 선행조치에 반하는 후행행위로 인해 구체적인 사인의 권익 침해가 있을 것을 요건으로 한다.

03 한계

1) 법률적합성과의 충돌

신뢰보호 원칙은 법적안정성을 위한 것이나, 행정청의 공적견해의 표명이 법률에 적합하지 않은 경우에도 개인의 신뢰와 그에 따른 행위가 보호받아야 하는지가 문제된다. 이에 대해

- ① 법률적합성이 우선되어 신뢰보호 원칙이 인정되지 않는다고 보는 견해(법률적합성 우위설)와
- ② 적법상태의 실현에 의해 달성되는 공익과 개인의 신뢰보호라는 사익을 비교·형량하여 결정하여야 한다는 견해(이익형량설) 등이 있다. 판례는 이익형량설을 취하고 있다.

생각건대, 행정의 법률적합성 원칙과 개인의 신뢰보호 원칙은 모두 법치주의의 핵심요소로서 어느 것을 우위에 두기 어려우므로 적법상태의 실현으로 달성하는 공익과 사익을 비교형량하여 구체적으로 결정함이 타당하다.

2) 제3자의 사익

행정청의 공적견해표명에 따른 후속행위로 다른 제3자의 사익이 침해 되는 경우에는 신뢰보호가 우선시된다고 볼 수 없고, 관련 규정의 취지와 당해 행정행위로 인하여 달성되는 공익과 관련 당사자의 손해를 종합적으로 비교형량하여 구체적으로 결정하여야 한다. 이는 주로 제3자효 행정행위에서 문제가 된다.

3) 사정변경 및 무효인 행정행위

신뢰형성에 기초되는 사실관계가 사후에 변경되고 상대방이 사후에 이를 알았거나 알 수 있는 경우에는 신뢰보호를 주장할 수 없다. 또한 무효인 행정행위에 대해서도 신뢰보호를 주장할 수 없다.

[대법원 2001. 9. 28. 선고 2000두8684 판결]

일반적으로 행정상의 법률관계에 있어서 행정청의 행위에 대하여 신뢰보호의 원칙이 적용되기 위하여는, 첫째 행정청이 개인에 대하여 신뢰의 대상이 되는 공적인 견해표명을 하여야 하고, 둘째 행정청의 견해표명이 정당하다고 신뢰한 데에 대하여 그 개인에게 귀책사유가 없어야 하며, 셋째 그 개인이 그 견해표명을 신뢰하고 이에 상응하는 어떠한 행위를 하였어야 하고, 넷째 행정청이 위 견해표명에 반하는 처분을 함으로써 그 견해표명을 신뢰한 개인의 이익이 침해되는 결과가 초래되어야 하며, 마지막으로 위 견해표명에 따른 행정처분을 할 경우 이로 인하여 공익 또는 제3자의 정당한 이익을 현저히 해할 우려가 있는 경우가 아니어야 한다.

[대법원 2005. 3. 10. 선고 2002두5474 판결 [도시계획변경결정취소청구]]

행정청이 용도지역을 자연녹지지역으로 지정결정하였다가 그보다 규제가 엄한 보전녹지지역으로 지정결정하는 내용으로 도시계획을 변경한 경우, 행정청이 용도지역을 자연녹지지역으로 결정만으로는 그 결정 후 그 토지의 소유권을 취득한 자에게 용도지역을 종래와 같이 자연녹지지역으로 유지하거나 보전녹지지역으로 변경하지 않겠다는 취지의 공적인 견해표명을 한 것이라고 볼 수 없고, 토지소유자가 당해 토지 지상에 물류창고를 건축하기 위한 준비행위를 하였더라도 그와 같은 사정만으로는 용도지역을 자연녹지지역에서 보전녹지지역으로 변경하는 내용의 도시계획 변경결정이 행정청의 공적인 견해표명에 반하는 처분을 함으로써 그 견해표명을 신뢰한 개인의 이익이 침해되는 결과가 초래된 것이라고도 볼 수 없다는 등의 이유로, 신뢰보호의 원칙이 적용되지 않는다.

04 위반의 효과

신뢰보호 원칙에 위반한 행정작용은 위법한 작용이 되며 행정쟁송 및 국가배상을 청구할 수 있다.

01 의의 및 근거

부당결부금지의 원칙이란 행정기관이 행정작용을 함에 있어 상대방에게 그것과 실질적인 관련이 없는 반대급부를 결부시켜서는 안 된다는 원칙을 말한다. 부당결부금지의 원칙은 헌법상 법치국가 원칙과 자의금지 원칙에서 그 이론적 근거를 찾을 수 있고, 실정법상 행정기본법 제13조에 그 근거가 있다.

[행정기본법] 제13조 (부당결부금지의 원칙)

행정청은 행정작용을 할 때 상대방에게 해당 행정작용과 실질적인 관련이 없는 의무를 부과해서는 아니 된다.

02 요건

부당결부금지의 원칙의 요건으로

- ① 행정청의 공권력 행사가 있을 것,
- ② 공권력의 행사가 상대방의 반대급부와 결부되어 있을 것,
- ③ 공권력의 행사와 반대급부 사이에 실질적 관련성이 없을 것이 있다.

실질적 관련성은 원인적 관련성과 목적적 관련성을 그 내용으로 하며, 부당결부금지의 원칙은 행정행위의 부관에서 주로 적용된다.

대법원 1997. 3. 11. 선고 96다49650 판결 [소유권이전등기말소]

지방자치단체장이 사업자에게 주택사업계획승인을 하면서 그 주택사업과는 아무런 관련이 없는 토지를 기부채납하도록 하는 부관을 주택사업계획승인에 붙인 경우, 그 부관은 부당결부금지의 원칙에 위반되어 위법하지만, 지방자치단체장이 승인한 사업자의 주택사업계획은 상당히 큰 규모의 사업임에 반하여, 사업자가 기부채납한 토지 가액은 그 100분의 1 상당의 금액에 불과한 데다가, 사업자가 그 동안 그 부관에 대하여 아무런 이의를 제기하지 아니하다가 지방자치단체장이 업무착오로 기부채납한 토지에 대하여 보상협조요청서를 보내자 그 때서야 비로소 부관의 하자를 들고 나온 사정에 비추어 볼 때 부관의 하자가 중대하고 명백하여 당연무효라고는 볼 수 없다.

※ 실질적 관련성의 의미

1. 원인적 관련성이란 행정작용과 반대급부 사이에 직접적인 인과관계가 있어야 함을 말한다.
2. 목적적 관련성이란 행정작용과 반대급부가 동일한 행정목적에 추구하여야 함을 말한다.

제1절

공법관계와 사법관계

01 개념

법률관계란 법에 의해 규율되는 권리, 의무 관계를 의미한다. 법률관계는 크게 공법관계와 사법관계로 구분할 수 있으며 소송, 관할법원, 공정력 인정 여부 등에 차이가 있어 구분의 실익이 있다.

구분	공법관계	사법관계
소송	행정소송	민사소송
관할법원	행정법원	지방법원
공정력	권력관계에서는 공정력이 인정	공정력 불인정

02 구별기준

1) 학설

공법관계인지 사법관계인지는 법규정이 구분의 1차적 기준이 된다. 법규정 해석으로도 구분이 불분명할 경우 어떤 기준으로 공법관계 또는 사법관계로 볼 것인지에 대해서는 학설이 대립하는데,

- ① 주체가 행정주체이면 공법관계로 보는 <주체설>,
- ② 법률관계가 상하관계이면 공법관계로 보는 <종속설>,
- ③ 법률관계가 공익을 위한 것이면 공법관계로 보는 <이익설>,
- ④ 권리의무의 귀속주체가 공권력 주체이면 공법관계로 보는 <귀속설>,
- ⑤ 위 기준을 종합 참작해야 한다고 보는 <복수기준설> 등이 있다.

2) 판례

(1) 공법관계 (보상금증감청구소송 및 주거이전비)

토지보상법에 따라 손실보상금의 증액을 구하는 소송은 공법상 당사자 소송으로 보며, 동법에 따른 주거이전비 지급을 구하는 소송도 공법상 당사자 소송으로 본다. 또한, 도시 및 주거환경정비법에 의한 재개발조합에 대한 조합원 지위 확인을 구하는 소송도 공법상 당사자 소송으로 본다.

(2) 사법관계 (공익사업을 위한 협의취득, 환매권)

토지보상법에 의한 협의취득은 사법상의 법률행위로 보고, 토지보상법에 따른 환매권 행사로 인한 매매도 사법상의 매매로 보아 민사소송에 의한다. 또한 환매금액의 증감을 구하는 소송도 민사소송에 의한다.

3) 소결

근거법규가 행정주체에게 우월적 지위를 부여하고 있거나 공익실현을 직접적인 목적으로 하고 있다면 공법관계로 보아야 하며, 근거법규가 명확하지 않을 경우 근거법규의 목적, 내용과 당해 행위의 성질 등을 종합적으로 검토하여 결정하는 것이 타당하다.

01 행정의 주체 [★]

- ① 행정주체란 행정권을 행사하고 그 행위의 법적 효과(권리·의무의 생성, 변경, 소멸 등)가 궁극적으로 귀속되는 당사자를 말한다. 예로는 국가, 지방자치단체, 공공조합과 공무수탁사인 등이 있다. 행정주체는 행정기관을 통해 행정사무를 처리한다.
- ② 즉, 행정사무를 담당하는 기관이 행정기관이고 행정기관이 한 행위의 법적 효과는 행정주체에게 귀속된다. 행정기관의 예로는 행정심판위원회, 토지수용위원회, 징계위원회 등이 있으며, 이러한 행정기관을 포괄하는 개념으로 행정기관의 대표를 행정청이라고 한다.
- ③ 행정청은 행정에 관한 의사를 결정하여 외부에 표시하는 권한을 가지고 있고, 예로는 지방자치단체의 장, 국토교통부장관 등이 있다.

02 행정의 상대방 (행정의 객체)

행정의 상대방이란 행정법 관계에서 행정주체의 상대방을 말한다.

행정의 상대방 또는 행정의 객체라고도 하며 행정법 관계에서 권리·의무를 가진다.

※ 공무수탁사인이란? [★]

공무수탁사인이란 공적인 행정 영역에서 행정 권한이나 공권력적인 지위를 부여받아 행정행위를 자기 이름과 자기책임으로 행하는 사인을 말한다. 예로는 「토지보상법」상 사업인정을 받은 사업시행자가 있다.

01 개념

공법관계는 공법상의 권리·의무를 말하는데, 그 중 공권은 공법관계에서의 권리를 의미한다.

공권은 귀속주체에 따라 국가가 가지는 국가적 공권과 개인이 가지는 개인적 공권으로 구분할 수 있다.

공권은 사권 및 공의무에 대응하는 개념으로 공적 의무이다.

02 개인적 공권 [★]

1) 의의

개인적 공권이란 개인이 직접 자기의 이익을 위하여 행정주체에게 일정한 행위를 할 것을 요구할 수 있는 법적인 힘을 말한다.

2) 성립요건

개인적 공권은 헌법규정, 법률 규정, 공법상 계약, 관습법 및 조리에 의해 성립될 수 있고 이러한 이를 전제로 하여 2가지 성립요건이 요구된다.

(1) 강행법규의 존재

제1요건으로 행정주체에게 일정한 의무를 부과하는 강행법규가 존재하여야 한다. 원칙적으로 행정청의 행위가 기속행위의 성질을 가져야 하기에 과거에는 행정주체에게 재량이 인정되는 경우 공권이 성립될 수 없다고 보았지만, 오늘날에는 공권의 확대화 경향에 따라 재량행위에도 일정한 공권이 성립할 수 있다고 본다.

(2) 사익보호성

제2요건으로 관련법규가 사익보호를 목적으로 하여야 한다.

사익보호의 판단기준은 처분의 근거법규 및 관련 법규의 목적, 취지 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

03 무하자재량행사청구권

1) 의의

무하자재량행사청구권이란 특정한 행위에서 행정청에게 재량이 부여되어 있는 경우에 행정청에 대하여 재량권을 하자 없이 행사하여 줄 것을 청구할 수 있는 권리를 말한다. 개인적 공권은 행정청에 법적 의무를 부과하는 강행규정이 존재할 때만 인정될 수 있고 행정청에 재량이 부여되어 있을 때는 법적 의무가 없으므로 개인의 청구권은 인정되지 않는다고 보았다. 그러나 실질적 법치주의가 발전함에 따라 재량행위 영역에서도 일정한 한계 내에서 재량을 행사할 의무를 부과한다는 점에서 부분적 강행성을 인정받게 되었다.

2) 법적성질 (형식적 권리)

무하자재량행사청구권은 특정처분을 청구하는 것이 아니라 특정처분의 형성과정에서 하자 없는 재량권 행사를 할 것을 요구하는 것을 말한다. 즉, 재량의 하자를 발생시키지 말 것을 청구하는 형식적 권리고, 행정결정의 내용과 관련된 권리라는 점에서 절차적 권리와 구별된다.

3) 독자성 인정여부

(1) 학설

- ① 재량의 하자가 있는 행위는 재량의 한계를 벗어난 위법한 행위가 되고 그로 인해 권익의 침해가 있다면 실체와 관련시켜 권리구제를 인정하면 될 것이지 굳이 무하자재량행사청구권을 따로 인정할 법적 실익이 없다고 보는 견해(부정설)가 있고,
- ② 재량권이 인정되는 영역에서 공권의 인정 여부를 규명하고, 사익보호성이 도출되는 경우에만 인정되므로 민중소송화 되지 않는다는 점을 근거로 무하자재량행사청구권을 긍정하는 견해(긍정설)가 다수설로 있다.

(2) 판례 및 소결

검사임용거부처분취소소송 사건에서 비록 무하자재량행사청구권이라는 용어를 명시적으로 사용하지 않았지만, 이 판례를 들어 무하자재량행사청구권의 개념을 인정하였다고 보는 것이 다수설의 입장이다. 생각건대, 재량행위에서도 공권이 인정될 수 있으므로 무하자재량청구권의 독자성을 인정하는 것이 타당하다.

4) 성립요건

(1) 강행법규성

행정청에 재량권을 행사하여 어떤 처분을 하여야 할 의무가 부과되어야 하며, 그 의무는 법령상 또는 조리상 인정될 수 있다.

(2) 사익보호성

근거 법규는 공익실현이라는 목적 이외에 사익을 보호하려는 목적도 있어야 개인에게 개인적 공권이 성립하여 무하자재량행사청구권이 인정될 수 있다.

01 의의 및 종류

사인의 공법행위는 공법적 효과의 발생을 목적으로 사인이 하는 일체의 행위를 말한다.

사인의 공법행위는

- ① 사인의 공법행위만으로 법률효과를 완결시키는 <자기 완결적 공법행위>와
- ② 사인의 공법행위가 단순히 국가나 지방자치단체의 행정작용의 요건 등에 그치고 그 자체만으로는 법률효과를 완성하지 못하는 <행위요건적 공법행위>로 구분할 수 있다.

대표적인 사인의 공법행위로는 신고가 있는데, 신고란 사인이 공법적 효과의 발생을 목적으로 행정주체에게 일정한 사실을 알리는 행위를 말한다. 이러한 신고는 행위의 기능에 따라 정보제공적 신고와 금지해제적 신고로 나눌 수 있고, 법적 효과에 따라 자기완결적 신고와 행위요건적 신고로 나눌 수 있다. 신고수리 또는 거부행위의 처분성에서 그 의미를 달리하므로 구별실익이 있다.

02 신고

1) 의의

(1) 자기완결적 신고 (수리를 요하지 않는 신고)

자기완결적 신고란 사인이 행정청에 대하여 일정한 사항을 통지하고 통지가 행정청에 도달함으로써 효과가 발생하는 신고를 말한다. 자기완결적 신고가 본래적 의미의 신고에 해당하며, 행정절차법 제40조를 자기완결적 신고의 근거로 보는 것이 다수설의 입장이다.

(2) 행위요건적 신고 (수리를 요하는 신고)

행위요건적 신고란 법령 등에 의하여 행정청에게 일정한 사항을 통지하고 행정청이 이를 수리함으로써 법적 효과가 발생하는 신고를 말한다. 변형적 신고라고도 불리며 실정법상 등록이라고도 한다.

2) 구별기준

(1) 관련 규정

행정기본법 제34조는 “법령등으로 정하는 바에 따라 행정청에 일정한 사항을 통지하여야 하는 신고로서 법률에 신고의 수리가 필요하다고 명시되어 있는 경우(행정기관의 내부 업무 처리 절차로서 수리를 규정한 경우는 제외한다)에는 행정청이 수리하여야 효력이 발생한다.”고 규정하고 있다.

(2) 학설

① 신고 요건이 형식적 요건만을 요구하는 경우에는 자기완결적 신고로 보고, 실질적 요건도 포함하는 경우 수리를 요하는 신고로 보는 <신고요건기준설>, ② 해당 법령의 목적과 문언에 대한 합리적이고 유기적인 해석을 통해서 구분하는 <법령해석기준설>, ③ 형식적 심사만 하는 경우는 자기완결적 신고로 보고, 실질적 심사까지 하는 경우에는 수리를 요하는 신고로 보는 <심사방식기준설> 등이 있다.

(3) 판례

판례는 실질적 적법요건을 두지 않고 형식적 요건만을 규정한 경우 자기완결적 신고로 보고, 근거 법에서 그 대상행위를 원칙적으로 금지하여 실질적 적법요건을 두고 있는 때에는 해당 신고의 수리를 거부할 수 있다고 보아 수리를 요하는 신고로 본다.

(4) 소결

자기완결적 신고와 수리를 요하는 신고는 일차적으로 **법령의 목적**을 기준으로 판단하는 것이 타당하다.

다만, 그 해석이 명확하지 않는 경우에는 신고요건의 내용에 **실질적 요건**이 포함되어 있는지를 판단기준으로 삼아 다른 **법령상의 요건 충족**을 전제로 하거나 그 신고가 **인·허가의제의 효과**를 갖는 경우에는 수리를 요하는 신고라고 봄이 타당하다.

3) 요건

(1) 자기완결적 신고 (수리를 요하지 않는 신고)

행정절차법 제40조 제2항에 따르면

- ① 신고서의 기재사항에 흠이 없을 것 ,
- ② 필요한 구비서류가 첨부되어 있을 것,
- ③ 그 밖에 법령 등에 규정된 형식상의 요건에 적합할 것을 요건으로 본다.

해당 요건만 충족되면 되고 그 내용의 진실함이 증명될 필요는 없다.

(2) 행위요건적 신고 (수리를 요하는 신고)

수리를 요하는 신고는 형식적 요건 외에 일정한 실질적 요건을 신고요건으로 하는 경우가 있다.

즉, 근거 법령에서 요구하는 요건을 모두 갖추어 신고하고 행정청이 이를 수리하여야 한다.

4) 수리거부의 처분성 [★★★]

(1) 자기완결적 신고

자기완결적 신고에 대해 행정청이 거부를 하였더라도 사인의 신고만으로 법적 효과가 완성되므로 행정청의 수리 또는 거부가 아무런 법적 의미를 갖지 않는다. 따라서 행정청의 수리 또는 수리거부행위는 처분성이 인정되지 않으며, 이에 대해 항고소송을 제기하더라도 부적법 하여 각하된다고 보는 것이 종래 통설의 태도이다.

다만, 판례는 자기완결적 신고 중 **인허가의제의 효과**를 수반하는 건축신고의 거부를 처분으로 본 바 있고 (대법원 2010. 11. 28. 선고 2008두167판결), **착공신고 수리거부**에 대해서도 처분성을 인정한바 있다.

(2) 행위요건적 신고

행위요건적 신고의 경우 사인의 신고만으로는 법적 효과가 발생하지 않고, 행정청이 수리를 하여야 비로소 법적 효과가 발생하므로, 행정청의 수리 또는 수리의 거부는 준법률행위적 행정행위의 하나로서 행정소송법상의 처분의 개념에 해당한다. 수리를 요하는 신고는 원칙적으로 기속행위로 보는 것이 타당하나 판례는 사실납골시설의 설치신고에 대해 법령상의 설치기준에 부합하더라도 중대한 공익상 필요가 있는 경우 수리를 거부할 수 있다고 보았다.

대법원 2010. 11. 18. 선고 2008두167 전원합의체 판결

건축주 등은 신고제하에서도 건축신고가 반려될 경우 당해 건축물의 건축을 개시하면 **시정명령, 이행강제금, 벌금**의 대상이 되거나 당해 건축물을 사용하여 행할 행위의 **허가**가 거부될 우려가 있어 **불안정한 지위에** 놓이게 된다. 따라서 건축신고 반려행위가 이루어진 단계에서 당사자로 하여금 반려행위의 적법성을 다투어 그 법적 불안을 해소한 다음 건축행위에 나아가도록 함으로써 **장차 있을지도 모르는 위험에서 미리 벗어날 수 있도록** 길을 열어 주고, 위법한 건축물의 양산과 그 철거를 둘러싼 분쟁을 조기에 근본적으로 해결할 수 있게 하는 것이 법치행정의 원리에 부합한다. 그러므로 건축신고 반려행위는 항고소송의 대상이 된다고 보는 것이 옳다.

PART 02

행정작용법

Chapter 01 행정입법

Chapter 02 행정행위

Chapter 03 행정계획

Chapter 04 인·허가의제 제도

행정작용이란 행정주체가 행정목적을 달성하기 위해 행하는 법률적·사실적 작용을 말한다.

이러한 행정작용의 형식은 행정입법, 행정행위, 행정계획, 공법상 계약, 사실행위, 행정지도 등으로 분류될 수 있다.

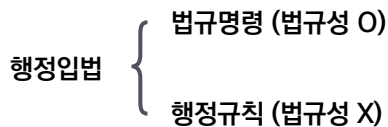
행정작용법 파트에서는 행정작용의 형식들을 하위 목차로 하여 학습한다.

제1절

일반론

행정입법은 국가 등 행정주체가 일반적·추상적 규범을 제정하는 작용 또는 그에 의하여 제정된 규범을 말한다.

행정입법은 실정법상 용어는 아니고 학문상의 용어이며, 행정권에 의해 제정된 행정입법이 법규성(대외적 구속력)이 있는지에 따라 법규명령과 행정규칙으로 구분할 수 있다. 삼권분립의 원칙에 따라 법규를 정립하는 권한은 입법부(국회)에 있으므로 행정권의 조직과 작용에 관한 모든 사항을 법률로 정하는 것이 법치행정의 원리에 부합하나, 행정의 전문적·기술적인 사항을 모두 법률로 정하기는 어려우므로 실효적인 행정의 집행을 위해 행정입법이 필요하다.



제2절

법규명령 [★★]

01 의미

법규명령이란 법령의 수권에 근거하여 행정권이 정립하는 일반적·추상적 규범을 말한다. 법규명령은 헌법 또는 법률 등으로부터 수권을 받은 정당한 기관이 수권의 범위 내에서 상위법령에 저촉되지 않고 실현가능하며 명백한 내용에 관하여, 입법예고와 법제처의 심사 등 필요한 절차를 거쳐 조문·번호·일자 등의 형식을 갖추어 제정되어야 한다.

특별한 규정이 없는 한 공포한 날로부터 20일이 경과함으로써 효력이 발생한다(법령 등의 공포에 관한 법률 제13조). 즉, ① 법령의 근거와 ② 국민과의 관계에서 구속성(법규성)이 법규명령의 필수요소가 된다.

02 종류

1) 법적근거 기준 분류

구체적인 위임규정의 유무에 따라 법규명령을 분류할 수 있다.

- ① 위임명령은 법률이나 상위명령의 위임에 의해 제정되는 명령으로서 위임의 범위 내에서 국민의 권리, 의무에 관한 사항에 관하여도 규율할 수 있고,

- ② 집행명령은 개별 구체적인 법률이나 명령상의 근거 없이 상위법령의 집행을 위하여 필요한 사항을 규율하는 명령을 말한다. 집행명령은 상위법의 시행에 필요한 절차 및 형식을 규율하는 것으로 새로운 법규사항을 정할 수는 없다.

2) 제정권자 기준 분류

법규명령을 제정권자를 기준으로 분류하면 크게 시행령과 시행규칙으로 구분할 수 있다.

- ① 시행령은 대통령이 제정하는 명령인 대통령령을 말하고,
 ② 시행규칙은 총리가 제정하는 명령인 총리령과 행정각부의 장이 발하는 명령인 부령을 말한다.

	시행령	시행규칙
근거조문	헌법 제75조	헌법 제95조
법규성	○	○
국무회의 심의	○ (헌법 제89조 제3호)	×

[헌법] 제75조

대통령은 법률에서 구체적으로 범위를 정하여 위임받은 사항과 법률을 집행하기 위하여 필요한 사항에 관하여 대통령령을 발할 수 있다.

[헌법] 제95조

국무총리 또는 행정각부의 장은 소관사무에 관하여 법률이나 대통령령의 위임 또는 직권으로 총리령 또는 부령을 발할 수 있다.

※ 법규성 이란?

법규성이란 법규로서의 성질 의미하며, 국민과의 관계에서의 구속력을 말한다.

03 법규명령의 한계

1) 위임명령의 한계

(1) 수권의 한계

① 포괄위임금지

헌법 제75조에서 “대통령은 법률에서 구체적으로 범위를 정하여 위임받은 사항과 법률을 집행하기 위하여 필요한 사항에 관하여 대통령령을 발할 수 있다”고 규정하고 있다. 즉, 법률의 수권은 구체적이어야 하며 일반적이고 포괄적인 수권은 안 된다. ‘구체적 위임’이란 법률 규정만으로 하위법규에서 규정된 내용의 대강을 예측할 수 있는 정도를 의미한다.

② 중요사항 위임금지

헌법 제37조 제2항에서는 국민의 기본권을 법률로써 제한 할 수 있으나, 제한하는 경우에도 그 본질적인 내용을 침해할 수 없다고 규정하고 있다. 이에 국민의 기본권을 제한하는 등 **공동체의 중요사항**은 입법자가 법률로써 제정하여야 하므로 행정입법에 위임할 수 없다.

(2) 내용상 한계

위임명령은 상위 수권 **법령의 범위** 내에서 제정되어야 한다. 모법에서 수권 되지 않은 입법사항에 대해 행정주체는 스스로 규정할 수 없고 규정의 내용도 **상위법령의 내용에 위반되지 않아야** 한다.

2) 집행명령의 한계

집행명령은 상위법령을 “집행하기 위하여 필요한 사항(헌법 제75조)”만을 규정할 수 있다.

법률이나 상위명령의 개별·구체적인 수권 없이 직권으로 규정할 수 있으나, 그 내용은 법령의 집행에 필요한 절차나 형식에 관한 것만 가능하고 국민의 권리·의무에 영향을 주는 새로운 법규사항을 규정할 수는 없다.

04 법규명령의 하자

1) 하자 있는 법규명령의 효력

법규명령이 적법요건을 갖추지 못하면 위법한 법규명령이 된다. 위법한 법규명령은 그것이 법령에 근거가 있다 하더라도 대외적 구속력이 인정될 수 없다. 통설·판례는 하자의 정도와 상관없이 무효가 된다고 본다.

2) 하자 있는 법규명령에 따른 행정행위의 효력

하자 있는 법규명령에 따른 행정행위는 당연히 하자 있는 행정행위가 된다. 이러한 행정행위의 하자는 중대한 하자이므로, 중대명백성설에 따라 근거가된 법규명령의 하자가 외관상 명백하다면 무효가 되고, 외관상 명백하지 않다면 취소사유가 될 것이다. 다만, 법규명령에 하자가 있다 하더라도 법원의 판결이 선고되기 전에는 그 법규명령의 위법 여부가 객관적으로 명백한 것이라고 할 수 없으므로 **취소사유**에 해당한다고 보는 것이 판례의 입장이다.

대법원 2007. 6. 14. 선고 2004두619 판결

하자 있는 행정처분이 당연무효로 되려면 그 하자가 법규의 중요한 부분을 위반한 중대한 것이어야 할 뿐 아니라 객관적으로 명백한 것이어야 하고, 행정청이 위헌이거나 위법하여 무효인 시행령을 적용하여 한 행정처분이 당연무효로 되려면 그 규정이 행정처분의 중요한 부분에 관한 것이어서 결과적으로 그에 따른 행정처분의 중요한 부분에 하자가 있는 것으로 귀착되고, 또한 그 규정의 위헌성 또는 위법성이 객관적으로 명백하여 그에 따른 행정처분의 하자가 객관적으로 명백한 것으로 귀착되어야 하는바, 일반적으로 시행령이 헌법이나 법률에 위반된다는 사정은 그 시행령의 규정을 위헌 또는 위법하여 무효라고 선언한 대법원의 판결이 선고되지 아니한 상태에서는 그 시행령 규정의 위헌 내지 위법 여부가 해석상 다툼의 여지가 없을 정도로 명백하였다고 인정되지 아니하는 이상 **객관적으로 명백한 것이라 할 수 없으므로**, 이러한 **시행령에 근거한 행정처분의 하자는 취소사유에 해당할 뿐 무효사유가 되지 아니한다.**

05 법규명령의 통제

1) 입법적 통제

(1) 직접적 통제

국회가 법규명령의 성립·발효·소멸 등에 직접 통제를 가하는 방법을 말한다. 법규명령의 성립·발효에 대한 동의 또는 승인권이나 일단 유효하게 성립한 법규명령의 효력을 소멸시키는 권한을 의회에 유보하는 방법에 의해 법규명령을 국회에서 직접 통제할 수 있다.

(2) 간접적 통제

국회가 행정부에 대해 가지는 국정감시권을 발동시켜 간접적으로 법규명령의 적법성이나 타당성을 확인하여 법규명령을 간접적으로 통제하는 것을 말한다.

2) 사법적 통제

(1) 일반법원에 의한 통제

① 구체적 규범통제 [★★]

a. 의의 및 근거

구체적 규범통제란 처분에 대해 다투는 소송에서 법규명령의 위헌·위법 여부가 재판의 전제가 되는 경우에 선결문제로 법규명령의 위헌·위법 여부를 심사하는 제도를 말한다. 헌법 제107조 제2항에 근거가 있으며, 법규명령 자체를 다투는 것이 아니라 구체적 사건을 해결하기 위한 전제로써 문제가 되는 경우에만 법원이 법규명령을 심사하여 통제하므로 간접적인 규범통제에 해당한다.

b. 주체 및 재판의 전제성

각급 법원이 통제하고 최종적인 심사권은 대법원에게 있다. 구체적 규범통제는 처분의 하자가 법규명령에 기한 것일 때 처분의 위법성 판단에 앞서 해당 법규명령의 위법성을 판단하는 것을 말하는 것이므로 재판의 전제성이 필요하다.

c. 대상

구체적 규범통제의 대상은 명령과 규칙이 된다. 명령은 법규명령을 의미하고, 규칙은 대법원규칙, 국회규칙 등과 같이 법규명령인 규칙을 의미한다. 자치법규인 조례와 규칙도 대상에 포함된다는 것이 판례 태도이며, 행정규칙 중 법규성이 있는 법령보충적 행정규칙도 통제의 대상이 된다.

d. 효력

명령이 위법하다는 대법원 판결이 있는 경우

① 당해 명령의 효력이 일반적으로 상실된다고 보는 견해(일반적 효력설)가 있으나,

② 법원은 구체적 사건의 심사를 목적으로 하는 것이지 법령의 심사를 목적으로 하는 것은 아니며,

“법률”의 위헌결정에 대해서는 일반적으로 효력을 상실한다는 규정(헌법재판소법 제47조)이 있는 것과 달리 “명령”에 대해서는 그와 같은 규정이 없으므로, 당해 사건에 한하여 적용된다는 견해(개별적 효력설)가 타당하다. 행정소송법 제6조에서 명령·규칙의 위헌·위법이 확정된 경우에 공고하도록 규정하여 다른 사건에 적용되는 것을 방지하고 있다.

② 항고소송에 의한 직접적 통제(처분적 법규명령)

행정소송법은 취소소송과 무효등확인소송의 대상을 '처분 등'으로 규정하고 있어, 일반적·추상적 규범인 법규명령은 원칙적으로 항고소송의 대상이 될 수 없다. 다만, 법규명령이 처분적 성질을 가지는 경우(처분적 법규명령)에는 항고소송의 대상이 될 수 있다. 판례는 조례의 집행행위가 없이도 그 자체로서 직접 국민의 구체적인 권리·의무나 법적 이익에 영향을 미치는 등의 법률상 효과를 발생하는 경우 행정처분에 해당한다고 하여 두밀분교폐지조례의 처분성을 긍정한 바 있다(대법원 1996. 9. 20. 선고 95누8003 판결).

※ 처분적 명령이란?

처분적 명령이란 처분성이 있는 명령을 말한다. 명령에는 법규명령뿐만 아니라 법령보충적 행정규칙도 포함된다.

(2) 헌법재판소에 의한 통제

① 문제점

공권력의 행사 또는 불행사로 헌법상 보장된 기본권을 침해받은 자는 헌법재판소에 헌법소원을 제기할 수 있다. 그런데 헌법 제107조 제2항은 명령·규칙에 대한 위헌·위법의 심사권을 일반법원에 부여하고 있고 행정입법에 대한 헌법소원을 인정하는 명문의 규정이 없어 헌법재판소가 명령·규칙에 대한 위헌·위법 심사권을 가질 수 있는지가 문제 된다.

② 학설 및 판례

헌법 제107조 제2항에서 명령·규칙에 대한 최종적 심사권을 대법원에 부여하고 있으므로 헌법재판소가 법규명령에 대한 심사권을 가지지 않는다고 보는 견해(부정설)가 있으나 다수설은 명령 등이 국민의 기본권을 직접 침해하는 경우에는 헌법재판소도 심사할 수 있다고 본다. 헌법재판소는 대법원규칙인 법무사 시행규칙 헌법소원 사건 등에서 법규명령 등이 별도의 집행행위를 기다리지 않고 직접 기본권을 침해하는 것인 때에는 헌법소원심판의 대상이 될 수 있다고 판시하였다.

③ 소결

기본권 보호 기능을 보장하기 위한 헌법소원의 제도적 취지에 비추어 법규명령에 대한 헌법소원을 일정한 경우 인정하는 긍정설이 타당하다.

01 의미

행정규칙이란 행정조직 내부에서 효력을 갖는 일반적·추상적 규율로서 행정의 조직과 활동을 규율하는 것을 목적으로 하는 행정기관 내부의 사무처리 기준을 말한다. 행정규칙은 내부적으로만 효력을 갖고 대외적 구속력 즉, 법규성은 없다. 다만 행정규칙도 개별적·구체적인 경우 행정처분으로 인정되어 행정소송의 대상이 되기도 하고 특히, 재량준칙의 경우에 행정관행이 성립되면 평등의 원칙과 신뢰보호의 원칙을 매개로 자기구속의 원칙에 따라 대외적 구속력을 갖게 되는 경우가 있다.

※ 재량준칙이란?

재량준칙이란 행정기관인 재량처분을 하는 데 있어 재량권 행사의 일정한 기준이 되는 행정규칙을 말한다.

02 행정규칙의 한계

행정규칙은 상위법률이나 규칙, 행정법 일반원칙에 위배되어서는 안 되며, 대외적 구속력이 없으므로 국민의 권리·의무에 관한 사항을 새로이 규정할 수 없다. 또한 행정의 조직과 활동에 관한 규율로서 그 목적상 필요한 범위를 벗어나서는 안 되고 그 내용은 실현가능한 것이어야 한다.

03 법적성질

1) 학설

- ① 행정규칙은 원칙적으로 행정조직 내부를 규율하는 것으로 대내적 구속력만 있고, 대외적 구속력(법규성)이 없다는 견해(비법규설),
- ② 행정권은 권한범위 내에서 고유한 입법권을 가지므로 행정규칙도 대외적 효력을 가진다고 보는 견해(법규설),
- ③ 행정규칙 중 재량준칙은 평등의 원칙 및 자기구속의 원칙에 의해 법규로 전환되어 법규성이 인정될 수 있다고 보는 견해(준법규설) 등 다양한 견해가 있다.

2) 판례

판례는 일관되게 행정규칙의 대외적 구속력 즉, 법규성을 부인하는 입장을 취하고 있다. 일부 법규성을 긍정하는 듯한 판례가 있으나 이는 행정규제기본법 제4조 제2항에 따른 법령보충적 행정규칙인 경우이며 재량준칙의 경우에도 행정관행이 성립된 경우 자기구속의 원칙을 매개로 대외적 구속력을 인정하는 것에 불과하다.

3) 소결

법률의 법규창조력에 의거 원칙적으로 행정규칙의 대외적 구속력을 부정하는 것이 타당하나, 재량준칙의 경우 평등의 원칙이나 자기구속의 원칙을 매개로 법규성 가질 수 있다고 판단된다.

04 행정규칙의 하자

행정규칙이 적법요건을 갖추지 못하면 위법한 행정규칙이 된다.

위법한 행정규칙은 효력을 발생시키지 못하고 행정행위의 하자과 달리 취소인 경우가 없고 무효인 경우만이 있다.

05 행정규칙의 통제

1) 입법적 통제

행정규칙에 대한 직접적인 통제 방법은 없으며, 법규명령과 같이 국회는 국정감사, 국무위원 해임건의, 대정부질문 등을 통해 간접적으로 통제할 수 있다.

2) 사법적 통제

(1) 법원에 의한 통제

① 구체적 규범통제

행정규칙은 헌법 제107조 제2항에 의한 명령·규칙 등 심사권의 대상에서 제외되나, 법규성이 인정되는 **법령보충적 행정규칙**은 구체적 규범통제의 대상이 될 수 있다.

② 항고소송의 대상

행정규칙은 그 자체로 처분성이 없으므로 항고소송의 대상이 되지 않으나, **처분성을 가지는 행정규칙**이 있다면 항고소송의 대상이 될 수 있다.

(2) 헌법재판소에 의한 통제

행정규칙은 일반적으로 행정조직 내부의 행위와 관련된 것으로서 국민에게 직접적인 효력이 없어 헌법소원의 대상이 될 수 없다. 다만 법령보충적 행정규칙처럼 국민에게 효력이 있는 경우에 이로 인해 직접 국민의 기본권이 침해된다면 헌법소원의 대상이 될 수 있고, 재량준칙인 행정규칙은 자기구속의 원칙을 매개로 대외적인 구속력을 갖게 되는 경우 헌법소원의 대상이 될 수 있다.

제4절

형식과 실질의 불일치 (형식≠실질) [★★★]

01 법규명령형식의 행정규칙

1) 의의

법규명령형식의 행정규칙이란 **형식은 법규명령**이나 그 내용이 **행정규칙의 실질**을 가지는 것을 말한다. 일반적으로 법규명령으로 국민의 권리·의무와 관련된 법규적 사항을 규율하고, 행정규칙으로는 행정청 내부의 사무처리기준 등을 정하는데, 상위법령의 위임에 따른 법규명령 형식으로 행정청 내부의 사무처리 기준이 규정되는 경우에 그 법적성질을 법규명령으로 볼 것이지 행정규칙으로 볼 것인지가 문제 된다. 이러한 논의는 법규명령형식의 행정규칙 중 그 내용이 제재적 처분의 기준인 경우에 중요하다.

※ 더보기 [감정평가사 시험2차 관련]

- ▷ 「**감정평가법**」 시행령 제29조 [별표3] : 감정평가법인등의 인가취소 등에 관한 규정
- ▷ 「**감정평가법**」 시행령 제43조 : 감정평가법인등의 과징금 부과기준 등에 관한 규정

2) 법적성질

(1) 학설

① 법규명령설(형식설)

규범의 형식을 중시하고 법적 안정성 확보를 위해 법규명령으로 보는 견해를 말한다.

특히 제재적 처분기준은 제재의 정도를 가감할 수 있는 가중·감경 조항이 있어 개별적·탄력적 적용이 가능하므로 법규성을 긍정한다.

② 행정규칙설(실질설)

규범의 실질을 중시하고 행정의 실질적 타당성과 탄력성 확보를 위해 행정규칙으로 보는 견해를 말한다.

즉, 행정규칙 사항을 대통령령·총리령·부령으로 정한다고 해서 그 성질이 법규명령이 되는 것은 아니라고 본다.

③ 수권여부기준설

수권여부를 기준으로 판단하는 견해로서, 상위법령의 수권에 근거하여 제정되었다면 법규명령으로 보고 위임이 없이 제정되었다면 행정규칙으로 본다. 이는 법규명령과 행정규칙의 개념을 중시하여 판단하는 견해이다.

(2) 판례

판례는 일반적으로 법규명령형식의 행정규칙의 법규성을 인정하여 법규명령으로 보는 입장이다.

그러나 제재적 처분기준의 경우 아래와 같이 부령과 대통령령에 따라 법규성을 다르게 보고 있다.

① 부령 형식

구) 「식품위생법」 시행규칙으로 규정된 영업정지 등의 제재적 처분기준은 그 성질과 내용이 행정내부의 사무처리기준에 불과하므로 행정규칙의 성질을 가지며 대외적으로 국민이나 법원을 구속하는 것은 아니라고 보고 있다. 다만, 대법원은 제재적 행정처분의 기준이 부령의 형식으로 규정되어 있는 경우 행정규칙(재량준칙)으로 보면서도 법원은 당해 제재적 처분기준을 존중하여야 한다고 본다.

대법원 2010. 4. 8. 선고 2009두22997 판결

구 법 시행규칙 제53조 [별표 15] 행정처분기준이 비록 행정청 내부의 사무처리 준칙을 정한 것에 지나지 아니하여 대외적으로 법원이나 국민을 구속하는 효력은 없지만, 위 행정처분기준이 수입업자들 및 행정청 사이에 처분의 수위를 가늠할 수 있는 유력한 잣대로 인식되고 있는 현실에 수입식품으로 인하여 생기는 위생상의 위해를 방지하기 위한 단속의 필요성과 그 일관성 제고라는 측면까지 아울러 참작하면, 위 행정처분기준에서 정하고 있는 범위를 벗어나는 처분을 하기 위해서는 그 기준을 준수한 행정처분을 할 경우 공익상 필요와 상대방이 받게 되는 불이익 등과 사이에 현저한 불균형이 발생한다는 등의 특별한 사정이 있어야 한다.

② 대통령령 형식

구) 「청소년보호법」 시행령으로 제정된 과징금 처분기준의 경우에 대외적 구속력을 긍정하여 법규명령으로 판시하였다. 다만, 대법원은 해당 과징금 처분의 기준을 최고한도액을 정한 것으로 보아 재량의 여지를 인정하고 있다.

구 청소년보호법(1999. 2. 5. 법률 제5817호로 개정되기 전의 것) 제49조 제1항, 제2항에 따른 같은 법 시행령(1999. 6. 30. 대통령령 제16461호로 개정되기 전의 것) 제40조 [별표 6]의 위반행위의 종별에 따른 과징금 처분기준은 법규명령이기는 하나 모법의 위임규정의 내용과 취지 및 헌법상의 과잉금지의 원칙과 평등의 원칙 등에 비추어 같은 유형의 위반행위라 하더라도 그 규모나 기간·사회적 비난 정도·위반행위로 인하여 다른 법률에 의하여 처벌받은 다른 사정·행위자의 개인적 사정 및 위반행위로 얻은 불법이익의 규모 등 여러 요소를 종합적으로 고려하여 사안에 따라 적절한 과징금의 액수를 정하여야 할 것이므로 그 수액은 정액이 아니라 최고한도액이다.

(3) 소결

대통령령과 부령의 형식적 차이에 따라 법규명령형식의 행정규칙의 법규성을 구분하는 것은 합리적인 이유가 없어 타당하지 않다. 대통령령과 부령 모두 헌법 제75조 및 제95조에 근거한 형식이며 법규명령으로서 절차적 정당성이 부여되어 있으므로 국민의 예측가능성을 보장하는 측면에서 형식을 기준으로 법규명령으로 보는 <법규명령설>이 타당하다.

02 법령보충적 행정규칙 (행정규칙형식의 법규명령)

1) 의의

법령보충적 행정규칙이란 상위법령의 위임에 따라 대통령령·총리령·부령과 같이 법규명령 형식으로 제정되어야 할 사항을 훈령 등 행정규칙의 형식으로 제정한 것을 말한다. 즉, 그 형식은 행정규칙이나 실질(내용)이 법규명령인 것으로 행정규칙형식의 법규명령이라고도 한다. 법규명령형식의 행정규칙과 마찬가지로 실질과 형식이 달라 그 법적성질을 어떻게 보아야 하는지가 문제가 된다.

※ 더보기 [감정평가사 시험2차 관련]

▷ 토지가격비준표 : 국토교통부장관이 한국부동산원에 업무를 위탁하며,

「부동산공시법」 제3조 제8항에 위임 규정이 있다.

▷ 표준지공시지가 조사평가기준 : 국토교통부 훈령 형식으로 제정되었으며,

「부동산공시법」 시행령 제6조 제3항에 위임 규정이 있다.

2) 법적성질

(1) 학설

① 법규명령설(실질설)

법규명령설은 실질을 중시하는 견해로서 상위법령을 보충·구체화 하는 기능이 있는 훈령·고시 등의 대외적 구속력을 긍정하여 법규명령으로 보는 견해이다.

② 행정규칙설(형식설)

법규명령 형식은 대통령령·부령·총리령으로 한정되어 있으므로 이러한 형식에 의하지 않은 훈령 등은 행정규칙이라고 보는 견해로서 형식을 중시한다.

③ 수권여부기준설

상위법령의 수권 유무에 따라 구분하는 견해로서, 위임 있다면 법규명령으로 보고 위임이 없는 경우에는 행정규칙으로 본다.

④ 규범구체화 행정규칙설

규범구체화 행정규칙설은 대외적으로는 법적 구속력을 인정하나, 내부적으로는 상위법령을 구체화하는 규범구체화 행정규칙으로 보는 견해이다.

⑤ 위헌무효설

헌법 제75조 및 제95조에서 법규명령의 형식을 한정하고 있으므로 행정규칙의 형식으로 법규명령을 제정하는 것은 위헌·무효라고 보는 견해이다.

(2) 판례

판례는 국세청장의 훈령 형식인 재산제세사무처리규정과 관련하여 해당 규정이 소득세법 시행령의 위임에 따라 그 내용을 보충하는 기능을 가지면 상위법령과 결합하여 대외적인 구속력이 있는 법규명령으로서의 효력을 갖는다고 본다.

대법원86누484판결

나. 소득세법 (1982.12.21. 법률 제3576호로 개정된 것) 제23조 제4항, 제45조 제1항 제1호에서 양도소득세의 양도차익을 계산함에 있어 실지거래가액이 적용될 경우를 대통령령에 위임함으로써 동법시행령(1982.12.31. 대통령령 제10977호로 개정된 것) 제170조 제4항 제2호가 위 위임규정에 따라 양도소득세의 실지거래가액이 적용될 경우의 하나로서 국세청장으로 하여금 양도소득세의 실지거래가액이 적용될 부동산투기억제를 위하여 필요하다고 인정되는 거래를 지정하게 하면서 그 지정의 절차나 방법에 관하여 아무런 제한을 두고 있지 아니하고 있어 이에 따라 국세청장이 재산제세사무처리규정 제72조 제3항에서 양도소득세의 실지거래가액이 적용될 부동산투기억제를 위하여 필요하다고 인정되는 거래의 유형을 열거하고 있으므로, 이는 비록 위 재산제세사무처리규정이 국세청장의 훈령 형식으로 되어 있다 하더라도 이에 의한 거래지정은 소득세법시행령의 위임에 따라 그 규정의 내용을 보충하는 기능을 가지면서 그와 결합하여 대외적 효력을 발생하게 된다 할 것이므로 그 보충규정의 내용이 위 법령의 위임한계를 벗어났다는 등 특별한 사정이 없는 한 양도소득세의 실지거래가액에 의한 과세의 법령상의 근거가 된다.

(3) 소결

상위법령의 위임을 받아 법규사항을 정하는 행정규칙은 위임을 한 명령을 보충·구체화 하는 것을 내용으로 하는 경우 상위법령의 위임의 한계 내에서 상위법령과 결합하여 대외적 구속력을 갖는다고 보는 것이 타당하다. 또한 행정규제기본법 제4조 제2항에 따라 전문적이고 기술적인 사항 등 최소한의 영역에서만 법령보충적 행정규칙의 법규성을 인정함이 타당하다.

[행정규제기본법] 제4조 (규제 법정주의)

② 규제는 법률에 직접 규정하되, 규제의 세부적인 내용은 법률 또는 상위법령(上位法令)에서 구체적으로 범위를 정하여 위임한 바에 따라 대통령령·총리령·부령 또는 조례·규칙으로 정할 수 있다. 다만, 법령에서 전문적·기술적 사항이나 경미한 사항으로서 업무의 성질상 위임이 불가피한 사항에 관하여 구체적으로 범위를 정하여 위임한 경우에는 고시 등으로 정할 수 있다.

제1절

개념

01 행정행위의 개념

행정행위란 학문상 용어로서 실정법으로는 인가, 허가, 면허, 결정 등 다양한 용어로 사용되는 것을 학문상 개념으로 정립한 것을 말한다. 실정법에서는 ‘행정처분’이나 ‘처분’이라는 용어를 행정행위와 상응하는 용어로 사용하고 있다. 통설에 따르면 행정행위는 행정청이 구체적 사실에 대한 법 집행으로서 행하는 권력적 단독행위인 공법행위라고 정의한다.

[행정소송법] 제2조 (정의) 제1항 제1호

“처분등”이라 함은 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서의 공권력의 행사 또는 그 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용(이하 “處分”이라 한다) 및 행정심판에 대한 재결을 말한다.

[행정심판법] 제2조 (정의) 제1호

“처분”이란 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서의 공권력의 행사 또는 그 거부, 그 밖에 이에 준하는 행정작용을 말한다.

02 행정행위의 개념요소

1) 행정청의 행위

행정행위란 행정청의 행위일 것을 요건으로 한다. 행정청이란 행정조직법상의 개념이 아닌 기능면에서 파악한 개념으로서 사인 등도 공무를 위탁받아 수행하는 한 행정청의 개념에 포함될 수 있다.

2) 구체적 사실에 대한 행위

행정행위는 규범을 정립하는 행위가 아니라 구체적 사실에 대한 법 집행 행위를 말한다. 즉, 국민의 권리·의무에 변경을 가져오는 행위를 의미하는 것으로 법규명령(처분적 명령은 제외)과 같은 규범 자체는 행정행위가 아니다.

3) 법적 행위

행정행위는 사실행위가 아닌 법적 행위에 해당하며 외부적으로 권리·의무의 발생, 변경, 소멸이라는 법적 효과를 일으키는 행위를 말한다.

4) 권력적 단독행위

행정행위는 국민에 대해 우월한 지위에서 일방적으로 행사하는 권력적 단독행위여야 한다.

따라서 비권력적 행위인 공법상 계약, 공법상 합동행위는 행정행위가 아니다.

03 행정행위의 종류

행정행위는 ① 법적 효과의 발생원인, ② 법적 효과의 성질, ③ 행정청의 선택·결정권 유무 등 다양한 기준으로 분류할 수 있다.

1) 법률행위적 행정행위와 준법률행위적 행정행위 (법적효과의 발생원인 기준)

(1) 의의 및 구별실익

법률행위적 행정행위란 행정청의 의사표시를 구성요소로 하고 그 의사표시의 내용에 따라 일정한 법적 효과가 발생하는 행위를 말하고, 준법률행위적 행정행위란 행정청의 의사표시 이외의 정신작용(판단, 인식 등)을 구성요소로 하고 행정청의 의사와는 무관하게 법규가 정한 바에 따라 법적 효과가 발생하는 행위를 의미한다.

종래 통설은 법률행위적 행정행위에는 부관을 붙일 수 있으나 준법률행위적 행정행위에는 부관을 붙일 수 없다고 보아 구별실익이 있었으나, 법률행위적 행정행위라도 귀화허가 등의 경우에는 부관을 붙일 수 없고, 준법률행위적 행정행위인 공증에는 기한 등과 같은 부관을 붙일 수 있다고 보아 그 구분에 의문이 제기되기도 한다.

(2) 법률행위적 행정행위

법률행위적 행정행위는 명령적 행정행위와 형성적 행정행위로 구분할 수 있다.

① 명령적 행정행위

명령적 행위란 질서유지를 위해 국민에 대하여 일정한 작위·부작위·금부·수인 등 의 의무를 명하거나 해제하는 행정행위를 말한다.

구 분	내 용
하명	행정청이 작위·부작위·금부·수인 등의 의무를 명하는 행위를 말하며, 침익적 성질을 가지므로 법령의 근거가 필요하다. 예) 작위하명(위반건축물 철거명령), 부작위(청소년 음주금지), 금부(세금부과), 수인(강제집행시 수인의무)
허가	허가란 질서유지·위험예방 등을 위해 법률로 개인의 자유를 제한하고 일정한 요건이 구비된 경우에 그 제한을 해제하여 본래의 자유를 회복시켜 주는 행정행위를 말한다. 예) 주류판매 허가, 건축허가, 운전면허 등
면제	면제란 법령에 의해 부과된 작위·금부·수인 등의 의무를 특정한 경우에 해제해 주는 행정행위를 말한다. 허가는 의무해제의 대상이 부작위라는 점에서 면제와 구별된다. 예) 조세감면, 예방접종 면제 등

② 형성적 행정행위

형성적 행위란 사인에게 새로운 권리·능력·법률상의 지위 또는 포괄적 법률관계, 기타 법률상의 힘을 발생, 변경, 소멸시키는 행정행위를 말한다.

구 분	내 용
특허	특허란 특정인에 대하여 새로운 권리, 능력 또는 포괄적 법률관계를 설정하는 행위를 말한다. 본래부터 있던 자연적 자유가 아닌 새로운 권리 등으로 설권행위라고 부르기도 한다. 예) 광업권, 어업권 등
인가	인가란 행정청이 제3자의 법률행위를 보충하여 그 법률상의 효과를 완성시키는 행정행위를 말한다. 제3자의 행위를 보충한다는 점에서 보충행위라고도 한다. 예) 「감정평가법」제29조에 의한 감정평가법인 설립인가
대리	대리란 제3자가 해야 할 일을 행정청이 대신하여 행함으로써 제3자가 스스로 행한 것과 같은 법적 효과를 발생시키는 행정행위를 말한다. 예) 사자의 유류품처분 등

- ※ 허가와 특허는 학문상 개념으로 실정법상으로는 양자가 혼용되어 사용되므로 그 내용에 따라 구분함이 필요하다.
- ※ 「토지보상법」 제20조의 사업인정의 법적성질에 대해 특허 또는 확인행위로 보는 견해 대립이 있다.
- ※ 「도정법」 상 재건축조합설립인가처분의 법적성질에 대해 종래는 인가로 보았으나 최근 특허설의 입장을 취한다.

(3) 준법률행위적 행정행위

준법률행위적 행정행위는 행정청의 의사표시(효과 의사) 이외의 정신작용(판단·인식) 등을 구성요건으로 하는 행정행위로서 그 효과가 행정청의 의사가 아닌 법률 규정에 의해 발생하는 행위를 말하며 확인, 공증, 통지 및 수리행위가 이에 해당한다.

구 분	내 용
확인	확인이란 진위가 불확실한 특정한 사실 또는 법률관계의 존재 여부 또는 정당성 여부에 관해 의문이나 다툼이 있는 경우 행정청이 공적인 권위로 판단하여 확정하는 행위를 말한다. 예) 소득금액 및 소득세액 결정, 국가시험 합격자 결정 등
공증	공증이란 진위가 확실한 특정한 사실 또는 법률관계의 존재 여부를 공적으로 증명하는 행위를 말한다. 각종의 등기·등록·증명서의 발급 등이 이에 해당한다. 예) 각종 공부의 등재(등기부, 토지대장 등), 각종 증명서 등
통지	통지란 행정청이 특정인 또는 불특정 다수인에 대해 일정한 사실을 알리는 행위를 말한다. 특정한 사실 또는 의사를 알리는 행위를 말하는 것으로서 일정한 법적 효과를 발생시키는 것을 의미한다. 예) 「대집행법」에 의한 계고
수리	수리란 행정청이 타인의 행위를 유효한 행위로서 받아들이는 행위를 말한다. 수리를 요하는 신고에서 수리는 준법률행위적 행정행위인 수리로서 항고소송의 대상인 처분에 해당한다.

- ※ 「토지보상법」 제29조의 협의성립확인의 법적성질에 대해 형성적 행정행위로 보는 견해와 준법률행위적 행정행위(확인, 공증)로 보는 견해가 대립한다.
- ※ 「토지보상법」 제22조의 사업인정고시의 법적성질에 대해 통지로 보는 견해와 특허로 보는 견해가 대립한다.
- ※ 「건축법」상 건축신고의 거부의 처분성이 문제된다.

2) 수익적·침익적·복효적 행정행위 (법적 효과의 성질 기준)

행정행위가 상대방 또는 관계자에게 어떠한 법적 효과를 발생시키는지로 기준으로 수익적·침익적·복효적 행정행위로 구분할 수 있다.

구 분	내 용
수익적 행정행위	상대방에게 권리·이익을 부여하거나 권리의 제한을 해제해 유리한 효과 를 발생시키는 행정행위를 말한다. 예 특허, 인가 등
침익적 행정행위	상대방에게 권리를 제한하거나 의무를 부과하는 등 불이익한 효과 를 발생시키는 행정행위를 말한다. 예 위반건축물 철거명령, 조세부과 등
복효적 행정행위	하나의 행정행위가 이익과 불이익이라는 복수의 효과 를 발생시키는 행정행위를 말한다. 이때 그 복수의 효과가 동일인에게 발생되면 혼합효 행정행위라 하고, 상대방에게는 이익을 주고 제3자에게는 불이익을 주는 경우(혹은 그 반대)는 제3자효 행정행위라고 한다. 예 개발행위 허가, 건축허가 등

※ 「토지보상법」 제20조의 사업인정은 사업시행자에게는 수익을 피수용자에게는 불이익을 주는 제3자효 행정행위이다.

3) 기속행위와 재량행위 (행정청의 선택·결정권 유무 기준)

(1) 의의

기속행위란 법령상 **요건이 충족되면** 행정청은 **반드시** 일정한 행위를 하거나 하여서는 안 되는 행정행위를 말한다. 기속행위는 행정청의 재량이 전혀 인정되지 않는데, 이에 반해 재량행위는 법령상 요건이 충족되더라도 행정법규가 행정청에 일정한 한도 내에서 **재량권**을 부여고 있어 행정청이 효과를 **선택**할 수 있는 행정행위를 말한다.

(2) 구별실익

기속행위와 재량행위는 **사법심사 방식**에 차이가 있어 그 구별에 실익이 있다. 기속행위는 법령상 요건 충족시 반드시 일정한 행위를 하여야 하는 법규에 대한 기속성이 있으므로 그 행위의 위법여부를 법원이 독자적으로 심사할 수 있다. 즉, 법원이 법규의 해석과 적용을 통해 **독자적인 결론**을 도출한 후 행정청의 행위에 대한 **적법여부**를 심사한다. 반면에 재량행위는 공익과 관련하여 행정청에 재량권이 있으므로 법원이 독자적 결론을 도출함이 없이 행정청의 행위에 대해 **재량권의 일탈·남용**이 있는지를 심사하게 된다. 부관의 부처 가능성과 관련하여 서는 종래에는 기속행위에는 부관을 부가할 수 없다고 하여 구별실익이 있었으나, 최근에는 기속행위에도 요건충족적 부관은 붙일 수 있다는 것이 다수의 견해이므로 부관과 관련하여서는 구별실익은 없다.

(3) 구별기준

기속행위와 재량행위는 법문의 해석을 통해 1차적으로 구분할 수 있다.

즉, 법령에서 ‘……하여야 한다’고 표현하면 기속행위로 보고, ‘……할 수 있다’고 표현하면 재량행위로 본다. 그러나 법문의 표현이 불분명한 경우에는 ① 당해 행위가 속하는 행정 분야의 주된 목적과 특성, ② 당해 행위 자체의 개별적 성질과 유형 등을 종합 고려하여 판단하여야 한다.

대법원 1997. 12. 26. 선고 97누15418 판결

어느 행정행위가 기속행위인지 재량행위인지 나아가 재량행위라고 할지라도 기속재량행위인지 또는 자유재량에 속하는 것인지의 여부는 이를 일률적으로 규정지을 수는 없는 것이고, 당해 처분의 근거가 된 규정의 형식이나 체재 또는 문언에 따라 개별적으로 판단하여야 한다.

(4) 재량권의 한계 (재량권 일탈·남용)

재량행위는 행정청에게 재량권이 있으므로 재량권에 부여된 목적과 한계 내에서 행해지는 행위는 적법한 것이 되어 사법심사의 대상이 되지 않는다. 즉, 그 목적과 한계 내의 것이라면 부당한 행위가 될 수는 있으나 위법한 것은 되지 않아 법원의 통제 대상이 되지 않는다.

재량의 하자에는 재량권 일탈과 남용, 재량권의 불행사 및 재량권의 해태가 있다. 다만, 판례는 재량권의 일탈과 재량권의 남용을 명확히 구분하지 않고 재량권의 행사에 ‘재량권의 일탈 또는 남용’이 없는지를 판단한다. 실질적으로 재량권 일탈과 남용을 구분할 실익이 없고 재량권의 한계를 위반한 재량권 행사는 위법하게 된다.

구 분	내 용
재량권 일탈	재량권 일탈이란 법령에 따라 부여된 재량의 한계를 벗어난 것으로, 재량권의 외적 한계(법적·객관적 한계)를 벗어난 것을 말한다. 예 법령상 업무정지 처분만을 규정하는데 영업취소 처분을 한 경우
재량권 남용	재량권 남용이란 관련 이익을 정당하게 형량하지 않은 것으로, 재량권의 내적 한계를 벗어난 것을 말한다. 예 사업인정시 당해 사업의 공익에 대한 비교형량을 제대로 하지 않은 경우

[행정소송법] 제27조 (재량처분의 취소)

행정청의 재량에 속하는 처분이라도 재량권의 한계를 넘거나 그 남용이 있는 때에는 법원은 이를 취소할 수 있다.

체류기간연장등불허가처분취소 [대법원 2016. 7. 14. 선고 2015두48846 판결]

관련 법령의 문언, 내용 및 형식, 체계 등에 비추어 보면, 체류자격 변경허가는 신청인에게 당초의 체류자격과 다른 체류자격에 해당하는 활동을 할 수 있는 권한을 부여하는 일종의 설권적 처분의 성격을 가지므로, 허가권자는 신청인이 관계 법령에서 정한 요건을 충족하였다고 하더라도, 신청인의 적격성, 체류 목적, 공익상의 영향 등을 참작하여 허가 여부를 결정할 수 있는 재량을 가진다고 할 것이다. 다만 이러한 재량을 행사할 때 판단의 기초가 된 사실인정에 중대한 오류가 있는 경우 또는 비례·평등의 원칙을 위반하거나 사회통념상 현저하게 타당성을 잃는 등의 사유가 있다면 이는 재량권의 일탈·남용으로서 위법하다.

제재적 행정처분이 사회통념상 재량권의 범위를 일탈하였거나 남용하였는지 여부는 처분사유로 된 위반행위의 내용과 당해 처분행위에 의하여 달성하려는 공익목적 및 이에 따르는 제반 사정 등을 객관적으로 심리하여 공익침해의 정도와 그 처분으로 인하여 개인이 입게 될 불이익을 비교 교량하여 판단하여야 한다.

(5) 불확정개념과 판단여지

① 불확정개념

불확정개념이란 법규의 요건 부분에 사용된 추상적이며 해석의 여지가 있는 다의적 개념을 말한다.

공공복지, 공공의 안녕과 질서 등의 개념을 예로 들 수 있으며, 행정의 다양성으로 그 사용이 증가하고 있다.

불확정개념은 법개념이고 사법심사의 대상이 된다.

② 판단여지

a. 의의

요건에 불확정개념이 규정된 경우에 그 불확정개념의 해석·적용에 있어서 하나의 판단만이 적법하다고 보면서도, 행정청의 결정이 일정한 한계 내에서 이루어진 경우 법원은 이를 존중하여야 한다는 이론이다.

판단여지는

- ① 비대체적 결정 영역(전문적, 학문적 평가에 관계되는 시험성적의 평가 등),
- ② 구속적 가치평가 영역(직무상 독립성을 가지는 위원회의 결정 등),
- ③ 형성적·정책적 결정 영역 등(외국인의 체류기간 연장 등)에서 인정될 수 있다.

판단여지가 인정되는 영역 내에서 행정청이 신중하게 내린 판단은 위법하지 않으며 법원에 의한 통제의 대상이 되지 않는다.

b. 학설 및 판례

판단여지를 재량과의 구별되는 독자적 개념으로 인정할 것인지에 대해서는 견해가 대립하는데,

- ① 사법심사가 제한된다는 점에서 양자를 구별할 실익이 없다는 <부정설>,
- ② 판단여지는 법인식 문제이고, 재량은 법률효과 선택의 문제라고 보아 양자를 구별하여 판단여지를 독자적 개념으로 인정하여야 한다고 보는 <긍정설>이 있다.

판례는 판단여지의 영역의 문제(시험평가, 독립된 위원회의 결정 등)를 재량과 구별되는 개념으로 인정하지 않고 있다.

c. 판단여지의 한계

판단여지는 행정행위의 요건에 불확정개념이 규정된 경우 그 해석·적용에서 인정되는데,

이렇게 판단여지가 존재하는 경우에도

- ① 판단기관이 적법하게 구성되었는지 여부,
- ② 절차 규정의 준수 여부,
- ③ 정당한 사실관계에서 출발하였는지 여부,
- ④ 일반적으로 승인된 평가 척도의 침해 여부 등은 사법심사의 대상이 된다.

지가공시및토지등의평가에관한법률시행령 제18조 제1항, 제2항은 감정평가사시험의 합격기준으로 절대평가제 방식을 원칙으로 하되, 행정청이 감정평가사의 수급상 필요하다고 인정할 때에는 상대평가제 방식으로 할 수 있다고 규정하고 있으므로, 감정평가사시험을 실시함에 있어 어떠한 합격기준을 선택할 것인가는 시험실시기관인 행정청의 고유한 정책적인 판단에 맡겨진 것으로서 자유재량에 속한다.

01 개설

행정행위가 성립하여 효력을 발생시키기 위해서는 성립 및 효력요건을 갖추어야 하며, 성립 및 효력요건은 행정행위의 적법요건으로서 이러한 요건을 갖추지 못한 경우는 하자 있는 행정행위가 된다.

02 행정행위의 성립요건

구 분	내 용
주체	행정행위는 정당한 권한을 가진 기관이 부여된 권한의 범위 내에서 정상적인 의사에 따라 행해야 한다.
절차	행정행위는 법령상 규정된 일정한 절차를 거쳐야 하며, 다른 기관과의 협력절차가 요구되는 경우에는 그러한 절차를 거쳐야 한다.
형식	행정행위는 그 내용과 존재를 객관적으로 명확히 하기 위해 일정한 형식이 요구되는 경우가 많다. 행정절차법은 행정청이 처분을 하는 경우에는 다른 법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 문서로 하여야 한다고 규정함으로써 서면주의 원칙을 정하고 있다. (「행정절차법」 제24조 제1항)
내용	행정행위는 그 내용이 법률에 적합하여야 하고, 법률상·사실상 실현 가능하며, 이해관계인이 인식할 수 있을 정도로 명확한 것이어야 한다.

03 행정행위의 효력발생요건

행정행위의 효력발생요건이란 성립요건을 갖춘 행정행위가 상대방에 대해 효력을 발생하기 위한 요건을 말한다. 상대방이 있는 행정행위는 원칙적으로 상대방에게 도달된 때(도달주의)에 그 효력이 발생한다(행정절차법 제15조). 여기에서 ‘도달’이란 상대방이 알 수 있는 상태에 두는 것을 말한다. 즉 상대방이 직접 수령하여 그 내용을 현실적으로 알 것까지 요하지는 않는다. 통지는 상대방이 특정된 경우는 원칙적으로 송달에 의하고, 상대방이 불특정 다수인 이거나 상대방의 주소 등이 불분명하여 송달이 불가능한 경우에는 고시 또는 공고에 의한다.

[행정절차법] 제15조 (송달의 효력 발생)

- ① 송달은 다른 법령등에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 문서가 송달받을 자에게 도달됨으로써 그 효력이 발생한다.

※ 「토지보상법」 제22조에 의거 사업인정은 사업인정고시 한날부터 효력이 발생한다.

04 행정행위의 효력

1) 구속력

구속력이란 행정행위가 성립·효력발생요건을 갖추면 행정청의 효과의사의 내용이나(법률행위적 행정행위), 법령이 정하는 바에 따라(준법률행위적 행정행위) 일정한 법적효과를 발생시키고 행정주체와 관계인을 구속하는 힘을 가지게 되는데 이를 구속력이라고 한다.

2) 공정력

공정력이란 행정행위에 하자가 있다 하더라도 그것이 중대·명백하여 당연히 무효로 인정되는 경우를 제외하고는 권한 있는 기관(처분청, 감독청, 행정심판위원회, 법원)에 의하여 취소되기 전까지 상대방이나 이해관계인은 그 효력을 부인할 수 없는 구속력을 말한다. 즉, 하자 있는 행정행위라도 취소되지 않는 한 일단 유효한 것으로 통용되는 힘을 말하며, 행정의 안정성과 실효성 확보에 그 이론적 근거가 있다.

[행정기본법] 제15조 (처분의 효력)

처분은 권한이 있는 기관이 취소 또는 철회하거나 기간의 경과 등으로 소멸되기 전까지는 유효한 것으로 통용된다. 다만, 무효인 처분은 처음부터 그 효력이 발생하지 아니한다.

3) 구성요건적 효력과 선결문제 [★★★]

(1) 의의

구성요건적 효력이란 취소할 수 있는 행정행위일지라도 그 행정행위가 유효하게 존재하는 한 다른 행정기관이나 법원은 그 행위와 관련이 있는 자들의 결정에 그 행위의 존재와 법적 효과를 인정해야 하고 그 내용에 구속되는 효력을 말한다.

(2) 선결문제

① 의의

선결문제란 민사·형사법원의 본안판단에 앞서 특정 행정행위의 위법 여부 또는 효력 유무가 먼저 해결되어야 할 문제인 된 경우에 그 특정 행정행위의 위법 여부 등의 문제를 선결문제라 한다. 선결문제를 공정력의 문제로 보는 견해도 있으나(공정력과 구성요건적 효력을 구분하지 않는 견해), 공정력과 구성요건적 효력은 내용, 범위 및 이론적·법적근거를 달리하므로 양자를 구별하는 것이 타당하며, 선결문제를 구성요건적 효력의 문제로 보는 것이 다수의 견해이다.

[행정소송법] 제11조 (선결문제)

① 처분등의 효력 유무 또는 존재 여부가 민사소송의 선결문제로 되어 당해 민사소송의 수소법원이 이를 심리·판단 하는 경우에는 제17조, 제25조, 제26조 및 제33조의 규정을 준용한다.

② 문제점

행정소송법 제11조 제1항은 처분의 효력 유무 또는 존재 여부에 대해서는 민사소송에서 선결문제로 심리·판단할 수 있다고 규정하고 있어 민사법원은 행정행위의 효력 유무(존재 여부)를 스스로 심사할 수 있다. 그러나 민사법원에서 행정행위의 위법 여부가 선결문제가 되는 경우나 형사법원에서 행정행위의 효력 유무(존재 여부) 또는 위법 여부가 선결문제가 되는 경우에 대해서는 규정이 없어 문제가 된다.

③ 선결문제의 유형

구 분	유형	심리·판단	판례
민사사건	효력 유무	가능	과세처분이 무효임을 이유로한 부당이득반환청구소송
	효력 부인	불가	
	위법 여부	가능	계고처분이 위법임을 이유로한 손해배상청구
형사사건	효력 유무	가능	무면허운전기소사건에서 운전면허가 취소되지 않는 한 무면허운전에 해당되지 않는다는 판례
	효력 부인	불가	
	위법 여부	가능	토지 무단형질 변경을 이유로 내린 원상회복 명령은 불이행한 사건에서 원상회복명령의 위법성을 확인하여 무죄판결

(3) 민사사건의 경우

가. 행정행위의 효력 유무가 선결문재인 경우

a) 문제점

행정행위가 당연무효인 경우 민사법원은 당해 행정행위가 당연무효인지를 심사하여 당연무효임을 전제로 하여 판단할 수 있으나, 행정행위의 하자가 취소사유인 경우 선결문제로 해당 행정행위의 효력을 부인할 수 있는지가 문제 된다.

b) 학설

위법한 행정행위라도 당연무효가 아닌 한 당해 행정행위의 구성요건적 효력으로 인해 유효하므로 그 효력을 부인할 수 없어 선결문제로 심사할 수 없다는 것이 일반적 견해이다.

c) 판례

[당연무효인 경우]

[대법원 2010.04.08 선고 2009다90092 판결]

민사소송에 있어서 어느 행정처분의 당연무효 여부가 선결문제로 되는 때에는 이를 판단하여 당연무효임을 전제로 판결할 수 있고 반드시 행정소송 등의 절차에 의하여 그 취소나 무효확인을 받아야 하는 것은 아니며, 한편 원고 조합의 조합설립결의나 관리처분계획에 대한 결의가 당연무효라는 위 피고들의 주장 속에는 조합설립 인가처분이나 관리처분계획에 당연무효사유가 있다는 주장도 포함되어 있다고 봄이 상당하다고 할 것이므로, 원심으로서 더 나아가 위 조합설립 인가처분이나 관리처분계획에 당연무효사유가 있는지를 심리하여 위 피고들 주장의 당부를 판단하였어야 할 것임에도, 원심이 그에 대해서는 아무런 판단도 하지 아니한 채, 단지 위 피고들이 항고소송의 방법으로 원고 조합의 조합설립 인가처분이나 관리처분계획에 대하여 취소 또는 무효확인을 받았음을 인정할 증거가 없다는 이유만으로 위 피고들의 주장을 모두 배척한 데에는 필요한 심리를 다하지 아니하고 판단을 유탈하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

[대법원 1973. 7. 10. 선고 70다1439 판결]

국세 등의 부과 및 징수처분 등과 같은 행정처분이 당연무효임을 전제로 하여 민사소송을 제기한 때에는 그 행정처분의 당연무효인지의 여부가 선결문제이므로, 법원은 이를 심사하여 그 행정처분의 하자가 중대하고 명백하여 당연무효라고 인정될 경우에는 이를 전제로 하여 판단할 수 있으나 그 하자가 단순한 취소사유에 그칠 때에는 법원은 그 효력을 부인할 수 없다 할 것이다.

[취소사유인 경우]

[대법원 1994. 11. 11. 선고 94다28000 판결]

조세의 과오납이 부당이득이 되기 위하여는 납세 또는 조세의 징수가 실체법적으로나 절차법적으로 전혀 법률상의 근거가 없거나 과세처분의 하자가 중대하고 명백하여 당연무효이어야 하고, 과세처분의 하자가 단지 취소할 수 있는 정도에 불과할 때에는 과세관청이 이를 스스로 취소하거나 항고소송절차에 의하여 취소되지 않는 한 그로 인한 조세의 납부가 부당이득이 된다고 할 수 없다.

[대법원 2001. 1. 16. 선고 98다58511 판결]

수용재결이 있는 후에 수용 대상 토지에 숨은 하자가 발견되는 때에는 불복기간이 경과되지 아니한 경우라면 공평의 견지에서 기업자는 그 하자를 이유로 재결에 대한 이의를 거쳐 손실보상금의 감액을 내세워 행정소송을 제기할 수 있다고 보는 것이 상당하나, 이러한 불복절차를 취하지 않음으로써 그 재결에 대하여 더 이상 다룰 수 없게 된 경우에는 기업자는 그 재결이 당연무효이거나 취소되지 않는 한 재결에서 정한 손실보상금의 산정에 있어서 위 하자가 반영되지 않았다는 이유로 민사소송절차로 토지소유자에게 부당이득의 반환을 구할 수는 없다.

나. 행정행위의 위법 여부가 선결문제인 경우

a) 문제점

행정소송법 제11조 제1항에 의거 민사법원의 행정행위의 효력 유무(존재 여부)를 심사할 수 있으나 행정행위의 위법 여부를 심리·판단할 수 있는지에 대해서는 명문에 규정이 없어 이에 대해 견해가 대립한다.

b) 학설

- ① 행정소송법 제11조 제1항의 선결문제심판권을 제한적으로 해석하여 행정행위의 위법 여부의 판단을 포함한 행정사건의 심판권은 행정법원이 배타적으로 관할한다고 보는 <부정설>이 있고,
- ② 해당 조항은 선결문제심판권의 예시적 규정으로 민사법원이 행정행위의 위법 여부를 확인해도 행정행위의 효력을 부인하는 것은 아니라고 보는 <긍정설>이 있다.

c) 판례

계고처분의 위법 여부가 선결문제가 된 손해배상청구소송에서 행정처분의 취소판결이 있어야만 배상을 청구할 수 있는 것은 아니라고 하여 긍정설의 입장을 취한 바 있다.

[대법원 1972. 4. 28. 선고 72다337 판결]

위법한 행정대집행이 완료되면 그 처분의 무효확인 또는 취소를 구할 소의 이익은 없다 하더라도, 미리 그 행정처분의 취소판결이 있어야만, 그 행정처분의 위법임을 이유로 한 손해배상 청구를 할 수 있는 것은 아니다.

d) 소결

국가배상청구소송의 수소법원인 민사법원이 처분의 위법성을 확인하여도 해당 처분의 효력은 유지되고, 그 효력을 부인하는 것은 아니므로 통설·판례와 같이 민사법원이 행정행위의 위법 여부를 심리·판단할 수 있다고 보는 <긍정설>이 타당하다.

(4) 형사사건의 경우

가. 행정행위의 효력 유무가 선결문제인 경우

a) 당연무효인 경우

행정행위가 당연무효인 경우 형사법원은 당해 행정행위의 효력을 부인하고 무효임을 전제로 본안판단을 할 수 있다고 보는 것이 통설·판례의 입장이다.

대법원 1971. 5. 31. 선고 71도742 판결

과세대상과 납세의무자 확정이 잘못되어 당연무효한 과세에 대하여는 체납이 문제될 여지가 없으므로 체납범이 성립하지 않는다.

b) 취소사유인 경우

행정행위에 취소사유가 있는 경우 형사법원은 구성요건적 효력으로 당해 행정행위의 효력을 부인(취소)할 수는 없다고 보는 것이 통설·판례의 입장이다. 반면에 피고의 인권보장과 신속한 재판받을 권리가 보장되어야 하는 형사소송의 특수성에 의거 행정행위의 효력을 부인할 수 있다고 보는 견해도 있다.

대법원 1982. 6. 8. 선고 80도2646 판결

연령미달의 결격자인 피고인이 소외인의 이름으로 운전면허시험에 응시, 합격하여 교부받은 운전면허는 당연무효가 아니고 도로교통법 제65조 제3호의 사유에 해당함에 불과하여 취소되지 않는 한 유효하므로 피고인의 운전행위는 무면허운전에 해당하지 아니한다.

나. 행정행위의 위법 여부가 선결문제인 경우

형사법원에서 행정행위의 위법 여부가 선결문제인 경우는 민사법원의 경우와 마찬가지로 형사법원이 위법 여부를 심리·판단할 수 있다고 보는 것이 통설·판례의 입장이다.

대법원 1992. 8. 18. 선고 90도1709 판결

구 도시계획법 제78조 제1항에 정한 처분이나 조치명령을 받은 자가 이에 위반한 경우 이로 인하여 같은 법 제92조에 정한 처벌을 하기 위하여는 그 처분이나 조치명령이 적법한 것이라야 하고, 그 처분이 당연무효가 아니라 하더라도 그것이 위법한 처분으로 인정되는 한 같은 법 제92조 위반죄가 성립될 수 없다.

4) 존속력 (불가쟁력·불가변력)

행정행위가 행해진 후 제소기간의 경과 등 일정한 사유가 발생하면 상대방 등이 더 이상 그 효력을 다툴 수 없게 되고(불가쟁력), 일정한 행정행위의 경우 그 행위를 한 행정청도 이를 취소·철회할 수 없게 되는 데(불가변력) 이러한 효력을 존속력 또는 확정력이라 한다.

5) 강제력 (자력집행력·제재력)

행정행위는 자력집행력과 제재력이라는 강제력을 가진다. 자력집행력은 행정행위에 의해 부과된 의무를 상대방이 불이행하는 경우 행정청이 스스로 강제력을 발동하여 그 내용을 실현시키는 힘을 말하고, 제재력은 행정행위에 의해 부과된 의무를 상대방이 불이행하는 경우 그에 대한 제재로서 행정벌(행정형벌과 행정질서벌)을 부과하는 힘을 말한다.

01 행정행위의 무효와 취소

1) 의의

(1) 무효인 행정행위

무효인 행정행위란 행정행위의 외형은 갖추고 있으나 **처음부터** 아무런 효력을 발생시키지 않는 행정행위를 말한다. 한편 행정행위의 일부에 무효사유인 하자가 있는 경우 무효부분이 본질적이거나(처분청이 무효부분 없이는 행정행위를 발하지 않았을 경우) 불가분적인 경우에는 행정행위 전부가 무효가 되고 무효부분이 본질적이지 않고 가분적인 경우 무효부분만이 무효가 된다.

(2) 취소할 수 있는 행정행위

취소할 수 있는 행정행위란 행정행위의 성립에 하자가 있어 권한 있는 기관이 그 법률상의 효력을 소멸시킬 수 있는 행정행위를 말한다. 취소할 수 있는 행정행위는 **일단 유효**하게 성립되어 효력을 발생시키고 있으므로 취소하기 전까지는 유효한 행위로 통용된다.

2) 무효와 취소의 구별실익

구분	무효인 행정행위	취소할 수 있는 행정행위
효력 발생 여부	처음부터 아무런 효력 발생하지 않음	취소될 때까지 유효함
선결문제 관련	민·형사법원은 무효 여부가 선결문제가 될 경우 무효 확인 가능	민·형사법원은 행정행위의 효력을 부인할 수 없고, 행정행위의 위법 여부의 판단은 가능
하자의 치유	불인정	인정
하자의 승계	무효인 선행행위 하자는 후행행위에 승계됨	선행·후행행위가 동일한 법률효과를 목적으로 하거나 일정한 요건 하에 선행행위의 하자가 승계됨
쟁송형태	무효확인심판 무효확인소송	취소심판 취소소송
쟁송기간	제한 없음 (불가쟁력 X)	제한 있음
사정판결	불인정	인정

3) 무효와 취소의 구별기준

(1) 학설

① 중대설

하자의 중대성을 기준으로 하자가 **중대**하면 그 하자가 명백하지 않더라도 무효라는 견해이다.

② 중대·명백설 [★]

하자의 중대성과 명백성 모두를 기준으로 하자의 내용이 중대하고, 그 하자가 외관상 객관적으로 명백하면 무효인 행정행위이고 중대성과 명백성 중 어느 하나라도 갖추지 못한 경우에는 취소사유라고 보는 견해이다. 여기에서 중대성이란 행정행위가 중대한 법률요건을 위반하고 그 위반 정도가 상대적으로 심한 경우를 말하며, 명백성이란 일반인의 판단에 의해서도 하자가 있음이 객관적으로 외관상 분명한 것을 말한다.

③ 명백성 보충요건설

하자의 중대성을 기준으로 하자가 중대하기만 하면 무효가 되는 것이 원칙이지만, 제3자나 공공의 신뢰보호가 필요한 경우에는 보충적으로 명백성을 요구하는 견해이다. 명백성을 항상 요구하는 것은 아니라는 점에서 중대·명백설보다 무효의 범위가 넓어지게 된다.

④ 구체적가치형량설

행정행위는 다양한 이해관계를 갖고 있으므로 구체적인 사안마다 권리구제의 요청과 법적안정성의 요청 및 제3자의 이익 등을 구체적이고 개별적으로 형량하여 결정하여야 한다는 견해이다.

(2) 판례

대법원은 중대·명백설의 입장을 취하고 있고, 헌법재판소도 원칙적으로 중대·명백설을 취하고 있지만, 예외를 인정하여 행정처분 자체의 효력이 쟁송기간 경과 후에도 존속 중이고 그 행정처분의 근거가 된 법규가 위헌으로 선고되는 경우로서 그 행정처분을 무효로 하더라도 법적 안정성을 해치지 않는 반면, 그 하자가 중대하여 개인의 권리구제의 필요성이 큰 경우에는 하자가 명백하지 않더라도 무효를 인정한다.

대법원 1985. 7. 23. 선고 84누419 판결

행정처분이 당연무효라고 하기 위하여는 그 처분에 위법사유가 있다는 것만으로는 부족하고 그 하자가 중요한 법규에 위반한 것이고 객관적으로 명백한 것이어야 하며 하자가 중대하고도 명백한 것인가의 여부를 판별함에 있어서는 그 법규의 목적, 의미, 기능 등을 목적론적으로 고찰함과 동시에 구체적 사안자체의 특수성에 관하여도 합리적으로 고찰함을 요한다.

헌법재판소 1994. 6. 30. 선고 92헌바23 결정

판례나 통설은 행정처분이 당연무효인가의 여부는 그 행정처분의 하자가 중대하고 명백한가의 여부에 따라 결정된다고 보고 있지만 행정처분의 근거가 되는 법규범이 상위법 규범에 위반되어 무효인가 하는 점은 그것이 헌법재판소 또는 대법원에 의하여 유권적으로 확정되기 전에는 어느 누구에게도 명백한 것이라고 할 수 없기 때문에 원칙적으로 당연무효사유에는 해당할 수 없게 되는 것이다.

그러나 행정처분 자체의 효력이 쟁송기간 경과 후에도 존속 중인 경우, 특히 그 처분이 위헌법률에 근거하여 내려진 것이고 그 행정처분의 목적달성을 위하여서는 후행(後行) 행정처분이 필요한데 후행행정처분은 아직 이루어지지 않은 경우, 그 행정처분을 무효로 하더라도 법적 안정성을 크게 해치지 않는 반면에 그 하자가 중대하여 그 구제가 필요한 경우에 대하여서는 그 예외를 인정하여 이를 당연무효사유로 보아서 쟁송기간 경과 후에도 무효확인을 구할 수 있는 것이라고 봐야 할 것이다. 학설상으로도 중대명백설 외에 중대한 하자가 있기만 하면 그것이 명백하지 않더라도 무효라고 하는 중대설도 주장되고 있고, 대법원의 판례로도 반드시 하자가 중대명백한 경우에만 행정처분의 무효가 인정된다고는 속단할 수 없기 때문이다.

(3) 소결

행정의 법적 안정성과 국민의 권리구제의 요청을 적절히 조화시키는 측면에서 통설·판례와 같이 무효와 취소에 대한 객관적인 기준을 정립하여 판별하는 중대·명백설이 타당하다.

02 하자의 유형

행정행위의 하자의 유형에는 주체에 관한 하자, 절차에 관한 하자, 형식에 관한 하자 및 내용에 관한 하자가 있으며, 내용상 하자를 제외한 주체, 절차, 형식상의 하자를 넓은 의미에서 형식적 하자라고 부르기도 한다.

1) 주체상 하자

행정행위는 **정당한 권한**이 있는 행정기관에 의해서 행해져야 한다. 따라서 권한이 없는 행정기관에 의한 행위나 합의제 행정기관이나 의결기관 등에 구성원 수 미달, 결격자가 참가한 등 **구성상에 하자**가 있는 경우를 주체상 하자라고 하고 주체상 하자는 원칙적으로 무효가 된다.

2) 절차상 하자

법률에서 규정된 절차 중 어느 하나를 거치지 않거나 거쳤으나 절차상 하자가 있는 행정행위는 위법한 행정행위가 된다.

3) 형식상 하자

법령상 **문서**나 기타 형식을 요구하는 경우에 그에 의하지 않으면 형식상 하자가 있는 행정행위가 된다. 예로는 서명날인, 이유부기 등을 결한 행위가 있다.

4) 내용상 하자

행정행위는 **법령을 위반하지** 않아야 하고 **실행가능**하며 **명확**하여야 한다. 따라서 그 내용이 법령을 위반한 것이거나 사실상 실현 불가능 하거나 불명확한 행위는 위법한 행위가 된다.

03 하자의 치유 [★★★]

1) 의의

하자의 치유란 **성립 당시에** 하자가 있는 행정행위라 하더라도 **사후**에 그 하자를 **보완**하였다든가 또는 그 하자가 취소를 요하지 않을 정도로 경미해진 경우에 그 행위를 적법한 것으로 보아 효력을 유지시키는 것을 말한다.

2) 인정여부

학설은 ① **행정의 능률성** 측면에서 하자의 치유를 인정하는 <긍정설>, ② **법치주의 관점**에서 원칙적으로 부정하는 <부정설> 및 ③ **국민의 방어권 보장**을 침해하지 않는 범위 내에서 제한적으로 허용해야 한다고 보는 <제한적 긍정설>이 있다. 판례는 법치주의 관점에서 원칙적으로 허용될 수 없으나 예외적으로 행정행위의 무용한 반복을 피하고 당사자의 법적 안정성을 위해 이를 허용할 수 있으나 이 경우에도 국민의 권리나 이익을 침해하지 않아야 한다고 하여 **제한적 긍정설**의 입장을 취하고 있다. 생각건대, **법치주의의 원칙상 원칙적으로 부정함**이 타당하나 **행정의 능률성 등을 종합 고려**하여 판례와 같이 제한적으로 긍정함이 타당하다.

대법원 2002. 7. 9. 선고 2001두10684 판결

행정소송에서 행정처분의 위법 여부는 행정처분이 있을 때의 법령과 사실상태를 기준으로 하여 판단하여야 하고, 처분 후 법령의 개폐나 사실상태의 변동에 의하여 영향을 받지는 않는다고 할 것이고, 하자 있는 행정행위의 치유는 행정행위의 성질이나 법치주의의 관점에서 볼 때 원칙적으로 허용될 수 없는 것이고, 예외적으로 행정행위의 무효한 반복을 피하고 당사자의 법적 안정성을 위해 이를 허용하는 때에도 국민의 권리나 이익을 침해하지 않는 범위에서 구체적 사정에 따라 합목적적으로 인정하여야 할 것이다.

3) 적용영역

전통적 견해와 판례는 하자의 치유는 취소할 수 있는 행위에만 인정되고, 무효인 행정행위에는 인정하지 않는다고 본다. 또한 내용상 하자도 치유 가능하다고 보는 견해도 있으나 행정의 법률적합성의 원칙을 고려할 때 부정하는 것이 타당하다. 따라서 하자의 치유는 취소할 수 있는 행위와 절차상 하자 또는 형식상 하자에만 가능하다고 보는 것이 일반적이다.

대법원 1992. 10. 23. 선고 92누2844 판결

행정청이 식품위생법상의 청문절차를 이행함에 있어 청문서 도달기간을 다소 어겼지만 영업자가 이의하지 아니한 채 청문일에 출석하여 의견을 진술하고 변명하는 등 방어 기회를 충분히 가진 경우 하자는 치유되었다고 봄이 상당하다.

대법원 1991. 5. 28. 선고 90누1359 판결

행정행위의 성질이나 법치주의의 관점에서 볼 때 하자있는 행정행위의 치유는 원칙적으로 허용될 수 없을 뿐만 아니라 이를 허용하는 경우에도 국민의 권리와 이익을 침해하지 않는 범위에서 구체적 사정에 따라 합목적적으로 가려야 할 것인 바, 이 사건 처분에 관한 하자가 행정처분의 내용에 관한 것이고 새로운 노선면허가 이 사건 소 제기 이후에 이루어진 사정 등에 비추어 하자의 치유를 인정치 않은 원심의 판단은 정당하고, 거기에 소론이 지적하는 바와 같은 법리오해의 위법이 있다 할 수 없다.

4) 요건(사유)

하자치유의 사유는 종래

- ① 요건의 사후보완,
- ② 장기간의 방치로 인한 법률관계의 확정,
- ③ 공공복리상의 필요 등을 치유사유로 보았으나,
- ②, ③은 행정행위의 취소의 제한사유로 보는 것이 타당하므로,
- ① 요건의 사후보완만을 엄밀한 의미의 하자의 치유 사유로 봄이 타당하다.

5) 한계

(1) 실체적 한계

하자의 치유는 제한적 긍정설의 입장에 따라 제한적으로 인정 되어야 한다고 보는 것이 통설·판례의 입장이다. 판례는 “행정행위의 성질이나 법치주의의 관점에서 볼 때 하자 있는 행정행위의 치유는 원칙적으로 허용될 수 없을 뿐만 아니라 이를 허용하는 경우에도 국민의 권리와 이익을 침해하지 않는 범위에서 구체적 사정에 따라 합목적적으로 가려야 할 것이다.”라고 판시하여 실체적 한계를 언급하고 있다.

대법원 1991. 5. 28. 선고 90누1359 판결

행정행위의 성질이나 법치주의의 관점에서 볼 때 하자있는 행정행위의 치유는 원칙적으로 허용될 수 없을 뿐만 아니라 이를 허용하는 경우에도 국민의 권리와 이익을 침해하지 않는 범위에서 구체적 사정에 따라 합목적적으로 가려야 할 것이다.

대법원 2001. 6. 26. 선고 99두11592판결

선행처분인 개별공시지가결정이 위법하여 그에 기초한 개발부담금 부과처분도 위법하게 된 경우 하자의 치유를 인정하면 개발부담금 납부의무자로서는 **위법한 처분에 대한 가산금 납부의무를 부담하게 되는 등 불이익이 있을 수 있으므로, 그 후 적법한 절차를 거쳐 공시된 개별공시지가결정이 종전의 위법한 공시지가결정과 그 내용이 동일하다는 사정만으로는** 위법한 개별공시지가결정에 기초한 개발부담금 부과처분이 **적법하게 된다고 볼 수 없다.**

(2) 시간적 한계

a. 학설

- ① 국민의 신뢰보호와 예측 가능성을 위해 하자의 치유는 **쟁송제기 이전**까지만 가능하다고 보는 <쟁송제기이전시설>.
- ② 행정심판의 내부통제 기능을 고려하여 **소송제기 이전**까지 가능하다고 보는 <소송제기이전시설>.
- ③ 국민의 권리구제의 침해가 없는 경우에 **쟁송종결이전**까지 허용된다고 보는 <쟁송종결이전시설>이 있다.

b. 판례

판례는 이유제시(부기)가 결여된 과세처분의 하자치유와 관련하여 **늦어도 처분에 대한 불복여부의 결정 및 불복신청에 편의를 줄 수 있는 상당한 기간 내에** 하여야 한다고 하여, **쟁송제기이전시설**을 취하고 있다.

대법원 1983. 7. 26. 선고 82누420 판결

피고의 이 사건 과세처분의 하자가 치유되었다는 주장에 대하여 행정행위의 취소원인인 하자의 보완, 관계 행정청의 추진, 행정처분을 장기간 방치함으로 인한 행정목적의 달성, 또는 법률관계의 확정 등으로 행정처분의 하자가 치유되는 것이 보통이지만 위 세율 과세표준등 산출근거 등을 아울러 고지하도록 규정한 취지가 조세행정의 공정성의 확보와 납세의무자에게 그 부과처분에 대한 불복여부의 결정과 그 불복신청에 편의를 주려는데 있다고 봐야하므로 그럴다면 피고 주장과 같은 위 뒤늦은 납세고지서의 송달이나 오랜기간(4년)의 경과로 위 각 과세처분의 하자가 치유되었다고 보기 어렵다고 판시하였는바 이와 같은 원심조치에 소론 이유불비의 위법이 있다고 할 수 없으므로 상고논지 또한 그 이유없음이 명백하다.

c. 소결

소송 중 치유가 가능하다고 보는 **쟁송종결이전시설**은 행정의 효율성을 일방적으로 강조하여 행정절차가 갖는 사전권리구제의 기능과 공정한 행정의 보장을 본질적으로 훼손시킬 우려가 있다. 따라서 **행정의 효율성과 공정한 행정 및 사전적 권리구제 기능 등을 종합 고려하여 쟁송제기 전까지** 가능하다고 보는 <쟁송제기이전시설>이 타당하다.

6) 효과

하자의 치유는 **소급효**가 있다. 즉, 행정행위의 하자가 치유되면 당해 행정행위는 치유시가 아니라 처음부터 하자가 없는 적법한 행정행위로서 그 효력이 발생한다.

04 하자있는 행정행위의 전환

1) 의의

하자 있는 행정행위의 전환이란 하자가 있는 행정행위가 행정청이 처음에 의도한 행정행위로서는 하자가 있지만 다른 행정행위의 적법요건을 갖춘 경우 **다른 행정행위로서 효력발생**을 인정하는 것을 말한다.

예를들면 사망자에게한 과세처분을 상속자에 인정하는 것을 말한다.

2) 인정근거 및 인정요건

하자 있는 행정행위의 전환은 행정의 법적 안정성을 도모하고 무용한 행정행위의 반복을 피하기 위해 인정된다.

하자있는 행정행위의 전환이 인정되기 위해서는

- ① 전환 전 행정행위와 전환 후의 행정행위가 요건, 목적, 효과 등에서 실질적인 공통성이 있어야 하고,
- ② 전환되는 행정행위는 성립·효력요건을 갖추어야 하며,
- ③ 상대방 및 제3자의 권익을 침해하지 않아야 하고,
- ④ 당사자에게 불이익한 법적 효과를 초래하지 않아야 한다.

3) 전환의 성질 및 효과

행정행위의 전환을 하나의 행정행위로 보는 견해가 통설이다. 따라서 전환 행위는 **처분성이 인정**되어 이해관계인은 전환 행위에 대해 항고소송을 제기할 수 있고, 전환으로 인해 생긴 새로운 행정행위는 종전 행정행위의 발령 당시로 소급하여 효력이 발생한다.

05 하자의 승계 [★★★]

1) 의의 및 취지

행정행위의 하자의 승계란 **둘 이상의 행정행위가 연속적으로 행해지는 경우** 일정한 요건 하에서 **선행행위의 위법이 후행 행정행위에 승계**되어 후행 행정행위를 다룰 수 있게 되는 것을 말한다. 즉, 하자의 승계가 인정되면 위법한 선행행위는 쟁송제기기간의 경과로 불가쟁력이 발생하여 취소할 수 없지만 선행행위가 위법함을 이유로 후행행위를 취소할 수 있게 된다. 하자의 승계는 **법적안정성과 국민의 권리구제**의 조화에 그 취지가 인정된다.

2) 전제조건

(1) 선행행위에 취소사유가 존재할 것

선행행위에는 **취소사유가 존재**하여야 한다. 선행행위가 무효인 경우에 당사자는 선행행위의 무효를 언제나 주장할 수 있고 또한 선행행위의 무효는 당연히 후행 행정행위에 승계되어 후행행위도 무효가 되므로 하자의 승계를 논의할 실익이 없다.

대법원 1999. 4. 27. 선고 97누6780 판결

적법한 건축물에 대한 철거명령은 그 하자가 중대하고 명백하여 당연무효라고 할 것이고, 그 후행행위인 건축물철거 대집행계고처분 역시 당연무효라고 할 것이다.

(2) 선행행위에 불가쟁력이 발생할 것

선행행위에 대한 제소기간이 경과하지 않은 경우에는 선행행위의 위법 여부를 직접 다룰 수 있으므로 하자의 승계가 논의되기 위해서는 **선행행위에 불가쟁력**이 발생하여야 한다.

(3) 선행행위와 후행행위 모두 처분일 것

선행행위와 후행행위 모두 항고소송의 대상이 되는 처분이어야 한다.

(4) 후행행위에는 적법할 것

후행행위에 고유한 위법 사유가 있으면 굳이 하자의 승계를 논의하지 않고 후행행위를 직접 다투면 되므로 하자의 승계가 논의되기 위해서는 후행행위가 적법하여야 한다.

3) 하자승계 인정범위

(1) 학설

① 하자승계론 (전통적 견해)

하자승계론은 행정행위의 하자는 독립적으로 판단되어야 한다는 전제 하에 선행행위와 후행행위가 결합하여 하나의 법률효과의 발생을 목적으로 하는 경우 하자의 승계를 인정하고, 서로 독립하여 별개의 법률효과의 발생을 목적으로 하는 경우에는 하자의 승계를 부정한다.

② 구속력론 (규준력 이론)

선행행위에 형식적 존속력이 발생되면 상대방, 이해관계인 및 행정청에 대한 포괄적인 구속력이 후행행위에 발생하여 행정청은 선행행위의 규율내용과 모순되는 결정을 내려서는 안 되며, 상대방은 후행행위의 불법을 다룰 때에도 선행행위의 내용을 다투어서는 안 된다. 다만, 구속력은 대인적(주관적)·사물적(목적)·시간적(사실 및 법상태) 한계 내에서 인정되고, 이 한계 내에서도 예측 가능하고 수인 가능한 경우에만 구속력이 미친다. 따라서 예측 불가능하거나 수인 불가능 한 경우는 구속력이 배제되어 하자의 승계가 인정될 수 있다.

(2) 판례

① 하자승계론 입장을 취한 판례

대법원 1998. 9. 8. 선고 97누20502 판결

이 사건 건물에 대한 철거명령이 당연무효라고 볼 자료가 없는 이 사건에서, 원고들이 위 철거명령에 대하여 쟁송절차를 거치지 아니하여 이를 다룰 수 없게 된 이상 위 철거명령의 위법사유를 들어 이 사건 계고처분을 다룰 수 없다고 판단한 것은 적법하고, 거기에 선행명령의 계고처분에 대한 영향에 관한 법리오해의 점이 있다고 할 수 없다.

대법원 1992. 12. 11. 선고 92누5584 판결

도시재개발법에 의한 재개발사업의 시행을 위하여 토지 등을 수용하는 경우 도시재개발법 제17조 등에 의한 재개발 사업시행인가는 토지수용법 제14조 소정의 사업인정으로 볼 것인바, 재개발사업시행인가처분 자체의 위법은 사업시행인가단계에서 다투어야 하고 이미 그 쟁송기간이 도과한 수용재결단계에서는 그 인가처분이 당연무효라고 볼 만한 특단의 사정이 없는 한 그 위법을 이유로 토지수용재결처분의 취소를 구할 수는 없다.

② 구속력론 입장을 취한 판례

대법원 2008. 8. 21. 선고 2007두13845 판결

표준지공시지가결정은 이를 기초로 한 수용재결 등과는 별개의 독립된 처분으로서 서로 독립하여 별개의 법률효과를 목적으로 하지만, 표준지공시지가는 이를 인근 토지의 소유자나 기타 이해관계인에게 개별적으로 고지하도록 되어 있는 것이 아니어서 인근 토지의 소유자 등이 표준지공시지가결정 내용을 알고 있었다고 전제하기가 곤란할 뿐만 아니라, 결정된 표준지공시지가가 공시될 당시 보상금 산정의 기준이 되는 표준지의 인근 토지를 함께 공시하는 것이 아니어서 인근 토지 소유자는 보상금 산정의 기준이 되는 표준지가 어느 토지인지를 알 수 없으므로, 인근 토지 소유자가 표준지의 공시지가가 확정되기 전에 이를 다투는 것은 불가능하다.

더욱이 장차 어떠한 수용재결 등 구체적인 불이익이 현실적으로 나타나게 되었을 경우에 비로소 권리구제의 길을 찾는 것이 우리 국민의 권리의식임을 감안하여 볼 때, 인근 토지소유자 등으로 하여금 결정된 표준지공시지가를 기초로 하여 장차 토지보상 등이 이루어질 것에 대비하여 항상 토지의 가격을 주시하고 표준지공시지가결정이 잘못된 경우 정해진 시정절차를 통하여 이를 시정하도록 요구하는 것은 부당하게 높은 주의의무를 지우는 것이고, 위법한 표준지공시지가결정에 대하여 그 정해진 시정절차를 통하여 시정하도록 요구하지 않았다는 이유로 위법한 표준지공시지가를 기초로 한 수용재결 등 후행 행정처분에서 표준지공시지가결정의 위법을 주장할 수 없도록 하는 것은 수인한도를 넘는 불이익을 강요하는 것으로서 국민의 재산권과 재판받을 권리를 보장한 헌법의 이념에도 부합하는 것이 아니다.

따라서 표준지공시지가결정이 위법한 경우에는 그 자체를 행정소송의 대상이 되는 행정처분으로 보아 그 위법 여부를 다퉴 수 있음은 물론, 수용보상금의 증액을 구하는 소송에서도 선행처분으로서 그 수용대상 토지 가격 산정의 기초가 된 비교표준지공시지가결정의 위법을 독립한 사유로 주장할 수 있다.

대법원 1994. 1. 25. 선고 93누8542 판결

개별공시지가결정은 이를 기초로 한 과세처분 등과는 별개의 독립된 처분으로서 서로 독립하여 별개의 법률효과를 목적으로 하는 것이나, 개별공시지가는 이를 토지소유자나 이해관계인에게 개별적으로 고지하도록 되어 있는 것이 아니어서 토지소유자 등이 개별공시지가결정 내용을 알고 있었다고 전제하기도 곤란할 뿐만 아니라 결정된 개별공시지가가 자신에게 유리하게 작용될 것인지 또는 불이익하게 작용될 것인지 여부를 쉽사리 예견할 수 있는 것도 아니며, 더욱이 장차 어떠한 과세처분 등 구체적인 불이익이 현실적으로 나타나게 되었을 경우에 비로소 권리구제의 길을 찾는 것이 우리 국민의 권리의식임을 감안하여 볼 때 토지소유자 등으로 하여금 결정된 개별공시지가를 기초로 하여 장차 과세처분 등이 이루어질 것에 대비하여 항상 토지의 가격을 주시하고 개별공시지가결정이 잘못된 경우 정해진 시정절차를 통하여 이를 시정하도록 요구하는 것은 부당하게 높은 주의의무를 지우는 것이라고 아니할 수 없고, 위법한 개별공시지가결정에 대하여 그 정해진 시정절차를 통하여 시정하도록 요구하지 아니하였다는 이유로 위법한 개별공시지가를 기초로 한 과세처분 등 후행 행정처분에서 개별공시지가결정의 위법을 주장할 수 없도록 하는 것은 수인한도를 넘는 불이익을 강요하는 것으로서 국민의 재산권과 재판받을 권리를 보장한 헌법의 이념에도 부합하는 것이 아니라고 할 것이므로, 개별공시지가결정에 위법이 있는 경우에는 그 자체를 행정소송의 대상이 되는 행정처분으로 보아 그 위법 여부를 다퉴 수 있음은 물론 이를 기초로 한 과세처분 등 행정처분의 취소를 구하는 행정소송에서도 선행처분인 개별공시지가결정의 위법을 독립된 위법사유로 주장할 수 있다고 해석함이 타당하다.

(3) 소결

하자승계론은 일정한 기준을 제시하여 객관적이고, 구속력론은 예측 가능성과 수인 가능성을 고려한다는 점에서 구체적 타당성을 기할 수 있으므로 양자 모두 합리성이 인정 된다. 따라서 동일한 법률효과를 목적으로 하는 경우를 기준으로 별개의 법률효과를 목적으로 하는 경우에도 예측 불가능하거나 수인 불가능 한 사정 등을 종합 고려하여 하자 승계를 인정하는 것이 타당하다.

※ 개별공시지가와 양도소득세 부과처분에서 하자승계를 부정한 판례 (비교)

개별공시지가 결정에 대하여 재조사청구를 하자, 소외 부산광역시 사하구청장은 이를 감액조정하여 1993. 9. 18. 원고에게 통지하고 같은 달 23. 공고하였으며, 원고는 이에 대하여 더 이상 불복하지 아니한 사실, 원고는 위 재조사청구에 따른 조정결정이 있기 전인 같은 해 8. 19. 부산광역시 사하구에 이 사건 토지를 협의매도한 후 1994. 5. 31. 피고에게 양도가액을 위 조정된 개별공시지가로 하여 산출한 양도소득세를 확정신고한 사실을 인정한 다음, 이와 같이 원고가 이 사건 토지를 매도한 이후에 그 양도소득세 산정의 기초가 되는 1993년도 개별공시지가 결정에 대하여 한 재조사청구에 따른 조정결정을 통지받고서도 더 이상 다투지 아니한 경우까지 선행처분인 개별공시지가 결정의 불가쟁력이나 구속력이 수인한도를 넘는 가혹한 것이거나 예측불가능하다고 볼 수 없어, 위 개별공시지가 결정의 위법을 이 사건 과세처분의 위법사유로 주장할 수 없다고 판단하고 있다. 기록과 위에서 본 법리에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 지적하는 바와 같은 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 이 점에 관한 상고이유는 받아들일 수 없다. [대법원 1998. 3. 13. 선고 96누6059 판결]

01 행정행위의 직권취소

1) 의의

행정행위의 취소란 위법 또는 부당한 하자를 이유로 행정행위를 발령한 처분청 등 권한 있는 기관이 행정행위의 효력을 소멸시키는 행위를 말한다. 취소는 처음부터 아무런 효력이 없는 무효나 성립 이후의 하자를 이유로 하는 철회와 구별된다.

2) 직권취소의 법적근거

행정행위를 행한 처분청이 그 행정행위를 취소할 수 있는 권한을 가진다고 보는 것이 통설·판례의 태도이다. 현재는 행정기본법이 규정되어 행정기본법 제18조를 통해 행정행위의 직권취소를 명확하게 명문화하고 있으며, 기타 개별법률에서도 직권취소에 대해 규정을 두고 있는 경우가 적지 않다.

[행정기본법] 제18조 (위법 또는 부당한 처분의 취소)

- ① 행정청은 위법 또는 부당한 처분의 전부나 일부를 소급하여 취소할 수 있다. 다만, 당사자의 신뢰를 보호할 가치가 있는 등 정당한 사유가 있는 경우에는 장래를 향하여 취소할 수 있다.
- ② 행정청은 제1항에 따라 당사자에게 권리나 이익을 부여하는 처분을 취소하려는 경우에는 취소로 인하여 당사자가 입게 될 불이익을 취소로 달성되는 공익과 비교·형량(衡量)하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
 1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 처분을 받은 경우
 2. 당사자가 처분의 위법성을 알고 있었거나 중대한 과실로 알지 못한 경우

대법원 1995. 9. 15. 선고 95누6311 판결

개별토지에 대한 가격결정도 행정처분에 해당하며, 원래 행정처분을 한 처분청은 그 행위에 하자가 있는 경우에는 원칙적으로 별도의 법적 근거가 없더라도 스스로 이를 직권으로 취소할 수 있다.

3) 직권취소의 제한

(1) 침익적 행정행위의 경우

침익적 행정행위의 직권취소는 상대방에게 이익을 주므로 침익적 행정행위의 취소권 행사는 원칙적으로 자유롭다.

(2) 수익적 행정행위의 경우

수익적 행정행위의 직권취소는 상대방에게 침익적 행위가 되므로 수익적 행정행위의 취소권 행사는 제한을 받는다. 특히, 비례의 원칙이나 신뢰보호의 원칙에 위배 되어서는 안되고, 취소권 행사에 재량권 일탈·남용이 있으면 위법한 처분이 된다.

4) 직권취소의 위법성 판단

(1) 비례의 원칙 (「행정기본법」 제10조)

직권취소로 달성되는 공익보다 상대방이 입게 되는 불이익이 더 큰 경우 취소권은 제한된다. 따라서 이익형량의 결과 상대방이 입는 불이익이 달성되는 공익보다 더 크다면 해당 직권취소는 위법한 처분이 된다.

(2) 신뢰보호의 원칙 (「행정기본법」 제12조 제1항)

행정행위의 상대방이 해당 행정행위가 계속될 것을 신뢰하고 그 신뢰에 기초해 일정한 행위를 하였고 그로 인해 어떠한 이익이 형성되었다면 처분청이 그 행정행위를 취소하는 것은 신뢰보호의 원칙에 위배되어 위법하게 된다.

(3) 실권의 법리 (「행정기본법」 제12조 제2항)

행정기관에 취소권이 인정된 경우라도 장기간 그 권한을 행사하지 않아 상대방이 더 이상 취소권을 행사하지 않을 것이라고 신뢰할 만한 정당한 사유가 있는 경우에는 취소권이 제한된다.

대법원 2004. 11. 26. 선고 2003두10251,10268 판결

수익적 행정처분을 취소 또는 철회하는 경우에는 이미 부여된 그 국민의 기득권을 침해하는 것이 되므로, 비록 취소 등의 사유가 있다고 하더라도 그 취소권 등의 행사는 기득권의 침해를 정당화할 만한 중대한 공익상의 필요 또는 제3자의 이익보호의 필요가 있는 때에 한하여 상대방이 받는 불이익과 비교·교량하여 결정하여야 하고, 그 처분으로 인하여 공익상의 필요보다 상대방이 받게 되는 불이익 등이 막대한 경우에는 재량권의 한계를 일탈한 것으로서 그 자체가 위법하다.

5) 직권취소의 효과

행정청은 위법 또는 부당한 처분을 소급하여 취소하거나 정당한 사유가 있는 경우에 장래를 향하여 취소할 수 있다고 행정기본법 제18조 제1항에서 규정하고 있다. 일반적으로 침익적 행정행위의 취소의 효력은 소급적이라고 보고, 수익적 행정행위의 취소의 효력은 상대방에게 귀책 사유가 없는 한 소급하지 않는다고 본다.

다만, 상대방에게 귀책 사유가 없는 경우에도 소급효를 인정하지 않는 것이 심히 공익에 반하는 경우에는 소급효를 인정하기도 하며, 복효적 행정행위는 상대방과 제3자의 이익을 비교형량하여 취소의 소급 또는 불소급을 개별적으로 결정한다.

6) 직권취소의 재취소

(1) 문제점

직권취소도 하나의 행정행위로서 그 직권취소에 하자가 있는 경우 해당 취소처분을 다투어 취소시킴으로써 원처분(원행정행위)의 효력을 회복시킬 수 있는지가 문제 된다.

(2) 학설

취소처분은 그 자체가 행정행위이므로 취소처분의 취소도 가능하며 취소처분이 취소되면 원행정행위가 원상회복된다고 보는 <긍정설>, 행정행위가 취소되면 당해 행정행위의 효력은 확정적으로 상실되므로 취소의 취소는 인정될 수 없다고 보는 <부정설> 및 행정행위의 성질, 상대방의 신뢰보호 및 새로운 이해관계인의 유무 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다고 보는 <절충설>이 있다.

(3) 판례

판례는 수익적 행정행위의 취소의 취소는 긍정하나, 침익적 행정행위의 취소의 취소는 부정한다. 또한 수익적 행정행위의 경우에도 수익적 행정행위가 취소된 후 새롭게 제3자의 권익이 형성되어 재취소시 그 이익이 침해되는 경우에는 취소의 취소가 허용되지 않는다고 판시한 바 있다.

대법원 1979. 5. 8. 선고 77누61 판결

행정행위를 일단 취소한 후에 그 취소처분 자체의 위법을 이유로 다시 그 취소처분을 취소함으로써 시초의 행정행위의 효력을 회복시킬 수 있는 것인가의 문제는 두가지 경우로 나누어 생각해 볼 수 있다. 하나는 취소처분의 위법이 중대하고 명백하므로 인하여 그 취소처분이 절대로 무효일 경우인데 이 경우에 있어서는 그 취소처분에 대한 무효선언으로서의 취소가 가능할 것이다. 다른 하나는 그 취소처분이 절대로 무효가 되는 경우가 아닌 단순위법인 경우인데 이 경우에도 취소처분에 대하여 법률이 명문으로 소원 또는 행정소송의 제기를 허용하고 있는 때에는 그 절차에 따라 해결하면 될 것이고 법률에 그와 같은 취소처분의 취소에 관한 명문의 규정이 없는 때에는, 취소처분은 비록 위법할지라도 일단 유효하게 성립하고, 따라서 행정행위의 효력을 확정적으로 상실시키는 것이므로, 취소처분의 취소에 의하여 이미 효력을 상실한 행정행위를 소생시킬 수는 없으며, 소생시키기 위하여는 원 행정행위와 동일한 내용의 새로운 행정행위를 행할 수 밖에 없는 것으로 풀이하는 것이 타당할 것이다.

(4) 소결

직권취소는 독립된 행정처분이므로 취소처분에 하자가 있다면 그 하자의 시정을 위해 직권취소의 취소를 인정하여야 한다. 다만, 직권취소 후 새로운 이해관계 등이 있는 경우 취소권 제한 법리인 이익형량으로 해결하는 것이 타당하다.

02 행정행위의 철회

1) 의의

행정행위의 철회란 적법하게 성립한 행정행위에 대해 그 효력을 존속시킬 수 없는 새로운 사정이 발생하였음을 이유로 장래에 향하여 그의 효력을 소멸시키는 행위를 말한다.

[취소와 철회의 비교]

	취소	철회
원 인	원시적 하자 (성립당시의 하자)	사후적 하자 (성립 이후의 하자)
효 과	소급효 (또는 장래효)	장래효
권한자	처분청 (또는 감독청)	처분청

2) 철회의 법적근거

행정기본법이 제정되기 전에는 철회의 법적근거가 필요한가에 대해 근거필요설, 근거불요설, 절충설이 대립하였는데, 현재는 행정기본법 제19조에서 철회의 근거를 명문화하고 있다.

[행정기본법] 제19조 (적법한 처분의 철회)

- ① 행정청은 적법한 처분이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 처분의 전부 또는 일부를 장래를 향하여 철회할 수 있다.
 1. 법률에서 정한 철회 사유에 해당하게 된 경우
 2. 법령등의 변경이나 사정변경으로 처분을 더 이상 존속시킬 필요가 없게 된 경우
 3. 중대한 공익을 위하여 필요한 경우
- ② 행정청은 제1항에 따라 처분을 철회하려는 경우에는 철회로 인하여 당사자가 입게 될 불이익을 철회로 달성되는 공익과 비교·형량하여야 한다.

대법원 1995. 6. 9. 선고 95누1194 판결

행정행위를 한 처분청은 비록 그 처분 당시에 별다른 하자가 없었고, 또 그 처분 후에 이를 취소할 별도의 법적 근거가 없다 하더라도 원래의 처분을 존속시킬 필요가 없게 된 사정변경이 생겼거나 또는 중대한 공익상의 필요가 발생한 경우에는 그 효력을 상실케 하는 별개의 행정행위로 이를 취소할 수 있다.

3) 철회의 사유

행정기본법 제19조 제1항에서 철회의 사유를 명문화 하고 있다. 규정을 살펴보면

- ① 법률에서 정한 철회 사유에 해당하게 된 경우,
- ② 법령등의 변경이나 사정변경으로 처분을 더 이상 존속시킬 필요가 없게 된 경우,
- ③ 중대한 공익을 위하여 필요한 경우가 있다.

4) 철회의 제한

(1) 침익적 행정행위의 철회

침익적 행정행위의 철회는 상대방에게 이익을 가져다주므로 별다른 제한을 받지 않고 자유롭게 할 수 있음이 원칙이다.

(2) 수익적 행정행위의 철회

수익적 행정행위의 철회는 상대방의 신뢰와 법적 안정성을 해할 우려가 있으므로 철회사유가 발생한 경우에도 철회를 하여야 하는 공익상의 필요, 상대방의 신뢰, 기득권 보호, 법적 안정성의 유지 등 관련된 모든 이익을 비교·형량하여 철회 여부를 결정하여야 한다. 따라서 직권취소와 마찬가지로 비례의 원칙이나 신뢰보호의 원칙 등을 위배하여 행한 철회는 위법한 처분이 된다.

대법원 1990. 2. 23. 선고 89누7061 판결

행정청이 일단 행정처분을 한 경우에는 행정처분을 한 행정청이라도 법령에 규정이 있는 때, 행정처분에 하자가 있는 때, 행정처분의 존속이 공익에 위반되는 때, 또는 상대방의 동의가 있는 때 등의 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 행정처분을 자의로 취소(철회의 의미를 포함한다) 할 수 없다.

대법원 2017. 3. 15. 선고 2014두41190 판결

행정행위를 한 처분청은 비록 처분 당시에 별다른 하자가 없었고, 처분 후에 이를 철회할 별도의 법적 근거가 없더라도 원래의 처분을 존속시킬 필요가 없게 된 사정변경이 생겼거나 중대한 공익상 필요가 발생한 경우에는 그 효력을 상실케 하는 별개의 행정행위로 이를 철회할 수 있다. 다만 수익적 행정행위를 취소 또는 철회하거나 중지시키는 경우에는 이미 부여된 국민의 기득권을 침해하는 것이 되므로, 비록 취소 등의 사유가 있다고 하더라도 그 취소권 등의 행사는 기득권의 침해를 정당화할 만한 중대한 공익상의 필요 또는 제3자의 이익을 보호할 필요가 있고, 이를 상대방이 받는 불이익과 비교·교량하여 볼 때 공익상의 필요 등이 상대방이 입을 불이익을 정당화할 만큼 강한 경우에 한하여 허용될 수 있다.

5) 철회의 효과

행정기본법 제19조 제1항에서 '행정청은 적법한 처분이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 처분의 전부 또는 일부를 장래를 향하여 철회할 수 있다'고 규정하고 있다. 따라서 철회의 효과는 **언제나 장래를 향한다** (장래효).

03 행정행위의 실효

행정행위의 실효란 하자 없이 **적법하게 성립한 행정행위**가 일정한 사실의 발생에 의하여 **장래를 향하여 그 효력이 소멸되는 것**을 말한다. 취소와 철회는 행정청의 의사표시가 필요하나, 실효는 행정청의 의사표시와 무관하게 당연히 효력이 소멸한다는 점에서 차이가 있다. 실효사유가 발생하면, 그 행정행위는 **행정청의 특별한 의사표시 없이** 장래를 향해 당연히 소멸 된다.

※ 「토지보상법」 제23조의 사업인정의 실효 : 사업인정의 고시가 된 날부터 1년 이내 재결신청 하지 않는 경우 사업인정고시가 된 날부터 1년이 되는 다음 날에 사업인정은 그 효력을 상실한다.

01 의의 및 구별개념

부관은 주된 행정행위의 **효과를 제한**하거나 **의무를 부과**하기 위해 부가된 **종된 규율**을 말한다. 주된 행정행위에 부가되는 부관은 종속적인 지위를 가지고 주된 행정행위에 의존하는 **부종성**을 가지므로 명문의 규정이나 약정이 없는 한 주된 행정행위가 효력을 상실하면 부관도 효력을 상실한다. 행정행위의 부관은 법령이 직접 행정행위의 조건, 기한 등을 정하는 법정부관과 구별된다. 법정부관은 법령의 규정에 의한 것으로 행정행위의 부관에 적용되는 부관의 한계 등이 적용되지 않아 양자를 구별함이 필요하다.

02 법적근거

행정기본법 제17조가 행정행위의 부관에 대한 일반법적 근거가 되며 부관의 요건 및 한계를 명문화하고 있다.

[행정기본법] 제17조 (부관)

- ① 행정청은 처분에 재량이 있는 경우에는 부관(조건, 기한, 부담, 철회권의 유보 등을 말한다. 이하 이 조에서 같다)을 붙일 수 있다.
- ② 행정청은 처분에 재량이 없는 경우에는 법률에 근거가 있는 경우에 부관을 붙일 수 있다.
- ③ 행정청은 부관을 붙일 수 있는 처분이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 처분을 한 후에도 부관을 새로 붙이거나 종전의 부관을 변경할 수 있다.
 1. 법률에 근거가 있는 경우
 2. 당사자의 동의가 있는 경우
 3. 사정이 변경되어 부관을 새로 붙이거나 종전의 부관을 변경하지 아니하면 해당 처분의 목적을 달성할 수 없다고 인정되는 경우
- ④ 부관은 다음 각 호의 요건에 적합하여야 한다.
 1. 해당 처분의 목적에 위배되지 아니할 것
 2. 해당 처분과 실질적인 관련이 있을 것
 3. 해당 처분의 목적을 달성하기 위하여 필요한 최소한의 범위일 것

03 부관의 종류

1) 종류

(1) 조건

조건이란 행정행위의 효력의 발생·소멸을 **장래에 발생 여부가 불확실한 사실**에 의존시키는 부관을 말한다.

조건에는 ① 조건이 성취되어야 효력이 발생하는 **정지조건**과 ② 조건이 성취되면 효력이 소멸하는 **해제조건**이 있다.

(2) 기한

기한이란 행정행위의 효력 발생·소멸을 장래 도래할 것이 확실한 사실에 의존시키는 부관을 말한다.

기한은 시점이 특정되어야 한다는 점에서 조건과 차이가 있다.

(3) 부담

부담이란 행정행위의 주된 내용에 부가하여 상대방에게 작위·부작위·급부·수인 등의 의무를 부과하는 부관을 말한다. 부담은 주로 허가·특허 등과 같은 수익적 행정행위에 부가된다. 부담은 다른 부관과 달리 그 자체를 하나의 행정행위로 보는 것이 일반적 견해이다. 따라서 부담만이 독립하여 강제 및 쟁송의 대상이 된다.

(4) 철회권 유보

철회권 유보란 일정한 경우에 행정행위를 철회하여 행정행위의 효력을 소멸시킬 수 있음을 정한 부관을 말한다.

2) 부담과 조건의 구별

(1) 구별실익

부담은 다른 부관과 달리 그 자체를 하나의 행정행위로 보아 독립하여 강제집행의 대상이 되고, 행정쟁송의 대상이 될 수 있으나 조건은 그러하지 않아 구별에 실익이 있다. 실무적으로 부담을 조건이라고 부르기도 하므로 일정한 기준으로 양자를 구별함이 필요하다.

(2) 구별기준

부담과 조건의 구별은 표현된 용어보다

① 행정청의 객관적인 의사를 고려하여 판단하여야 한다.

즉, 행정청이 행정행위의 효력 자체를 그 조건에 의존시키려는 의사였을 경우에는

조건으로 보고 그렇지 않은 경우에는 부담으로 볼 수 있다. 또한 행정청의 의사가 불분명한 경우에는

② 최소침해의 원칙에 따라 상대방에게 유리하게 부담으로 추정하여야 한다.

04 부관의 가능성

종래에는 행정청의 의사표시를 요건으로 하는 법률행위적 행정행위에만 부관을 부착할 수 있고 준법률행위적 행정행위에는 부관의 부착이 불가능하다고 보는 견해와 법률행위적 행정행위의 경우에도 기속행위의 경우에는 법령에 근거가 없는 한 부관을 부착할 수 없다고 보는 견해가 있었다. 그러나 최근에는 준법률행위적 행정행위나 기속행위의 경우에도 일정한 경우 부관이 부착 가능한 경우가 있고, 재량행위도 부관의 부착이 불가능한 경우가 있으므로 개별적으로 검토하여야 한다고 보는 것이 일반적인 견해이다. 또한 행정기본법이 제정되었으므로 행정기본법 제17조 제1항 및 제2항에 규정된 바에 따라 재량행위와 기속행위에 부관이 부착될 수 있으며 특히, 기속행위의 경우 법률에 근거가 있는 경우에만 가능하며 판례도 동일한 입장이다.

[행정기본법] 제17조 (부관)

① 행정청은 처분에 재량이 있는 경우에는 부관(조건, 기한, 부담, 철회권의 유보 등을 말한다. 이하 이 조에서 같다)을 붙일 수 있다.

② 행정청은 처분에 재량이 없는 경우에는 법률에 근거가 있는 경우에 부관을 붙일 수 있다.

대법원 1988. 4. 27. 선고 87누1106 판결

일반적으로 기속행위나 기속적 재량행위에는 부관을 붙일 수 없는 것이고, 위 이사회소집승인 행위가 기속행위 내지 기속적 재량행위에 해당함은 위에서 실시한 바에비추어 분명하므로, 여기에는 부관을 붙이지 못한다 할 것이며, 기사 부관을 붙였다 하더라도 이는 무효의 것으로서 당초부터 부관이 붙지 아니한 소집승인 행위가 있었던 것으로 보아야 할 것이다.

※ 준법률행위적 행정행위의 부관의 예시 : 여권의 유효기간

※ 기속행위의 부관의 예시 : 요건충족적 부관 (허가시 필요한 서류 중 일부 불비시 일부 제출을 조건으로 하는 허가)

※ 재량행위의 부관 불가의 예시 : 귀하 허가를 하면서 국내법 위반시 귀하허가를 취소한다는 조건 부칙 불가

05 부관의 한계

1) 시간적 한계 (사후부관 가능성)

(1) 의의

행정행위를 발령한 후에 부관을 새로이 부칙하거나 변경할 수 있는가가 부관의 시간적 한계로서 문제가 된다. 즉, 행정행위의 발령 이후에 부칙하는 부관을 사후부관이라고 한다.

(2) 요건

행정기본법이 제정되기 전에는 제한적 긍정설(명문 규정, 당사자 동의, 유보시 가능), 부담긍정설(부담만 가능) 및 부정설(부관의 부종성으로 불가)이 대립하였으나 행정기본법이 제정되면서 사후부관이 가능한 경우가 명문화 되었다. 행정기본법 제17조 제3항에서는

- ① 법률에 근거가 있는 경우,
- ② 당사자의 동의가 있는 경우,
- ③ 사정이 변경되어 부관을 새로 붙이거나 종전의 부관을 변경하지 아니하면

해당 처분의 목적을 달성할 수 없다고 인정되는 경우에 사후부관이 가능하다고 규정하고 있다.

2) 내용상 한계

(1) 적법성

부관은 행정행위에 부가되는 종된 규율로서 행정행위의 한 구성부분이 된다. 따라서 행정행위와 마찬가지로 행정행위로서 법령에 위반되어서는 안 되고 헌법에 보장된 기본권을 침해하여서는 안 된다.

대법원 2003. 5. 30. 선고 2003다9339 판결

주택건설촉진법에 따른 주택건설사업계획승인을 함에 있어, 법률상 지방자치단체가 부담하도록 되어 있는 상수도시설 설치비용을 사업자에게 전가시키는 내용의 부관을 부기한 경우, 그 부관은 위법하나 당연무효사유는 아니다.

(2) 목적상 요건

부관은 주된 행정행위의 목적상 필요한 범위를 넘어서는 안 된다. 즉, 주된 행정행위의 목적에 반하는 부관은 부칙할 수 없으며 이는 행정기본법 제17조 제4항 제1호에서 명문화하고 있다.

(3) 실질적 관련성

부관은 주된 행정행위와 실질적 관련성이 있어야 한다. 실질적 관련성이란 원인적 관련성과 목적적 관련성으로 구분할 수 있는데, 원인적 관련성은 행정작용의 발령에 반대급부의 부과가 필요한 것을 말하고 목적적 관련성은 주된 행정작용과 반대급부가 동일한 행정목적에 기여하여야함을 말한다. 실질적 관련성의 유무는 부당결부금지의 원칙으로 판단할 수 있다.

[행정기본법] 제17조 (부관)

④ 부관은 다음 각 호의 요건에 적합하여야 한다.

1. 해당 처분의 목적에 위배되지 아니할 것
2. 해당 처분과 실질적인 관련이 있을 것
3. 해당 처분의 목적을 달성하기 위하여 필요한 최소한의 범위일 것

대법원 1997. 3. 11. 선고 96다49650 판결

수익적 행정행위에 있어서는 법령에 특별한 근거규정이 없다고 하더라도 그 부관으로서 부담을 붙일 수 있으나, 그러한 부담은 비례의 원칙, 부당결부금지의 원칙에 위반되지 않아야만 적법하다고 할 것이다. 기록에 의하면, 원고의 이 사건 토지 중 2,791㎡는 자동차전용도로로 도시계획시설결정이 된 광1류6호선에 편입된 토지이므로, 그 위에 도로 개설을 하기 위하여는 소유자인 원고에게 보상금을 지급하고 소유권을 취득하여야 할 것임에도 불구하고, 소외 인천시장은 원고에게 주택사업계획승인을 하게 됨을 기회로 그 주택사업과는 아무런 관련이 없는 토지인 위 2,791㎡를 기부채납하도록 하는 부관을 위 주택사업계획승인에 붙인 사실이 인정되므로, 위 부관은 부당결부금지의 원칙에 위반되어 위법하다고 할 것이다.

(4) 이행가능성 및 행정법 일반원칙

부관은 이행 가능하여야 하며 비례원칙, 평등의 원칙 및 부당결부금지원칙 등 행정법의 일반원칙에 적합하여야 한다.

대법원 1997. 3. 14. 선고 96누16698 판결

주택건설촉진법 제33조에 의한 주택건설사업계획의 승인은 상대방에게 권리나 이익을 부여하는 효과를 수반하는 이른바 수익적 행정처분으로서 법령에 행정처분의 요건에 관하여 일의적으로 규정되어 있지 아니한 이상 행정청의 재량행위에 속한다 할 것, 그 부관의 내용은 적법하고 이행가능하여야 하며 비례의 원칙 및 평등의 원칙에 적합하고 행정처분의 본질적 효력을 해하지 아니하는 한도의 것이어야 한다.

06 위법한 부관

1) 위법한 부관과 행정행위의 효력

(1) 학설

위법한 부관이 부착된 행정행위의 효력에 대하여

- ① 부관만 무효가 되고, 행정행위에는 아무런 영향을 미칠 수 없다는 견해,
- ② 부관부 행정행위 전부가 무효가 된다는 견해 및
- ③ 원칙적으로 부관이 없는 단순한 행정행위가 되나 예외적으로 부관이 없었다면

주된 행정행위를 하지 않았을 것이라고 인정되는 경우에는 전체 행정행위가 무효가 된다는 견해가 있다.

(2) 판례

판례는 기부채납 받은 행정재산에 대한 사용·수익허가에서 허가기간은 행정행위의 **본질적 요소**에 해당하므로 허가기간에 위법사유가 있다면 이로써 허가 **전부가** 위법하게 된다고 본다.

대법원 2001. 6. 15. 선고 99두509 판결

기부채납받은 공원시설의 사용·수익허가에서 그 허가기간은 행정행위의 본질적 요소에 해당한다고 볼 것이어서 부관인 허가기간에 위법사유가 있다면 이로써 이 사건 허가 전부가 위법하게 된다.

(3) 검토

행정청은 수익적 행정행위를 발령할 때 부관을 부차하여 주된 행정행위를 제한하거나 의무를 부과하려는 목적이 있으므로 위법한 부관만을 무효로 보고 부관이 없는 단순한 행정행위로 보는 것은 행정청의 의사에 반하여 타당하지 않다. 따라서 부관과 주된 행정행위의 성질과 관계를 종합 고려하여 판단하는 ③설 타당하다.

2) 위법한 부관의 행정쟁송

(1) 부관의 독립쟁송 가능성 (소송요건)

a. 문제점

위법한 부관이 부차된 행정행위의 상대방은 침익적인 부관이 부차되지 않은 행정행위의 발령만을 원할 것이다. 이에 그 상대방이 위법한 부관에 대해 소송을 제기하여 권리구제를 받을 수 있는지가 문제 되며, 이는 소송요건의 문제로서 주된 행정행위와 분리하여 부관만을 소송대상으로 삼을 수 있는지와 이때, **소송형태**는 무엇인지가 문제 된다.

b. 학설

- ① ‘처분의 일부취소’가 가능한 만큼 소의 이익이 있다면 **모든 위법한 부관에 대해 독립하여 행정쟁송**을 제기할 수 있다고 보는 <모든부관가능성설>.
- ② 독립쟁송가능의 문제는 부관의 독립 취소가능성 문제의 전제조건이므로 독립취소가 인정될 수 있을 정도의 독자성(주된 행정행위와의 분리가능성)이 있다면 부관만 독립하여 행정쟁송으로 다룰 수 있다고 보는 <분리가능성설> 및
- ③ 부담은 그 자체가 독립된 행정행위이므로 **부담만이 독립적으로 행정쟁송 제기가 가능**하고 이외의 부관은 부관부행정행위 전체를 소의 대상으로 삼아야 한다고 보는 <부담·기타부관 구별설>이 있다.

※ 분리가능성 판단기준

- ① 부관이 없더라도 주된 행정행위가 적법하게 존속 할 수 있을 것.
- ② 부관이 없더라도 주된 행정행위가 달성하려는 공익에 장애가 발생하지 않을 것.

c. 판례

대법원은 일관되게 **부담만이 항고소송의 대상**이 될 수 있다고 보며, 기타 부관은 독립하여 항고소송의 대상이 될 수 없다는 입장이다. 또한 부담을 제외한 기타 부관만의 취소를 구하는 소송에 대하여는 각하판결을 하여야 한다고 본다.

대법원 1992. 1. 21. 선고 91누1264 판결

행정행위의 부관은 행정행위의 일반적인 효력이나 효과를 제한하기 위하여 의사표시의 주된 내용에 부가되는 종된 의사표시이지 그 자체로서 직접 법적 효과를 발생하는 독립된 처분이 아니므로 현행 행정쟁송제도 아래서는 부관 그 자체만을 독립된 쟁송의 대상으로 할 수 없는 것이 원칙이나 행정행위의 부관 중에서도 행정행위에 부수하여 그 행정행위의 상대방에게 일정한 의무를 부과하는 행정청의 의사표시인 부담의 경우에는 다른 부관과는 달리 행정행위의 불가분적인 요소가 아니고 그 존속이 본체인 행정행위의 존재를 전제로 하는 것일 뿐이므로 부담 그 자체로서 행정쟁송의 대상이 될 수 있다.

대법원 1986. 8. 19. 선고 86누202 판결

어업면허처분을 함에 있어 그 면허의 유효기간을 1년으로 정한 경우, 위 면허의 유효기간은 행정청이 위 어업면허처분의 효력을 제한하기 위한 행정행위의 부관이라 할 것이고 이러한 행정행위의 부관은 독립하여 행정소송의 대상이 될 수 없는 것이므로 위 어업면허처분 중 그 면허유효기간만의 취소를 구하는 청구는 허용될 수 없다.

d. 소결

〈모든부관가능성설〉은 부담 이외의 기타 부관은 처분성이 인정되지 않는다는 점을 간과한다는 문제가 있고, 〈분리가능성설〉은 분리가능성이라는 본안문제를 소송요건 단계에서 고려한다는 문제가 있다. 생각건대, 부관의 독립쟁송가능성은 부관의 독립취소가능성의 전제조건으로 파악하여 처분성이 인정되는 **부담만이 독립쟁송가능**하다고 보는 〈부담·기타부관 구별설〉이 타당하다.

(2) 쟁송의 형태

구분	소의 대상			쟁송형태	
모든부관가능성설	모든 부관			부담	진정일부취소소송
				기타 부관	부진정일부취소소송
분리가능성설	분리가능성 ×	전체 행정행위		전체 취소소송	
	분리가능성 ○	처분성 ○	부담	진정일부취소소송	
		처분성 ×	기타부관	부진정일부취소소송	
부담·기타 부관 구별설	부담	부담		진정일부취소소송	
	기타 부관	전체 행정행위		전체 취소소송	

판례는 부진정일부취소소송을 인정하지 않으므로, **부담만이 독립쟁송가능**하며 **진정일부취소소송**으로 다룰 수 있다고 본다. 또한 **기타 부관**은 부관부 행정행위 **전체**의 취소를 구하거나 행정청에 부관이 없는 처분으로 변경을 청구한 후 그것이 거부된 경우 비로소 **거부처분취소소송**을 제기하여야 한다는 입장이다.

수산업법 제15조에는 행정관청은 어업조정 기타 공익상 필요하다고 인정할 때에는 어업의 면허 또는 허가를 할 때에 제한 또는 조건을 부할 수 있다고 규정하고 있으나 이러한 부관은 그 성질상 허가된 어업의 본질적 효력을 해하지 않는 한도의 것이어야 하고, 허가된 어업의 내용 또는 효력 등에 대하여는 행정청이 임의로 제한 또는 조건을 붙일수는 없다고 보아야 할 것이다. 그런데 수산업법시행령 제14조의4 제3항에는 제14조의3 제5호에 정한 기선망어업(근해선망어업)의 허가를 받고자 하는 자는 어선의 부속선으로 운반선, 등선을 갖추어야 한다. 이 경우에 등선은 1톤당 3척이내이어야 한다고 규정되어 있고, 이는 수산업법 제11조, 같은시행령 제14조의3 제5호에 정한 '근해구역을 주요업구역으로 하는 기선선망어업(근해선망어업)'이기만 하면 그 어선규모의 대소를 가리지 않고 등선과 운반선을 갖추어야 하는 것이라고 해석되므로 (당원 1989.5.23. 선고 87누769 판결 참조) 피고가 원고에 대하여 이 사건 기선선망어업의 허가를 하면서 운반선, 등선 등 부속선을 사용할 수 없도록 제한한 부관은 그것이 비록 위법 제15조의 규정에 터잡은 것이라 하더라도 위 어업허가의 목적달성을 사실상 어렵게 하여 그 본질적 효력을 해하는 것일 뿐만 아니라 위시행령 제14조의 4 제3항의 규정에도 어긋나는 것이며, 더욱 뒤에 보는 바와 같이 어업조정이나 기타 공익상 필요하다고 인정되는 사정이 없는 이 사건에서는 위법한 것이라고 할 것 이고, 나아가 이 부관을 삭제하여 등선과 운반선을 사용할 수 있도록 하여 달라는 내용의 원고의 이 사건 어업허가사항변경신청을 불허기한 피고의 처분 역시 위법하다고 보아야 할 것이다.

(3) 부관의 독립취소가능성 (본안 문제)

a. 문제점

원고가 부관만의 취소를 구하는 경우에 법원이 그 부관이 위법하다고 판단하여 **부관만을 독립하여 취소할 수 있는지** 아니면 부관부 행정행위 전체를 취소해야 하는지가 문제 된다.

b. 학설

- ① **기속행위**는 법령의 근거 없이 행정청이 임의로 부관을 부가할 수 없으므로 위법한 부관만의 취소가 **가능**하나(단, 요건충족적 부관 제외), **재량행위**의 경우에는 부관이 주된 행정행위의 **본질적 요소**이므로 부관의 독립 취소를 인정하지 않는 <기속·재량 구별설>.
- ② 부관이 **주된 행정행위의 중요한 요소인지를 기준으로** 중요한 요소가 아닌 경우에만 부관의 독립취소를 인정하는 <중요성 기준설> 및
- ③ 취소소송의 **소송물**은 부관의 위법성 그 자체이므로 위법한 부관은 독립 취소 가능하다고 보는 <위법성 기준설> 등이 있다.

c. 판례

판례는 일관되게 **부담만이 독립하여 소의 대상**이 된다고 보고, **본안에서는 부담만이 소송물이므로 부담만 취소판결 할 수 있다고 본다.** 이외의 기타 부관의 경우에는 독립 쟁송가능성을 부정하므로 부관부 행정행위 전체가 소의 대상이 되고, 본안에서는 기속행위에 부가된 부관은 당연무효이므로, 부관만에 대한 무효선언을 하고 본체인 행정행위는 존속시키고, 재량행위의 경우에는 부관이 위법하고 중요한 요소인 경우 법원은 부관부 행정행위 전체를 취소판결하게 된다. 그러나 중요한 요소가 아닌 경우의 법원의 태도는 불명확하다.

d. 소결

부관은 주로 재량행위에 부가되므로 기속·재량 구별설은 부관에 대한 행정소송을 유명무실하게 한다는 문제가 있고, 위법성 기준설은 행정청이 부가한 부관을 법원이 취소하는 것으로 행정청의 의사에 반하게 되어 권력분립의 문제가 발생할 우려가 있다. 따라서 주된 행정행위의 본질적인 요소인지에 따라 판단하는 <중요성 기준설>이 타당하다.

※ 부담의 위법성 판단 기준시점 (처분 당시 법령 기준)

행정청이 수익적 행정처분을 하면서 부가한 부담의 위법 여부는 처분 당시 법령을 기준으로 판단하여야 하고, 부담이 처분 당시 법령을 기준으로 적법하다면 처분 후 부담의 전제가 된 주된 행정처분의 근거 법령이 개정됨으로써 행정청이 더 이상 부관을 붙일 수 없게 되었다 하더라도 곧바로 위법하게 되거나 그 효력이 소멸하게 되는 것은 아니다. 따라서 행정처분의 상대방이 수익적 행정처분을 얻기 위하여 행정청과 사이에 행정처분에 부가할 부담에 관한 협약을 체결하고 행정청이 수익적 행정처분을 하면서 협약상의 의무를 부담으로 부가하였으나 부담의 전제가 된 주된 행정처분의 근거 법령이 개정됨으로써 행정청이 더 이상 부관을 붙일 수 없게 된 경우에도 곧바로 협약의 효력이 소멸하는 것은 아니다. [대법원 2009. 2. 12. 선고 2005다65500]

[기부채납부담의 하자과 기부채납의 효력]

1. 문제점

기부채납부담에 하자가 있는 경우 그 부담에 기한 기부채납의 효력은 어떻게 되는지가 문제 된다.
즉, 기 납부된 기부채납 부분이 부당이득이 되는지가 논점이 된다.

2. 학설

① 부담과 그 부담의 이행으로 인한 기부채납(사법상 법률행위)을 별개의 행위로 보아, 부담이 취소되더라도 기 이행한 사법상 법률행위가 당연무효가 되는 것은 아니라고 보는 <독립설>과 ② 부담이 무효이거나 취소되면 기부채납은 법률상 원인 없이 이루어진 것이므로 부당이득이 된다고 보는 <종속설> 등이 있다.

3. 판례

판례는 기부채납을 사법상 행위로 보면서 부담과 기부채납은 별개의 행위이므로 효력도 별개로 논해야 한다는 독립설의 입장을 취한다.

4. 검토

기부채납부담의 이행으로서 이루어진 기부채납은 자발적인 기부채납과 달리 공법상의 법률행위로 파악하는 것이 합리적이며, 기부채납을 취소하였는데도 여전히 기부채납부담의 효력이 존재한다고 본다면 이는 공정력과도 모순되므로 종속설이 타당하다.

01 의미

행정청이 사인에 대해 장래에 일정한 행정작용을 하거나 하지 않을 것을 내용으로 하는 의사표시를 말한다.

대법원 1995. 1. 20. 선고 94누6529 판결

어업권면허에 선행하는 우선순위결정은 행정청이 우선권자로 결정된 자의 신청이 있으면 어업권면허처분을 하겠다는 것을 약속하는 행위로서 강학상 확약이다.

대법원 1996. 8. 20. 선고 95누10877 판결

구 건축법상의 사전결정제도만 있고 주택건설촉진법상의 사전결정제도는 신설되기 이전에 주택건설사업 승인신청을 하기에 앞서 구 건축법상의 사전결정을 받은 경우, 행정청이 그 건축법상의 사전결정에 기속되어 주택건설촉진법상의 주택건설사업계획을 반드시 승인하여야 하는 것은 아니고, 주택건설사업승인 거부처분이 구 건축법상의 사전결정에 배치된다는 이유만으로 위법하게 되는 것은 아니다.

02 법적성질

확약이 그 자체로 행정행위인가에 대하여

① 확약은 행정청에 대해 장래에 확약의 내용을 이행 하여야 할 법적의무를 발생시킨다고 보아

확약의 처분성을 긍정하는 <긍정설>과

② 사정변경에 의해 변경될 수 있어 종국적 규율성이 없다는 점에서 처분성을 부정하는 <부정설>이 대립한다.

판례는 어업권 우선순위결정에 관한 사건에서 어업권 우선순위결정을 확약으로 보면서 이는 행정처분이 아니므로 공정력, 불가쟁력 등과 같은 효력이 인정되지 않는다고 하여 <부정설>의 입장을 취한다. 생각건대, 확약은 **종국적인 행위는 아니지만 행정청은 확약을 준수하여야 할 의무가 있으므로 확약의 처분성을 긍정하여 사전적 권리구제가 가능하게 하는 것이 타당하다.**

03 법적근거 (『행정절차법』제40조의2)

행정절차법 제40조의2 제1항에서는 법령등에서 당사자가 신청할 수 있는 처분을 규정하고 있는 경우 행정청은 당사자의 신청에 따라 장래에 어떤 처분을 하거나 하지 아니할 것을 내용으로 하는 의사표시(이하 “확약”이라 한다)를 할 수 있다고 규정하고 있다. 즉, 확약은 **본 행정처분권한에 포함되어 있으므로 별도의 명문의 규정이 없는 경우에도 허용될 수 있다.**

04 요건 및 효과

확약은 요건으로는

- ① (주체) 본 행정처분을 할 수 있는 권한을 가진 행정청이 **권한 범위 내에서** 할 것,
- ② (형식) **문서로** 할 것,
- ③ (내용) 법령등에서 당사자가 신청할 수 있는 처분을 대상으로
그 내용은 **법의 일반원칙에** 부합하고, **실현가능한 내용일 것,**

④ (절차) 일정한 절차가 필요한 경우 그 절차를 거칠 것이 있다.

확약을 발령한 행정기관은 자기구속의 의무를 지게 되어 확약 상대방에게 그 내용에 따른 행정행위를 해야 할 의무를 부담하며, 상대방에게는 행정기관에 대해 확약의 내용을 이행할 것을 청구할 수 있는 권리가 인정된다.

05 실효

확약이 있는 후에 사실적·법률적 상태의 변경이 있는 경우 행정청의 별다른 의사표시가 없더라도 확약은 실효된다는 것이 통설·판례의 태도이다.

대법원 1996. 8. 20. 선고 95누10877 판결

행정청이 상대방에게 장차 어떤 처분을 하겠다고 확약 또는 공적인 의사표명을 하였다고 하더라도, 그 자체에서 상대방으로 하여금 언제까지 처분의 발령을 신청을 하도록 유효기간을 두었는데도 그 기간 내에 상대방의 신청이 없었다거나 확약 또는 공적인 의사표명이 있는 후에 사실적·법률적 상태가 변경되었다면, 그와 같은 확약 또는 공적인 의사표명은 행정청의 별다른 의사표시를 기다리지 않고 실효된다.

06 구별개념

1) 사전결정

사전결정이란 종국적인 행정결정을 내리기 전에 사전적인 단계로서 여러 요건 중 하나 또는 일부에 대해 우선적으로 심사하여 내린 결정을 말한다. 사전결정은 그 자체로 하나의 완결된 행정행위라고 보는 것이 통설·판례의 태도이다.

대법원 1998. 4. 24. 선고 97누1501 판결

주택건설촉진법 제33조 제1항이 정하는 주택건설사업계획의 승인은 이른바 수익적 행정처분으로서 행정청의 재량행위에 속하고, 따라서 그 전 단계로서 같은 법 제32조의4 제1항이 정하는 주택건설사업계획의 사전결정 역시 재량행위라고 할 것이므로, 사전결정을 받으려고 하는 주택건설사업계획이 관계 법령이 정하는 제한에 배치되는 경우는 물론이고, 그러한 제한사유가 없는 경우에도 공익상 필요가 있으면 처분권자는 그 사전결정 신청에 대하여 불허가결정을 할 수 있다.

2) 가행정행위

가행정행위란 최종적인 행정행위가 있기 전에 사실관계 법률관계의 계속적인 심사를 유보한 상태에서 행정법관계의 권리·의무의 전부 또는 일부에 대해 잠정적으로만 행정행위로서의 구속력을 가지는 행정작용을 말한다.

즉, 최종적으로 결정되기 전까지만 행정행위로서의 구속력을 가진다.

3) 부분허가

부분허가란 단계적 행정행위의 일부에 대하여 행하는 허가를 말하는데, 예를들면 원자력발전소와 같이 장기간이 소요되는 대형 시설물을 건설할 때 단계적으로 시설의 일부에 대하여 하는 행하는 허가를 말한다.

※ 단계적 행정행위

행정청의 결정이 여러 단계의 행정결정을 통해 연쇄적으로 이루어지는 것을 단계적 행정행위라고 한다.

단계적 행정행위에는 확약, 사전결정, 가행정행위 및 부분허가가 있다.

제1절 개념

행정계획이란 행정주체가 일정한 행정활동을 위해 **목표를 설정**하고 그 목표를 달성하기 위해 **행정수단을 선정**하고 **조정·종합화** 하는 활동기준 또는 설정행위를 말한다. 판례는 ‘행정계획이라 함은 행정에 관한 전문적·기술적 판단을 기초로 하여 도시의 건설·정비·개량 등과 같은 특정한 행정목표를 달성하기 위하여 서로 관련되는 행정수단을 종합·조정함으로써 장래의 일정한 시점에 있어서 일정한 질서를 실현하기 위한 활동기준으로 설정된 것’(대법원 2007. 4. 12. 선고 2005두1893 판결)이라고 정의하고 있다. 행정계획의 예로는 처분적 성질을 가지는 도시·군관리계획, 관리처분계획이 있고, 처분성이 없는 광역도시계획, 도시·군기본계획 등이 있다.

제2절 법적성질

01 문제점

행정계획이 특정한 행위형식을 취하지 않는 경우 그 법적성질에 대해 권리구제 방법 등과 관련이 있어 문제 된다.

02 학설

행정계획의 법적성질에 대하여

- ① 행정계획은 **일반적·추상적 규율**로서 처분이 아니라 입법의 성질을 가진다고 보는 <입법행위설>,
- ② **특정인의 권리나 법률상 이익에 개별적이고 구체적인 변동**을 초래하므로 행정행위의 성질을 가진다고 보는 <행정행위설>,
- ③ 행정계획은 그 **종류가 다양하고 형태도 여러 가지**이므로 개별적으로 검토하여야 한다고 보는 <개별검토설>,
- ④ 행정계획은 **규범도 아니고 행정행위도 아닌 독자적인 성질**을 가진다고 보는 <독자성설>이 있다.

03 판례

헌법재판소는 ‘일반적으로 국민적 구속력을 갖는 행정계획은 행정행위에 해당되지만, 구속력을 갖지 않고 행정기관 내부의 행동지침에 지나지 않는 행정계획은 행정행위가 될 수 없다’고 하여 <개별검토설>의 입장을 취하며[전원재판부 2011헌마291, 2014. 3. 27.], 대법원도 개별적으로 행정계획의 성질 등을 고려하여 판단하는 입장이다.

1) 처분성 긍정 (도시계획, 관리처분계획)

대법원 1982. 3. 9. 선고 80누105 판결

도시계획법 제12조 소정의 도시계획결정이 고시되면 도시계획구역안의 토지나 건물 소유자의 토지형질변경, 건축물의 신축, 개축 또는 증축 등 권리행사가 일정한 제한을 받게 되는바 이런 점에서 볼 때 고시된 도시계획결정은 특정 개인의 권리 내지 법률상의 이익을 개별적이고 구체적으로 규제하는 효과를 가져오게 하는 행정청의 처분이라 할 것이고, 이는 행정소송의 대상이 되는 것이라 할 것이다.

대법원 2002. 12. 10. 선고 2001두6333 판결

도시재개발법에 의한 재개발조합은 조합원에 대한 법률관계에서 적어도 특수한 존립목적에 부여받은 특수한 행정주체로서 국가의 감독하에 그 존립 목적인 특정한 공공사무를 행하고 있다고 볼 수 있는 범위 내에서는 공법상의 권리의무 관계에서 있는 것이므로 분양신청 후에 정하여진 관리처분계획의 내용에 관하여 다툼이 있는 경우에는 그 관리처분계획은 토지 등의 소유자에게 구체적이고 결정적인 영향을 미치는 것으로서 조합이 행한 처분에 해당하므로 항고소송의 방법으로 그 무효확인이나 취소를 구할 수 있다.

2) 처분성 부정 (도시기본계획, 환지계획)

대법원 2007. 4. 12. 선고 2005두1893 판결

도시기본계획이라는 것은 도시의 장기적 개발방향과 미래상을 제시하는 도시계획 입안의 지침이 되는 장기적·종합적인 개발계획으로서 직접적인 구속력은 없다.

대법원 1999. 8. 20. 선고 97누6889 판결

환지예정지 지정이나 환지처분은 그에 의하여 직접 토지소유자 등의 권리의무가 변동되므로 이를 항고소송의 대상이 되는 처분이라고 볼 수 있으나, 환지계획은 위와 같은 환지예정지 지정이나 환지처분의 근거가 될 뿐 그 자체가 직접 토지소유자 등의 법률상의 지위를 변동시키거나 또는 환지예정지 지정이나 환지처분과는 다른 고유한 법률효과를 수반하는 것이 아니어서 이를 항고소송의 대상이 되는 처분에 해당한다고 할 수가 없다.

04 소결

국민의 권리·의무에 직접적인 영향을 미치는 행정계획은 처분성이 긍정되므로 신속한 국민의 권리구제를 위해 행정행위로 보아야 하고, 직접적으로 국민의 권리·의무에 변동을 초래하지 않는 행정계획의 경우는 처분성이 없다고 봄이 타당하다. 즉, 행정계획을 개별적으로 검토하는 <개별적 검토설>이 타당하다.

01 의미

계획재량이란 계획청이 행정계획을 수립함에 있어서 인정되는 광범위한 형성의 자유를 말한다. 통상 계획법률은 추상적인 목표와 절차만을 규정하고 있을 뿐 행정계획의 내용에 대하여는 별다른 규정을 두고 있지 않는데, 이러한 계획법률의 특성에 기인하여 계획청에게 재량이 인정된다.

대법원 2000. 3. 23. 선고 98두2768 판결

행정계획이라 함은 행정에 관한 전문적·기술적 판단을 기초로 하여 도시의 건설·정비·개량 등과 같은 특정한 행정목표를 달성하기 위하여 서로 관련되는 행정수단을 종합·조정함으로써 장래의 일정한 시점에 있어서 일정한 질서를 실현하기 위한 활동기준으로 설정된 것으로서, 도시계획법 등 관계 법령에는 추상적인 행정목표와 절차만이 규정되어 있을 뿐 행정계획의 내용에 대하여는 별다른 규정을 두고 있지 아니하므로 행정주체는 구체적인 행정계획을 입안·결정함에 있어서 비교적 광범위한 형성의 자유를 가진다.

02 행정재량과의 구분

1) 학설

- ① 계획재량은 목적과 수단으로 구성되었으나 재량행위는 요건과 효과로 구성되어 양자는 규범구조가 서로 다르고, 계획재량에는 형량명령이라는 고유한 하자이론이 존재하여 질적 차이가 있다고 보는 <질적 차이 긍정설>과,
- ② 규범구조의 차이는 본질적인 것이 아니고 형량명령도 비례의 원칙의 내용에 해당하는 법원리라고 보아 질적 차이를 부정하고 양적 차이만을 인정하는 <질적 차이 부정설>이 대립한다.

2) 판례

종래에는 계획재량에 하자와 관련하여 재량권의 일탈·남용으로 사안을 해결하였는데, 최근에는 재량의 일탈·남용이라는 용어 대신 형량에 하자가 있다고 하여 계획재량의 고유한 하자론을 인정하여 계획재량의 독자성을 긍정하는 입장에 있다.

2005두1893 판결

행정주체는 구체적인 행정계획을 입안·결정함에 있어서 비교적 광범위한 형성의 자유를 가지는 것이지만, 행정주체가 가지는 이와 같은 형성의 자유는 무제한적인 것이 아니라 그 행정계획에 관련되는 자들의 이익을 공익과 사익 사이에서는 물론이고 공익 상호간과 사익 상호간에도 정당하게 비교교량하여야 한다는 제한이 있으므로, 행정주체가 행정계획을 입안·결정함에 있어서 이익형량을 전혀 행하지 아니하거나 이익형량의 고려 대상에 마땅히 포함시켜야 할 사항을 누락한 경우 또는 이익형량을 하였으나 정당성과 객관성이 결여된 경우에는 그 행정계획결정은 형량에 하자가 있어 위법하게 된다.

3) 소결

계획재량은 행정재량에 비해 비교적 광범위한 형성의 자유가 인정된다고 보는 것이 일반적이다. 그러나 이는 양적인 차이로 이해하여야 하며, 양자 모두 행정청의 선택의 자유를 인정하는 것이므로 본질적으로 차이가 있다고 보기는 어렵다.

03 계획재량의 통제 [★★★]

1) 계획재량의 한계

행정계획을 수립함에 있어서는 계획청에게 계획재량이 인정되는데, 이러한 계획재량은 무제한적인 것이 아니라 일정한 한계를 가진다.

- ① 행정계획은 근거 법령의 목적에 부합하는 것이어야 하며,
- ② 행정계획은 그 목적 달성에 필요한 수단이어야 한다. 또한
- ③ 필요한 수단이라 하더라도 관련된 이익을 정당하게 형량하여야 한다(형량명령).

2) 형량명령의 준수

형량명령이란 행정계획을 입안·결정함에 있어서 관련된 이익을 정당하게 형량하여야 한다는 원칙을 말한다.

형량명령의 준수는

- ① 조사단계(비교형량하여야 할 모든 관련이익을 조사),
- ② 평가단계(관련이익을 중요도에 따라 평가),
- ③ 비교·형량단계(협의를 비교형량)를 거쳐 행해진다.

3) 형량하자 (판례)

형량하자의 종류로는

- ① 형량을 전혀 하지 않은 <형량의 해태>,
- ② 형량에 반드시 포함되어야 할 특정이익을 형량하지 않은 <형량의 흠결>,
- ③ 형량을 하기는 하였으나 객관성과 비례성을 결여한 <오형량>이 있다.

종래에는 형량명령의 법리를 재량권 일탈·남용으로 해결하였으나, 원지동추모공원과 관련한 판례에서 형량명령을 인정하고 형량하자로 '이익형량을 전혀 행하지 아니하거나 이익형량의 고려 대상에 마땅히 포함시켜야 할 사항을 누락한 경우 또는 이익형량을 하였으나 정당성과 객관성이 결여된 경우'를 언급하였으며, 형량에 하자가 있는 행정계획은 위법하다고 판시하였다. 다만, 형량하자의 효과에 관해서는 행정의 효율성 측면에서 일률적으로 판단하기보다 하자의 정도에 따라 개별적으로 판단하는 것이 타당하다.

대법원 2006. 9. 8. 선고 2003두5426 판결

행정주체는 구체적인 행정계획을 입안·결정함에 있어서 비교적 광범위한 형성의 자유를 가지는 것이지만, 행정주체가 가지는 이와 같은 형성의 자유는 무제한적인 것이 아니라 그 행정계획에 관련되는 자들의 이익을 공익과 사익 사이에서서는 물론이고 공익 상호간과 사익 상호간에도 정당하게 비교교량하여야 한다는 제한이 있으므로, 행정주체가 행정계획을 입안·결정함에 있어서 이익형량을 전혀 행하지 아니하거나 이익형량의 고려 대상에 마땅히 포함시켜야 할 사항을 누락한 경우 또는 이익형량을 하였으나 정당성과 객관성이 결여된 경우에는 위법하다.

01 의미

행정계획은 장래에 행정지침으로서 행정의 방향을 제시하는 기능을 하고, 국민은 그러한 행정계획을 신뢰하고 투자하는 등의 조치를 취하게 된다. 그런데 행정계획은 장래 여건의 변화 등으로 인해 변경 또는 폐지 될 수 있는데, 계획보장청구권이란 그러한 경우에 행정계획은 존속을 청구하거나 변경으로 인한 손실의 보상을 청구할 수 있는 권리 등을 말한다.

02 내용

1) 계획존속청구권

계획존속청구권이란 행정계획의 변경 또는 폐지에 대해 계획의 존속을 주장하는 권리이다. 행정계획은 유연성과 가변성이 있어 원칙적으로 인정될 수 없으나, 예외적으로 취소와 철회의 제한의 원칙에 의해 개인의 신뢰를 보호할 수 있는 경우에는 인정될 수 있다.

2) 계획이행청구권

계획이행청구권이란 확정된 계획을 행정주체로 하여금 이행하도록 요구하는 권리를 말한다. 계획존속청구권에서와 마찬가지로 원칙적으로 인정되지 않는다. 국토계획법 제47조는 도시·군계획시설에 대해 도시·군계획시설결정의 고시일부터 10년 이내 사업이 시행되지 않는 경우 토지(지목이 '대')를 매수할 수 있다고 규정하고 있는데, 이를 계획이행청권에 갈음하는 청구권으로 볼 수 있다.

3) 경과조치청구권

경과조치청구권이란 행정계획의 변경 또는 폐지로 인하여 불이익을 받는 것을 방지하기 위해 행정청에 경과조치나 적응조치를 요구할 수 있는 권리를 말한다. 이는 명시적인 법률의 근거가 있는 경우에만 인정될 수 있다.

4) 손해전보청구권

손해전보청구권이란 행정계획의 변경 및 폐지로 인해 가해진 개인의 손해가 보호할 가치가 있는 신뢰인 경우에 손실보상이나 손해배상을 주장할 수 있는 청구권을 말한다.

03 인정여부

행정계획은 유연성·가변성이라는 성질을 가지고 있고 행정계획의 근거 법률인 계획법률은 일차적으로 공익 보호를 목적으로 하고, 사익보호를 목적으로 하는 것이 아니므로 행정의 효율성 측면에서 계획보장청구권은 인정되기 어렵다. 다만, 예외적으로 법규상 조리상 청구권이 인정되는 경우가 있으며 이러한 경우에는 행정계획의 존속 등을 청구할 수 있다.

04 계획변경청구권

계획변경청구권이란 기존 행정계획의 변경을 청구할 수 있는 권리를 말한다. 계획변경청구권은 기존 계획을 신뢰하는 경우뿐만 아니라, 장래에 발전적 계획으로의 변경까지 요구하는 것을 포함한다. 판례는 계획변경청구권을 원칙적

으로 부정하지만 계획변경신청을 거부하는 것이 실질적으로 당해 처분 자체를 거부하는 결과가 되는 경우에는 예외적으로 인정(법규상·조리상 신청권 인정)한 바 있다.

대법원 1989. 10. 24. 선고 89누725 판결 (부정)

국민의 신청에 대한 행정청의 거부가 행정처분이 되기 위하여는 국민이 그 신청에 따른 행정행위를 요구할 수 있는 법규상 또는 조리상의 권리가 있어야 할 것인 바, 도시계획법상 주민이 도시계획 및 그 변경에 대하여 어떤 신청을 할 수 있다는 규정이 없을 뿐만 아니라 도시계획과 같이 장기성, 종합성이 요구되는 행정계획에 있어서는 **그 계획이 일단확정된 후에 어떤 사정의 변경이 있다 하여 지역주민에게 일일이 그 계획의 변경을 청구할 권리를 인정해 줄 수도 없는** 이치이므로 도시계획시설인 공원조성계획 취소신청을 거부한 행위는 항고소송의 대상이 되는 행정처분이라고 볼 수 없다.

[그 외 행정작용]

구 분	내 용
공법상 계약	공법적 효과의 발생을 목적으로 행정주체를 한쪽 당사자로 하는 계약을 말한다. (대등한 양 당사자의 반대방향의 의사 합치)
행정조사	행정기관이 정책을 결정하거나 직무를 수행하는 데 필요한 정보나 자료를 수집하기 위하여 현장조사·문서열람·시료채취 등을 하거나 조사 대상자에게 보고요구·자료제출요구 및 출석·진술을 요구하는 활동을 말한다. (행정조사기본법 제2조 제1호)
공법상 사실행위	일정한 법적 효과의 발생을 목적으로 하는 것이 아니라, 사실상의 효과나 결과의 실현을 목적으로 하는 행정작용을 말한다. 예컨대, 교량의 건설이나 도로의 청소 등이 있다.
행정지도	행정기관이 그 소관사무의 범위 안에서 행정목적을 실현하기 위해 특정인에게 지도·권고·조언 등을 하는 행정작용을 말한다. (행정절차법 제2조 제3호)

제1절 의의 및 취지

인·허가의제 제도란 하나의 인·허가를 받으면 법률에서 정하는 바에 따라 그와 관련된 다른 인·허가를 받은 것으로 보는 것을 말한다. 하나의 목적을 실현하기 위해 관계 법령 등에서 여러 관계기관으로부터 허가, 인가, 승인, 협의 등을 받아야 하는 복합민원의 경우 개별적으로 모든 허가 등을 받도록 하는 것은 민원인에게 불편을 초래할 수 있다. 이에 하나의 인·허가신청만으로 관련된 인·허가를 받은 것으로 보아, 무용한 행정절차의 반복을 피하고 절차를 간소화하여 신속하고 편리한 사무처리를 할 수 있도록 함에 그 취지가 있다.

예 「건축법」 제11조의 건축허가를 받은 경우 「국토계획법」 제56조의 개발행위허가, 「농지법」상 농지전용허가를 포함하여 20여개의 인·허가 등 의제 됨.

제2절 법적근거 (「행정기본법」 제24조)

[행정기본법] 제24조 (인허가의제의 기준)

- ① 이 절에서 "인허가의제"란 하나의 인허가(이하 "주된 인허가"라 한다)를 받으면 법률로 정하는 바에 따라 그와 관련된 여러 인허가(이하 "관련 인허가"라 한다)를 받은 것으로 보는 것을 말한다.
- ② 인허가의제를 받으려면 주된 인허가를 신청할 때 관련 인허가에 필요한 서류를 함께 제출하여야 한다.
다만, 불가피한 사유로 함께 제출할 수 없는 경우에는 주된 인허가 행정청이 별도로 정하는 기한까지 제출할 수 있다.
- ③ 주된 인허가 행정청은 주된 인허가를 하기 전에 관련 인허가에 관하여 미리 관련 인허가 행정청과 협의하여야 한다.
- ④ 관련 인허가 행정청은 제3항에 따른 협의를 요청받으면 그 요청을 받은 날부터 20일 이내(제5항 단서에 따른 절차에 걸리는 기간은 제외한다)에 의견을 제출하여야 한다. 이 경우 전단에서 정한 기간(민원 처리 관련 법령에 따라 의견을 제출하여야 하는 기간을 연장한 경우에는 그 연장한 기간을 말한다) 내에 협의 여부에 관하여 의견을 제출하지 아니하면 협의가 된 것으로 본다.
- ⑤ 제3항에 따라 협의를 요청받은 관련 인허가 행정청은 해당 법령을 위반하여 협의에 응해서는 아니 된다.
다만, 관련 인허가에 필요한 심의, 의견 청취 등 절차에 관하여는 법률에 인허가의제 시에도 해당 절차를 거친다는 명시적인 규정이 있는 경우에만 이를 거친다.

집중효란 일정한 절차를 거쳐 행정계획이 확정되면 다른 법규에서 규정된 승인 또는 허가 등을 받은 것으로 보는 효과를 집중효라고 한다. 인·허가의제와 행정계획의 집중효는 절차의 간소화와 신속한 사업진행을 목적으로 하고, 법령에 근거하여 행정관청의 권한이 통합된다는 점에서 본질적인 차이가 없다는 견해도 있으나, 행정계획의 방식을 통하지 않고 사업의 시행을 위한 인·허가 등을 의제하는 제도라는 점에서 양자는 엄밀히는 구별된다.

01 절차의 집중

1) 문제점

주무행정청이 인·허가의제가 되는 주된 행정행위를 발령하는 경우 의제되는 행위에서 요구되는 절차적 요건에 얼마나 구속되는지가 문제 된다. 즉, 의제되는 행위가 거쳐야 하는 모든 절차를 준수하여야 하는지, 아니면 집중효로 해당 절차를 거치지 않아도 되는지 등이 논점이다.

2) 학설

- ① 주된 인·허가에 요구되는 절차만 거치면 되고, 의제되는 인·허가의 절차를 거칠 필요가 없다는 <절차집중설>,
- ② 의제되는 인·허가의 모든 절차를 거칠 필요는 없으나,
이해관계 있는 제3자의 권익보호와 같은 중요한 절차적 요건에는 구속 된다고 보는 <제한적 절차집중설>,
- ③ 주무행정청은 관계 행정청이 준수하여야 하는 모든 절차적 요건에 구속된다고 보는 <절차집중 부정설>이 있다.

3) 판례

판례는 행정청이 관계기관의 장과의 협의를 거쳐 사업계획승인을 한 이상 해당 법령에 따른 허가·인가·결정·승인 등이 있는 것으로 보아, 그 절차와 별도로 법령에서 정하는 절차를 거칠 필요는 없다고 하여 <절차집중설>의 입장을 취한다.

대법원 1992. 11. 10. 선고 92누1162 판결

건설부장관이 구 주택건설촉진법 제33조에 따라 관계기관의 장과의 협의를 거쳐 사업계획승인을 한 이상 같은 조 제4항의 허가·인가·결정·승인 등이 있는 것으로 볼 것이고, 그 절차와 별도로 도시계획법 제12조 등 소정의 중앙도시 계획위원회의 의결이나 주민의 의견청취 등 절차를 거칠 필요는 없다.

4) 소결

의제되는 행위의 모든 절차적 요건에 구속되도록 하여 해당 절차를 모두 거치도록 하는 것은 절차의 간소화라는 인·허가의제 제도의 취지를 고려할 때 부당하다. 따라서 이해관계 있는 제3자의 권익보호의 존중을 위해 중요한 절차는 거쳐야 한다고 보는 <제한적 긍정설>이 타당하다.

02 실체의 집중

1) 문제점

주무행정청이 집중효의 대상이 되는 인·허가의 실체적 요건에 합치되는지 여부를 심사하여야 하는지와 관련하여 의제되는 인·허가 요건의 심리범위가 문제 된다.

2) 학설

- ① 주무행정청은 의제되는 인·허가의 실체적 요건에 구속되지 않고, 자유롭게 판단할 수 있다고 보는 <실체집중설>,
- ② 의제되는 인·허가의 실체적 요건에 엄격하게 구속되지는 않고, 이익형량의 요소로 종합적으로 고려하면 족하다고 보는 <제한적 실체집중설> 및
- ③ 의제되는 인·허가의 요건이 모두 충족되어야 주된 인·허가를 할 수 있다고 보는 <실체집중 부정설>이 있다.

3) 판례

판례는 도시계획시설인 주차장에 대한 건축허가신청을 받은 행정청은 건축법상 허가 요건뿐 아니라 국토계획법상의 실시계획인가 요건도 충족하는지를 심사하여야 한다고 하여 <실체집중 부정설>의 입장을 취한 바 있다.

대법원 2015. 7. 9. 선고 2015두39590 판결

건축법에서 인허가의제 제도를 둔 취지는, 인허가의제사항과 관련하여 건축허가의 관할 행정청으로 창구를 단일화하고 절차를 간소화하며 비용과 시간을 절감함으로써 국민의 권익을 보호하려는 것이지, 인허가의제사항 관련 법률에 따른 각각의 인허가 요건에 관한 일체의 심사를 배제하려는 것으로 보기는 어려우므로, 도시계획시설인 주차장에 대한 건축 허가신청을 받은 행정청으로서 건축법상 허가 요건뿐 아니라 국토의 계획 및 이용에 관한 법령이 정한 도시계획시설 사업에 관한 실시계획인가 요건도 충족하는 경우에 한하여 이를 허가해야 한다.

4) 소결

절차의 간소화라는 인·허가 의제 제도의 취지를 고려하더라도 법치행정의 원칙상 의제되는 인·허가도 그 내용상 요건은 모두 충족되어야 하므로 판례와 같이 <실체집중 부정설>이 타당하다.

행정기본법 제25조에서 인·허가 의제의 효과에 대해 주무행정청의 주된 행정행위에 대한 인·허가가 있게 되면

- ① 협의가 된 사항에 관해서는 주된 인·허가를 받았을 때, 의제되는 인·허가를 받은 것으로 보고,
 - ② 인·허가 의제의 효과는 주된 인·허가의 해당 법률에 규정된 관련 인·허가에 한정된다고 규정하고 있다.
- 또한, 인·허가 의제의 효력은 주된 사업을 시행하는 데
- ③ 필요한 범위 내에서만 그 효력이 유지된다.

[행정기본법] 제25조 (인허가의의제의 효과)

- ① 제24조제3항·제4항에 따라 협의가 된 사항에 대해서는 주된 인허가를 받았을 때 관련 인허가를 받은 것으로 본다.
- ② 인허가의의제의 효과는 주된 인허가의 해당 법률에 규정된 관련 인허가에 한정된다.

대법원 2015. 4. 23. 선고 2014두2409판결

주된 인·허가에 관한 사항을 규정하고 있는 어떠한 법률에서 주된 인·허가가 있으면 다른 법률에 의한 인·허가를 받은 것으로 의제한다는 규정을 둔 경우에는, 주된 인·허가가 있으면 다른 법률에 의한 인·허가가 있는 것으로 보는데 그치는 것이고, 거기에서 더 나아가 다른 법률에 의하여 인·허가를 받았음을 전제로 한 다른 법률의 모든 규정들까지 적용되는 것은 아니다.

PART 03

행정절차와 실효성 확보

Chapter 01 행정절차법

Chapter 02 행정의 실효성 확보수단

제1절 일반론 (행정절차 및 행정절차법)

행정절차란 광의로는 행정기관이 행정 과정상 거쳐야 하는 법적 절차를 말한다. 행정입법절차, 행정처분절차, 행정집행절차, 구제절차, 행정처벌절차 등이 모두 포함된다. 그러나 통상 행정절차라 함은 행정기관이 행정활동을 할 때 거쳐야 하는 사전적 절차로서 대외적 교섭과정을 의미하며, 이 협의의 행정절차에는 사전통지, 의견청취, 이유제시 등이 있다.

행정절차법 제3조 제1항에서 '행정절차에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따른다'고 규정하고 있어 행정절차법은 행정절차에 관한 일반법적 지위를 갖는다. 행정절차법은 '처분, 신고, 확약, 위반사실 등의 공표, 행정계획, 행정상 입법예고, 행정예고 및 행정지도의 절차'를 행정절차로 규정하고 있고, 행정절차에 관한 공통적인 사항을 규정하여 국민의 행정 참여를 도모함으로써 행정의 공정성·투명성 및 신뢰성을 확보하고 국민의 권익을 보호함을 목적으로 한다.

제2절 사전 통지 (「행정절차법」제21조) [★★★]

01 의미 및 취지

사전통지란 행정청이 당사자에게 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분을 하는 경우에 미리 처분의 제목, 당사자의 성명 또는 명칭과 주소, 처분의 원인이 되는 사실과 처분의 내용 및 법적근거 등을 통지하는 것을 말한다. 행정절차법 제21조에 근거가 있으며, 사전통지는 신중하고 공정한 행정을 도모하고, 상대방에게 쟁송제기 여부의 판단 등에 편의를 제공함에 그 취지가 인정된다.

[행정절차법] 제21조 (처분의 사전 통지)

- ① 행정청은 당사자에게 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분을 하는 경우에는 미리 다음 각 호의 사항을 당사자 등에게 통지하여야 한다.

02 생략사유 (「행정절차법」 제21조 제4항)

- ① 공공의 안전 또는 복리를 위하여 긴급히 처분을 할 필요가 있는 경우,
 ② 법령 등에서 요구된 자격이 없거나 없어지게 되면 반드시 일정한 처분을 하여야 하는 경우에 그 자격이 없거나 없어지게 된 사실이 법원의 재판 등에 의하여 객관적으로 증명된 경우,
 ③ 해당 처분의 성질상 의견청취가 현저히 곤란하거나 명백히 불필요하다고 인정될 만한 상당한 이유가 있는 경우에는 처분의 사전통지를 하지 않을 수 있다.

[행정절차법] 제21조 (처분의 사전 통지)

④ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항에 따른 통지를 하지 아니할 수 있다.

1. 공공의 안전 또는 복리를 위하여 긴급히 처분을 할 필요가 있는 경우
2. 법령등에서 요구된 자격이 없거나 없어지게 되면 반드시 일정한 처분을 하여야 하는 경우에 그 자격이 없거나 없어지게 된 사실이 법원의 재판 등에 의하여 객관적으로 증명된 경우
3. 해당 처분의 성질상 의견청취가 현저히 곤란하거나 명백히 불필요하다고 인정될 만한 상당한 이유가 있는 경우

03 거부처분의 사전통지 [★★]

1) 문제점

행정절차법 제21조 제1항에서는 당사자에게 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분을 하는 경우에 사전통지를 하도록 규정하고 있다. 이에 사전통지의 적용 범위와 관련하여 수익적 행정처분의 신청을 거부하는 것이 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분인지가 문제 된다.

2) 학설

- ① 수익적 행정처분의 신청만으로는 아직 당사자에게 아무런 권익이 부여되지 않았으므로, 그 거부는 권익을 제한하는 처분이 아니며, 신청 과정에서 행정청과 당사자가 계속 협의를 하는 상태이므로 사전통지가 불필요 하다고 보는 <불요설>,
- ② 신청을 한 당사자는 긍정적인 처분을 기대하므로 그 거부는 권익을 제한하는 처분에 해당하여 사전통지가 필요하다고 보는 <필요설> 및
- ③ 원칙적으로는 부정하나, 갱신허가의 거부 등 신청인의 권익이 보호될 필요가 있는 경우에는 사전통지를 하여야 한다고 보는 <절충설>이 있다.

3) 판례

판례는 신청에 따른 처분이 이루어지지 않은 경우에는 아직 당사자에게 아무런 권익이 부과되어 있지 않으므로 그 거부가 권익을 제한하는 처분에 해당하지 않고 이에 사전통지의 대상이 되지 않는다고 하여 <불요설>의 입장을 취한다.

대법원 2003. 11. 28. 선고 2003두674 판결

신청에 따른 처분이 이루어지지 아니한 경우에는 아직 당사자에게 권익이 부과되지 아니하였으므로 특별한 사정이 없는 한 신청에 대한 거부처분이라고 하더라도 직접 당사자의 권익을 제한하는 것은 아니어서 신청에 대한 거부처분을 여기에서 말하는 '당사자의 권익을 제한하는 처분'에 해당한다고 할 수 없는 것이어서 처분의 사전통지대상이 된다고 할 수 없다.

4) 소결

행정절차법 제21조에서 사전통지의 적용 대상을 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분을 하는 경우라고 규정하고 있으므로 원칙적으로 거부처분의 사전통지는 불필요하다고 볼 수 있다. 다만, 갱신허가의 거부의 경우 신청의 당사자는 침익적 처분과 마찬가지로 권익의 침해 또는 제한을 받게 되므로, 이러한 경우에는 사전통지를 하도록 하여 당사자의 권익을 보호할 필요가 있다.

01 의의 및 취지

의견청취절차는 행정청이 처분을 할 때 ① 당사자 등의 의견을 직접 듣고, ② 증거를 조사하는 절차를 말한다.

행정절차법 제22조에는 의견청취의 절차로서 청문, 공청회, 의견제출을 규정하고 있다. 의견청취는 행정처분을 함에 있어 당사자의 절차적 참여를 보장하고, 의견제출의 기회를 부여하여 국민의 방어권을 보호함에 그 취지가 인정된다.

	청문	공청회	의견제출
의의	행정청이 어떠한 처분을 하기 전에 당사자 등의 의견을 직접 듣고 증거를 조사하는 절차.	행정청이 공개적인 토론을 통하여 어떠한 행정작용에 대하여 당사자 등, 전문 지식과 경험을 가진 사람, 그 밖의 일반인으로부터 의견을 널리 수렴하는 절차.	행정청이 어떠한 행정작용을 하기 전에 당사자 등이 의견을 제시하는 절차로서 청문이나 공청회에 해당하지 아니하는 절차.
사유	① 다른법령 등에 청문 규정 有 ② 행정청이 필요하다고 인정 ③ 다음의 처분시 가. 인허가 등의 취소 나. 신분·자격의 박탈 다. 법인·조합 등의 설립허가의 취소	① 다른법령 등에 공청회 규정 有 ② 행정청이 필요하다고 인정 (처분의 영향이 광범위한 경우) ③ 일정 수 이상의 당사자등 요구 (국민생활에 큰 영향)	의무부과, 권익제한의 처분으로 청문, 공청회를 하지 않는 경우

[행정절차법] 제22조 (의견청취)

① 행정청이 처분을 할 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 청문을 한다.

1. 다른 법령등에서 청문을 하도록 규정하고 있는 경우
2. 행정청이 필요하다고 인정하는 경우
3. 다음 각 목의 처분을 하는 경우
 - 가. 인허가 등의 취소
 - 나. 신분·자격의 박탈
 - 다. 법인이나 조합 등의 설립허가의 취소

② 행정청이 처분을 할 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 공청회를 개최한다.

1. 다른 법령등에서 공청회를 개최하도록 규정하고 있는 경우
2. 해당 처분의 영향이 광범위하여 널리 의견을 수렴할 필요가 있다고 행정청이 인정하는 경우
3. 국민생활에 큰 영향을 미치는 처분으로서 대통령령으로 정하는 처분에 대하여 대통령령으로 정하는 수 이상의 당사자등이 공청회 개최를 요구하는 경우

③ 행정청이 당사자에게 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분을 할 때 제1항 또는 제2항의 경우 외에는 당사자 등에게 의견제출의 기회를 주어야 한다.

02 생략사유

1) 생략사유 (「행정절차법」 제22조 제4항)

- ① 공공의 안전 또는 복리를 위하여 긴급히 처분을 할 필요가 있는 경우,
- ② 법령 등에서 요구된 자격이 없거나 없어지게 되면 반드시 일정한 처분을 하여야 하는 경우에 그 자격이 없거나 없어지게 된 사실이 법원의 재판 등에 의하여 객관적으로 증명된 경우,
- ③ 해당 처분의 성질상 의견청취가 현저히 곤란하거나 명백히 불필요하다고 인정될 만한 상당한 이유가 있는 경우,
- ④ 당사자가 의견진술의 기회를 포기한다는 뜻을 명백히 표시한 경우에 의견청취를 생략할 수 있다.

2) '의견청취가 현저히 곤란하거나 명백히 불필요하다고 인정될 만한 상당한 이유'의 판단

판례는 '의견청취가 현저히 곤란하거나 명백히 불필요하다고 인정될 만한 상당한 이유가 있는 경우'에 해당하는지는 해당 행정처분의 성질에 비추어 판단하여야 하며, 처분상대방이 이미 행정청에 위반사실을 시인하였다거나 처분의 사전통지 이전에 의견을 진술할 기회가 있었다는 사정을 고려하여 판단할 것은 아니라고 하였고, 청문통지서가 반송되었다거나, 행정처분의 상대방이 청문일시에 불출석하였다는 이유로 청문을 생략한 처분은 위법하고 판시한 바 있다.

대법원 2016. 10. 27. 선고 2016두41811 판결

'의견청취가 현저히 곤란하거나 명백히 불필요하다고 인정될 만한 상당한 이유가 있는 경우'에 해당하는지는 해당 행정처분의 성질에 비추어 판단하여야 하며, 처분상대방이 이미 행정청에 위반사실을 시인하였다거나 처분의 사전통지 이전에 의견을 진술할 기회가 있었다는 사정을 고려하여 판단할 것은 아니다.

대법원 2001. 4. 13. 선고 2003두3337 판결

행정절차법 제21조 제4항 제3호는 침해적 행정처분을 할 경우 청문을 실시하지 않을 수 있는 사유로서 "당해 처분의 성질상 의견청취가 현저히 곤란하거나 명백히 불필요하다고 인정될 만한 상당한 이유가 있는 경우"를 규정하고 있으나, 여기에서 말하는 '의견청취가 현저히 곤란하거나 명백히 불필요하다고 인정될 만한 상당한 이유가 있는지 여부'는 당해 행정처분의 성질에 비추어 판단하여야 하는 것이지, 청문통지서의 반송 여부, 청문통지의 방법 등에 의하여 판단할 것은 아니며, 또한 행정처분의 상대방이 통지된 청문일시에 불출석하였다는 이유만으로 행정청이 관계 법령상 그 실시가 요구되는 청문을 실시하지 아니한 채 침해적 행정처분을 할 수는 없을 것이므로, 행정처분의 상대방에 대한 청문통지서가 반송되었다거나, 행정처분의 상대방이 청문일시에 불출석하였다는 이유로 청문을 실시하지 아니하고 한 침해적 행정처분은 위법하다.

3) 협약으로 배제 가능한지 여부 (부정)

판례는 행정청과 당사자가 협약으로 청문 등 의견청취절차를 배제하는 조항을 두었다고 하더라도 행정의 공정성·투명성 및 신뢰성을 확보하고 국민의 권익을 보호한다는 행정절차법의 목적 및 청문제도의 취지 등에 비추어 볼 때, 그러한 배제 조항은 의견청취절차의 생략사유에 해당하지 않는다고 보고 있다.

대법원 2004. 7. 8. 선고 2002두8350 판결

행정청이 당사자와 사이에 도시계획사업의 시행과 관련한 협약을 체결하면서 관계 법령 및 행정절차법에 규정된 청문의 실시 등 의견청취절차를 배제하는 조항을 두었다고 하더라도, 국민의 행정참여를 도모함으로써 행정의 공정성·투명성 및 신뢰성을 확보하고 국민의 권익을 보호한다는 행정절차법의 목적 및 청문제도의 취지 등에 비추어 볼 때, 위와 같은 협약의 체결로 청문의 실시에 관한 규정의 적용을 배제할 수 있다고 볼 만한 법령상의 규정이 없는 한, 이러한 협약이 체결되었다고 하여 청문의 실시에 관한 규정의 적용이 배제된다거나 청문을 실시하지 않아도 되는 예외적인 경우에 해당한다고 할 수 없다.

01 의미 및 취지

이유제시란 행정청이 처분을 할 때에 당사자에게 그 근거와 이유를 제시하는 것을 말한다. 행정절차법 제23조에 근거가 있으며, 신중하고 공정한 행정을 도모하고, 상대방의 쟁송제기에 편의를 제공함에 그 취지가 인정된다. 행정청은 수익적·침익적 처분을 불문하고 모든 행정처분을 할 때 이유제시를 하여야 한다.

[행정절차법] 제23조 (처분의 이유 제시)

- ① 행정청은 처분을 할 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 당사자에게 그 근거와 이유를 제시하여야 한다.

02 요건

1) 정도, 방식, 시점

이유제시는

- ① 당사자가 그 처분 사유를 이해할 수 있을 정도로 구체적으로 하여야 하며,
- ② 처분시 고려되었던 사실상·법률상 근거를 제시하여야 한다.
- ③ 행정절차법 제24조 제1항에 의거 이유제시는 원칙적으로 문서로 하여야 하며,
- ④ 처분시 하여야 한다.

2) 요건의 완화

판례는

- ① 당사자가 근거규정 등을 명시하여 신청하는 인·허가 등을 거부하는 처분을 함에 있어, 당사자가 그 근거를 알 수 있을 정도로 상당한 이유를 제시한 경우에는 구체적 조항 및 내용까지 명시하지 않더라도 그 처분이 위법한 것이 된다고 할 수 없다 하였고,
- ② 당사자가 어떠한 근거와 이유로 처분이 이루어진 것인지를 충분히 알 수 있어서 그에 불복하여 행정구제절차로 나아가는 데에 별다른 지장이 없었던 것으로 인정되는 경우도 이유제시의 정도가 완화된다고 보았다.

대법원 2002. 5. 17. 선고 2000두8912 판결

행정절차법 제23조 제1항은 행정청은 처분을 하는 때에는 당사자에게 그 근거와 이유를 제시하여야 한다고 규정하고 있는바, 일반적으로 당사자가 근거규정 등을 명시하여 신청하는 인·허가 등을 거부하는 처분을 함에 있어 당사자가 그 근거를 알 수 있을 정도로 상당한 이유를 제시한 경우에는 당해 처분의 근거 및 이유를 구체적 조항 및 내용까지 명시하지 않았더라도 그로 말미암아 그 처분이 위법한 것이 된다고 할 수 없다.

행정절차법 제23조 제1항은 행정청이 처분을 하는 때에는 당사자에게 그 근거와 이유를 제시하도록 규정하고 있고, 이는 행정청의 자의적 결정을 배제하고 당사자로 하여금 행정구제절차에서 적절히 대처할 수 있도록 하는 데 그 취지가 있다. 따라서 처분서에 기재된 내용과 관계 법령 및 당해 처분에 이르기까지 전체적인 과정 등을 종합적으로 고려하여, 처분 당시 당사자가 어떠한 근거와 이유로 처분이 이루어진 것인지를 충분히 알 수 있어서 그에 불복하여 행정구제절차로 나아가는 데에 별다른 지장이 없었던 것으로 인정되는 경우에는 처분서에 처분의 근거와 이유가 구체적으로 명시되어 있지 않았다고 하더라도 그로 말미암아 그 처분이 위법한 것으로 된다고 할 수는 없다.

03 생략사유 (「행정절차법」 제23조 제1항)

- ① 신청내용을 모두 그대로 인정하는 처분인 경우,
 - ② 단순·반복적인 처분 또는 경미한 처분으로서 당사자가 그 이유를 명백히 알 수 있는 경우,
 - ③ 긴급히 처분을 할 필요가 있는 경우에는 이유제시를 하지 않아도 된다.
- 다만, ②, ③의 경우 처분 후 당사자가 요청하는 경우에는 그 근거와 이유를 제시하여야 한다.

01 절차상 하자의 독자적 위법성 [★★★]

1) 문제점

행정절차법에는 절차상 하자의 효과에 대한 규정을 두고 있지 않다. 따라서 절차상 하자 있는 행정행위의 위법성과 관련하여 그 행정행위가 실체법상 적법함에도 불구하고 절차상 하자만으로 취소할 수 있는지가 문제가 된다.

일반적으로 재량행위에 절차상 하자가 있는 경우에는 행정청은 적법한 절차를 거쳐 더 신중하게 사실관계를 파악한 후 기존 처분과 다른 처분을 할 수 있으므로 재량행위에 절차의 하자가 있는 경우는 독자적 위법 사유가 된다고 본다. 반면에 기속행위의 경우에는 적법한 절차를 거쳐 동일한 처분을 발령할 수 있으므로 특히 기속행위에서 절차상 하자의 독자적 위법성 인정 여부가 문제가 된다.

2) 학설

- ① 적법절차의 원칙에 비추어 행정행위는 적정한 절차를 거쳐야 하고, 행정소송법 제30조 제3항에서 절차의 하자를 이유로 취소하는 경우에도 기속력을 인정하고 있다는 점 등에 비추어 절차상 하자의 독자적 위법성을 인정하는 <적극설>.
- ② 행정절차는 적정한 행정결정을 위한 수단에 불과하고, 절차상 하자를 이유로 취소하더라도 행정청을 그 적정한 절차를 거쳐 동일한 처분을 할 수 있으므로 행정능률과 소송경제상 부정하는 <소극설> 및
- ③ 재량행위와 기속행위를 나누어 재량행위의 경우는 절차상 하자의 독자적 위법성을 인정하나, 기속행위의 경우는 내용상 하자가 없는 한 절차상 하자만으로 그 행정행위가 위법한 것은 아니라고 보는 <절충설>이 있다.

3) 판례

판례는 재량행위인 영업정지처분에서 청문절차를 거치지 않은 경우 위법하다고 하였을 뿐만 아니라, 기속행위인 과세처분에서 고지 절차에 하자가 있는 경우에 과세처분이 위법하여 취소대상이 된다고 하여 <적극설>의 입장을 취한다.

대법원 1991. 7. 9. 선고 91누971 판결

식품위생법 제64조의 규정에 의하면 보건사회부장관과 또는 시·도지사는 제58조, 제59조 또는 제63조의 규정에 의한 처분을 하고자 하는 경우에는 대통령령의 정하는 바에 따라 미리 당해 처분의 상대방 또는 그 대리인에게 의견을 진술할 기회를 주어야 하도록 되어 있고, 같은법시행령 제37조 제1항의 규정에 의하면 위 법 제64조의 규정에 의한 청문을 행하기 위하여 영업자 또는 그 대리인의 출석을 요구하고자 할 때에는 지체없이 청문서를 당해 영업자 또는 그 대리인에게 발송하여야 하되 청문일 7일 전에 도달되어야 하도록 되어 있다. 이러한 청문제도의 취지는 이 사건 영업정지와 같은 위 법 제58조 등의 규정에 의한 처분으로 말미암아 불이익을 받게 된 영업자에게 미리 변명과 유리한 자료를 제출할 기회를 부여함으로써 처분의 신중을 기하고 그 적정성을 확보하여 부당한 영업자의 권리침해를 예방하려는 데에 있으므로, 위와 같은 법령 소정의 청문절차를 전혀 거치지 아니하거나 거쳤다고 하여도 그 절차적 요건을 제대로 준수하지 아니한 경우에는 가사 영업정지사유 등 위 법 제58조 등 소정사유가 인정된다고 하더라도 그 처분은 위법하여 취소를 면할 수 없는 것이다

대법원 1983. 7. 26. 선고 82누420 판결

법인세법 등이 과세처분에 과세표준과 세액의 계산명세서 등을 첨부하여 고지하도록 규정한 취의는 단순한 세무행정상의 편의에 기한 훈시규정이 아니라 헌법과 국세기본법이 규정하는 조세법률주의의 원칙에 따라 처분청으로 하여금 자의를 배제하고 신중하고도 합리적인 처분을 행하게 함으로써 조세행정의 공정성을 기함과 동시에 납세의무자에게 부과처분의 내용을 상세히 알려서 불복여부의 결정 및 그 불복신청에 편의를 주려는 취지에서 나온 것이라고 해석되어 이와 같은 여러 규정은 강행규정으로서 납세고지서에 그와 같은 기재가 누락되면 그 과세처분 자체가 위법하게 되고 하자있는 처분으로서 취소대상이 되는 것이므로 과세관서의 이 사건의 경우와 같은 추완행위는 그것이 세액을 확정고지하는 일련의 절차로서 무용한 부과처분의 반복을 피한다는 뜻에서는 일단 이에 의하여 이 하자는 치유될 수 있다고 할 것이나 위 실시와 같이 과세처분에 과세표준과 세액의 계산명세서 등을 첨부하여 고지하도록 한 것은 납세의무자에게 부과처분의 내용을 상세히 알려서 불복여부의 결정 및 그 불복신청에 편의를 주려는데에도 그 취지가 있으므로 이 치유를 허용하려면 늦어도 과세처분에 대한 불복여부의 결정 및 불복신청에 편의를 줄 수 있는 상당한 기간내에 하여야 한다고 할 것인바 원심이 이와 같은 취지에서 피고의 원심 확정사실과 같은 뒤늦은 납세고지서의 송달로서는 이 과세처분의 하자가 치유되었다고 보기 어렵다고 판시한 조치는 정당하여 아무 위법이 없고 소론 지적의 대법원 판례는 사안을 달리하여 이 사건에 적절한 것이 되지 못한다.

4) 소결

행정작용은 **법률적합의 원칙**에 따라 그 내용(실체)뿐 아니라 **절차도 적법**하여야 한다. 또한, 행정소송법 제30조 제3항에서 취소소송 등의 기속력이 절차의 위법을 이유로 하는 경우에도 준용되므로 판례와 같이 적극설이 타당하다.

02 절차상 하자의 위법성 정도

통설·판례와 같이 절차상 하자의 독자적 위법성을 인정하는 입장에 절차상 하자가 있는 행정행위의 효력이 문제 된다. 행정행위의 무효와 취소를 구별하는 일반적 기준인 **중대·명백성설**에 따라 절차상 하자가 중대하고 명백하면 무효인 행정행위가 되고, 중대성과 명백성 중에 어느 하나를 결한 경우는 취소할 수 있는 행정행위가 되며, 판례도 동지의 입장이다.

대법원 2000. 11. 14. 선고 99두5870 판결

행정절차법 제21조 제1항, 제4항, 제22조 제1항 내지 제4항에 의하면, 행정청이 당사자에게 의무를 과하거나 권익을 제한하는 처분을 하는 경우에는 미리 처분하고자 하는 원인이 되는 사실과 처분의 내용 및 법적 근거, 이에 대하여 의견을 제출할 수 있다는 뜻과 의견을 제출하지 아니하는 경우의 처리방법 등의 사항을 당사자 등에게 통지하여야 하고, 다른 법령 등에서 필요적으로 청문을 실시하거나 공청회를 개최하도록 규정하고 있지 아니한 경우에도 당사자 등에게 의견제출의 기회를 주어야 하되, 당해 처분의 성질상 의견청취가 현저히 곤란하거나 명백히 불필요하다고 인정될 만한 상당한 이유가 있는 경우 등에는 처분의 사전통지나 의견청취를 하지 아니할 수 있도록 규정하고 있으므로, 행정청이 **침해적 행정처분을 함에 있어서 당사자에게 위와 같은 사전통지를 하거나 의견제출의 기회를 주지 아니하였다면** 사전통지를 하지 않거나 의견제출의 기회를 주지 아니하여도 되는 예외적인 경우에 해당하지 아니하는 한 그 처분은 위법하여 취소를 면할 수 없다.

03 절차상 하자와 취소판결의 기속력

절차상 하자를 이유로 취소판결이 선고된 후 처분청이 절차상 하자를 보완하여 다시 동일한 처분을 하는 것이 판결의 기속력(「행정소송법」 제30조 제3항)에 반하는 것인지가 문제 된다. 이에 대해 통설·판례는 종전 처분과 동일한 처분을 하여도 이는 취소된 종전 처분과 별개의 처분에 해당하므로 판결의 기속력에 반하지 않는 적법한 처분이라고 본다. 즉, 청문에 하자를 이유로 과세처분의 취소판결이 있은 후 청문을 거쳐 다시 동일한 과세처분을 하더라도 이는 기속력에 반하지 않는 적법한 처분이 된다.

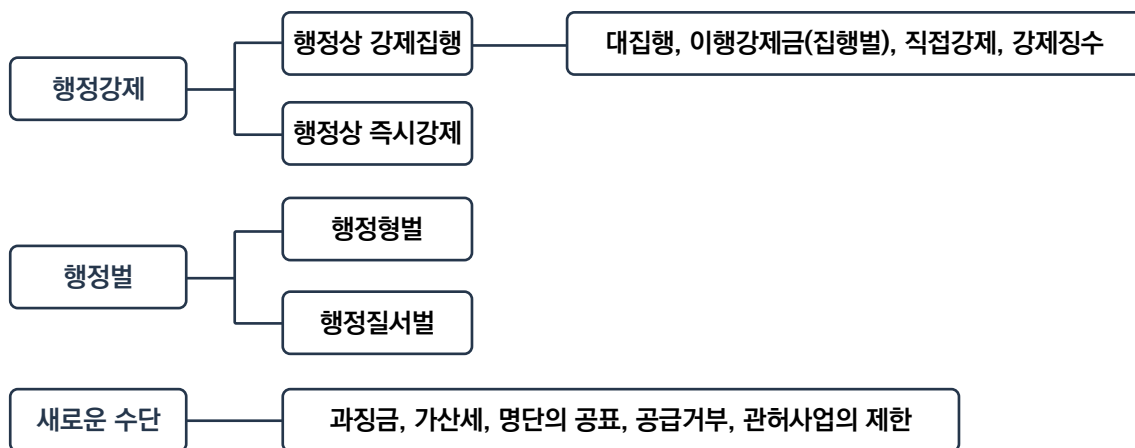
제1절

행정의 실효성 확보수단 [★]

01 개념

행정청이 공익을 목적으로 국민에게 작위·부작위 등 의무를 부과하였으나, 이를 이행하지 않는 경우 행정청이 행정목적 달성을 위하여 취하는 여러 가지 법적 수단을 행정의 실효성 확보수단이라고 한다. 여기에서 행정의 실효성이란 행정목적의 의미이며, 전통적인 수단으로 행정강제와 행정벌이 있다. 그러나 최근에는 이러한 전통적 수단만으로 행정의 실효성을 확보하기에 부족하여 그 외의 새로운 수단들이 도입되고 있는데, 여기에는 명단의 공표, 과징금 등이 있다.

02 종류



1) 행정강제

행정청은 행정목적 달성을 위해 사람의 신체나 재산에 실력을 가하여 행정상 필요한 조치를 취할 수 있는데 이러한 권력적 사실행위를 행정강제라고 한다. 행정기본법 제30조에서는 이러한 수단들을 행정상 강제라고하여 그 내용을 명문화하고 있다.

[행정기본법] 제30조 (행정상 강제)

① 행정청은 행정목적 달성을 위하여 필요한 경우에는 법률로 정하는 바에 따라 필요한 최소한의 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 할 수 있다.

1. 행정대집행: 의무자가 행정상 의무(법령등에서 직접 부과하거나 행정청이 법령등에 따라 부과한 의무를 말한다. 이하 이 절에서 같다)로서 타인이 대신하여 행할 수 있는 의무를 이행하지 아니하는 경우 법률로 정하는 다른 수단으로는 그 이행을 확보하기 곤란하고 그 불이행을 방치하면 공익을 크게 해칠 것으로 인정될 때에 행정청이 의무자가 하여야 할 행위를 스스로 하거나 제3자에게 하게 하고 그 비용을 의무자로부터 징수하는 것

2. 이행강제금의 부과: 의무자가 행정상 의무를 이행하지 아니하는 경우 행정청이 적절한 이행기간을 부여하고, 그 기한까지 행정상 의무를 이행하지 아니하면 금전급부 의무를 부과하는 것
3. 직접강제: 의무자가 행정상 의무를 이행하지 아니하는 경우 행정청이 의무자의 신체나 재산에 실력을 행사하여 그 행정상 의무의 이행이 있었던 것과 같은 상태를 실현하는 것
4. 강제징수: 의무자가 행정상 의무 중 금전급부 의무를 이행하지 아니하는 경우 행정청이 의무자의 재산에 실력을 행사하여 그 행정상 의무가 실현된 것과 같은 상태를 실현하는 것
5. 즉시강제: 현재의 급박한 행정상의 장애를 제거하기 위한 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에 행정청이 곧바로 국민의 신체 또는 재산에 실력을 행사하여 행정 목적을 달성하는 것

(1) 행정상 강제집행

행정상 강제집행이란 행정법상 의무불이행이 있는 경우 행정주체가 의무자의 신체 또는 재산에 실력을 가하여 그 의무가 이행되도록 하거나, 의무가 이행된 것과 동일한 상태를 실현시키는 작용을 말한다. 행정상 강제집행에는 대집행, 이행강제금, 직접강제, 강제징수가 있다.

구 분	내 용
대집행	대체적 작위의무(타인이 대신하여 이행할 수 있는 의무)의 불이행이 있는 경우 행정청이 그 의무를 스스로 행하거나 제3자로 하여금 이를 이행하게 하고 그 비용을 의무자로부터 징수하는 것을 말한다.
이행강제금 (집행벌)	행정법상 의무의 불이행이 있는 경우 그 의무를 강제하기 위해 일정기간을 부여하고 그 기한까지 이행하지 않으면 일정한 금전급부 의무를 부과하는 것을 말한다. 이행기간을 주고 불이행시 이행강제금을 부과한다는 뜻을 계고하여 의무자에게 심리적 압박을 가하여 간접적으로 의무를 강제시키는 수단이다.
직접강제	행정법상 의무의 불이행이 있는 경우 행정청이 직접 의무자의 신체 또는 재산에 실력을 가하여 의무자가 의무를 이행한 것과 동일한 상태를 실현하는 작용을 말한다.
강제징수	행정법상 금전급부 의무의 불이행이 있는 경우 행정청이 의무자의 재산에 실력을 가하여 행정상 의무가 실현된 것과 동일한 상태를 실현하는 작용을 말한다.

(2) 행정상 즉시강제

행정상 즉시강제란 급박한 행정상의 위험 또는 장애를 제거할 필요가 있으나 의무를 부과할 시간적 여유가 없거나, 그 성질상 의무를 명하여서는 목적을 달성할 수 없는 경우에 행정청이 직접 개인의 신체 또는 재산에 실력을 가하여 행정상 필요한 상태를 실현하는 행정작용을 말한다.

2) 행정벌

행정벌이란 행정법상의 의무를 위반한 자에게 행정주체가 행정법상의 제재로서 가하는 처벌을 말한다.
행정벌에는 행정형벌과 행정질서벌이 있다.

구 분	내 용
행정형벌	행정형벌이란 행정법규를 위반한 경우 형법에 정해져 있는 벌을 과하는 것을 말한다. 사형·징역·금고·자격상실·자격정지·벌금 등이 있으며 형벌이므로 형법과 형사소송법이 적용된다.
행정질서벌	행정질서벌이란 행정법규 위반행위 중 행정목적에 간접적으로 침해하는 비교적 가벼운 질서위반에 대해 과태료를 부과하는 행정벌을 말한다.

3) 새로운 수단

구 분	내 용
과징금	행정법규의 위반이나 법령등에 따른 의무를 위반한 자에 대하여 그 위반행위로 경제상의 이익을 얻게 되는 경우 그러한 경제적 이익의 박탈을 위하여 부과·징수하는 금전을 말한다. (「행정기본법」 제28조 제1항)
가산세	「국세기본법」 및 「세법」에서 규정하는 신고 등 의무의 성실한 이행을 확보하기 위하여 그 법에 따라 산출된 세액에 가산하여 징수하는 금액을 말한다.
명단의 공표	명단의 공표란 행정법상 의무의 위반 또는 불이행이 있는 경우에 그 위반자의 성명, 위반사실 등을 일반에게 공개하여 명예 또는 신용에 침해를 가하여 행정법상 의무를 이행하도록 심리적 압박을 가하는 간접강제수단을 말한다.
공급거부	행정법상의 의무를 위반하거나 불이행한 자에 대하여 행정상의 서비스나 재화의 공급을 거부하는 행위를 말한다.
관허사업의 제한	행정법상의 의무를 위반하거나 불이행한 자에 대하여 각종 인·허가를 거부, 정지, 철회함으로써 행정법상 의무준수 또는 의무이행을 간접적으로 강제하는 것을 말한다.

01 의의 및 근거

대체적 작위의무(타인이 대신하여 이행할 수 있는 의무)의 불이행이 있는 경우 행정청이 그 의무를 스스로 행하거나 제3자로 하여금 이를 이행하게 하고 그 비용을 의무자로부터 징수하는 것을 말한다. 대집행의 일반법으로 행정 대집행법이 있으며 토지보상법 제89조에도 대집행에 대한 규정이 있다.

02 요건 (「행정대집행법」 제2조)

[행정대집행법] 제2조 (대집행과 그 비용징수)

법률(법률의 위임에 의한 명령, 지방자치단체의 조례를 포함한다. 이하 같다)에 의하여 직접명령되었거나 또는 법률에 의거한 행정청의 명령에 의한 행위로서 타인이 대신하여 행할 수 있는 행위를 의무자가 이행하지 아니하는 경우 다른 수단으로써 그 이행을 확보하기 곤란하고 또한 그 불이행을 방지함이 심히 공익을 해할 것으로 인정될 때에는 당해 행정청은 스스로 의무자가 하여야 할 행위를 하거나 또는 제삼자로 하여금 이를 하게 하여 그 비용을 의무자로부터 징수할 수 있다.

1) 공법상 의무의 불이행

대집행의 대상이 되는 의무는 공법상의 의무이다. 사법상의 의무는 법령에 특별한 규정이 없는 한 대집행의 대상이 되지 않는다. 대집행의 대상이 되는 공법상 의무는 법령에 의해 직접 명해지는 것도 있고(「토지보상법」 제43조), 법률에 의한 행정행위에 의해 명해질 수도 있다(철거명령, 위험물 제거명령).

대법원 2006. 10. 13. 선고, 2006두7096, 판결

토지 등의 협의취득은 공공사업에 필요한 토지 등을 그 소유자와의 협의에 의하여 취득하는 것으로서 공공기관이 사경제주체로서 행하는 사법상 매매 내지 사법상 계약의 실질을 가지는 것이므로, 그 협의취득시 건물소유자가 매매대상 건물에 대한 철거의무를 부담하겠다는 취지의 약정을 하였다고 하더라도 이러한 철거의무는 공법상의 의무가 될 수 없고, 이 경우에도 행정대집행법을 준용하여 대집행을 허용하는 별도의 규정이 없는 한 위와 같은 철거의무는 행정대집행법에 의한 대집행의 대상이 되지 않는다.

2) 대체적 작위의무의 불이행

대집행의 대상이 되는 의무는 공법상 의무로서 대체적 작위의무이어야 한다. 대체적 작위의무란 누구나 이행을 하여 타인이 대신 행할 수 있는 의무를 말한다. 따라서 일신전속적인 성질이 강하거나(병역의무) 고도의 개인적 기술·지능을 요하는 작위의무, 부작위의무는 대체성이 없으므로 대집행의 대상이 되지 못한다. 부작위의무는 철거명령 등을 통하여 작위의무로 전환시킨 뒤에 그 철거명령에 대한 불이행이 있는 경우 대집행이 가능하다. 또한 토지·건물의 인도 의무에서 사람이 그 인도·이전을 거부한다면 이는 사람을 실력으로 배제해야 하는 것이므로(대체적 작위의무가 아님) 대집행의 대상이 될 수 없다.

대법원 1998. 10. 23. 선고 97누157 판결

도시공원시설인 매점의 관리청이 그 공동점유자 중의 1인에 대하여 소정의 기간 내에 위 매점으로부터 퇴거하고 이에 부수하여 그 판매 시설물 및 상품을 반출하지 아니할 때에는 이를 대집행하겠다는 내용의 계고처분은 그 주된 목적이 매점의 원형을 보존하기 위하여 점유자가 설치한 불법 시설물을 철거하고자 하는 것이 아니라, 매점에 대한 점유자의 점유를 배제하고 그 점유이전을 받는 데 있다고 할 것인데, 이러한 의무는 그것을 강제적으로 실현함에 있어 직접적인 실행행사가 필요한 것이지 대체적 작위의무에 해당하는 것은 아니어서 직접강제의 방법에 의하는 것은 별론으로 하고 행정대집행법에 의한 대집행의 대상이 되는 것은 아니다.

3) 다른 수단으로 그 이행을 확보하기가 곤란할 것 (보충성)

행정지도 등 의무이행을 확보할 수 있는 다른 수단이 있는 경우에는 대집행이 허용되지 않는다. 여기에서 다른 수단이란 비례의 원칙이 적용되는 것으로 대집행 보다 경미한 수단을 의미한다.

4) 불이행을 방지함이 심히 공익을 해할 것

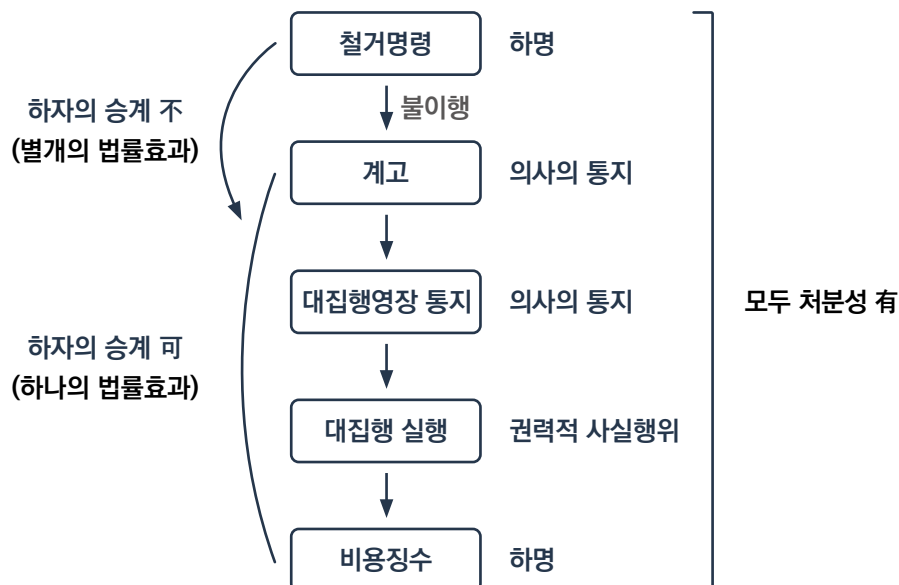
이는 비례의 원칙 중 협의의 비례의 원칙을 의미하는 것으로, 의무불이행의 정도가 경미한 경우에는 상대방의 권익보호를 위해 대집행을 할 수 없다.

대법원 1983. 7. 12. 선고 83누150 판결

철거계고처분을 받은 건물과 지방문화재인 용건능보호구역 경계사이에는 노폭 8M의 도로가 있고 위 건물을 그대로 두어도 용건능의 보존관리상 아무런 지장이 없으며 위 보호구역 내에는 다른 건물이 있는 것을 고려하면 위 건물에 대한 건축허가가 취소되었다는 사유만으로 위 건물을 방지함이 심히 공익을 해한다고 볼 수 없으므로 위 건물에 대한 계고처분은 위법하다.

03 대집행의 절차

대집행은 계고 → 대집행영장에 의한 통지 → 대집행의 실행 → 대집행의 비용징수의 4단계 절차를 거치며, 각 단계는 하자의 승계가 인정된다.



[행정대집행법] 제3조 (대집행의 절차)

- ① 전조의 규정에 의한 처분(이하 대집행이라 한다)을 하려함에 있어서는 상당한 이행기한을 정하여 그 기한까지 이행되지 아니할 때에는 대집행을 한다는 뜻을 미리 문서로써 계고하여야 한다. 이 경우 행정청은 상당한 이행기한을 정함에 있어 의무의 성질·내용 등을 고려하여 사회통념상 해당 의무를 이행하는 데 필요한 기간이 확보되도록 하여야 한다.
- ② 의무자가 전항의 계고를 받고 지정기한까지 그 의무를 이행하지 아니할 때에는 당해 행정청은 대집행영장으로써 대집행을 할 시기, 대집행을 시키기 위하여 파견하는 집행책임자의 성명과 대집행에 요하는 비용의 개산에 의한 견적액을 의무자에게 통지하여야 한다.
- ③ 비상시 또는 위험이 절박한 경우에 있어서 당해 행위의 급속한 실시를 요하여 전2항에 규정한 수속을 취할 여유가 없을 때에는 그 수속을 거치지 아니하고 대집행을 할 수 있다.

[행정대집행법] 제6조 (비용징수)

- ① 대집행에 요한 비용은 국세징수법의 예에 의하여 징수할 수 있다.
- ② 대집행에 요한 비용에 대하여서는 행정청은 사무비의 소속에 따라 국세에 다음가는 순위의 선취특권을 가진다.
- ③ 대집행에 요한 비용을 징수하였을 때에는 그 징수금은 사무비의 소속에 따라 국고 또는 지방자치단체의 수입으로 한다.

1) 계고

(1) 의의 및 성질

계고는 **상당한 기간 내에 의무를 이행하지 않으면 대집행을 한다는 뜻을 문서로써 알리는 행위**를 말한다.

상당한 기간이란 사회통념상 의무 이행에 필요한 기간을 말하는데, 의무의 성질·내용 등을 고려하여야 하며, 계고는 문서에 의하여야 한다. 계고는 **준법률행위적 행정행위로서 통지에 해당하며 항고소송의 대상**이 된다.

(2) 생략가능성 (「행정대집행법」 제3조 제3항)

법률에 다른 규정이 있거나 비상시 또는 위험이 절박한 경우에 계고절차를 거치지 않고 대집행을 할 수 있다.

(3) 관련 판례

1. 상당한 기간 위반한 계고처분은 위법

행정대집행법 제3조 제1항은 행정청이 의무자에게 대집행영장으로써 대집행할 시기 등을 통지하기 위하여는 그 전제로서 대집행계고처분을 함에 있어서 의무이행을 할 수 있는 상당한 기간을 부여할 것을 요구하고 있으므로, 행정청인 피고가 의무이행기한이 1988.5.24.까지로 된 이 사건 대집행계고서를 5.19. 원고에게 발송하여 원고가 그 이행종기인 5.24. 이를 수령하였다면, 설사 피고가 대집행영장으로써 대집행의 시기를 1988.5.27 15:00로 늦추었다더라도 위 대집행계고처분은 상당한 이행기한을 정하여 한 것이 아니어서 대집행의 적법절차에 위배한 것으로 위법한 처분이라고 할 것이다. 판례는 **상당한 기간을 부여하지 않은 경우 대집행영장으로 대집행의 시기를 늦추었다고 하더라도, 계고처분은 적법절차에 위배되어 위법하다고 보았다.** [대법원 1990. 9. 14. 선고 90누2048판결]

2. 반복된 계고처분시 2, 3차 계고의 처분성 (부정)

건물의 소유자에게 위법건축물을 일정기간까지 철거할 것을 명함과 아울러 불이행할 때에는 대집행한다는 내용의 철거 대집행 계고처분을 고지한 후 이에 불응하자 다시 제2차, 제3차 계고서를 발송하여 일정기간까지의 자진철거를 촉구하고 불이행하면 대집행을 한다는 뜻을 고지하였다면 행정대집행법상의 건물철거의무는 제1차 철거명령 및 계고처분으로서 발생하였고 제2차, 제3차의 계고처분은 새로운 철거의무를 부과한 것이 아니고 다만 대집행기한의 연기통지에 불과하므로 행정처분이 아니다. [대법원 1994. 10. 28. 선고 94누5144판결]

3. 철거명령과 계고처분의 결합가능성 (긍정)

계고서라는 명칭의 1장의 문서로서 일정기간 내에 위법건축물의 자진철거를 명함과 동시에 그 소정기한내에 자진철거를 하지 아니할 때에는 대집행할 뜻을 미리 계고한 경우라도 위 건축법에 의한 철거명령과 행정대집행법에 의한 계고처분은 독립하여 있는 것으로서 각 그 요건이 충족되었다고 볼것이고, 이 경우 철거명령에서 주어진 일정기간이 자진철거에 필요한 상당한 기간이라면 그 기간속에는 계고시에 필요한 '상당한 이행기간'도 포함되어 있다고 보아야 할 것이다. [대법원 1992. 6. 12. 선고 91누13564판결]

2) 대집행 영장에 의한 통지

(1) 의의 및 성질

대집행영장에 의한 통지란 의무자가 계고를 받고도 지정된 기한까지 그 의무를 이행하지 않을 때, 당해 행정청이 대집행영장으로써 대집행을 할 시기, 대집행책임자의 성명 및 대집행비용의 개산액을 의무자에게 알리는 것을 말한다. 이는 준법률행위적 행정행위인 통지로서 항고소송의 대상이 되는 처분에 해당한다.

(2) 생략가능성 (「행정대집행법」 제3조 제3항)

계고와 마찬가지로 법률에 다른 규정이 있거나 비상시 또는 위험이 절박한 경우에 통지 절차를 생략할 수 있다.

3) 대집행의 실행

(1) 의의 및 성질

대집행의 실행이란 의무자가 지정된 기한까지 의무를 이행하지 않는 경우에 당해 행정청 스스로 또는 제3자로 하여금 그 의무를 이행시키는 물리력의 행사를 말한다. 이는 수인하명(건물철거행위를 참고 받아 들어야 하는 의무를 부과)과 사실행위(철거행위)가 결합된 합성행위의 성질을 가지는 권력적 사실행위로서 행정처분에 해당한다.

(2) 실력행사 가능성

a. 문제점

대집행 실행에서 의무자가 수인의무(하명)를 위반하여 저항하는 경우 행정청이 실력으로 이를 배제할 수 있는지와 관련하여 명문의 규정이 없어 문제가 된다.

b. 학설

- ① 대집행에 필요한 최소한의 한도 내에서 부득이한 경우에 실력으로 그 저항을 배제 할 수 있다고 보는 <긍정설>과 ② 의무자의 저항을 실력으로 배제 하는 것은 신체에 물리력을 행사하는 것이므로 대집행에 내재 하는 권능으로 보기 어려우므로 부정하는 <부정설>이 대립한다.

c. 판례

판례는 도시공원시설인 매점에 대한 점유자의 점유를 배제하는 것은 그것을 강제적으로 실현함에 있어 직접적인 실력행사가 필요한 것이지 대체적 작위의무에 해당하는 것은 아니어서 행정대집행법에 의한 대집행의 대상이 되는 것은 아니라고 판시한 바 있다. 또한, 건물철거의무에 퇴거의무도 포함되어 있다고 보아 건물철거 대집행 과정에서 부수적으로 건물의 점유자들에 대한 퇴거 조치를 할 수 있고, 대집행을 위력을 행사하여 방해하는 경우 경찰관 직무집행법에 근거한 위험발생 방지조치 또는 형법상 공무집행방해죄의 범행방지 내지 현행범체포의 차원에서 경찰의 도움을 받을 수도 있다고 하여 직접 실력행사를 하는 것은 부정하는 입장이다.

대법원 2017. 4. 28. 선고 2016다213916 판결

건물의 점유자가 철거의무자일 때에는 건물철거의무에 퇴거의무도 포함되어 있는 것이어서 별도로 퇴거를 명하는 집행권원이 필요하지 않다. 따라서 행정청이 행정대집행의 방법으로 건물철거의무의 이행을 실현할 수 있는 경우에는 건물철거 대집행 과정에서 부수적으로 그 건물의 점유자들에 대한 퇴거 조치를 할 수 있는 것이고, 그 점유자들이 적법한 행정대집행을 위력을 행사하여 방해하는 경우 형법상 공무집행방해죄가 성립하므로, 필요한 경우에는 「경찰관 직무집행법」에 근거한 위험발생 방지조치 또는 형법상 공무집행방해죄의 범행방지 내지 현행범체포의 차원에서 경찰의 도움을 받을 수도 있다.

대법원 1998. 10. 23. 선고 97누157 판결

도시공원시설인 매점의 관리청이 그 공동점유자 중의 1인에 대하여 소정의 기간 내에 위 매점으로부터 퇴거하고 이에 부수하여 그 판매 시설물 및 상품을 반출하지 아니할 때에는 이를 대집행하겠다는 내용의 계고처분은 그 주된 목적이 매점의 원형을 보존하기 위하여 점유자가 설치한 불법 시설물을 철거하고자 하는 것이 아니라, 매점에 대한 점유자의 점유를 배제하고 그 점유이전을 받는 데 있다고 할 것인데, 이러한 의무는 그것을 강제적으로 실현함에 있어 직접적인 실력행사가 필요한 것이지 대체적 작위의무에 해당하는 것은 아니어서 직접강제의 방법에 의하는 것은 별론으로 하고 행정대집행법에 의한 대집행의 대상이 되는 것은 아니다.

d. 소결

신체에 대한 실력행사는 명문에 근거가 있어야 하고, 경찰관직무집행법 등에 따른 경찰권의 발동으로 저항이 배제될 수 있으므로 <부정설>이 타당하다.

4) 비용징수

대집행에 소요된 비용은 원칙적으로 의무자가 부담한다. 따라서 대집행 이후 이에 소요된 비용을 의무자에게 명령하여 징수하는 절차로서 비용납부명령은 하명이며 처분에 해당하여 항고소송의 대상이 된다. 의무자가 비용을 납부하지 않는 경우에는 국세징수법에 따라 강제징수 할 수 있다.

04 대집행에 대한 권리구제

1) 행정쟁송

대집행의 절차상 모든 행위는 처분성이 인정되므로, 행정심판 또는 행정소송의 제기가 가능하다. 다만, 대집행 실행이 완료된 경우에는 소의 이익이 없어 항고소송을 제기할 수 없으므로, 항고소송을 제기하면서 집행정지를 신청하여 대집행의 실행을 정지시킬 필요가 있다.

대법원 1967. 10. 23. 선고 67누115 판결

행정대집행법 제2조에 의하여 의무자에게 명령된 행위에 관하여, 동법 제3조의 계고와 대집행영장에 의한 통지 절차를 거쳐서 이미 그 대집행이 사실행위로서 실행이 완료된 이후에 있어서는 그 행위의 위법을 이유로 하는 손해배상 또는 원상회복의 청구를 하는 것은 몰라도, 그 처분의 취소를 구함은, 권리보호의 이익이 없는 것이라 할것인바, …(중략)… 대집행 실행에 의하여 철거되었음에 대하여 당사자 사이에 다툼이 없는바이니, 앞서 설명한바에 의하여 본건 계고처분의 취소를 구할 권리보호의 이익은 이미 상실되었다고할 것이어서 본건 소송은 결국 소송요건 흠결로 인하여 소 각하를 면할 수 없을 것이다.

2) 손해배상 및 결과제거청구

위법한 대집행에 의하여 손해를 입은 자는 국가나 지방자치단체를 상대로 손해배상을 청구할 수 있다.
또한 대집행 이후에 위법의 상태가 계속된다면 결과제거 청구를 주장할 수도 있다.

05 기타 논점

1) 하자의 승계 가능성

건축법상 철거명령과 행정대집행법상 대집행의 절차상 행위는 별개의 법적효과를 목적으로 하므로 하자의 승계가 부정된다. 반면에 대집행 절차인 계고, 통지, 실행 및 비용징수는 하나의 법적효과를 목적으로 하여 각각 하자의 승계가 인정된다는 것이 통설·판례의 태도이다. 다만, 철거명령이 무효인 경우에는 이를 근거한 대집행의 절차상 행위도 무효이다.

대법원 1993. 11. 9. 선고 93누14271 판결

대집행의 계고·대집행영장에 의한 통지·대집행의 실행·대집행에 요한 비용의 납부명령 등은, 타인이 대신하여 행할 수 있는 행정의무의 이행을 의무자의 비용부담하에 확보하고자 하는, 동일한 행정목적을 달성하기 위하여 단계적인 일련의 절차로 연속하여 행하여지는 것으로서, 서로 결합하여 하나의 법률효과를 발생시키는 것이므로, 선행처분인 계고처분이 하자가 있는 위법한 처분이라면, 비록 하자가 중대하고도 명백한 것이 아니어서 당연무효의 처분이라고 볼 수 없고 대집행의 실행이 이미 사실행위로서 완료되어 계고처분의 취소를 구할 법률상 이익이 없게 되었으며, 또 대집행비용 납부명령 자체에는 아무런 하자가 없다 하더라도, 후행처분인 대집행비용납부명령의 취소를 청구하는 소송에서 청구원인으로 선행처분인 계고처분이 위법한 것이기 때문에 그 계고처분을 전제로 행하여진 대집행비용납부명령도 위법한 것이라는 주장을 할 수 있다.

2) 이행강제금과의 관계

건축법에서는 행정상 강제집행수단으로 대집행과 이행강제금 모두를 규정하고 있다.

이와 관련하여 헌법재판소는 양자를 선택적으로 활용할 수 있으며, 이를 중첩적 제재에 해당한다고 보지는 않는다.

건축법 위반자에 대하여 이행강제금을 부과함으로써 시정명령에 응할 것을 강제하고 있으므로 적절한 수단이 된다. 또한 개별사건에 있어서 위반내용, 위반자의 시정 의지 등을 감안하여 허가권자는 행정대집행과 이행강제금을 선택적으로 활용할 수 있고, 행정대집행과 이행강제금 부과가 동시에 이루어지는 것이 아니라 허가권자의 합리적인 재량에 의해 선택하여 활용하는 이상 이를 중첩적인 제재에 해당한다고 볼 수 없으며, 이행강제금은 위법건축물의 원상회복을 궁극적인 목적으로 하고, 그 궁극적인 목적을 달성하기 위해서는 위법건축물이 존재하는 한 계속하여 부과할 수밖에 없으며, 만약 통산 부과횟수나 통산 부과상한액의 제한을 두면 위반자에게 위법건축물의 현상을 고착할 수 있는 길을 열어 주게 됨으로써 이행강제금의 본래의 취지를 달성할 수 없게 되므로 이 사건 법률조항에서 이행강제금의 통산 부과횟수나 통산 부과상한액을 제한하는 규정을 두고 있지 않다고 하여 침해 최소성의 원칙에 반한다고 할 수는 없다. 그리고 이 사건 법률조항에 의하여 위반자는 위법건축물의 사용·수익·처분 등에 관한 권리가 제한되지만, 건축물의 안전과 기능, 미관을 향상시켜 공공복리의 증진을 도모하고자 하는 공익이 훨씬 크다고 할 것이므로, 이 사건 법률조항은 법익 균형성의 원칙에 위배되지 아니한다. 따라서 이 사건 법률조항은 과잉금지의 원칙에 위배되지 아니하므로 위반자의 재산권을 침해하지 아니한다.

3) 「토지보상법」의 인도·이전의무의 대집행 가능성 [★★★]

(1) 문제점

인도란 물건에 대한 점유를 이전시키는 것을 의미하므로, 점유자의 퇴거가 요구되고, 퇴거는 대체적 작위의무라 할 수 없으므로 대집행의 대상이 될 수 없다. 그런데 토지보상법 제89조에서는 대집행을 규정하고 있어, 해당 규정을 토지 또는 물건의 인도·이전에 대해 대집행을 인정하는 특별규정으로 보아야 하는지 견해가 대립한다.

(2) 학설

① 대집행이 불가능하다고 보는 것은 토지보상법 제89조를 무의미 하게 하는 것이므로 해당 규정을 합리적·합목적적으로 해석하여 대집행이 가능하다고 보는 <긍정설>과 ② 인도 의무는 실력으로 점유를 배제시키는 직접강제에 해당한다고 보아 대집행을 부정하는 <부정설>이 대립한다.

(3) 판례

인도의무는 그것을 강제적으로 실현하면서 직접적인 실력행사가 필요한 것이지 대체적 작위의무라고 볼 수 없으므로, 특별한 사정이 없는 한 대집행의 대상이 될 수 있는 것은 아니라고 하여 <부정설>의 입장을 취한다.

'인도'에는 명도도 포함되는 것으로 보아야 하고, 이러한 명도의무는 그것을 강제적으로 실현하면서 직접적인 실력행사가 필요한 것이지 대체적 작위의무라고 볼 수 없으므로 특별한 사정이 없는 한 행정대집행법에 의한 대집행의 대상이 될 수 있는 것이 아니다.

(4) 소결

「토지보상법」 제89조 제1항에서는 '「행정대집행법」에서 정하는 바에 따라 대집행을 신청할 수 있다'고 규정하고 있다. 이에 해당 규정을 행정대집행법의 특례 규정으로 보기 어렵고, 인도 의무는 직접적인 실력행사가 필요하므로, 특별한 사정이 없는 한 대집행의 대상이 될 수 없다고 보는 <부정설>이 타당하다.

01 의의 및 근거

과징금이란 행정법규의 위반이나 법령등에 따른 의무를 위반한 자에 대하여 그 위반행위로 경제상의 이익을 얻게 되는 경우 그러한 경제적 이익의 박탈을 위하여 부과·징수하는 금전을 말한다. 행정기본법 제28조에 근거가 있으며, 감정평가법 제41조 내지 제44조 등 개별법에서 그 근거를 두고 있다.

[행정기본법] 제28조 (과징금의 기준)

- ① 행정청은 법령등에 따른 의무를 위반한 자에 대하여 법률로 정하는 바에 따라 그 위반행위에 대한 제재로서 과징금을 부과할 수 있다.

[감정평가법] 제41조 (과징금의 부과)

- ① 국토교통부장관은 감정평가법인등이 제32조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 되어 업무정지처분을 하여야 하는 경우로서 그 업무정지처분이 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제3조에 따른 표준지공시지가의 공시 등의 업무를 정상적으로 수행하는 데에 지장을 초래하는 등 공익을 해칠 우려가 있는 경우에는 업무정지처분을 갈음하여 5천만원(감정평가법인인 경우는 5억원) 이하의 과징금을 부과할 수 있다. 전액을 일시에 납부하기 어렵다고 인정될 때에는 그 납부기한을 연장하거나 분할납부하게 할 수 있다. 이 경우 필요하다고 인정할 때에는 담보를 제공하게 할 수 있다.

02 종류**1) 본래적 과징금**

본래적 의미의 과징금은 행정법상의 의무위반으로 인하여 얻은 경제적 이익을 박탈하는 금전적 제재를 말한다. 따라서 과징금 액수는 이득액의 규모 등과 상호 균형을 이룰 것이 요구된다는 것이 판례의 입장이다.

2) 변형된 과징금

변형된 과징금이란 영업정지 등에 갈음하여 과징금을 부과하는 것을 말한다.

즉, 의무위반행위가 사업의 인·허가 등을 철회하거나 정지시킬 사유에 해당하지만 그 사업을 철회·정지시킬 경우 초래되는 공익 또는 사익의 침해를 이유로 정지 등의 처분 대신에 과징금을 부과하는 것을 말한다.

감정평가법 제41조의 과징금이 여기에 해당한다.

03 법적성질 (처분, 재량행위)

과징금부과행위는 행정행위로서 급부하명의의 성격을 가지며 행정소송의 대상이 되는 처분이다.

또한 통상 영업정지처분을 할 것인지 과징금을 부과할 것인지는 행정청의 재량에 속하는 것으로 본다.

감정평가법 제41조 제1항에서도 ‘~부과할 수 있다’고 규정하여 문언상 재량행위로 볼 수 있다.

구 영유아보육법 제45조 제1항 제1호, 제4항, 제45조의2 제1항, 구 영유아보육법 시행규칙(2013. 8. 5. 보건복지부령 제202호로 개정되기 전의 것) 제38조 [별표 9]의 문언·취지·체계 등에 비추어, 구 영유아보육법 제45조 제1항 각 호의 사유가 인정되는 경우, 행정청에는 운영정지 처분이 영유아 및 보호자에게 초래할 불편의 정도 또는 그 밖에 공익을 해칠 우려가 있는지 등을 고려하여 어린이집 운영정지 처분을 할 것인지 또는 이에 갈음하여 과징금을 부과할 것인지를 선택할 수 있는 재량이 인정된다.

04 위법한 과징금 부과 처분 (일부취소 가능성 - 부정)

과징금 부과처분은 행정청에 재량이 인정되는 재량행위이다. 따라서 위법한 과징금 부과처분을 한 경우 해당 과징금 부과 처분을 전부 취소하여야 하는지, 아니면 법상 한도를 초과한 부분만을 취소할 수 있는지가(일부취소) 문제 된다. 이에 대하여 법원은 **재량행위인 과징금의 경우 초과한 과징금 부분만을 취소할 수는 없고 그 전부를 취소하여야 한다고** 판시한 바 있다.

05 이중징과 가능성 [★★]

1) 문제점

헌법 제13조 제1항에서는 ‘~동일한 범죄에 대하여 거듭 처벌받지 아니한다’고 규정하고 있다. 따라서 **동일한 위반행위에** 대해 행정벌과 과징금을 병과하는 것이 **이중처벌금지 원칙**에 반하는 것이 아닌지가 문제 된다.

2) 학설

- ① 행정벌과 과징금은 그 **성질과 목적에 차이가** 있어 병과가 이중처벌금지 원칙에 반하는 것은 아니라고 보는 견해와
- ② **동일한 위반행위에 대한 제재로 보아** 과징금 등이 다른 법적 형식을 취하고 있더라도 병과가 불가능하다고 보는 견해가 있다.

3) 판례

판례는 행정벌과 과징금을 병과하는 것을 이중처벌로 보지 아니하는 입장이다.

과징금은 그 취지와 기능, 부과 주체와 절차 등을 종합할 때 부당지원행위의 억지(抑止)라는 행정목적 실현하기 위한 입법자의 정책적 판단에 기하여 그 위반행위에 대하여 제재를 가하는 행정상의 제재금으로서의 기본적인 성격에 부당이득환수적 요소도 부가되어 있는 것이라고 할 것이어서 그것이 헌법 제13조 제1항에서 금지하는 국가형벌권 행사로서의 처벌에 해당한다고 할 수 없으므로 구 독점규제및공정거래에관한법률에서 형사처벌과 아울러 과징금의 부과처분을 할 수 있도록 규정하고 있다 하더라도 **이중처벌금지원칙이나 무죄추정원칙에 위반된다거나 사법권이나 재판청구권을 침해한다고 볼 수 없다.**

01 의미

명단의 공표란 행정법상 의무의 위반 또는 불이행이 있는 경우에 그 위반자의 성명, 위반사실 등을 일반에게 공개하여 명예 또는 신용에 침해를 가하여 행정법상 의무를 이행하도록 심리적 압박을 가하는 간접강제수단을 말한다.

명단의 공표는 개인의 명예와 신용의 침해를 초래하므로 법에 근거가 있는 경우에 한하여 가능하다.

감정평가법 제39조의2에서 징계의 공고가 명단의 공표에 해당한다.

[감정평가법] 제39조의2 (징계의 공고)

- ① 국토교통부장관은 제39조제1항 및 제2항에 따라 징계를 한 때에는 지체 없이 그 구체적인 사유를 해당 감정평가사, 감정평가법인등 및 협회에 각각 알리고, 그 내용을 대통령령으로 정하는 바에 따라 관보 또는 인터넷 홈페이지 등에 게시 또는 공고하여야 한다.
- ② 협회는 제1항에 따라 통보받은 내용을 협회가 운영하는 인터넷홈페이지에 3개월 이상 게재하는 방법으로 공개하여야 한다.
- ③ 협회는 감정평가를 의뢰하려는 자가 해당 감정평가사에 대한 징계 사실을 확인하기 위하여 징계 정보의 열람을 신청하는 경우에는 그 정보를 제공하여야 한다.

02 법적성질

명단의 공표는 불명예 또는 영업상 불이익이라는 간접적·심리적 강제에 의해 행정상 의무이행을 확보하려는 것으로 사실행위이지 의사표시를 요소로 하는 법적 행위는 아니다. 따라서 법적 효과가 발생하지 않으므로 비권력적 사실행위로 보는 것이 일반적이다. 다만, 프라이버시권 등이 침해된다는 점을 근거로 권력적 사실행위라고 보는 견해도 있다.

03 권리구제

1) 행정쟁송 (처분성 여부)

(1) 학설

학설은

- ① 명단의 공표를 비권력적 사실행위로 보아 처분성을 부정하는 견해,
- ② 비권력적 사실행위로 보면서도 형식적 행정행위 관념을 전제로 처분성을 긍정하는 견해,
- ③ 권력적 사실행위로 보아 처분성을 긍정하는 견해 등이 있다.

(2) 판례

판례는 명단공표를 공권력 행사로 보면서도 공개라는 사실행위는 행정결정의 집행행위로 보고 있는 점에서 명단공표를 사실행위로 보지 않고 행정행위(일반처분)로 보고 있는 것으로 보인다(박균성 교수님).

(3) 소결

공표는 순수한 사실행위일 뿐이며 수인의무를 수반하는 권력적 사실행위로 보기는 어렵다. 따라서 행정쟁송의 대상에 해당한다고 볼 수 없으나, 예외적으로 공표의 내용이 처분의 실질을 담고 있다면 처분성을 긍정하여 행정쟁송으로 다룰 수 있게 함이 타당하다.

2) 손해배상청구 등

위법한 공표에 대해 손해배상청구가 가능하며, 손해배상청구는 명단 공표에 대한 취소소송과 관련청구소송으로서 병합하여 제기 할 수 있다(행정소송법 제10조 제2항). 또한 공표철회, 정정요구 등 시정조치를 구하는 이행소송을 공법상 당사자소송으로 제기할 수 있으나, 판례는 이를 인정하지 않는다.

01 개념

행정조사는 행정기관이 정책을 결정하거나 직무를 수행하는 데 필요한 정보나 자료를 수집하기 위하여 현장조사·문서열람·시료채취 등을 하거나 조사대상자에게 보고요구·자료제출요구 및 출석·진술요구를 행하는 활동으로 「행정조사기본법」 제2조에서 정의하고 있다.

02 법적성질

행정조사는 비권력적 조사와 권력적 조사로 구별되고 그 형식은 사실행위의 형식을 취한다. 따라서 비권력 조사는 비권력적 사실행위이고, 권력적 조사는 권력적 사실행위로서 항고소송의 대상이 된다. 행정상 즉시강제는 행정상 필요한 상태의 실현을 목적으로 하고, 행정조사는 행정상 필요한 자료를 수집하여 적정한 행정을 하도록 준비하는데에 그 목적이 있어 양자는 구별된다.

03 실행가능성 [★]

1) 문제점

행정조사를 함에 있어 상대방이 조사를 거부하거나 방해하는 경우에 당해 공무원이 실력으로 이를 억압하고 강제 조사를 할 수 있는지가 문제 된다.

2) 학설

- ① 조사의 거부·방해가 있는 경우에 대한 제재 규정이 있는 것은 거부·방해 등이 위법하다는 것을 전제한 것이므로 비례의 원칙 내에서 실행가능성이 가능하다고 보는 <긍정설>.
- ② 제재규정은 간접적인 실효성 확보 수단에 불과하므로 실행가능성은 허용되지 않는다고 보는 <부정설> 및
- ③ 원칙적으로는 허용되지 않으나 예외적으로 행정조사의 필요성이 긴급하고, 다른 수단이 없는 경우에 한하여 허용된다고 보는 <제한적 긍정설>이 있다.

3) 소결

국민의 신체나 재산에 실력을 행사하는 것은 법치주의 관점에서 인정될 수 없으므로 명문의 근거가 없는 한 실행가능성을 할 수 없다고 보는 <부정설>이 타당하다.

04 위법한 행정조사에 기한 행정행위의 효력【★】

1) 문제점

행정조사는 필요한 정보나 자료를 수집하는 활동으로 **조사 그 자체를 목적으로** 하는 것이지 어떠한 행정결정을 하기 위해 **선행되는 전제요건이 아니다**. 따라서 절차상 하자가 있거나 비례의 원칙에 위반되는 **위법한 행정조사**가 행해졌고, 이에 근거하여 행정결정이 이루어진 경우 그러한 **행정결정이 위법한지**가 문제 된다.

2) 학설

- ① **적법절차의 원칙**에 비춰 위법한 행정조사에 기초한 행정행위는 위법하다고 보는 <적극설>,
- ② 법령에서 행정행위의 전제요건으로서 행정조사를 규정하고 있는 경우를 제외하고는 양자는 **일응 별개의 제도**이므로 조사의 위법이 행정행위를 위법하게 만들지는 않는다고 보는 <소극설>,
- ③ 행정조사와 행정결정이 **하나의 과정**을 구성하고 있는 경우로서 **행정조사에 중대한 위법사유**가 있다면 행정행위도 위법하다고 보는 <절충설>이 있다.

3) 판례

판례는 **위법한 세무조사에 기한 과세처분**은 위법하다고 하였으나, **행정조사의 하자가 경미한 경우에는** 그에 기초한 행정행위가 **위법하다고** 까지는 할 수 없다고 판시한 바 있다.

대법원 2016. 12. 15. 선고 2016두47659 판결

이 사건 세무조사는 구 국세기본법 제81조의6에서 정한 세무조사 대상 선정사유에 해당하지 아니함에도 세무조사권을 남용하여 이루어진 것으로 위법하고, 이 사건 처분도 **위법한 세무조사를 통하여 수집한 과세자료에 기초하여 이루어진 것으로서 적법절차의 원칙에 위반되어 위법하므로 취소되어야 한다고** 판단하였다.

대법원 2009. 1. 30. 선고 2006두9498 판결

토양오염공정시험방법은 행정기관 내부의 사무처리준칙을 정한 행정규칙에 해당하고, 채취된 시료의 대상지역 토양에 대한 대표성을 전혀 인정할 수 없을 정도로 그 위반의 정도가 **중대한 경우가 아니라면**, 토양오염공정시험방법에 규정된 내용에 위반되는 방식으로 시료를 채취하였다는 사정만으로는 **그에 기초하여 내려진 토양정밀조사명령이 위법하다고 할 수 없다고** 한 다음 …(중략)… 원심의 사실인정과 판단은 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유 주장과 같은 채증법칙 위배, 토양환경보전법 및 토양오염공정시험방법의 해석에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

4) 소결

적법절차의 원칙에 따라 행정결정은 적법하고 정당한 절차를 거쳐야 한다.

따라서 **위법한 행정조사에 기초한 행정결정은 위법하다고** 보는 <적극설>이 타당하다.

이는 행정조사가 단지 예비적인 작용으로서 행해지는 경우에도 마찬가지이다.

PART 04

행정구제법

Chapter 01 개설

Chapter 02 행정심판

Chapter 03 행정소송

제1절 행정구제의 개념

행정구제란 행정주체의 행정권행사로 인해 권리나 이익이 침해되었다고 주장하는 자가 행정기관이나 법원을 통해 그 침해에 대한 손해전보 또는 당해 행정작용의 취소·변경 등을 청구하는 절차를 의미한다. 행정구제는 국민의 기본권과 법치행정의 원칙을 보장하기 위한 수단이며, 그 종류로는 행정상 손해전보(손해배상, 손실보상)와 행정쟁송 등이 있다.

제2절 행정구제의 종류

1) 행정쟁송

행정쟁송이란 행정법관계에서 위법·부당한 행정작용으로 권리나 이익을 침해당한 자가 국가기관에 이익을 제기하여 위법·부당한 행정작용을 심리·판정하는 절차를 말한다. 오늘날 행정쟁송은 행정심판과 행정소송을 총칭하는 개념으로 사용된다.

2) 손해전보

행정상 손해전보란 행정작용으로 인해 발생한 국민의 재산상 손해 또는 손실을 보전하는 제도를 말한다. 그 원인행위의 형태에 따라 크게 손해배상(국가배상)과 손실보상으로 구분할 수 있다.

행정구제	행정쟁송	행정심판	취소심판 무효등확인심판 의무이행심판		
		행정소송	주관적 소송	항고소송	취소소송 무효등확인소송 부작위위법확인소송
				무명항고소송	의무이행소송 예방적 부작위소송
			객관적 소송	민중소송	
				기관소송	
		손해전보	손해배상		
			손실보상		
	헌법소원, 결과제거청구권 등				

제1절

개념

행정심판이란 행정청의 위법 또는 부당한 처분 또는 부작위로 인해 권리나 이익을 침해당한 자가 행정심판위원회에 그 시정을 구하고, 행정심판위원회가 재결을 행하는 절차를 말한다. 행정심판에 대한 일반법으로는 「행정심판법」이 있고, 개별법률에서 행정심판에 대한 특별 규정을 두기도 한다.

제2절

이의신청과 행정심판

01 이의신청의 개념 및 근거

이의신청은 행정청의 위법·부당한 처분으로 인해 권리나 이익이 침해된 자가 통상 처분청에 제기하는 처분에 대한 불복절차를 말한다. 이의신청에 대한 일반법으로 「행정기본법」 제36조가 있고, 그 밖의 개별법령에서 이의신청에 관해 규정하고 있는 경우도 있다. 「행정기본법」 제36조에서는 「행정심판법」상 처분을 이의신청의 대상으로 한다고 규정하고 있으며, 개별법률에 다른 규정이 있는 경우는 처분 이외의 행정작용에 대한 이의신청도 인정될 수 있다.

【행정기본법】 제36조 (처분에 대한 이의신청)

- ① 행정청의 처분(「행정심판법」 제3조에 따라 같은 법에 따른 행정심판의 대상이 되는 처분을 말한다. 이하 이 조에서 같다)에 이의가 있는 당사자는 처분을 받은 날부터 30일 이내에 해당 행정청에 이의신청을 할 수 있다.
- ② 행정청은 제1항에 따른 이의신청을 받으면 그 신청을 받은 날부터 14일 이내에 그 이의신청에 대한 결과를 신청인에게 통지하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 14일 이내에 통지할 수 없는 경우에는 그 기간을 만료일 다음 날부터 기산하여 10일의 범위에서 한 차례 연장할 수 있으며, 연장 사유를 신청인에게 통지하여야 한다.
- ③ 제1항에 따라 이의신청을 한 경우에도 그 이의신청과 관계없이 「행정심판법」에 따른 행정심판 또는 「행정소송법」에 따른 행정소송을 제기할 수 있다.
- ④ 이의신청에 대한 결과를 통지받은 후 행정심판 또는 행정소송을 제기하려는 자는 그 결과를 통지받은 날(제2항에 따른 통지기간 내에 결과를 통지받지 못한 경우에는 같은 항에 따른 통지기간이 만료되는 날의 다음 날을 말한다)부터 90일 이내에 행정심판 또는 행정소송을 제기할 수 있다.
- ⑤ 다른 법률에서 이의신청과 이에 준하는 절차에 대하여 정하고 있는 경우에도 그 법률에서 규정하지 아니한 사항에 관하여는 이 조에서 정하는 바에 따른다.

02 이의신청과 행정심판의 구별 [★★]

1) 구별실익

행정심판의 성격을 갖는 이의신청은 「행정심판법」이 적용된다. 따라서 행정심판의 성격을 갖는 이의신청을 거친 후에 다시 「행정심판법」상 행정심판을 청구하는 것은 허용되지 않는다(「행정심판법」 제51조). 반면에 행정심판의 성격을 갖지 않는 이의신청은 이를 거친 후 다시 「행정심판법」상 행정심판을 청구할 수 있다(「행정기본법」 제36조 제3항). 따라서 양자를 구별하는 것에 실익이 있다.

[행정심판법] 제51조 (행정심판 재청구의 금지)

심판청구에 대한 재결이 있으면 그 재결 및 같은 처분 또는 부작위에 대하여 다시 행정심판을 청구할 수 없다.

대법원 1993. 12. 24. 선고 92누17204 판결

토지소유자 및 이해관계인이 개별토지가격결정에 대하여 재조사청구를 하지 않고 바로 행정심판법 소정의 행정심판을 제기하거나 또는 재조사청구를 하여 결과통지를 받은 후 다시 행정심판법 소정의 행정심판을 제기하여 그 재결을 거쳐 행정소송을 제기하는 것이 가능하고, 개별토지가격결정에 대하여 재조사청구를 하여 재조사 결과통지를 받은 자는 별도의 행정심판절차를 거치지 않더라도 곧바로 행정소송을 제기할 수 있다.

2) 구별기준

(1) 학설

- ① 심판기관을 기준으로 이의신청을 제기하는 기관이 처분청인 경우에는 단순 이의신청으로 보고, 처분청이 아닌 상급행정청이나 행정심판위원회에 제기하는 이의신청은 행정심판의 성격을 갖는 이의신청으로 보는 <심판기관기준설>과
- ② 헌법 제107조 제3항에 의거 개별법률에서 준사법절차가 보장되는 것은 행정심판의 성격을 갖는 이의신청으로 보고, 그렇지 않은 경우는 단순 이의신청으로 보는 <불복절차기준설> 등이 있다.

(2) 판례

판례는 단순 이의신청과 행정심판을 구별하는 기준으로 절차 및 담당기관에 차이가 있다는 점을 고려하여 판단한 바 있다.

(3) 소결

헌법 제107조 제3항에서 행정심판은 사법절차가 준용되어야 한다고 규정하고 있는 점 등에 비춰 불복절차를 기준으로 양자를 구별하는 <불복절차기준설>이 타당하다.

대법원 2010. 1. 28. 선고 2008두19987 판결

부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률 제12조, 행정소송법 제20조 제1항, 행정심판법 제3조 제1항의 규정 내용 및 취지와 아울러 부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률에 행정심판의 제기를 배제하는 명시적인 규정이 없고 부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률에 따른 이의신청과 행정심판은 그 절차 및 담당 기관에 차이가 있는 점을 종합하면, 부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률이 이의신청에 관하여 규정하고 있다고 하여 이를 행정심판법 제3조 제1항에서 행정심판의 제기를 배제하는 '다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우'에 해당한다고 볼 수 없으므로, 개별공시지가에 대하여 이의가 있는 자는 곧바로 행정소송을 제기하거나 부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률에 따른 이의신청과 행정심판법에 따른 행정심판청구 중 어느 하나만을 거쳐 행정소송을 제기할 수 있을 뿐 아니라,

이의신청을 하여 그 결과 통지를 받은 후 다시 행정심판을 거쳐 행정소송을 제기할 수도 있다고 보아야 하고, 이 경우 행정소송의 제소기간은 그 행정심판 재결서 정본을 송달받은 날부터 기산한다.

03 이의신청에 대한 불복

단순 이의신청에 대한 처분청의 결정에 다시 불복하는 경우 그 불복 대상이 문제 된다.

먼저 ① 이의신청을 받아들여 원처분을 취소하는 처분은 **직권취소**이고, 변경하는 결정은 **변경처분**이므로 그 **직권취소**와 **변경처분**이 **행정심판 또는 행정소송의 대상**이 된다. 반면에 ② 이의신청을 기각하는 결정은 **종전 처분**을 유지하는 것으로 독립된 처분의 성격을 갖지 않아 **행정쟁송의 대상**이 될 수 없다. 또한, ③ 이의신청의 일부만을 받아들여 **일부취소**를 하는 경우는 **변경**되고 남은 원처분이 **행정쟁송의 대상**이 될 수 있다(견해 대립).

대법원 2016. 7. 27. 선고 2015두45953 판결

「국가유공자법」 제4조 제1항 제6호, 제6조 제3항, 제4항, 제74조의18의 문언 취지 등에 비추어 알 수 있는 다음과 같은 사정, 즉 국가유공자법 제74조의18 제1항이 정한 **이의신청**은, 국가유공자 요건에 해당하지 아니하는 등의 사유로 국가유공자 등록 신청을 거부한 **처분청인** 국가보훈처장이 신청 대상자의 신청 사항을 **다시 심사하여** 잘못이 있는 경우 **스스로 시정하도록 한** 절차인 점, 이의신청을 받아들이는 것을 **내용으로 하는 결정**은 당초 국가유공자 등록신청을 받아들이는 **새로운 처분**으로 볼 수 있으나, 이와 달리 이의신청을 받아들이지 아니하는 **내용의 결정**은 **종전의 결정 내용을 그대로 유지하는 것에 불과한 점**, 보훈심사위원회의 심의·의결을 거치는 것도 최초의 국가유공자 등록신청에 대한 결정에서나 이의신청에 대한 결정에서 마찬가지로 거치도록 규정된 절차인 점, 이의신청은 원결정에 대한 행정심판이나 행정소송의 제기에도 영향을 주지 아니하는 점 등을 종합하면, 국가유공자법 제74조의18 제1항이 정한 **이의신청을 받아들이지 아니하는 결정**은 이의신청인의 **권리·의무에 새로운 변동**을 가져오는 **공권력의 행사나 이에 준하는 행정작용**이라고 할 수 없으므로 원결정과 별개로 **항고소송의 대상**이 되지는 않는다.

[처분의 재심사]

처분의 재심사란 **처분의 불복기간 경과** 등으로 행정심판, 행정소송 등 쟁송을 통해 **더 이상 다룰 수 없게 된 경우**로서 일정한 사유가 발생하면 당사자는 **처분을 한 행정청에 처분의 취소·철회 또는 변경의 신청**을 할 수 있고, 이에 따라 **처분청이 처분을 재심사하는 것**을 말한다. 처분의 재심사는 법적 안정성을 침해하는 성격을 가지므로 법적근거가 필요하고, 「행정기본법」 제37조가 처분의 재심사에 대한 근거 규정이 된다.

[행정기본법] 제37조 (처분의 재심사)

- ① 당사자는 처분(제재처분 및 행정상 강제는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)이 행정심판, 행정소송 및 그 밖의 쟁송을 통하여 다룰 수 없게 된 경우(법원의 확정판결이 있는 경우는 제외한다)라도 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 처분을 한 행정청에 처분을 취소·철회하거나 변경하여 줄 것을 신청할 수 있다.
1. 처분의 근거가 된 사실관계 또는 법률관계가 추후에 당사자에게 유리하게 바뀐 경우
 2. 당사자에게 유리한 결정을 가져다주었을 새로운 증거가 있는 경우
 3. 「민사소송법」 제451조에 따른 재심사유에 준하는 사유가 발생한 경우 등 대통령령으로 정하는 경우

01 행정심판의 종류 [★]

1) 취소심판 (「행정심판법」 제5조 제1호)

취소심판은 행정청의 위법 또는 부당한 처분을 취소하거나 변경하는 행정심판을 말한다.

행정심판의 중심을 이루는 것으로, 「행정심판법」은 취소심판을 중심으로 구성되어 있다.

취소심판에서의 '변경'은 적극적 변경(영업취소처분을 영업정지처분으로 변경)을 의미한다.

2) 무효등확인심판 (「행정심판법」 제5조 제2호)

무효등확인심판은 행정청의 처분의 효력 유무 또는 존재 여부를 확인하는 행정심판을 말한다.

무효등에는 무효, 유효, 실효, 존재 및 부존재가 모두 포함된다.

무효등확인심판에는 무효확인심판, 유효확인심판, 실효확인심판, 존재확인심판 및 부존재확인심판이 있다.

3) 의무이행심판 (「행정심판법」 제5조 제3호)

의무이행심판이란 당사자의 신청에 대한 행정청의 위법 또는 부당한 거부처분이나 부작위에 대하여 일정한 처분을 하도록 하는 행정심판을 말한다. 거부나 부작위와 같은 행정청의 소극적 행위에 대한 실효적인 국민의 권리구제 수단이다.

[행정심판법] 제5조 (행정심판의 종류) 행정심판의 종류는 다음 각 호와 같다.

1. **취소심판** : 행정청의 위법 또는 부당한 처분을 취소하거나 변경하는 행정심판
2. **무효등확인심판** : 행정청의 처분의 효력 유무 또는 존재 여부를 확인하는 행정심판
3. **의무이행심판** : 당사자의 신청에 대한 행정청의 위법 또는 부당한 거부처분이나 부작위에 대하여 일정한 처분을 하도록 하는 행정심판

02 거부처분취소심판의 가능성 [★]

1) 문제점

「행정심판법」 제5조에서 거부처분은 의무이행심판을 거치도록 규정하고 있다.

이에 의무이행심판이 아닌 거부처분취소심판의 청구가 인정될 수 있는지가 문제가 된다.

2) 학설

- ① 「행정심판법」 제5조 제3호를 근거로 거부처분은 의무이행심판의 대상이라고 보아 부정하는 견해가 있으나,
- ② 「행정심판법」 제2조 제1호의 처분에 거부도 포함되므로 거부처분취소심판도 가능하다고 보는 견해가 통설이다.

3) 판례

판례는 '당사자의 신청을 거부하는 처분을 취소하는 재결이 있는 경우'라고 하여 거부처분취소심판을 긍정하는 입장이다.

당사자의 신청을 거부하는 처분을 취소하는 재결이 있는 경우에는 행정청은 그 재결의 취지에 따라 다시 이전의 신청에 대한 처분을 하여야 하는 것이므로(행정심판법 제37조 제1항, 제2항 참조) 행정청이 그 재결의 취지에 따른 처분을 하지 아니하고 그 처분과는 양립할 수 없는 다른 처분을 하는 것은 위법한 것이라 할 것이고 이 경우 그 재결의 신청인은 위법한 다른처분의 취소를 소구할 이익이 있다 할 것이다.

4) 소결

「행정심판법」 제49조 제2항에서 거부처분을 취소하는 재결을 하는 경우 처분청은 재결의 취지에 따라 다시 처분을 할 의무가 있다고 규정하고 있으므로, 당사자의 효율적 권리구제를 위해 통설·판례와 같이 거부처분취소심판을 인정하는 것이 타당하다.

[행정심판법] 제49조 (재결의 기속력 등)

- ① 심판청구를 인용하는 재결은 피청구인과 그 밖의 관계 행정청을 기속(羈束)한다.
- ② 재결에 의하여 취소되거나 무효 또는 부존재로 확인되는 처분이 당사자의 신청을 거부하는 것을 내용으로 하는 경우에는 그 처분을 한 행정청은 재결의 취지에 따라 다시 이전의 신청에 대한 처분을 하여야 한다.

[행정심판법] 제27조 (심판청구의 기간)

- ① 행정심판은 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내에 청구하여야 한다.
- ② 청구인이 천재지변, 전쟁, 사변(事變), 그 밖의 불가항력으로 인하여 제1항에서 정한 기간에 심판청구를 할 수 없었을 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 14일 이내에 행정심판을 청구할 수 있다. 다만, 국외에서 행정심판을 청구하는 경우에는 그 기간을 30일로 한다.
- ③ 행정심판은 처분이 있었던 날부터 180일이 지나면 청구하지 못한다. 다만, 정당한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ④ 제1항과 제2항의 기간은 불변기간(不變期間)으로 한다.
- ⑤ 행정청이 심판청구 기간을 제1항에 규정된 기간보다 긴 기간으로 잘못 알린 경우 그 잘못 알린 기간에 심판청구가 있으면 그 행정심판은 제1항에 규정된 기간에 청구된 것으로 본다.
- ⑥ 행정청이 심판청구 기간을 알리지 아니한 경우에는 제3항에 규정된 기간에 심판청구를 할 수 있다.
- ⑦ 제1항부터 제6항까지의 규정은 무효등확인심판청구와 부작위에 대한 의무이행심판청구에는 적용하지 아니한다.

01 원칙

행정심판은 청구기간은 원칙적으로 **처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내**, **처분이 있었던 날부터 180일 이내**에 청구하여야 한다. 두 기간 중 어느 하나라도 먼저 경과하면 당해 행정심판청구는 부적법한 것이 되어 각하 결정된다.

1) 처분이 있음을 알게 된 날의 의미

‘처분이 있음을 알게 된 날’이란 **통지·공고 기타의 방법**에 의하여 처분이 있었음을 **현실적으로 알게 된 날**을 의미한다.

대법원 1995. 11. 24. 선고 95누11535 판결

행정심판법 제18조 제1항 소정의 심판청구기간 기산점인 ‘처분이 있음을 안 날’이라 함은 당사자가 통지·공고 기타의 방법에 의하여 당해 처분이 있었다는 사실을 현실적으로 안 날을 의미하고, 추상적으로 알 수 있었던 날을 의미하는 것은 아니라 할 것이며, 다만 처분을 기재한 서류가 당사자의 주소에 송달되는 등으로 사회통념상 처분이 있음을 당사자가 알 수 있는 상태에 놓여진 때에는 반증이 없는 한 그 처분이 있음을 알았다고 추정할 수는 있다.

2) 처분이 있었던 날의 의미

‘처분이 있었던 날’이란 처분이 **고지되어 효력이 발생한 날**을 의미한다. 상대방이 불특정 다수인이며, 고시 또는 공고에 의하여 행정처분을 하는 경우에는 일률적으로 처분의 효력이 적용되어야 한다. 따라서, 고시 또는 공고가 있었다는 사실을 현실적으로 알았는지와 무관하게 고시가 효력이 발생하는 날에 처분이 있음을 알았다고 보아 그때로부터 청구기간을 기산하여야 한다고 본다. 이때 고시일 또는 공고일이란 고시 또는 공고의 효력발생일을 의미한다.

대법원 2000. 9. 8. 선고 99두11257 판결

통상 고시 또는 공고에 의하여 행정처분을 하는 경우에는 그 **처분의 상대방이 불특정 다수인**이고, 그 **처분의 효력이 불특정 다수인에게 일률적으로 적용되는** 것이므로, 그에 대한 행정심판 청구기간도 그 행정처분에 이해관계를 갖는 자가 고시 또는 공고가 있었다는 사실을 **현실적으로 알았는지 여부에 관계없이 고시가 효력을 발생하는 날인 고시 또는 공고가 있은 후 5일이 경과한 날에 행정처분이 있음을 알았다고 보아야 할 것이다.**

02 예외

1) 천재지변 등

청구인이 천재지변, 전쟁, 사변(事變), 그 밖의 불가항력으로 인하여 제1항에서 정한 기간에 심판청구를 할 수 없었을 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 14일 이내에 행정심판을 청구할 수 있다.

다만, 국외에서 행정심판을 청구하는 경우에는 그 기간을 30일로 하며, 이 기간은 불변기간이다.

2) 정당한 사유

「행정심판법」 제27조 제3항 단서에 따라 정당한 사유가 있는 경우에는 처분이 있었던 날부터 180일이 지난 이후에도 심판청구가 가능하다. 여기에서 정당한 사유란 사회통념에 의해 판단되어야 한다.

일반적으로 제3자요 행정행위에서 제3자에게 통지 되지 않은 경우의 제3자가 이에 해당 한다.

대법원 1992. 7. 28. 선고 91누12844 판결

행정처분의 직접 상대방이 아닌 제3자는 일반적으로 처분이 있는 것을 바로 알 수 없는 처지에 있으므로, 위와 같은 심판 청구기간 내에 심판청구를 제기하지 아니하였다고 하더라도, 그 기간 내에 처분이 있는 것을 알았거나 쉽게 알 수 있었기 때문에 심판청구를 제기할 수 있었다고 볼 만한 특별한 사정이 없는 한, 위 법조항 본문의 적용을 배제할 “정당한 사유”가 있는 경우에 해당한다고 보아 위와 같은 심판청구기간이 경과한 뒤에도 심판청구를 제기할 수 있다.

3) 오고지·불고지

행정청이 심판청구 기간을 제1항에 규정된 기간보다 긴 기간으로 잘못 알린 경우 그 잘못 알린 기간에 심판청구가 있으면 그 행정심판은 제1항에 규정된 기간에 청구된 것으로 보며, 행정청이 심판청구 기간을 알리지 아니한 경우에는 제3항에 규정된 기간에 심판청구를 할 수 있다.

4) 특별법상 청구기간

개별법에서 심판청구기간에 대한 특례를 두었다면 그 규정이 행정심판법에 우선한다.

01 재결의 의의 및 성질

재결이란 행정심판의 청구에 대하여 「행정심판법」 제6조에 따른 행정심판위원회가 행하는 판단이라고 「행정심판법」 제2조 제3호에서 정의하고 있다. 즉, 행정법상 법률관계에 관한 분쟁에 대하여 행정심판위원회가 심리를 거쳐 하는 결정을 말한다. 재결은 일정한 절차를 거쳐 행정심판위원회가 판단·확정하는 행위로서, 법원의 판결과 그 성질이 비슷하여 **준사법적 행위의 성질**을 갖는다.

02 재결의 범위

[행정심판법] 제47조 (재결의 범위)

- ① 위원회는 심판청구의 대상이 되는 처분 또는 부작위 외의 사항에 대하여는 재결하지 못한다.
- ② 위원회는 심판청구의 대상이 되는 처분보다 청구인에게 불리한 재결을 하지 못한다.

1) 불고불리의 원칙

위원회는 심판청구의 대상이 되는 처분 또는 부작위 **외의** 사항에 대하여는 **재결하지 못한다**. 이는 청구인에게 예상치 못한 불이익이 발생 되는 것을 방지하기 위함에 그 취지가 있다.

2) 불이익 변경금지의 원칙

위원회는 심판청구의 대상이 되는 처분보다 청구인에게 불리한 **재결**을 하지 못한다. 청구인의 심판청구가 오히려 청구인에게 불이익한 결과로 이어지는 것을 방지하기 위한 것이다.

03 재결의 종류

[행정심판법] 제43조 (재결의 구분)

- ① 위원회는 심판청구가 적법하지 아니하면 그 심판청구를 각하(却下)한다.
- ② 위원회는 심판청구가 이유가 없다고 인정하면 그 심판청구를 기각(棄却)한다.
- ③ 위원회는 취소심판의 청구가 이유가 있다고 인정하면 처분을 취소 또는 다른 처분으로 변경하거나 처분을 다른 처분으로 변경할 것을 피청구인에게 명한다.
- ④ 위원회는 무효등확인심판의 청구가 이유가 있다고 인정하면 처분의 효력 유무 또는 처분의 존재 여부를 확인한다.
- ⑤ 위원회는 의무이행심판의 청구가 이유가 있다고 인정하면 지체 없이 신청에 따른 처분을 하거나 처분을 할 것을 피청구인에게 명한다.

1) 각하재결

각하재결이란 행정심판의 청구가 적법하지 아니한 경우에 하는 재결을 말한다.

각하재결은 본안심리를 거절하는 재결이며, **요건을 갖추지 못한** 경우에 하는 것으로 **요건재결**이라고도 한다.

2) 기각재결

기각재결이란 본안심리의 결과 심판청구가 이유 없다고 인정하는 경우에 하는 재결을 말한다. 다만, 예외적으로 심판청구가 이유 있다고 인정하는 경우에도 이를 인용하는 것이 공공복리에 크게 위배 된다고 인정될 때 기각재결을 할 수 있는데, 이를 사정재결이라고 한다.

[행정심판법] 제44조 (사정재결)

- ① 위원회는 심판청구가 이유가 있다고 인정하는 경우에도 이를 인용(認容)하는 것이 공공복리에 크게 위배된다고 인정하면 그 심판청구를 기각하는 재결을 할 수 있다. 이 경우 위원회는 재결의 주문(主文)에서 그 처분 또는 부작위가 위법하거나 부당하다는 것을 구체적으로 밝혀야 한다.

3) 인용재결

인용재결이란 본안심리의 결과 심판청구가 이유 있다고 인정되어 청구인의 청구취지를 받아들여 하는 재결을 말한다. 인용재결은 청구의 내용에 따라 취소·변경재결, 무효등확인재결, 의무이행재결로 구분된다.

(1) 취소·변경 등 재결

위원회는 취소심판의 청구가 이유가 있다고 인정하면 처분을 취소(취소재결) 또는 다른 처분으로 변경(변경재결)하거나 처분을 다른 처분으로 변경할 것을 처분청(피청구인)에게 명(변경명령재결)한다. 여기서 취소는 전부취소뿐만 아니라 일부취소도 포함되고, 변경이란 적극적 의미의 변경(자격취소 처분을 업무정지 처분으로 변경하는 것)을 말한다.

(2) 무효등확인재결

위원회는 무효등확인심판의 청구가 이유가 있다고 인정하면 처분의 효력 유무 또는 존재 여부를 확인한다. 효력유무를 확인하여 무효확인재결 또는 유효확인재결을 하고, 존재 여부를 확인하여 부존재확인재결 또는 존재확인재결을 한다. 통설은 실효확인재결도 인정한다.

(3) 의무이행재결

위원회는 의무이행심판의 청구가 이유가 있다고 인정하면 지체 없이 신청에 따른 처분을 하거나 처분을 할 것을 피청구인에게 명한다. 직접 처분을 하는 경우에 하는 재결을 처분재결(형성재결)을 하고, 처분을 명하는 경우에 하는 재결을 처분명령재결(이행재결)이라 한다.

01 형성력 [★★]

재결의 형성력이란 위원회의 **형성재결**(취소재결, 변경재결)이 있으면 행정법상 **법률관계**의 발생·변경·소멸을 가져오는 효력을 말한다. 즉,

- ① 위원회의 **취소재결**이 있으면 원처분은 재결 자체에 의해서 **당연히 취소되어 소멸**하고,
- ② **변경재결**이 있으면 원처분은 **변경재결로 변경되어 존재**한다고 본다.

02 불가쟁력 및 불가변력 [★]

심판청구에 대한 **재결**이 있으면 그 재결 및 같은 처분 또는 부작위에 대하여 **다시 행정심판을 청구할 수 없**는데 이를 불가쟁력이라고 하며, 「행정심판법」 제51조에 근거가 있다. 또한 위원회의 재결이 있으면 비록 그것이 위법·부당하다고 하더라도 행정심판위원회 스스로 이를 취소·변경할 수 없는데, 이러한 효력을 불가변력이라고 한다.

03 기속력 [★★★★]

[행정심판법] 제49조 (재결의 기속력 등)

- ① 심판청구를 인용하는 재결은 피청구인과 그 밖의 관계 행정청을 기속(羈束)한다.
- ② 재결에 의하여 취소되거나 무효 또는 부존재로 확인되는 처분이 당사자의 신청을 거부하는 것을 내용으로 하는 경우에는 그 처분을 한 행정청은 재결의 취지에 따라 다시 이전의 신청에 대한 처분을 하여야 한다.
- ③ 당사자의 신청을 거부하거나 부작위로 방치한 처분의 이행을 명하는 재결이 있으면 행정청은 지체 없이 이전의 신청에 대하여 재결의 취지에 따라 처분을 하여야 한다.
- ④ 신청에 따른 처분이 절차의 위법 또는 부당을 이유로 재결로써 취소된 경우에는 제2항을 준용한다.

1) 의의 및 성질

심판청구를 인용하는 **재결**이 **피청구인(처분청)**과 그 밖의 관계 행정청이 **재결의 취지에 따르도록 구속**하는 효력을 재결의 기속력이라 한다. 「행정심판법」 제49조 제1항에서 재결의 기속력에 관한 명문 규정을 두고 있다. 재결의 기속력은 **인용재결**에서만 인정되며, 각하재결·기각재결에서는 인정되지 않는다.

2) 기속력의 범위 (요건)

(1) 주관적 범위

기속력은 **피청구인(처분청)**과 그 밖의 모든 **관계 행정청**에 대하여 미친다. 여기에서 관계 행정청이란 심판의 대상이 되는 처분(거부 또는 부작위) 등과 **관련된 처분**이나 **부수적 행위**를 할 수 있는 행정청을 말한다.

(2) 시간적 범위

처분의 위법성 판단기준시점에 대해 통설·판례는 **처분시점**의 입장을 취하는바, 처분시점에 따라 기속력은 처분시점까지의 사유를 판단의 대상으로 한다. 따라서, 기속력은 **처분시에 존재했던 사유**에만 미치고, 처분 이후의 새로운 법률관계나 사실관계에는 기속력이 미치지 않는다.

(3) 객관적 범위

기속력은 재결의 주문 및 그 전제가 된 요건사실의 인정과 판단, 즉 처분 등의 구체적 위법사유에 관한 판단에만 미친다.

대법원 2005. 12. 9. 선고 2003두7705 판결

재결의 기속력은 재결의 주문 및 그 전제가 된 요건사실의 인정과 판단, 즉 처분 등의 구체적 위법사유에 관한 판단에만 미친다고 할 것이고, 종전 처분이 재결에 의하여 취소되었다 하더라도 종전 처분시와는 다른 사유를 들어서 처분을 하는 것은 기속력에 저촉되지 않는다고 할 것이며, 여기에서 동일 사유인지 다른 사유인지는 종전 처분에 관하여 위법한 것으로 재결에서 판단된 사유와 기본적 사실관계에 있어 동일성이 인정되는 사유인지 여부에 따라 판단되어야 한다.

※ 절차나 형식의 위법에 있는 경우 재결의 기속력은 재결에 적시된 개개의 위법사유에 미치므로, 절차나 형식의 위법사유를 보완하여 다시 동일한 내용의 처분을 하는 것은 기속력에 위반되지 않는다.

3) 기속력의 내용

(1) 반복금지 의무

반복금지 의무란 위원회가 청구인용재결을 하면 처분청(피청구인)과 관계 행정청은 동일한 사실관계 하에서 동일한 내용의 처분을 할 수 없도록 하는 의무를 말한다. 반복금지 의무는 「행정심판법」 제49조 제1항의 해석에 의해 인정되며, 일종의 부작위 의무로서 소극적 의무에 해당한다.

(2) 재처분 의무

a. 변경명령재결

취소심판에 있어서 처분의 변경을 명하는 재결이 있는 때에는 「행정심판법」 제49조 제1항(기속력)에 의해 처분청은 당해 처분을 다른 처분으로 변경하여야 한다.

b. 신청거부에 대한 취소재결·무효등확인재결

재결에 의하여 취소되거나 무효 또는 부존재로 확인되는 처분이 당사자의 신청을 거부하는 것을 내용으로 하는 경우에는 그 처분을 한 행정청은 재결의 취지에 따라 다시 이전의 신청에 대한 처분을 하여야 한다. 이는 「행정심판법」 제49조 제2항에 근거한다.

c. 의무이행재결

당사자의 신청을 거부하거나 부작위로 방치한 처분의 이행을 명하는 재결이 있는 때에는 「행정심판법」 제49조 제3항에 따라 행정청은 지체 없이 이전의 신청에 대하여 재결의 취지에 따라 처분을 하여야 한다. 다만, 재량행위의 경우에는 청구인이 신청한 대로 처분을 해야 하는 것이 아니라, 하자 없는 재량행위를 하면 충분하다.

d. 절차의 하자를 이유로 한 취소재결에 따른 재처분 의무

신청에 따른 처분이 절차의 위법 또는 부당을 이유로 재결로써 취소된 경우에는 행정청은 재결의 취지에 따라 다시 이전의 신청에 대한 처분을 하여야 한다. 이는 「행정심판법」 제49조 제4항에 근거한다.

(3) 결과제거의무

재결의 기속력에는 원상회복의무가 포함되는 것으로 보는 것이 타당하며, 이는 「행정심판법」 제49조 제1항의 해석에 의해 인정된다. 즉, 취소재결 무효등확인재결이 확정되면 행정청은 해당 처분에 의해 야기된 위법상태를 제거할 의무를 부담하게 된다.

4) 기속력의 위반

반복금지의무를 위반하여 동일한 내용의 처분을 다시 한 경우 그 처분은 하자가 중대하고 명백하여 무효이고, 재처분의무를 위반한 경우에는 그 실효성을 확보하기 위해 직접처분(행정심판법 제50조)과 간접강제(행정심판법 제50조의2)가 규정되어 있다.

(1) 직접처분 (「행정심판법」 제50조 제1항)

[행정심판법] 제50조 (위원회의 직접 처분)

- ① 위원회는 피청구인이 제49조제3항에도 불구하고 처분을 하지 아니하는 경우에는 당사자가 신청하면 기간을 정하여 서면으로 시정을 명하고 그 기간에 이행하지 아니하면 직접 처분을 할 수 있다. 다만, 그 처분의 성질이나 그 밖의 불가피한 사유로 위원회가 직접 처분을 할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

a. 의의 및 성질

직접처분이란 행정심판위원회가 이행명령재결을 하였음에도 불구하고 피청구인(처분청)이 재처분의무를 이행하지 않는 경우, 청구인의 신청에 의하여 위원회가 직접 처분을 하는 것을 말한다. 직접처분은 이행명령재결의 실효성 확보에 그 취지가 인정되며, 위원회가 하는 행정심판작용이자 행정처분으로서의 성질을 갖는다.

b. 요건

위원회가 직접처분을 하기 위한 요건으로는

- ① 위원회의 이행명령재결에도 불구하고 피청구인(처분청)이 처분을 하지 아니할 것,
- ② 청구인의 신청이 있을 것,
- ③ 위원회가 시정기간을 정하여 서면으로 시정을 명 할 것 및
- ④ 시정명령기간이 경과할 것이 있다. 또한 소극적 요건으로
- ⑤ 처분의 성질이나 그 밖의 불가피한 사유로 위원회가 직접 처분을 할 수 없는 경우에 해당하지 않아야 한다.

c. 후속 조치

위원회는 직접처분을 하였을 때에는 그 사실을 해당 행정청에 통보하여야 하며, 통보를 받은 행정청은 위원회가 한 처분을 자기가 한 처분으로 보아 관리·감독 등 필요한 조치를 하여야 한다(행정심판법 제50조 제2항).

(2) 간접강제 (「행정심판법」 제50조의 2)

[행정심판법] 제50조의2 (위원회의 간접강제)

- ① 위원회는 피청구인이 제49조제2항(제49조제4항에서 준용하는 경우를 포함한다) 또는 제3항에 따른 처분을 하지 아니하면 청구인의 신청에 의하여 결정으로 상당한 기간을 정하고 피청구인이 그 기간 내에 이행하지 아니하는 경우에는 그 지연기간에 따라 일정한 배상을 하도록 명하거나 즉시 배상을 할 것을 명할 수 있다.

a. 의의

간접강제란 행정심판의 인용재결(거부처분취소재결, 처분이행명령재결 등)에 따라 재처분의무가 있음에도 불구하고 피청구인(처분청)이 처분을 하지 않는 경우에 청구인의 신청에 의하여 위원회가 피청구인(처분청)에게 일정한 배상을 하도록 명하는 것을 말한다.

b. 요건

간접강제의 요건으로는

- ① 피청구인이 「행정심판법」 제49조 제2항(4항에서 준용하는 경우 포함) 및 제3항에 따른 재처분을 하지 않을 것,
- ② 당사자의 신청이 있을 것,
- ③ 위원회가 결정으로 상당한 기간을 정하고, 피청구인이 그 기간 내에 이행하지 않을 것이 있다.
- ④ 위원회는 제1항에 따른 간접강제나 제2항에 따른 결정의 변경을 하는 경우에는 미리 신청 상대방의 의견을 들어야 한다.

c. 내용

간접강제 요건이 충족되면 위원회는

- ① 지연기간에 따라 일정한 배상을 하도록 명하거나,
- ② 즉시 배상을 할 것을 명할 수 있다.

d. 불복과 효력

청구인은 간접강제 결정에 불복하는 경우 행정소송을 제기 할 수 있다(행정심판법 제50조의2 제4항). 또한, 간접강제의 효력은 피청구인인 행정청이 소속된 국가·지방자치단체 또는 공공단체에 미치며, 결정서 정본은 행정소송제기와 관계없이 「민사집행법」에 따른 강제집행에 관하여는 집행권원과 같은 효력을 가진다(동조 제5항).

01 재심판청구금지 및 행정소송

「행정심판법」 제51조에 따라 심판청구에 대한 재결이 있으면 그 재결 및 같은 처분 또는 부작위에 대하여 다시 행정심판을 청구할 수 없다. 따라서 재결에 불복하는 경우에는 행정소송을 제기하여야 한다.

02 피청구인의 불복

1) 문제점

행정심판에서 인용재결이 있는 경우 피청구인(행정청)이 이에 불복하여 행정소송을 제기할 수 있는지가 문제 된다.

2) 학설

- ① 「행정심판법」 제49조 제1항은 재결의 기속력을 규정하고 있으며, 이를 근거로 피청구인과 관계 행정청은 재결에 기속 되어 재결에 불복할 수 없다고 보는 <부정설>과
- ② 재결의 기속력에 의해 원칙적으로는 부정하나, 자치권은 지방자치단체의 주관적 공권이므로 재결로 인해 자치권이 침해된 경우에는 지방자치단체장이 행정소송을 제기할 수 있다고 보는 <제한적 긍정설>이 있다.

3) 판례

판례는 인용재결이 있으면 처분청은 그러한 재결에 기속되므로 피청구인인 처분청은 이에 불복하여 취소소송을 제기할 수 없다고 판시하여 <부정설>의 입장을 취한다(대법원 1998. 5. 8. 선고 97누15432).

4) 소결

항고소송은 국민의 권리구제에 그 목적이 있으며, 「행정심판법」 제49조 제1항을 근거로 피청구인의 불복 가능성을 부정함이 타당하다. 또한, 피청구인의 불복을 긍정하면 국민의 권리구제가 어려워질 수 있으므로 판례와 같이 <부정설>이 타당하다 판단된다.

01 집행정지

[행정심판법] 제30조 (집행정지)

- ① 심판청구는 처분의 효력이나 그 집행 또는 절차의 속행(續行)에 영향을 주지 아니한다.
- ② 위원회는 처분, 처분의 집행 또는 절차의 속행 때문에 중대한 손해가 생기는 것을 예방할 필요성이 긴급하다고 인정할 때에는 직권으로 또는 당사자의 신청에 의하여 처분의 효력, 처분의 집행 또는 절차의 속행의 전부 또는 일부의 정지(이하 “집행정지”라 한다)를 결정할 수 있다. 다만, 처분의 효력정지는 처분의 집행 또는 절차의 속행을 정지함으로써 그 목적을 달성할 수 있을 때에는 허용되지 아니한다.
- ③ 집행정지는 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 있을 때에는 허용되지 아니한다.

1) 집행부정지 원칙과 집행정지

심판청구가 있더라도 처분의 효력이나 그 집행 또는 절차의 속행에 영향을 주지 않는 것을 집행부정지라고 한다. 「행정심판법」 제30조 제1항에 따라 집행부정지가 원칙이지만, 중대한 손해의 예방 등을 위해 일정한 요건을 갖추는 경우에는 집행정지를 인정하고 있다(제2항). 집행정지는 직권 또는 당사자의 신청에 의해 위원회가 결정한다.

2) 집행정지의 요건 (「행정심판법」 제30조 제2항 및 제3항)

(1) 적극적 요건

적극적 요건으로

- ① 심판청구가 계속되고 있을 것,
- ② 집행정지 대상인 처분이 존재할 것,
- ③ 집행 부정지시 중대한 손해가 발생할 것 및
- ④ 긴급한 필요성이 있다.

(2) 소극적 요건

집행정지는 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 있을 때에는 허용되지 아니한다(제3항).

02 임시처분 (「행정심판법」 제31조) [★★]

[행정심판법] 제31조 (임시처분)

- ① 위원회는 처분 또는 부작위가 위법·부당하다고 상당히 의심되는 경우로서 처분 또는 부작위 때문에 당사자가 받을 우려가 있는 중대한 불이익이나 당사자에게 생길 급박한 위험을 막기 위하여 임시지위를 정하여야 할 필요가 있는 경우에는 직권으로 또는 당사자의 신청에 의하여 임시처분을 결정할 수 있다.
- ② 제1항에 따른 임시처분에 관하여는 제30조제3항부터 제7항까지를 준용한다. 이 경우 같은 조 제6항 전단 중 “중대한 손해가 생길 우려”는 “중대한 불이익이나 급박한 위험이 생길 우려”로 본다.
- ③ 제1항에 따른 임시처분은 제30조제2항에 따른 집행정지로 목적을 달성할 수 있는 경우에는 허용되지 아니한다.

1) 의의

임시처분이란 처분 또는 부작위가 **위법·부당하다고 상당히 의심되는 경우** 처분 또는 부작위로 당사자에게 **중대한 불이익 등이 발생할 위험을 막기** 위해 **임시지위를 정할 필요가 있을 때** 발하는 가구제이다.

「행정심판법」 제31조에 근거가 있으며, 임시처분은 직권 또는 당사자의 신청에 의해 위원회가 결정한다.

2) 요건

임시처분의 요건으로는

- ① 심판청구가 계속되고 있을 것(통설은 의무이행심판만 인정),
- ② 처분 등이 위법 부당하다고 **상당히 의심될 것**,
- ③ 당사자가 받을 우려 있는 **중대한 불이익이나 급박한 위험이 있을 것**,
- ④ 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 없을 것,
- ⑤ 집행정지로 목적을 달성할 수 없을 것(보충성 요건)이 있다.

제9절

고지제도 [★★]

[행정심판법] 제58조 (행정심판의 고지)

- ① 행정청이 처분을 할 때에는 처분의 상대방에게 다음 각 호의 사항을 알려야 한다.
 1. 해당 처분에 대하여 행정심판을 청구할 수 있는지
 2. 행정심판을 청구하는 경우의 심판청구 절차 및 심판청구 기간
- ② 행정청은 이해관계인이 요구하면 다음 각 호의 사항을 지체 없이 알려 주어야 한다.

이 경우 서면으로 알려 줄 것을 요구받으면 서면으로 알려 주어야 한다.

 1. 해당 처분이 행정심판의 대상이 되는 처분인지
 2. 행정심판의 대상이 되는 경우 소관 위원회 및 심판청구 기간

01 의의 및 근거

고지제이란 행정청이 처분을 할 때에 처분의 상대방에게 **행정심판을 청구할 수 있는지와 청구 절차 및 청구기간**을 알리도록 하는 제도를 말한다. 고지제도는 국민이 불복여부를 결정하고 불복신청에 편의를 제공하도록 함에 그 취지가 인정되며, 「행정심판법」 제58조에 근거가 있다. 또한 「행정절차법」도 제26조에도 고지의무에 관한 규정이 있다.

02 법적성질

고지는 불복청구에 필요한 사항을 통지하는 **비권력적 사실행위**로서, 그 자체로는 아무런 법적 효과를 발생시키지 않는다.

03 종류

1) 직권에 의한 고지 (제1항)

행정청은 처분을 할 때에는 처분의 상대방에게

- ① 해당 처분에 대하여 행정심판을 청구할 수 있는지와
- ② 행정심판을 청구하는 경우의 심판청구 절차 및 심판청구 기간을 알려야 한다.

2) 신청에 의한 고지 (제2항)

행정청은 이해관계인이 요구하면

- ① 해당 처분이 행정심판의 대상이 되는 처분인지와
 - ② 행정심판의 대상이 되는 경우 소관 위원회 및 심판청구 기간을 지체 없이 알려주어야 한다.
- 또한, 서면으로 알려 줄 것을 요구 받으면 서면으로 알려주어야 한다.

04 고지의무 위반의 효과

1) 처분의 효력

불고지나 오고지가 처분을 위법하게 만드는지와 관련하여 판례는 고지절차는 행정심판 절차를 밟는 데 편의를 제공하려는 것이어서 처분청이 위 규정에 따른 고지의무를 이행하지 않았다고 하더라도 경우에 따라 행정심판의 제기기간이 연장될 수 있음에 그칠 뿐, 그 때문에 심판의 대상이 되는 행정처분이 위법하다고 할 수는 없다고 판시한 바 있다. 즉, 고지의무 위반은 처분의 효력에 직접적인 영향을 미치지 않는다.

대법원 1987. 11. 24. 선고 87누529 판결

행정청이 처분을 할 때에는 당사자에게 그 처분에 관하여 행정심판 및 행정소송을 제기할 수 있는지 여부, 그 밖에 불복을 할 수 있는지 여부, 청구절차 및 청구기간 그 밖에 필요한 사항을 알려야 한다."라고 규정하고 있다. 이러한 고지절차에 관한 규정은 행정처분의 상대방이 그 처분에 대한 행정심판의 절차를 밟는 데 편의를 제공하려는 것이어서 처분청이 위 규정에 따른 고지의무를 이행하지 않았다고 하더라도 경우에 따라 행정심판의 제기기간이 연장될 수 있음에 그칠 뿐, 그 때문에 심판의 대상이 되는 행정처분이 위법하다고 할 수는 없다.

2) 심판청구서의 제출

행정청이 고지를 하지 않거나(불고지), 잘못 고지(오고지)하여 청구인이 심판청구서를 다른 행정기관에 제출한 경우에는 그 행정기관은 그 심판청구서를 지체 없이 정당한 권한이 있는 피청구인에게 보내야 한다(행정심판법 제23조 제2항). 이 경우 심판청구서를 보낸 행정기관은 지체 없이 그 사실을 청구인에게 알려야 하고(제3항), 심판청구기간의 계산은 제1항에 따른 피청구인이나 위원회 또는 제2항에 따른 행정기관에 심판청구서가 제출되었을 때에 행정심판이 청구된 것으로 본다(제4항).

3) 심판청구기간

행정청이 심판청구 기간을 「행정심판법」 제27조 제1항(처분이 있음을 알게 된 날부터 90일)에 규정된 기간보다 긴 기간으로 잘못 알린 경우 그 잘못 알린 기간에 심판청구가 있으면 그 행정심판은 제1항에 규정된 기간에 청구된 것으로 본다(행정심판법 제27조 제5항). 또한, 행정청이 심판청구 기간을 알리지 아니한 경우에는 제3항에 규정된 기간(처분이 있었던 날부터 180일)에 심판청구를 할 수 있다(제6항).

제1절

개관

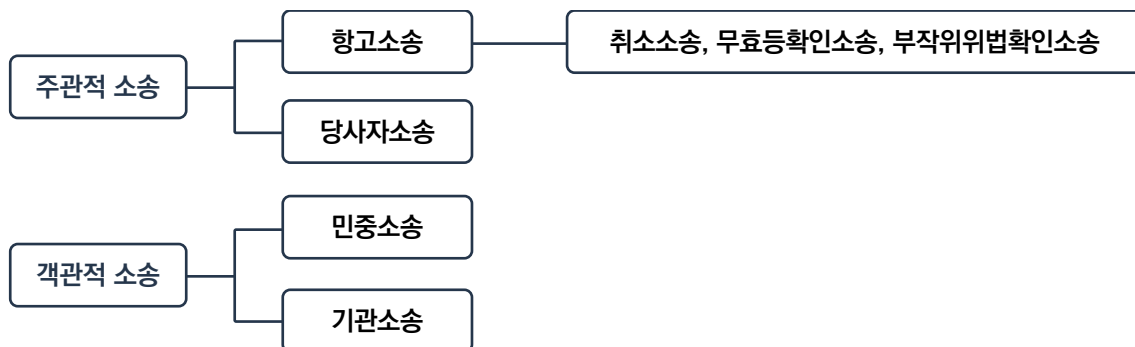
01 행정소송의 의미

행정소송은 행정법상의 법률관계에 대한 분쟁으로 행정청의 위법한 처분등으로 인해 권리·이익을 침해받은 자가 소송을 제기하고 법원이 이를 심리·판단하여 다툼을 해결하는 정식의 소송절차를 말한다. 행정소송에 관한 일반법으로 「행정소송법」이 있으며, 이 법은 취소소송을 중심으로 다른 소송은 이를 준용하는 형식으로 구성되어 있다.

02 행정소송의 종류

행정소송은 그 내용에 따라 주관적 소송과 객관적 소송으로 구분할 수 있다.

주관적 소송은 개인의 권리·이익 구제를 주된 내용으로 하고, 객관적 소송은 적법성 통제를 주된 내용으로 한다.



※ 항고소송이란?

항고소송은 행정청의 처분등이나 부작위에 대하여 제기하는 소송(행정소송법 제3조 제1호)이다.
즉, 행정청의 우월하고 일방적인 공권력행사에 대한 불복으로서 국민의 권익을 보호하는 소송을 말한다.

※ 당사자소송이란?

당사자소송은 행정청의 처분등을 원인으로 하는 법률관계에 관한 소송 그 밖에 공법상의 법률관계에 관한 소송으로서 그 법률관계의 한쪽 당사자를 피고로 하는 소송(행정소송법 제3조 제2호)이다.
즉, 공법상 법률관계 당사자가 각각 원고와 피고가 되어 공법상 법률관계에 대해 다투는 소송을 말한다.

01 의의 및 성질

취소소송이란 행정청의 **위법한 처분 등을 취소** 또는 **변경**하는 소송을 말한다(행정소송법 제4조 제1호). 취소소송의 성질에 대해 확인소송설, 준형성소송설 등의 견해가 있으나, 취소소송은 법률관계를 변경 또는 소멸시키는 것으로 **형성소송**으로 보는 것이 통설·판례의 태도이다.

02 소송요건 [★★★]

1) 의의

소송요건이란 본안판단의 전제요건으로서 **본안심리를** 받기 위한 요건을 말한다. 소송요건은 불필요한 소송을 각하시켜 법원의 부담을 경감시키고, 적법한 소송에 대하여 충실한 심판이 이루어질 수 있도록 요구되는 요건이다. 소송요건은 법원의 **직권심사사항**이며, 소송요건이 결여되면 법원은 각하판결을 한다. 소송요건이 갖추어지면 본안심리로 넘어가므로 소송요건을 본안심판요건이라고도 하고, 소의 적법요건이라고도 한다.

대상적격 (제19조)	대상적격이란 소송의 대상이 될 수 있는 자격을 말하며, 취소소송은 처분등을 대상으로 한다.
원고적격 (제12조 전문)	원고적격이란 행정소송에서 원고가 되어 본안판결을 받을 자격을 말하며, 취소소송은 처분등의 취소를 구할 법률상 이익이 있는 자가 제기할 수 있다.
협의를 소의 (제12조 후문)	협의를 소의이란 원고가 소송을 청구하여 본안판결을 구할 현실적 필요성을 말하며, 권리보호의 필요성이라고도 한다.
피고적격 (제13조)	피고적격이란 소송이 올바른 피고를 상대방으로 제기되는 것을 말한다. 취소소송은 다른 법률에 특별한 규정이 없는 한 그 처분등을 행한 행정청을 피고로 한다. 다만, 처분등이 있는 뒤에 그 처분등에 관계되는 권한이 다른 행정청에 승계된 때에는 이를 승계한 행정청을 피고로 한다.
제소기간 (제20조)	제소기간이란 소송을 제기할 수 있는 시간적 간격을 말한다. 취소소송은 처분등이 있음을 안 날부터 90일 또는 처분등이 있은 날부터 1년 이내에 제기하여야 한다.
재판관할 (제9조)	재판관할은 어떤 법원에 소를 제기하여야 하는지에 관한 것으로, 취소소송의 제1심관할법원은 피고의 소재지를 관할하는 행정법원으로 한다.
행정심판의 전치 (제18조)	행정심판의 전치란 행정소송을 제기하기 전에 행정심판법상 행정심판을 거치는 것을 말한다. 취소소송은 법령의 규정에 의하여 당해 처분에 대한 행정심판을 제기할 수 있는 경우에도 이를 거치지 아니하고 제기할 수 있다고 하여 임의적 전치주의를 취한다.

2) 대상적격 (「행정소송법」 제19조) [★★★]

[행정소송법] 제19조 (취소소송의 대상)

취소소송은 처분등을 대상으로 한다. 다만, 재결취소소송의 경우에는 재결 자체에 고유한 위법이 있음을 이유로 하는 경우에 한한다.

[행정소송법] 제2조 (정의) ①이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “처분등”이라 함은 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서의 공권력의 행사 또는 그 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용(이하 “處分”이라 한다) 및 행정심판에 대한 재결을 말한다.

(1) 처분등의 개념 (「행정소송법」 제2조 제1항)

취소소송은 처분등을 대상으로 하여야 한다. ‘처분등’이란 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서 공권력의 행사 또는 그 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용(처분) 및 행정심판에 대한 재결을 말한다.

(2) 처분등의 개념요소

행정청	행정청은 행정조직법상 개념이 아닌 기능적 의미의 행정청을 말하며, 법령에 의하여 행정권한의 위임 또는 위탁을 받은 행정기관, 공공단체 및 그 기관 또는 사인이 포함된다.
구체적 사실에 관한 행위	구체적 사실이란 규율내용이 구체적인 것으로 특정인에게 직접적인 영향을 미치는 행위를 말한다. 일반적·추상적인 규율인 법령은 원칙적으로 처분등에 해당 될 수 없으나, 구체적 성질을 가지는 처분법규(두밀분교폐지조례)나 불특정 다수인을 대상으로 하나 규율의 내용이 구체적인 일반처분은 처분에 해당 될 수 있다.
법집행 행위	행정소송법상 처분은 일반적·추상적인 법령이 아닌, 법 집행 행위이어야 한다.
공권력 행사	공권력 행사란 행정청이 우월한 지위에서 일방적으로 행하는 일체의 행정작용을 말한다. 따라서, 대등한 지위에서 행하는 공법상 계약은 대상이 되지 않는다.

(3) 거부의 처분성

a. 거부의 의의

거부란 사인의 행정행위 신청에 대해 행정청이 그 신청에 따른 행정행위를 발령 하지 않겠다고 거절하는 행위를 말한다. 거부는 신청에 대한 명백한 거절의 의사표시로서 행정청이 처음부터 아무런 의사표시를 하지 않은 부작위와 구별된다. 이러한 거부가 처분이 되기 위해서는 몇 가지 요건이 충족되어야 한다 (전제요건).

b. 거부처분이 처분이 되기 위한 요건

대법원 1998. 7. 10. 선고 96누14036 판결

국민의 적극적 행위신청에 대하여 행정청이 그 신청에 따른 행위를 하지 않겠다고 거부한 행위가 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당하는 것이라고 하려면, 그 신청한 행위가 공권력의 행사 또는 이에 준하는 행정작용이어야 하고 그 거부행위가 신청인의 법률관계에 어떤 변동을 일으키는 것이어야 하며, 그 국민에게 그 행위발동을 요구할 법규상 또는 조리상의 신청권이 있어야만 한다.

① 공권력 행사의 거부일 것

거부가 처분이 되려면 신청의 내용(행위)이 공권력 행사 또는 그에 준하는 행정작용이어야 한다.
공권력 행사란 행정청이 행하는 구체적 사실에 대한 법집행 행위로서 우월한 지위에서 일방적으로 행하는 행정작용을 말한다.

② 신청인의 법률관계에 영향을 미칠 것

거부가 처분이 되려면 그 거부행위가 신청인의 법률관계에 어떤 변동을 일으키는 것이어야 한다.
판례는 신청인의 실체상의 권리관계에 직접적인 변동을 일으키는 것은 물론, 그렇지 않다 하더라도 신청인이 실체상의 권리자로서 권리를 행사함에 중대한 지장을 초래하는 것도 포함한다고 본다.

대법원 2007. 10. 11. 선고 2007두 1316판결

국민의 적극적 행위 신청에 대하여 행정청이 그 신청에 따른 행위를 하지 않겠다고 거부한 행위가 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당하는 것이라고 하려면 …(중략)… ‘신청인의 법률관계에 어떤 변동을 일으키는 것’이라는 의미는 신청인의 실체상의 권리관계에 직접적인 변동을 일으키는 것은 물론, 그렇지 않다 하더라도 신청인이 실체상의 권리자로서 권리를 행사함에 중대한 지장을 초래하는 것도 포함한다.

[수리거부가 항고소송의 대상인 처분인지 여부]

1. 문제점

「감정평가법」 제17조에서 등록 및 등록갱신을 규정하고 있는데, 이러한 신고(등록)에 대한 행정청의 수리 거부 행위가 신청인의 법률관계에 어떠한 변경을 일으키는 것인지와 관련하여 항고소송의 대상인 거부처분에 해당하는지가 문제 된다.

2. 학설

① 신고의 법적성질에 따라 구분하는 견해로서 자기완결적 신고의 수리거부는 항고소송의 대상이 되지 않고, 수리를 요하는 신고의 수리거부는 항고소송의 대상이 된다고 보는 견해와 ② 신고의 법적성질과 관계 없이 수리가 반려될 경우 신고인이 불이익을 받을 위험 등 법적 지위가 불안정하게 될 수 있는지 여부를 기준으로 개별적으로 검토하여야 한다고 보는 견해가 있다.

3. 판례

종래에는 신고의 법적성질을 기준으로 수리를 요하는 신고의 수리거부만이 항고소송의 대상이 된다고 보았으나, 최근 「건축법상」 신고와 관련하여 건축신고를 자기완결적 신고로 보면서도 그 신고의 거부를 항고소송의 대상이 되는 처분으로 보아 개별적으로 검토하는 견해를 취하고 있다.

대법원 2010. 11. 18. 선고 2008두167 전원합의체 판결

건축신고가 반려될 경우 당해 건축물의 건축을 개시하면 시정명령, 이행강제금, 벌금의 대상이 되거나 당해 건축물을 사용하여 행할 행위의 허가가 거부될 우려가 있어 불안정한 지위에 놓이게 된다. 따라서 건축신고 반려행위가 이루어진 단계에서 당사자로 하여금 반려행위의 적법성을 다투어 그 법적 불안을 해소한 다음 건축행위에 나아가도록 함으로써 장차 있을지도 모르는 위험에서 미리 벗어날 수 있도록 길을 열어 주고, 위법한 건축물의 양산과 그 철거를 둘러싼 분쟁을 조기에 근본적으로 해결할 수 있게 하는 것이 법치행정의 원리에 부합한다.
그러므로 건축신고 반려행위는 항고소송의 대상이 된다고 보는 것이 옳다.

4. 소결

신고의 법적성질을 기준으로 하는 견해는 국민의 재판청구권을 침해할 우려가 있으므로, 미신고행위에 대한 제재규정이 있다면 이는 사인에게 신고의무를 지우는 것으로서 그러한 신고에 대한 수리거부의 처분성을 긍정함이 타당하다.

③ 법규상·조리상 신청권이 있을 것

신청권이 필요한지에 대해서는 견해가 대립하는데, 판례는 거부한 행위가 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당하려면 국민에게 그 행위발동을 요구할 법규상 또는 조리상의 신청권이 있어야 한다고 본다.

[거부가 처분이 되기 위해 신청권이 필요한지 여부]

1. 문제점

신청에 대한 거부가 처분이 되기 위해서 법규상·조리상 신청권이 필요한지가 문제 된다.

2. 학설

① 신청권의 존부를 원고적격의 문제로 보는 〈원고적격설〉, ② 신청권의 존부는 본안에서 판단하여야 한다고 보는 〈본안요건설〉 및 ③ 단순한 응답을 받을 권리로서 신청권이 필요하다고 보는 〈대상적격설〉이 있다.

3. 판례 (잠수기어업불허가처분취소, 대법원 1996. 6. 11. 선고 95누12460 판결)

거부처분의 처분성을 인정하기 위한 전제요건이 되는 신청권의 존부는 구체적 사건에서 신청인이 누구인가를 고려하지 않고 관계 법규의 해석에 의하여 일반 국민에게 그러한 신청권을 인정하고 있는가를 살펴 추상적으로 결정되는 것이고, 신청인이 그 신청에 따른 단순한 응답을 받을 권리를 넘어서 신청의 인용이라는 만족적 결과를 얻을 권리를 의미하는 것은 아니다. 따라서 국민이 어떤 신청을 한 경우에 그 신청의 근거가 된 조항의 해석상 행정발동에 대한 개인의 신청권을 인정하고 있다고 보여지면 그 거부행위는 항고소송의 대상이 되는 처분으로 보아야 할 것이고, 구체적으로 그 신청이 인용될 수 있는가 하는 점은 본안에서 판단하여야 할 사항인 것이다.

4. 소결

거부의 처분성을 인정하기 위한 전제요건인 신청권은 신청인이 누구인가를 고려하지 않고, 단순한 응답받을 권리를 의미하므로, 판례와 같이 신청권의 존부를 거부처분의 요건으로 보는 〈대상적격설〉이 타당하다.

c. 반복된 거부의 경우

판례는 거부처분은 관할행정청이 국민의 신청에 대해 거절의 의사표시를 함으로써 성립되고, 그 이후 동일한 내용의 새로운 신청에 대하여 다시 거절의 의사표시를 한 경우에는 새로운 거부처분이 있는 것으로 보아야 한다고 판시한 바 있다.

대법원 2002. 3. 29. 선고 2000두6084 판결

거부처분은 관할 행정청이 국민의 처분신청에 대하여 거절의 의사표시를 함으로써 성립되고, 그 이후 동일한 내용의 새로운 신청에 대하여 다시 거절의 의사표시를 한 경우에는 새로운 거부처분이 있는 것으로 보아야 할 것이다.

대법원 2022. 3. 17. 선고 2021두53894 판결

수익적 행정처분을 구하는 신청에 대한 거부처분이 있은 후 당사자가 다시 신청을 한 경우에는 신청의 제목 여하에 불구하고 그 내용이 새로운 신청을 하는 취지라면 관할 행정청이 이를 다시 거절하는 것은 새로운 거부처분이라고 보아야 한다. 나아가 어떠한 처분이 수익적 행정처분을 구하는 신청에 대한 거부처분이 아니라고 하더라도, 해당 처분에 대한 이의신청의 내용이 새로운 신청을 하는 취지로 볼 수 있는 경우에는, 그 이의신청에 대한 결정의 통보를 새로운 처분으로 볼 수 있다.

※ 2·3차 계고처분의 처분성 (부정)

판례는 「행정대집행법」에 따른 계고처분의 경우 2·3차 계고처분은 대집행기한의 연기통지에 불과하여 행정처분이 아니라고 본다. 따라서, 반복된 계고처분은 항고소송의 대상이 되지 않는다.

대법원 1994. 10. 28. 선고 94누5144 판결

건물의 소유자에게 위법건축물을 일정기간까지 철거할 것을 명함과 아울러 불이행할 때에는 대집행한다는 내용의 철거대집행 계고처분을 고지한 후 이에 불응하자 다시 제2차, 제3차 계고서를 발송하여 일정기간까지의 자진철거를 촉구하고 불이행하면 대집행을 한다는 뜻을 고지하였다면 행정대집행법상의 건물철거의무는 제1차 철거명령 및 계고처분으로서 발생하였고 제2차, 제3차의 계고처분은 새로운 철거의무를 부과한 것이 아니고 다만 대집행기한의 연기통지에 불과하므로 행정처분이 아니다.

(4) 변경처분

a. 문제점

처분이 있은 후 처분청이 처분을 변경한 경우에 원처분과 변경처분 중 어느 것을 소의 대상으로 하여야 하는지가 문제 된다.

b. 학설

- ① 변경처분과 원처분은 각각 독립된 처분이므로 양자 모두 소의 대상이라고 보는 <병존설>,
- ② 변경처분으로 원처분은 취소되어 변경처분으로 대체 되므로 변경처분이 소의 대상으로 보는 <흡수설>,
- ③ 변경처분은 원처분의 일부취소로 원처분은 변경된 원처분으로 존재하게 되어 이를 소의 대상으로 삼아야 한다고 보는 <역흡수설> 등이 있다.

c. 판례

① 감액처분

행정청이 과세처분을 한 뒤에 이를 감액하는 경정처분을 한 경우에 그 경정처분은 감소된 부분에만 법적효과를 미치는 것이므로 이러한 경정처분은 독립한 과세처분이 아니고, 당초 부과처분(원처분)의 일부취소로서 납세자에게 유리한 효과를 가져오므로, 항고소송의 대상은 당초 부과처분 중 경정처분에 의해 취소되지 않고 남은 부분이라고 판시한 바 있다. 또한, 제소기간의 준수 여부도 감액처분이 아닌 당초 처분을 기준으로 판단해야 한다는 것이 판례의 태도이다.

대법원 1986. 7. 8. 선고 84누50 판결

과세관청이 과세처분을 한 뒤에 당초 부과처분의 일부를 취소, 감액하는 내용의 경정결정을 한 경우 위 경정처분은 그에 의하여 감소된 세액부분에 관하여서만 법적 효과를 미치는 것으로서 당초 부과처분과 독립의 과세처분이 아니라 그 실질은 당초 부과처분의 변경이고 그에 의하여 세액의 일부취소라는 납세자에게 유리한 효과를 가져오는 처분이라 할 것이므로 그 경정결정으로도 아직 취소되지 않고 남아 있는 부분이 위법하다고 하여 다투는 경우에는 항고소송의 대상이 되는 것은 당초의 부과처분중 경정결정에 의하여 취소되지 않고 남은 부분이 된다 할 것이고 경정결정이 항고소송의 대상이 되는 것은 아니라 할 것이므로 이 경우 적법하게 전심절차를 밟았는가 여부도 당초처분을 기준으로 판단하여야 할 것이다.

대법원 2012. 9. 27. 선고 2011두27247 판결

행정청이 산업재해보상보험법에 의한 보험급여 수급자에 대하여 부당이득 징수결정을 한 후 징수결정의 하자를 이유로 징수금 액수를 감액하는 경우에 감액처분은 감액된 징수금 부분에 관해서만 법적 효과가 미치는 것으로서 당초 징수결정과 별개 독립의 징수금 결정처분이 아니라 그 실질은 처음 징수결정의 변경이고, 그에 의하여 징수금의 일부취소라는 징수의무자에게 유리한 결과를 가져오는 처분이므로 징수의무자에게는 그 취소를 구할 소의 이익이 없다. 이에 따라 감액처분으로도 아직 취소되지 않고 남아 있는 부분이 위법하다 하여 다투고자 하는 경우, 감액처분을 항고소송의 대상으로 할 수는 없고, 당초 징수결정 중 감액처분에 의하여 취소되지 않고 남은 부분을 항고소송의 대상으로 할 수 있을 뿐이며, 그 결과 제소기간의 준수 여부도 감액처분이 아닌 당초 처분을 기준으로 판단해야 한다.

② 증액처분

판례는 증액경정처분이 있는 경우 당초 처분은 증액경정처분에 흡수되어 독립된 존재가치를 잃으므로 증액경정처분만이 항고소송의 대상이 된다는 입장이다.

대법원 2009. 5. 14. 선고 2006두17390 판결

국세기본법 제22조의2 제1항의 주된 입법 취지는 증액경정처분이 있더라도 불복기간의 경과 등으로 확정된 당초 신고 또는 결정에서의 세액만큼은 그 불복을 제한하려는 데 있는 점 등을 종합하여 볼 때, 국세기본법 제22조의2의 시행 이후에도 증액경정처분이 있는 경우 당초 신고나 결정은 증액경정처분에 흡수됨으로써 독립된 존재가치를 잃게 된다고 보아야 할 것이므로, 원칙적으로는 당초 신고나 결정에 대한 불복기간의 경과 여부 등에 관계없이 증액경정처분만이 항고소송의 심판대상이 되고, 납세의무자는 그 항고소송에서 당초 신고나 결정에 대한 위법사유도 함께 주장할 수 있다고 해석함이 타당하다.

③ 적극적 변경처분

판례는 변경처분이 종전 처분을 완전히 대체하는 것이거나 주요 부분을 실질적으로 변경하는 내용인 경우에는 종전처분을 효력을 상실하므로, <변경처분>만이 항고소송의 대상이 된다. 그러나, 처분청 제재처분을 한 후 그 처분을 영업자에게 유리하게 변경하는 처분을 하는 경우에는 당초처분은 유리하게 변경된 내용의 처분으로 존재하므로 <변경된 내용의 당초처분>을 소의 대상으로 삼아야 한다. 또한, 당초처분의 내용 중 일부만을 소폭 변경하는 정도에 불과한 경우에는 당초처분이 소멸한다고 볼 수 없으므로, 이 경우는 종전처분이 여전히 소의 대상이 된다고 판시한다.

대법원 2015. 11. 19. 선고 2015두295 전원합의체 판결

기존의 행정처분을 변경하는 내용의 행정처분이 뒤따르는 경우, 후속처분이 종전 처분을 완전히 대체하는 것이거나 주요 부분을 실질적으로 변경하는 내용인 경우에는 특별한 사정이 없는 한 종전처분은 효력을 상실하고 후속처분만이 항고소송의 대상이 되지만, 후속처분의 내용이 종전처분의 유효를 전제로 내용 중 일부만을 추가·철회·변경하는 것이고 추가·철회·변경된 부분이 내용과 성질상 나머지 부분과 불가분적인 것이 아닌 경우에는, 후속처분에도 불구하고 종전처분이 여전히 항고소송의 대상이 된다.

대법원 2007. 4. 27. 선고 2004두9302 판결

행정청이 식품위생법령에 따라 영업자에게 행정제재처분을 한 후 그 처분을 영업자에게 유리하게 변경하는 처분을 한 경우, 변경처분에 의하여 당초 처분은 소멸하는 것이 아니고 당초부터 유리하게 변경된 내용의 처분으로 존재하는 것이므로, 변경처분에 의하여 유리하게 변경된 내용의 행정제재가 위법하다 하여 그 취소를 구하는 경우 그 취소소송의 대상은 변경된 내용의 당초 처분이지 변경처분은 아니고, 제소기간의 준수 여부도 변경처분이 아닌 변경된 내용의 당초 처분을 기준으로 판단하여야 한다.

대법원 2012. 10. 11. 선고 2010두12224 판결

당초처분의 주요 부분을 실질적으로 변경하는 내용으로 새로운 변경처분을 한 경우 당초처분은 특별한 사정이 없는 한 그 효력을 상실하지만, 변경처분이 있었다고 하여 일률적으로 당초처분이 존재하지 않게 되는 것은 아니고 당초처분의 내용 중 일부만을 소폭 변경하는 정도에 불과한 경우에는 당초처분이 소멸한다고 볼 수 없다.

d. 소결

당초 처분을 당사자에게 유리하게 변경하는 경우에는 변경되고 남은 원처분을 소의 대상으로 하는 것이 원처분의 연속성 측면에서 타당하고, 증액경정처분의 경우에는 국민의 재판청구권을 보장하기 위해 증액처분인 변경처분을 소의 대상으로 삼는 것이 타당하다.

(5) 재결

a. 의의

「행정심판법」 제2조 제3호에서는 재결을 행정심판의 청구에 대하여 행정심판위원회가 행하는 판단으로 정의하고 있는데, 「행정소송법」에서 재결은 「행정심판법」상의 재결과 개별법상 이의신청 중 행정심판의 성질을 갖는 이의신청에 대한 재결을 모두 포함한다. 「토지보상법」 제83조의 이의신청에 따른 중앙토지수용위원회의 이의재결이 여기에 해당한다.

b. 원처분주의와 재결주의

원처분주의란 원칙적으로는 원처분을 소의 대상으로 하고, 예외적으로 재결 자체에 고유한 위법이 있는 경우에 재결을 소의 대상으로 삼는 것을 말한다. 이에 반해 재결주의란 재결에 대해서만 취소소송을 제기할 수 있도록 하는 것을 말한다. 양자 중 어느 것을 취할지는 입법정책의 문제이며, 「행정소송법」은 원처분주의를 취하고 있다.

※ 「토지보상법」은 제85조 제1항에서 수용재결(원처분)과 이의재결(재결)을 모두 소의 대상으로 삼을 수 있다고 규정하여 원처분주의를 취한다.

[원처분주의 위반의 효과]

1. 문제점

「행정소송법」은 원처분주의를 취하고 있는데, 원처분주의를 위반하여 재결 자체에 고유한 위법이 없음에도 재결취소소송을 제기한 경우 법원이 어떠한 판결을 하여야 하는지가 문제 된다.

2. 학설

① 「행정소송법」 제19조 단서를 소극적 소송요건으로 보아 재결 자체의 고유한 위법이 없음에도 제기한 소는 소송요건이 결여된 것이므로 <각하판결>을 하여야 한다고 보는 견해와 ② 해당 규정을 본안요건으로 보아 <기각판결>을 하여야 한다는 견해가 대립한다.

3. 판례

「행정소송법」 제19조는 취소소송은 행정청의 원처분을 대상으로 하되(원처분주의), 다만 "재결 자체에 고유한 위법이 있음을 이유로 하는 경우"에 한하여 행정심판의 재결도 취소소송의 대상으로 삼을 수 있도록 규정하고 있으므로 재결취소소송의 경우 재결 자체에 고유한 위법이 있는지 여부를 심리할 것이고, 재결 자체에 고유한 위법이 없는 경우에는 원처분의 당부와는 상관없이 당해 재결취소소송은 이를 기각하여야 한다고 판시하고 있다.

4. 검토

재결 자체에 고유한 위법이 있는지 여부는 본안에서 심리하여야 하는 본안요건이므로 재결 자체에 고유한 위법이 없는 경우에는 <기각판결>을 하여야 한다고 보는 견해가 타당하다.

c. 구체적 검토

㉠ 각하재결

행정심판청구가 적법함에도 불구하고 본안심리를 하지 않고 각하재결을 한 경우, 이러한 각하재결은 원처분에 없는 고유한 하자가 있는 것이므로 재결취소소송의 대상이 된다.

㉡ 기각재결

기각재결은 원처분이 정당하다고 인정하여 원처분을 유지하겠다는 내용의 재결이므로 원칙적으로는 재결 자체에 고유한 하자가 없어 재결취소소송을 제기할 수 없다. 그러나, 심판청구요건을 구비하지 않아 각하재결을 하여야 함에도 기각재결을 한 경우는 재결이 소의 대상이 될 수 있다.

㉔ 인용재결

행정심판청구인은 인용재결이 내려졌다면 목적을 달성한 것이므로 원칙적으로는 그 인용재결에 불복할 필요성이 없다. 다만, 제3자효 행정행위에서 제3자의 심판청구에 대해 인용재결이 내려진 경우라면 처분의 상대방은 그 인용재결을 다룰 필요가 있고, 이는 원처분에는 없는 재결 자체의 고유한 위법을 주장하는 것으로 재결이 항고소송의 대상이 된다(이를 행정소송법 제19조 본문에 따른 소송으로 보는 견해도 있다).

대법원 2001. 5. 29. 선고 99두10292 판결

이른바 복효적 행정행위, 특히 제3자효를 수반하는 행정행위에 대한 행정심판청구에 있어서 그 청구를 인용하는 내용의 재결로 인하여 비로소 권리이익을 침해받게 되는 자는 그 인용재결에 대하여 다룰 필요가 있고, 그 인용재결은 원처분과 내용을 달리하는 것이므로 그 인용재결의 취소를 구하는 것은 원처분에는 없는 재결에 고유한 하자를 주장하는 셈이어서 당연히 항고소송의 대상이 된다.

(6) 심화내용

a. 일부인용재결과 변경재결

㉔ 문제점

행정심판청구인의 청구가 일부만 받아 들여진 경우인 일부인용재결(일부취소재결)이나 변경재결이 있는 경우에 청구인이 여전히 이에 불복하여 소송을 제기하려면 소의 대상이 무엇이 되어야 하는지가 문제 된다.

㉔ 학설

① 일부취소(변경)재결은 원처분의 일부취소이므로 일부 취소되고 남은 원처분(변경된 원처분)이 소의 대상이 된다고 보는 견해, ② 일부취소(변경)재결은 원처분을 전부 취소하고 원처분을 대체하는 새로운 처분이므로 일부취소(변경)재결이 소의 대상이 된다고 보는 견해 및 ③ 일부취소재결과 변경재결을 구분하여 일부취소재결은 양적 변경으로 남은 원처분이 소의 대상이 되고, 변경재결은 질적 변경으로 변경재결이 소의 대상이 된다고 보는 견해 등이 있다.

㉔ 판례

서울고등법원은 감봉 3월의 징계처분을 소청심사위원회가 감봉 1월로 감경한 사안에서 원처분청을 피고로 감봉 1월의 처분에 대해 본안판단을 하였다. 이는 일부 취소되고 남은 원처분을 취소소송의 대상으로 인정한 것이며, 변경재결의 경우 대법원은 소청심사위원회가 감봉 1월의 징계처분을 견책으로 변경한 소청결정은 재결 자체에 고유한 위법을 주장하는 것으로 볼 수 없다고 하여 변경되고 남은 원처분을 대상으로 처분청을 피고로 하여 소송을 제기하여 한다고 판시한바 있다.

※ 일부취소재결에 관해서는 대법원 판례는 없음.

대법원 1993. 8. 24. 선고 93누5673 판결

항고소송은 원칙적으로 당해 처분을 대상으로 하나, 당해 처분에 대한 재결 자체에 고유한 주체, 절차, 형식 또는 내용상의 위법이 있는 경우에 한하여 그 재결을 대상으로 할 수 있다고 해석되므로, 징계혐의자에 대한 감봉 1월의 징계처분을 견책으로 변경한 소청결정 중 그를 견책에 처한 조치는 재량권의 남용 또는 일탈로서 위법하다는 사유는 소청결정 자체에 고유한 위법을 주장하는 것으로 볼 수 없어 소청결정의 취소사유가 될 수 없다.

㉔ 소결

「행정소송법」 제19조에 의해 재결 자체에 고유한 위법이 없는 한 원처분을 소송의 대상으로 하여야 하는데, 일부취소재결과 변경재결을 구별하는 것은 일관성이 결여되어 타당하지 않고, 일부취소(변경)재결이 있으면 원처분 일부취소(변경)되고 남은 원처분으로 존재하므로 판례와 같이 이를 소의 대상으로 삼는 것이 타당하다.

b. 변경명령재결에 따른 변경처분

㉕ 문제점

위원회의 변경명령재결이 있고 이에 따라 처분청이 재결의 취지에 따라(행정심판법 제49조 제3항) 변경처분을 한 경우 명령재결과 변경처분 중 어느 것이 소의 대상이 되는지가 문제 된다.

㉖ 학설

- ① 명령재결이 있다고 하여도 행정청의 처분이 있기 전까지는 구체적·현실적인 권리이익의 침해가 있다고 볼 수 없으므로 명령재결에 따른 처분청의 <변경되고 남은 원처분>만이 소의 대상이 된다고 보는 견해,
- ② 명령재결을 둔 채 명령재결에 따른 처분만의 취소를 구하는 것은 재결의 기속력(행정심판법 제49조)으로 인해 인정될 수 없으므로 <명령재결>의 취소가 선행되어야 한다고 보는 견해,
- ③ 명령재결과 그에 따른 변경처분은 모두 독립된 행정처분이므로 각각 소의 대상이 된다고 보는 견해가 있다.

㉗ 판례

판례는 재결 자체의 고유한 위법을 부정하는 전제하에서, 처분변경명령재결에 따른 변경처분의 경우 취소소송의 대상은 변경된 내용의 당초처분이 된다고 판시한바 있다. 또한 제소기간은 재결서의 정본을 송달받은 날로부터 기산되어야 한다고 본다.

대법원 2007. 4. 27. 선고 2004두9302 판결

행정청이 식품위생법령에 따라 영업자에게 행정제재처분을 한 후 그 처분을 영업자에게 유리하게 변경하는 처분을 한 경우, 변경처분에 의하여 당초 처분은 소멸하는 것이 아니고 당초부터 유리하게 변경된 내용의 처분으로 존재하는 것이므로, 변경처분에 의하여 유리하게 변경된 내용의 행정제재가 위법하다 하여 그 취소를 구하는 경우 그 취소소송의 대상은 변경된 내용의 당초 처분이지 변경처분은 아니고, 제소기간의 준수 여부도 변경처분이 아닌 변경된 내용의 당초 처분을 기준으로 판단하여야 한다.

㉘ 소결

변경명령재결도 일부취소재결과 마찬가지로 당사자에게 유리하게 원처분이 변경되는 것에 불과하므로 명령재결에 따른 처분청의 변경처분으로 인해 변경되고 남은 원처분을 소의 대상으로 삼을 수 있다고 보는 것이 타당하다. 다만, 재결자체에 고유한 위법이 있다면 재결도 소의 대상으로 삼을 수 있을 것이다.

3) 원고적격 (「행정소송법」 제12조) [★★★]

(1) 의의

원고적격이란 행정소송에서 원고가 되어 본안판결을 받을 자격을 말한다. 「행정소송법」 제12조에서 원고적격과 관련하여 취소소송은 처분등의 취소를 구할 법률상 이익이 있는 자가 제기할 수 있다고 규정하고 있다.

[행정소송법] 제12조 (원고적격)

취소소송은 처분등의 취소를 구할 법률상 이익이 있는 자가 제기할 수 있다. 처분등의 효과가 기간의 경과, 처분등의 집행 그 밖의 사유로 인하여 소멸된 뒤에도 그 처분등의 취소를 인하여 회복되는 법률상 이익이 있는 자의 경우에는 또한 같다.

(2) 법률상 이익의 의미

a. 학설

- ① 취소소송은 침해된 개인의 권리 회복을 목적으로 하므로, 권리가 침해된 자가 원고적격을 가진다고 보는 <권리구제설>,
- ② 항고소송의 기능을 법에 의하여 보호되는 이익을 구제하는 것으로 보아, 처분에 의해 권리가 침해된 자 뿐만 아니라 법에 의해 보호되고 있는 이익을 가진 자도 원고적격이 있다고 보는 <법률상 이익구제설>,
- ③ 침해된 이익이 법률상 이익이든 사실상 이익이든 간에 실질적으로 재판상 보호할 가치 있는 이익이 침해된 자는 원고적격이 있다고 보는 <보호가치 있는 이익설> 및
- ④ 취소소송의 기능을 개인의 권리구제보다 행정행위의 적법성 통제에 있다고 보아, 처분의 적법성 확보와 가장 밀접한 이익을 가진 자가 원고적격을 가진다고 보는 <적법성 보장설>이 있다.

b. 판례

판례는 법률상 보호되는 이익은 당해 처분의 근거법규 및 관련법규에 의하여 보호되는 개별적·직접적·구체적 이익이 있는 경우를 말한다고 하여 <법률상 이익구제설>의 입장을 취한다.

대법원 2006. 3. 16. 선고 2006두330 전원합의체 판결

법률상 보호되는 이익이라 함은 당해 처분의 근거 법규 및 관련 법규에 의하여 보호되는 개별적·직접적·구체적 이익이 있는 경우를 말하고, 공익보호의 결과로 국민 일반이 공통적으로 가지는 일반적·간접적·추상적 이익이 생기는 경우에는 법률상 보호되는 이익이 있다고 할 수 없다.

c. 소결

「행정소송법」은 취소소송을 주관적 소송으로 보아 개인의 권익구제를 주된 기능으로 규정하고 있으며, 동법 제12조의 원고적격의 해석상 <법률상 이익구제설>이 타당하다.

(3) '법률'의 범위

법률상 보호되는 이익에서 '법률'의 범위가 문제 된다. 종래에는 당해 처분의 근거법규만을 고려 하였지만 오늘날에는 근거법규 뿐만 아니라 관련법규까지 고려하며, 헌법상의 기본권도 법률상 이익으로 인정하는 듯한 판례도 있다. 근거법규와 관련법규를 기본으로하여 보충적으로 헌법상 기본권도 고려하여야 한다고 보는 것이 일반적인 견해이다.

(4) 제3자의 원고적격

a. 경쟁자 소송

경쟁자소송이란 여러 영업자가 경쟁관계에 있는 경우, 경쟁관계에 있는 영업자들 중에서 특정 영업자에 대한 처분을 다른 경쟁업자가 다투는 소송을 말한다. 예를들면, 기존업자가 신규업자가 얻은 버스운송사업에 대한 사업계획변인가처분의 취소를 구하는 소송을 제기하는 것이 있다. 통설·판례는 기존업자가 받은 처분이 특허처분인 경우에는 특허로 받은 이익을 법률상 이익으로 보아 원고적격을 인정하고 있고, 이전 처분이 허가처분인 경우에는 기존업자의 이익은 반사적 이익 또는 사실상 이익에 불과한 것으로 보아 원고적격을 부정하고 있다.

※ 법률상이익이 (긍정) : 자동차운수사업의 노선연장허가, 선박운항사업면허, 광업허가

※ 법률상이익이 (부정) : 숙박업허가, 공중목욕장영업허가, 석탄가공업허가

b. 경원자 소송

경원자소송이란 수인의 신청을 받고, 그 일부에 대하여만 인·허가 등의 수익적 행정처분을 하는 경우에 인·허가 등의 처분을 받지 못한 자가 타방에 대한 인·허가처분을 대상으로 제기하는 항고소송을 말한다. 예로는 동일 지역에서 수인이 도로점용허가를 신청하였는데 그 중 한명에게만 허가하는 경우를 들 수 있다.

c. 인인소송 (이웃소송)

인인소송이란 어떠한 시설의 설치를 허가하는 처분 등에 대하여 당해 시설의 인근주민이 다투는 소송을 말한다. 예로는 어떠한 지역에 개발행위허가에 대해 당해 지역의 인근주민들이 소송을 제기하는 것을 들 수 있다.

대법원 2006. 3. 16. 선고 2006두330 전원합의체 판결

구 환경정책기본법 시행령의 각 관련 규정의 취지는, 공유수면매립과 농지개량사업시행으로 인하여 직접적이고 중대한 환경피해를 입으리라고 예상되는 환경영향평가 대상지역 안의 주민들이 전과 비교하여 수인한도를 넘는 환경침해를 받지 아니하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있는 개별적 이익까지도 이를 보호하려는 데에 있다고 할 것이므로, 위 주민들이 공유수면매립면허처분 등과 관련하여 갖고 있는 위와 같은 환경상의 이익은 주민 개개인에 대하여 개별적으로 보호되는 직접적·구체적 이익으로서 그들에 대하여는 특단의 사정이 없는 한 환경상의 이익에 대한 침해 또는 침해우려가 있는 것으로 사실상 추정되어 공유수면매립면허처분 등의 무효확인을 구할 원고적격이 인정된다. 한편, 환경영향평가 대상지역 밖의 주민이라 할지라도 공유수면매립면허처분 등으로 인하여 그 처분 전과 비교하여 수인한도를 넘는 환경피해를 받거나 받을 우려가 있는 경우에는, 공유수면매립면허처분 등으로 인하여 환경상 이익에 대한 침해 또는 침해우려가 있다는 것을 입증함으로써 그 처분 등의 무효확인을 구할 원고적격을 인정받을 수 있다.

4) 협의의 소익 (「행정소송법」 제12조 제2문)

(1) 의의 및 근거

협의의 소익이란 원고가 소송을 청구하여 본안판결을 구할 현실적 필요성을 말하며, 권리보호의 필요성이라고도 한다. 협의의 소익은 소권남용을 방지하여 법원의 부담을 경감하는데 그 취지가 인정된다. 「행정소송법」 제12조 제2문에서는 처분 등의 효력이 소멸된 뒤에도 그 처분등의 취소로 인하여 회복되는 법률상 이익이 있는 자는 소송을 제기할 수 있도록 규정하고 있는데, 이를 협의의 소익의 근거로 보는 것이 일반적이다.

[행정소송법] 제12조 (원고적격)

취소소송은 처분등의 취소를 구할 법률상 이익이 있는 자가 제기할 수 있다. 처분등의 효과가 기간의 경과, 처분등의 집행 그 밖의 사유로 인하여 소멸된 뒤에도 그 처분등의 취소로 인하여 회복되는 법률상 이익이 있는 자의 경우에는 또한 같다.

(2) 회복되는 법률상 이익의 범위

a. 문제점

「행정소송법」 제12조 제2문의 회복되는 법률상 이익의 해석과 관련하여 전문의 법률상 이익과 동일하게 해석할 것인지 아니면 그 범위를 더 넓게 해석할 것인지에 대해 견해가 대립한다.

b. 학설

① 「행정소송법」 제12조 제2문의 회복되는 법률상의 이익을 전문의 법률상 이익과 같은 개념으로 보는 견해가 있고, ② 회복되는 법률상의 이익을 전단의 개념보다 넓게 해석하여 경제적, 정치적, 사회적, 문화적, 종교적 이익까지 포함하는 것으로 보는 견해가 대립한다.

c. 판례

판례는 후문의 회복되는 법률상의 이익과 전문의 법률상의 이익을 구별하지 않고, 처분으로 인한 명예, 신용 등 인격적인 이익이 침해되더라도 그러한 불이익은 처분의 직접적인 효과라고 할 수 없다고 하여 ①의 입장을 취한다.

대법원 1995. 10. 17. 선고 94누14148 전원합의체 판결

항고소송에 있어서 소의 이익이 인정되기 위하여는 행정소송법 제12조 소정의 "법률상 이익"이 있어야 하는바, 그 법률상 이익은 당해 처분의 근거 법률에 의하여 보호되는 직접적이고 구체적인 이익이 있는 경우를 말하고 간접적이거나 사실적, 경제적 이해관계를 가지는데 불과한 경우는 여기에 해당되지 아니한다.

d. 소결

「행정소송법」 제12조 제2문은 협의의 소익에 대한 근거 조항으로 전문의 법률상 이익과 후문의 회복되는 법률상 이익을 일치시킬 필요가 없으며, 국민의 권리구제 확대를 위해 전문의 법률상 이익보다 넓게 보아, 명예 신용 등 인격적 이익도 포함된다고 보는 것이 타당하다.

(3) 협의의 소익이 부정되는 경우

일반적으로 원고적격이 인정되면 협의의 소익이 긍정되지만, 몇 가지 경우에 협의의 소익(권리보호 필요성)이 부정된다. ① 취소소송보다 더 간이한 권리구제 수단이 있는 경우, ② 원고의 청구가 오로지 이론상으로만 의미있는 경우, ③ 원고가 오로지 부당한 목적으로 소송을 청구하는 소권남용에 해당하는 경우에는 협의의 소익이 부정된다.

(4) 처분의 효력기간이 경과하여 소멸한 경우

a. 원칙 (부정)

처분등의 효력이 소멸하면 원칙적으로 권리보호의 필요성이 없게 된다.

b. 예외 (긍정)

처분등의 효력이 소멸한 뒤에도 당해 처분을 취소할 현실적인 이익이 있는 경우에는 그 처분의 취소를 구할 협의의 소익이 인정된다.

c. 제재적 처분기준이 법령에 있는 경우

㉠ 문제점

법령등에서 제재적 처분기준을 규정하고 있어, 제재적 처분이 효력을 상실하였더라도 장래에 가중요건이나 전제요건이 되어 가중된 제재적 처분을 받을 위험이 있는 경우에 협의의 소익이 있는지가 문제 된다.

㉡ 학설

- ① 가중요건등이 법률이나 법규명령의 효력을 갖는 행정입법에 의해 규정되어 있다면 가중된 제재적 처분을 받을 불이익은 현실적이므로 협의의 소익이 인정되지만, 행정규칙으로 규정되어 있는 경우에는 불이익을 받을 현실적 위험이 불확실하여 협의의 소익을 부정하는 <부정설>과
- ② 제재적 처분기준이 행정규칙의 형식으로 규정된 경우에도 행정청이나 담당공무원은 행정규칙에 따라 가중된 제재적 처분을 행할 것이므로 장래 불이익을 받을 위험이 있다고 보아 긍정하는 <제한적 긍정설> 등이 있다.

㉢ 판례

종래에는 제재적 처분기준이 법률 또는 법적성질이 법규명령인 경우에만 소의 이익을 긍정했다. 그러나 최근 대법원은 판례를 변경하여 제재적 처분기준에서 가중사유나 전제요건을 규정하고 있다면, 그 기준의 법적성질이 법규명령인지 행정규칙인지와 상관없이 행정청은 이를 준수할 의무가 있으므로 선행처분을 받은 상대방이 장래에 불이익한 후행처분을 받을 위험은 구체적이고 현실적인 것이므로 협의의 소익을 긍정하는 입장이다.

대법원 2006. 6. 22. 선고 2003두1684 전원합의체 판결

제재적 행정처분이 그 처분에서 정한 제재기간의 경과로 인하여 그 효과가 소멸되었으나, 부령인 시행규칙 또는 지방자치단체의 규칙의 형식으로 정한 처분기준에서 제재적 행정처분을 받은 것을 가중사유나 전제요건으로 삼아 장래의 제재적 행정처분을 하도록 정하고 있는 경우, 제재적 행정처분의 가중사유나 전제요건에 관한 규정이 법령이 아니라 규칙의 형식으로 되어 있다고 하더라도, 그러한 규칙이 법령에 근거를 두고 있는 이상 그 법적 성질이 대외적·일반적 구속력을 갖는 법규명령인지 여부와는 상관없이, 관할 행정청이나 담당공무원은 이를 준수할 의무가 있으므로 이들이 그 규칙에 정해진 바에 따라 행정작용을 할 것이 당연히 예견되고, 그 결과 행정작용의 상대방인 국민으로서 그 규칙의 영향을 받을 수밖에 없다. 따라서 그러한 규칙이 정한 바에 따라 선행처분을 받은 상대방이 그 처분의 존재로 인하여 장래에 받을 불이익, 즉 후행처분의 위험은 구체적이고 현실적인 것이므로, 상대방에게는 선행처분의 취소소송을 통하여 그 불이익을 제거할 필요가 있다.

대법관 이강국의 별개의견

다수의견은, 제재적 행정처분의 기준을 정한 부령인 시행규칙의 법적 성질에 대하여는 구체적인 논급을 하지 않은 채, 시행규칙에서 선행처분을 받은 것을 가중사유나 전제요건으로 하여 장래 후행처분을 하도록 규정하고 있는 경우, 선행처분의 상대방이 그 처분의 존재로 인하여 장래에 받을 불이익은 구체적이고 현실적이라는 이유로, 선행처분에서 정한 제재기간이 경과한 후에도 그 처분의 취소를 구할 법률상 이익이 있다고 보고 있는바, 다수의견이 위와 같은 경우 선행처분의 취소를 구할 법률상 이익을 긍정하는 결론에는 찬성하지만, 그 이유에 있어서는 **부령인 제재적 처분기준의 법규성을 인정하는 이론적 기초 위에서 그 법률상 이익을 긍정하는 것이 법리적으로는 더욱 합당하다고 생각한다.** 상위법령의 위임에 따라 제재적 처분기준을 정한 **부령인 시행규칙은 헌법 제95조에서 규정하고 있는 위임명령에 해당**하고, 그 **내용도 실질적으로 국민의 권리의무에 직접 영향을 미치는 사항에 관한 것이므로, 단순히 행정기관 내부의 사무처리준칙에 지나지 않는 것이 아니라 대외적으로 국민이나 법원을 구속하는 법규명령에 해당한다고 보아야 한다.**

㉔ 소결

가중요건이 규정된 제재적 처분기준이 행정규칙의 형식으로 규정되어 있더라도, 담당공무원은 이를 준수할 의무가 있다. 따라서, 제재적 처분의 상대방은 그 처분의 효력이 소멸한 이후에도 당초 처분의 취소를 통해 장래 가중된 처분을 받을 불이익을 제거할 소의 이익이 인정되므로 <제한적 긍정설>이 타당하다. 이는 제재적 처분기준이 법규명령형식의 행정규칙으로 규정되어 있는 경우도 마찬가지이다.

5) 제소기간 (「행정소송법」 제20조) [★★★]

[행정소송법] 제20조 (제소기간)

- ① 취소소송은 처분등이 있음을 안 날부터 90일 이내에 제기하여야 한다. 다만, 제18조제1항 단서에 규정한 경우와 그 밖에 행정심판청구를 할 수 있는 경우 또는 행정청이 행정심판청구를 할 수 있다고 잘못 알린 경우에 행정심판청구가 있는 때의 기간은 재결서의 정본을 송달받은 날부터 기산한다.
- ② 취소소송은 처분등이 있는 날부터 1년(第1項 但書の 경우는 裁決이 있는 날부터 1年)을 경과하면 이를 제기하지 못한다. 다만, 정당한 사유가 있는 때에는 그러하지 아니하다.
- ③ 제1항의 규정에 의한 기간은 불변기간으로 한다.

(1) 의의

제소기간이란 소송을 제기할 수 있는 시간적 간격을 말한다. 제소기간은 행정의 안정성과 국민의 재판청구권의 조화를 고려해 입법 정책적으로 규정하며, 제소기간의 준수 여부는 법원의 직권조사사항이다.

(2) 안 날부터 90일

a. 행정심판을 거치지 않은 경우

취소소송은 **처분등이 있음을 안 날부터 90일 이내에** 제기하여야 하는데, ‘처분 등이 있음을 안 날’이란 **통지, 공고, 기타의 방법에 의하여 당해 처분 등이 있었다는 사실을 현실적으로 안 날**을 의미하고, 상대방이 있는 행정처분의 경우에는 행정처분이 **상대방에게 고지되어 상대방이 이러한 사실을 인식함**으로써 행정처분이 있다는 사실을 **현실적으로 알았을 때**를 의미한다. 일반적으로 처분에 관한 서류가 당사자의 주소지에 송달되는 등 **사회통념상 처분이 있음을 당사자가 알 수 있는 상태에 놓여진 때**에는 반증이 없는 한 그 처분이 있음을 알았다고 추정할 수 있다.

대법원 2014. 9. 25. 선고 2014두8254 판결

행정소송법 제20조 제1항이 정한 제소기간의 기산점인 '처분 등이 있음을 안 날'이란 통지, 공고 기타의 방법에 의하여 당해 처분 등이 있었다는 사실을 현실적으로 안 날을 의미한다. 상대방이 있는 행정처분의 경우에는 특별한 규정이 없는 한 의사표시의 일반적 법리에 따라 행정처분이 상대방에게 고지되어야 효력을 발생하게 되므로, 행정처분이 상대방에게 고지되어 상대방이 이러한 사실을 인식함으로써 행정처분이 있다는 사실을 현실적으로 알았을 때 행정소송법 제20조 제1항이 정한 제소기간이 진행한다고 보아야 한다.

대법원 1999. 12. 28. 선고 99두9742 판결

행정심판법 제18조 제1항 소정의 심판청구기간 기산점인 '처분이 있음을 안 날'이라 함은 당사자가 통지·공고 기타의 방법에 의하여 당해 처분이 있었다는 사실을 현실적으로 안 날을 의미하고, 추상적으로 알 수 있었던 날을 의미하는 것은 아니지만, 처분에 관한 서류가 당사자의 주소지에 송달되는 등 사회통념상 처분이 있음을 당사자가 알 수 있는 상태에 놓여진 때에는 반증이 없는 한 그 처분이 있음을 알았다고 추정할 수 있다.

[공고 또는 고시에 의한 방법으로 통지되는 경우]

고시 또는 공고에 의하여 행정처분을 하는 경우에는 그 처분의 상대방이 불특정 다수인이고, 그 처분의 효력이 불특정 다수인에게 일률적으로 적용되어야 하므로 고시 또는 공고의 효력발생일을 '처분 등이 있음을 안 날'로 보아 제소기간을 기산하여야 한다고 본다.

대법원 2006. 4. 14. 선고 2004두3847 판결

통상 고시 또는 공고에 의하여 행정처분을 하는 경우에는 그 처분의 상대방이 불특정 다수인이고, 그 처분의 효력이 불특정 다수인에게 일률적으로 적용되는 것이므로, 그 행정처분에 이해관계를 갖는 자는 고시 또는 공고가 있었다는 사실을 현실적으로 알았는지 여부에 관계없이 고시가 효력을 발생하는 날에 행정처분이 있음을 알았다고 보아야 하고, 따라서 그에 대한 취소소송은 그 날로부터 90일 이내에 제기하여야 한다.

대법원 1993. 12. 24. 선고 92누17204 판결

개별토지가격결정에 있어서는 그 처분의 고지방법에 있어 개별토지가격합동조사지침의 규정에 의하여 행정편의상 일단의 각 개별토지에 대한 가격결정을 일괄하여 읍·면·동의 게시판에 공고하는 것일 뿐 그 처분의 효력은 각각의 토지 또는 각각의 소유자에 대하여 각별로 효력을 발생하는 것이므로 개별토지가격결정의 공고는 공고 일로부터 그 효력을 발생하지만 처분 상대방인 토지소유자 및 이해관계인이 공고일에 개별토지가격결정처분이 있음을 알았다고까지 의제할 수는 없어 결국 개별토지가격결정에 대한 재조사 또는 행정심판의 청구기간은 처분 상대방이 실제로 처분이 있음을 안 날로부터 기산하여야 할 것이나, 시장, 군수 또는 구청장이 개별토지가격결정을 처분 상대방에 대하여 별도의 고지절차를 취하지 않는 이상 토지소유자 및 이해관계인이 위 처분이 있음을 알았다고 볼 경우는 그리 흔치 않을 것이므로, 특별히 위 처분을 알았다고 볼만한 사정이 없는 한 개별토지가격결정에 대한 재조사청구 또는 행정심판청구는 행정심판법 제18조 제3항 소정의 처분이 있는 날로부터 180일 이내에 이를 제기하면 된다.

b. 행정심판을 거친 경우

행정심판법 제18조 제1항 단서에 규정한 경우(다른 법률에 당해 처분에 대한 행정심판의 재결을 거치지 아니하면 취소소송을 제기할 수 없다는 규정이 있는 때)와 그 밖에 행정심판청구를 할 수 있는 경우 또는 행정청이 행정심판청구를 할 수 있다고 잘못 알린 경우에 행정심판청구가 있는 때의 기간은 재결서의 정본을 송달받은 날부터 기산한다. 즉, 행정심판을 거친 경우는 행정심판에 대한 재결서 정본을 송달받은 날부터 90일 이내에 취소소송을 제기하여야 한다.

대법원 2006. 9. 8. 선고 2004두947 판결

행정소송법 제20조 제1항에 의하면 취소소송은 원칙적으로 처분 등이 있음을 안 날부터 90일 이내에 제기하여야 하나, 행정청이 행정심판청구를 할 수 있다고 잘못 알려 행정심판의 청구를 한 경우에는 그 제소기간은 행정심판 재결서의 정본을 송달받은 날부터 기산하여야 한다.

대법원 2012. 9. 27. 선고 2011두27247 판결

이미 제소기간이 지남으로써 불가쟁력이 발생하여 불복청구를 할 수 없었던 경우라면 그 이후에 행정청이 행정심판 청구를 할 수 있다고 잘못 알렸다고 하더라도 그 때문에 처분 상대방이 적법한 제소기간 내에 취소소송을 제기할 수 있는 기회를 상실하게 된 것은 아니므로 이러한 경우에 잘못된 안내에 따라 청구된 행정심판 재결서 정본을 송달받은 날부터 다시 취소소송의 제소기간이 기산되는 것은 아니다.

c. 불변기간

불변기간이란 법정기간으로 법원 등이 기간을 변경할 수 없는 것을 말한다.

위 90일은 불변기간(행정소송법 제20조 제3항)으로 법원 등이 기간을 늘리거나 단축시킬 수 없다.

(3) 있는 날부터 1년

a. 행정심판을 거치지 않은 경우

취소소송은 처분등이 있는 날부터 1년을 경과하면 제기하지 못한다.

즉, 처분이 있는 날로부터 1년 내에 취소소송을 제기하여야 한다. ‘처분이 있는 날’이란 행정처분이 상대방에게 도달되어 효력이 발생한 날이라는 것이 통설·판례의 입장이다.

대법원 1990. 7. 13. 선고 90누2284 판결

행정소송법 제20조 제2항에서 “처분이 있는 날”이라 함은 상대방이 있는 행정처분의 경우는 특별한 규정이 없는 한 의사표시의 일반적 법리에 따라 그 행정처분이 상대방에게 고지되어 효력이 발생한 날을 말한다고 할 것이다.

b. 행정심판을 거친 경우

행정소송법 제20조 제2항 본문에서 ‘취소소송은 처분등이 있는 날부터 1년’이라고 규정하고 있는데, 이 처분등에는 행정심판에 따른 재결도 포함된다. 따라서 재결이 있는 날부터 1년 이내에 취소소송을 제기하여야 한다.

c. 정당한 사유

행정소송법 제20조 제2항 단서에서는 정당한 사유가 있는 때에는 처분등이 있은 날부터 1년이 경과하여도 제소할 수 있다고 규정하고 있다. 여기서 '정당한 사유'란 사회통념에 따라 개별적·구체적으로 판단하여야 한다고 보는 것이 판례의 태도이다. 또한, 제3자요 행정행위에서 처분의 상대방이 아닌 제3자는 특별한 사정이 없는 한 정당한 사유가 있는 경우에 해당 하여 행정소송법 제20조 제2항 본문의 취소소송 제기기간을 배제할 수 있다고 본다.

대법원 1991. 6. 28. 선고 90누6521 판결

행정소송법 제20조 제2항 소정의 "정당한 사유"란 불확정 개념으로서 그 존부는 사안에 따라 개별적, 구체적으로 판단하여야 하나 민사소송법 제160조의 "당사자가 그 책임을 질 수 없는 사유"나 행정심판법 제18조 제2항 소정의 "천재, 지변, 전쟁, 사변 그 밖에 불가항력적인 사유"보다는 넓은 개념이라고 풀이되므로, 제소기간도과의 원인 등 여러 사정을 종합하여 지연된 제소를 허용하는 것이 사회통념상 상당하다고 할 수 있는가에 의하여 판단하여야 한다.

대법원 1989. 5. 9. 선고 88누5150 판결

행정처분의 직접상대방이 아닌 제3자는 행정처분이 있음을 곧 알 수 없는 처지이므로 행정심판법 제18조 제3항 소정의 심판청구의 제척기간내에 처분이 있음을 알았다는 특별한 사정이 없는 한 그 제척기간의 적용을 배제할 같은 조항 단서 소정의 정당한 사유가 있는 때에 해당한다.

(4) 안 날과 있는 날의 관계

처분이 있음을 안 날과 처분이 있은 날 중 어느 하나의 기간이라도 경과 하면 제소할 수 없다.
즉, 양자 중 먼저 경과하는 날을 기준으로 제소기간은 종료 된다.

(5) 이의신청을 거친 경우

[행정기본법] 제36조 (처분에 대한 이의신청)

- ① 행정청의 처분(「행정심판법」 제3조에 따라 같은 법에 따른 행정심판의 대상이 되는 처분을 말한다. 이하 이 조에서 같다)에 이의가 있는 당사자는 처분을 받은 날부터 30일 이내에 해당 행정청에 이의신청을 할 수 있다.
- ② 행정청은 제1항에 따른 이의신청을 받으면 그 신청을 받은 날부터 14일 이내에 그 이의신청에 대한 결과를 신청인에게 통지하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 14일 이내에 통지할 수 없는 경우에는 그 기간을 만료일 다음 날부터 기산하여 10일의 범위에서 한 차례 연장할 수 있으며, 연장 사유를 신청인에게 통지하여야 한다.
- ③ 제1항에 따라 이의신청을 한 경우에도 그 이의신청과 관계없이 「행정심판법」에 따른 행정심판 또는 「행정소송법」에 따른 행정소송을 제기할 수 있다.
- ④ 이의신청에 대한 결과를 통지받은 후 행정심판 또는 행정소송을 제기하려는 자는 그 결과를 통지받은 날(제2항에 따른 통지기간 내에 결과를 통지받지 못한 경우에는 같은 항에 따른 통지기간이 만료되는 날의 다음 날을 말한다)부터 90일 이내에 행정심판 또는 행정소송을 제기할 수 있다.

처분에 이의가 있는 당사자는 처분을 받을 날부터 30일 이내에 해당 행정청에 이의를 신청할 수 있고(행정기본법 제36조 제1항), 이러한 이의신청을 거친 경우에는 행정기본법 제36조 제4항이 적용되어 이의신청에 대한 결과를 통지받은 날부터 90일 이내에 행정심판 또는 행정소송을 제기할 수 있다.

※ 법제처 해석에서 행정기본법 제36조 제4항의 '90일'은 결과를 통지받은 날부터 기산되므로 이의신청이나 행정심판 및 행정소송의 제기를 동시에 하거나 이의신청에 대한 결과를 받기 전에 이뤄지는 경우에는 위 조항이 적용되지 않는다'고 본다(이효진).

6) 피고적격 (「행정소송법」 제13조)

피고적격을 가진 자는 처분 등을 행한 행정청, 즉 처분청이 됨이 원칙이다(행정소송법 제13조). 처분청이라 함은 국가 또는 공공단체 등의 의사를 결정하여 외부적으로 표시할 수 있는 기관을 의미한다. 또한, 피고를 잘못 지정한 경우 피고경정을 통해 피고를 변경할 수 있다.

7) 행정심판의 전치 (「행정소송법」 제18조)

행정심판의 전치란 행정소송을 제기하기 전에 행정청에 먼저 행정심판을 청구하여 처분의 시정을 구하고, 그에 불복하는 경우에 비로소 소송을 제기하는 것을 말한다. 행정소송법은 행정심판 임의주의를 취하고 있다. 따라서 처분에 대해 행정심판을 거쳐서 취소소송을 제기할 수도 있고, 곧바로 취소소송을 제기할 수도 있다. 만일 개별법에서 행정심판 전치주의를 규정하고 있다면, 행정소송을 제기하기 전에 반드시 행정심판을 거친 후 행정소송을 제기 할 수 있다.

03 가구제

가구제란 소송의 본안판결이 확정되기 전에 원고의 권리보호를 위해 잠정적으로 행해지는 수단을 말한다. 소송의 실효성 확보를 위한 가구제로는 집행정지제도와 가처분이 있는데, 행정소송법에서는 집행정지만을 규정하고 있어 민사집행법상의 가처분을 행정소송에서도 준용할 수 있는지가 문제 된다.

1) 집행정지 [★★★]

(1) 집행부정지 원칙과 집행정지(예외) (「행정소송법」 제23조)

행정소송법 제23조 제1항은 '취소소송의 제기는 처분등의 효력이나 그 집행 또는 절차의 속행에 영향을 주지 아니한다'고 하여 집행부정지를 원칙으로 규정하고 있다. 또한, 동조 제2항에서는 예외 규정으로 일정한 요건 하에서 처분의 효력등을 정지시키는 집행정지를 인정하고 있다. 소송의 과정은 장기간 소요되기도 하는데, 소송이 길어지면 승소판결이 있다고 하더라도 당사자에게 회복되기 어려운 손해가 발생하는 등 실익이 없는 경우가 있을 수 있다. 따라서 예외적으로 집행정지를 인정하여 효과적인 권리보호를 실현하는데 그 취지가 인정된다.

[행정소송법] 제23조 (집행정지)

- ① 취소소송의 제기는 처분등의 효력이나 그 집행 또는 절차의 속행에 영향을 주지 아니한다.
- ② 취소소송이 제기된 경우에 처분등이나 그 집행 또는 절차의 속행으로 인하여 생길 회복하기 어려운 손해를 예방하기 위하여 긴급한 필요가 있다고 인정할 때에는 본안이 계속되고 있는 법원은 당사자의 신청 또는 직권에 의하여 처분등의 효력이나 그 집행 또는 절차의 속행의 전부 또는 일부의 정지(이하 "執行停止"라 한다)를 결정할 수 있다. 다만, 처분의 효력정지는 처분등의 집행 또는 절차의 속행을 정지함으로써 목적을 달성할 수 있는 경우에는 허용되지 아니한다.
- ③ 집행정지는 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 있을 때에는 허용되지 아니한다.

(2) 요건

집행정지의 요건은 적극적 요건과 소극적 요건으로 구분할 수 있다. 판례는 적극적 요건에 관한 주장·소명책임은 신청인측에 있고, 소극적 요건의 주장·소명책임은 행정청에게 있다고 본다.

대법원 1999. 12. 20.자 99무42 결정

행정소송법 제23조 제2항에서 행정청의 처분에 대한 집행정지의 요건으로 들고 있는 '회복하기 어려운 손해'라고 하는 것은 원상회복 또는 금전배상이 불가능한 손해는 물론 종국적으로 금전배상이 가능하다고 하더라도 그 손해의 성질이나 태양 등에 비추어 사회통념상 그러한 금전배상만으로는 전보되지 아니할 것으로 인정되는 현저한 손해를 가리키는 것으로서 이러한 집행정지의 적극적 요건에 관한 주장·소명책임은 원칙적으로 신청인측에 있다.

행정소송법 제23조 제3항에서 집행정지의 요건으로 규정하고 있는 '공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려'가 없을 것이라고 할 때의 '공공복리'는 그 처분의 집행과 관련된 구체적이고도 개별적인 공익을 말하는 것으로서 이러한 집행정지의 소극적 요건에 대한 주장·소명책임은 행정청에게 있다.

a. 적극적 요건

① 적법한 본안소송의 계속

민사소송법상의 가구제와는 다르게 행정소송법상 집행정지를 신청하기 위해서는 적법한 본안소송이 계속 중일 것을 요한다. 따라서 본안소송이 취하되면 집행정지결정의 효력도 소멸한다.

② 처분 등의 존재

집행정지의 대상이 되는 처분 등이 존재하여야 한다. 따라서 부작위에 대해서는 집행정지가 허용되지 않고, 처분의 효력이 발생하기 전이나 처분의 효력이 소멸된 후에도 집행정지가 허용되지 않는다.

[거부처분의 집행정지 가능성]

1. 문제점

집행정지는 처분이 없었던 것과 같은 종전의 상태로 회복시키는 소극적인 조치일뿐 종전 상태를 변경시키는 적극적인 조치는 아니다. 따라서 거부처분취소소송에서 거부처분이 집행정지의 대상이 될 수 있는지가 문제 된다.

2. 학설

- ① 집행정지결정은 행정청에 사실상의 구속력을 가진다고 보아 긍정하는 <긍정설>.
- ② 집행정지는 처분이 없었던 것과 같은 상태를 만드는 것일 뿐이며, 행정소송법 제23조 제6항은 집행정지결정의 구속력과 관련하여 행정소송법 제30조 제1항만을 준용하고, 재처분의무를 규정한 동조 제2항을 준용하지 아니하므로 거부처분의 집행정지를 부정하는 <부정설> 및
- ③ 원칙적으로는 거부처분의 집행정지를 부정하나, 예외적으로 갱신허가의 거부와 같이 신청인에게 어떠한 법적 이익이 있다고 인정되는 경우에는 집행정지를 인정할 실익이 있으므로 제한적으로 긍정하여야 한다고 보는 <제한적 긍정설>이 있다.

3. 판례

판례는 거부처분의 효력을 정지하더라도 거부처분이 없었던 것과 같은 즉, 신청의 상태로 되돌아가는 데에 불과하고, 행정청에게 신청에 따른 처분을 할 의무가 생기는 것은 아니므로 부정하는 <부정설>의 입장을 취한다.

대법원 1995. 6. 21.자 95두26 결정

신청에 대한 거부처분의 효력을 정지하더라도 거부처분이 없었던 것과 같은 상태, 즉 거부처분이 있기 전의 신청시의 상태로 되돌아가는 데에 불과하고 행정청에게 신청에 따른 처분을 하여야 할 의무가 생기는 것이 아니므로, 거부처분의 효력정지는 그 거부처분으로 인하여 신청인에게 생길 손해를 방지하는 데 아무런 보탬이 되지 아니하여 그 효력정지를 구할 이익이 없다.

4. 소결

쟁신허가 신청에 대한 거부처분과 같이 거부처분이 없었던 상태로 돌아가는 경우 이전 권리가 계속 존속될 수 있는 경우라면, 신청인에게 법적 이익이 인정될 수 있으므로 <제한적 긍정설>이 타당하다.

③ 회복하기 어려운 손해발생의 우려

처분등이나 그 집행 또는 절차의 속행으로 인하여 생길 회복하기 어려운 손해가 발생할 우려가 있어야 한다. '회복하기 어려운 손해'란 특별한 사정이 없는 한 금전으로 보상할 수 없는 손해로서 이는 금전보상이 불능인 경우 또는 금전보상으로는 사회관념상 당사자가 참고 견딜수 없거나 또는 참고 견디기가 현저히 곤란한 경우의 유형, 무형의 손해를 말한다. 특히, 기업의 경우 기업 이미지 및 신용의 훼손으로 인하여 사업 자체를 계속할 수 없거나 중대한 경영상의 위기를 맞게 될 것으로 보이는 등의 사정이 이에 해당될 수 있다.

대법원 2003. 4. 25.자 2003무2 결정

행정소송법 제23조 제2항에 정하고 있는 행정처분 등의 집행정지 요건인 '회복하기 어려운 손해'라 함은 특별한 사정이 없는 한 금전으로 보상할 수 없는 손해로서 이는 금전보상이 불능인 경우 내지는 금전보상으로는 사회관념상 행정처분을 받은 당사자가 참고 견딜 수 없거나 또는 참고 견디기가 곤란한 경우의 유형, 무형의 손해를 일컫는다.

당사자가 행정처분 등이나 그 집행 또는 절차의 속행으로 인하여 재산상의 손해를 입거나 기업 이미지 및 신용이 훼손당하였다고 주장하는 경우에 그 손해가 금전으로 보상할 수 없어 '회복하기 어려운 손해'에 해당한다고 하기 위해서는, 그 경제적 손실이나 기업 이미지 및 신용의 훼손으로 인하여 사업자의 자금사정이나 경영 전반에 미치는 파급효과가 매우 중대하여 사업 자체를 계속할 수 없거나 중대한 경영상의 위기를 맞게 될 것으로 보이는 등의 사정이 존재하여야 한다.

④ 긴급한 필요

회복하기 어려운 손해를 예방하기 위하여 긴급한 필요가 있다고 인정되어야 한다. '긴급한 필요'란 본안판결을 기다릴 여유가 없는 것을 의미한다. 판례는 처분의 성질과 내용, 처분상대방이 입는 손해, 원상회복·금전배상의 방법 및 난이 등은 물론 본안청구의 승소가능성의 정도 등을 종합적으로 고려하여 구체적·개별적으로 판단하여야 한다고 본다.

대법원 2018. 7. 12.자 2018무600

'처분 등이나 그 집행 또는 절차의 속행으로 인하여 생길 회복하기 어려운 손해를 예방하기 위하여 긴급한 필요'가 있는지는 처분의 성질, 양태와 내용, 처분상대방이 입는 손해의 성질·내용과 정도, 원상회복·금전배상의 방법과 난이도 등은 물론 본안청구의 승소가능성 정도 등을 종합적으로 고려하여 구체적·개별적으로 판단하여야 한다.

b. 소극적 요건

① 공공복리에 중대한 영향을 줄 우려가 없을 것

행정소송법 제23조 제3항에 의거 집행정지는 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 있는 경우에는 허용되지 않는다. 여기서의 '공공복리'는 그 처분의 집행과 관련된 구체적이고도 개별적인 공익을 말하는 것이라고 보는 것이 판례의 입장이며, 비례의 원칙에 의해 집행정지가 공공복리에 미치는 영향과 집행부정지를 통해 당사자가 입는 손해를 비교·형량하여 결정한다.

② 본안청구가 이유 없음이 명백하지 아니할 것

행정소송법상 명문으로 규정된 요건은 아니지만 '본안청구가 이유 없음이 명백하지 아니할 것'이 집행정지의 소극적 요건인지에 대해 견해 대립이 있다. 이에 대해 처분의 취소 가능성이 없음에도 집행정지를 인정하는 것은 집행정지제도의 취지에 반하며, 집행정지신청의 남용을 방지할 필요도 있으므로 '본안청구가 이유 없음이 명백하지 아니할 것'을 집행정지의 소극적 요건으로 보는 것이 일반적 견해이다.

(3) 내용

집행정지의 내용에는 ① 처분 효력의 정지, ② 집행의 정지 및 ③ 절차의 속행을 정지하는 것이 있다. 다만, 처분의 효력정지는 처분등의 집행 또는 절차의 속행을 정지함으로써 목적을 달성할 수 있는 경우에는 허용되지 않는다(행정소송법 제23조 제2항 단서).

(4) 절차 및 효력

집행정지는 법원이 당사자의 신청 또는 직권에 의하여 결정할 수 있다. 행정소송법 제23조 제6항에서는 집행정지 결정은 동법 제30조 제1항의 규정을 준용한다고 규정하고 있다. 따라서 집행정지의 결정은 기속력에 의해 당사자인 행정청과 관계 행정청을 기속하여, 집행정지결정에 반하는 처분을 할 수 없다. 또한 이 기속력은 제3자효 행정행위의 경우에는 신청인과 피신청인뿐만 아니라 제3자에게도 미친다. 집행정지 효력은 결정시부터 발생하고, 결정주문에서 따로 정하는 것을 제외하고는 본안소송의 판결확정시까지 존속한다.

(5) 불복 및 취소

행정소송법 제23조 제5항에 의거 집행정지의 결정 또는 기각의 결정에 대하여 즉시항고할 수 있다. 다만, 집행정지의 결정에 대해 즉시항고 하더라도 결정의 집행을 정지하는 효력은 없다. 또한, 집행정지의 결정이 확정된 후 집행정지가 공공복리에 중대한 영향을 미치거나 그 정지사유가 없어진 때에는 당사자의 신청 또는 직권에 의하여 결정으로써 집행정지의 결정을 취소할 수 있다(행정소송법 제24조 제1항).

2) 가처분 가능성 [★★]

(1) 문제점

가처분이란 확정판결이 있을 때까지 발생할 수 있는 현저한 손해나 급박한 위험 등을 막기 위해 다툼이 있는 권리관계에 대하여 임시의 지위를 정하는 것을 목적으로 하는 가구제 수단을 말한다(「민사집행법」 제300조). 행정소송법에는 가처분에 대한 명문의 규정을 두고 있지 않아 민사집행법의 가처분에 관한 규정을 준용할 수 있는지가 문제 된다.

(2) 학설

- ① 행정소송법이 가처분을 배제하는 규정을 두고 있지 않고, 행정소송법 제8조 제2항에 의거 민사집행법상 가처분이 준용될 수 있다고 보는 <긍정설>.
- ② 권력분립의 원칙상 가처분을 인정하는 것은 사법권의 범위를 벗어나는 것이고, 현행법상 가처분의 본안소송인 의무이행소송을 인정하고 있지 않아 가처분을 부정하는 <부정설> 및
- ③ 행정소송법이 집행정지제도를 두고 있는 관계상 집행정지를 통해 실효적인 권리구제가 되지 않는 경우에만 가처분제도가 인정될 수 있다고 보는 <제한적 긍정설>이 있다.

(3) 판례

판례는 민사집행법상의 가처분으로 행정청의 행정행위 금지를 구하는 것은 허용될 수 없다고 하여 <부정설>의 입장을 취한다.

대법원 2011. 4. 18.자 2010마1576 결정

민사집행법 제300조 제2항이 규정한 임시의 지위를 정하기 위한 가처분은 그 성질상 주장 자체에 의하여 다툼이 있는 권리관계에 관한 정당한 이익이 있는 자가 가처분 신청을 할 수 있고, 그 경우 주장 자체에 의하여 신청인과 저촉되는 지위에 있는 자를 피신청인으로 하여야 한다. 한편 민사집행법상의 가처분으로 행정청의 행정행위 금지를 구하는 것은 허용될 수 없다.

(4) 소결

행정소송법에서 가구제 수단으로서 집행정지제도를 규정하고 있는데, 이는 민사집행법상의 가처분제도를 배제하는 특별 규정으로 볼 수 있다. 따라서 해석론상으로는 <부정설>이 타당하다. 다만, 국민의 권리보호 확대를 위해 입법론적으로는 가처분제도의 도입이 필요하며, 행정소송법 개정안에서도 가처분제도를 인정하고 있다.

04 취소소송의 심리

1) 심리의 원칙 (당사자주의)

소송의 심리란 소에 대한 판결을 하기 위하여 그 기초가 되는 소송자료를 수집하는 절차를 말한다.

심리는 소송요건심리와 본안심리로 나누어지고, 소송요건 충족여부는 법원이 직권으로 조사할 수 있다.

법원은 소송요건이 충족되지 못한 경우에는 소송을 각하하고, 소송요건이 충족된 경우에는 본안심리를 통해 인용판결 또는 기각판결을 내린다.

심리에 관한 원칙으로는 당사자주의와 직권주의가 있다. 당사자주의는 소송절차에서 당사자에게 주도권을 부여한다는 원칙이고, 직권주의는 법원의 주도권을 인정하는 원칙이다. 행정소송은 당사자주의를 취한다고 보는 것이 일반적이며, 행정소송법 제26조에서 직권심리주의를 보충적으로 인정하고 있다. 당사자주의는 처분권주의와 변론주의를 그 내용으로 하는데, 처분권 주의는 소송의 개시, 종료 또는 그 범위의 결정을 소송 당사자가 결정할 수 있다는 원칙을 말하고, 변론주의는 판결의 기초가 되는 자료의 수집·제출을 당사자의 권능과 책임으로 맡기는 원칙을 말한다.

2) 심리의 범위 (불고불리의 원칙)

행정소송법 제8조에 의해 불고불리의 원칙이 적용된다(민사소송법 제203조).

불고불리의 원칙이란 법원은 **소송의 제기가 없으면 재판할 수 없고**, 소송의 제기가 있는 경우에도 당사자가 신청한 사항에 대하여 **신청의 범위 내에서만 심리·판단**하여야 하는 것을 말한다.

3) 처분사유의 추가·변경 [★★★]

(1) 의의

처분사유의 추가·변경이란 처분청이 처분을 하면서 제시하지 않은 처분의 사실상·법률상 근거를 행정소송 계속 중에 추가·변경하여 처분의 적법성을 유지하는 것을 말한다. 처분사유의 추가·변경은 소송경쟁 및 분쟁의 일회적 해결을 위해 그 취지가 인정되며, 원고의 방어권 보장과 이유제시제도의 취지를 고려하여 일정한 한계 내에서 이루어진다.

(2) 구별개념

처분사유의 추가·변경은 소송의 심리에 관한 것으로 **실질적 적법성** 및 **소송법상**의 문제이고, 절차상 하자의 치유는 형식적 적법성 및 행정작용법상의 문제로 양자는 구별된다.
또한, 처분사유의 추가·변경은 처분의 동일성(소송물)을 전제로 하므로 처분변경으로 인한 소의 변경(행정소송법 제22조)과도 다르다.

※ 소의 변경이란?

종전의 청구를 새로운 청구로 변경하거나 새로운 청구를 추가하는 것으로, 소송물의 변경을 말한다.

(3) 인정 여부

a. 문제점

행정소송법은 처분사유의 추가·변경에 관한 명문의 규정을 두고 있지 않아 행정소송 계속 중에 처분사유의 추가·변경이 인정될 수 있는지에 대한 견해가 대립한다.

b. 학설

- ① 처분사유의 추가·변경을 거부하여도 행정청은 새로운 사유를 들어 새로운 처분을 할 수 있으므로 분쟁의 일회적 해결과 소송경제 측면에서 추가·변경을 인정하는 <긍정설>.
- ② 처분사유의 추가·변경을 인정하면 처분의 상대방은 예기치 않은 불이익을 받을 수 있으므로 부정하는 <부정설>
- ③ **소송경제와 원고의 방어권 보장을 조화**시켜 제한적으로 허용하여야 한다고 보는 <제한적 긍정설>이 있다.

c. 판례

판례는 당초 처분의 근거로 삼은 사유와 **기본적 사실관계의 동일성**이 있다고 인정되는 한도 내에서만 다른 사유를 추가하거나 변경할 수 있다고 하여 <제한적 긍정설>의 입장을 취한다.

대법원 1992. 2. 14. 선고 91누3895 판결

행정처분의 취소를 구하는 항고소송에 있어서 처분청은 당초 처분의 근거로 삼은 사유와 **기본적 사실관계가 동일성이 있다고 인정되는 한도 내에서만** 다른 사유를 추가하거나 변경할 수 있을 뿐, 기본적 사실관계와 동일성이 인정되지 않는 별개의 사실을 들어 처분사유로서 주장함은 허용되지 아니한다.

d. 소결

처분사유의 추가·변경을 부정하면 당해 처분이 취소되더라도 처분청은 다른 사유를 들어 새로운 재처분을 할 수 있으므로 소송경제 측면에서 타당하지 않다. 따라서 **소송경제와 원고의 방어권을 보장을 조화시켜 당초 처분사유와 기본적 사실관계가 동일한 범위 내에서만 제한적으로 처분사유의 추가·변경을 긍정함**이 타당하다.

(4) 인정 요건

a. 시간적 범위

① 처분사유의 추가·변경은 **사실심 변론종결시**까지만 허용되며, ② 취소소송에서 처분의 위법성 판단의 기준시점을 처분시로 보는 **〈처분시설〉**에 따르면 **처분시에 객관적으로 존재하였던 사유**만이 처분사유의 추가·변경의 대상이 된다. 다만, 위법성 판단시점에 대해 판결시설 또는 절충설을 취하는 경우에는 판결시까지의 사유도 처분사유의 추가·변경의 대상이 될 수 있다고 볼 수 있으나, 이는 판결의 지체 여부에 따라서 판결의 내용이 달라질 수 있다는 문제가 있다.

대법원 1999. 8. 20. 선고 98두17043 판결

행정청은 기본적 사실관계의 동일성이 있다고 인정되는 한도 내에서만 다른 처분사유를 추가, 변경할 수 있다고 할 것이나 이는 **사실심 변론종결시**까지만 허용된다.

[처분의 위법성 판단의 기준시점] [★]

1. 문제점

처분 등이 이루어진 후에 당해 처분 등의 근거가 된 **법령 및 사실상태가 변경되는** 경우가 있다. 이러한 경우에 법원이 처분의 위법여부를 판단함에 있어서 어느 시점의 법령 및 사실상태를 기준으로 하여야 하는지가 문제 된다.

2. 학설

- ① 처분 이후의 사정을 고려하는 것은 행정권의 1차적 판단을 침해하는 것이므로, 처분 등의 위법 여부의 판단은 **처분시의 법령 및 사실상태를** 기준으로 하여야 한다고 보는 〈처분시설〉,
- ② 취소소송의 본질은 처분으로 인해 형성된 위법상태를 제거하는 것에 있으므로, **판결시의 법령 및 사실상태를** 기준으로 처분의 위법 여부를 판단하여야 한다고 보는 〈판결시설〉 및
- ③ 원칙적으로 **처분시설**을 취하나, 예외적으로 계속효 있는 행위(압수처분, 영업허가의 취소) 등에 대한 소송에 있어서는 **판결시**라고 보는 〈절충설〉이 있다.

3. 판례

판례는 행정처분의 위법 여부는 행정처분이 행해졌을 때의 법령과 사실상태를 기준으로 판단하여야 한다고 하여 〈처분시설〉을 취한다.

대법원 2007. 5. 11. 선고 2007두1811 판결

행정소송에서 행정처분의 위법 여부는 행정처분이 행하여졌을 때의 법령과 사실상태를 기준으로 하여 판단하여야 하고, 처분 후 법령의 개폐나 사실상태의 변동에 의하여 영향을 받지 않는다.

4. 소결

행정소송의 본질은 개인의 권익구제에 있고, 취소소송은 위법한 처분 등에 의해 권익을 침해당한 자가 처분을 다투어 취소를 구하는 것이므로 〈처분시설〉이 타당하다.

b. 객관적 범위

① 처분사유의 추가·변경은 취소소송의 소송물 범위 내에서만 가능하다. 즉, 처분의 동일성이 유지되어야 하며 처분사유 추가·변경으로 소송물이 변경되면 이는 청구가 변경되는 것으로 행정소송법 제22조에 따라 처분변경으로 인한 소의 변경을 하여야 한다. 또한, ② 추가·변경되는 처분사유는 당초 처분의 근거로 삼은 사유와 **기본적 사실관계에 있어서 동일성이 인정되는 범위** 내에서만 가능하다.

[기본적 사실관계의 동일성 판단기준 관련 판례]

대법원 2007. 2. 8. 선고 2006두4899 판결

판례는 **기본적 사실관계가 동일하다는 것은 처분사유를 법률적으로 평가하기 이전의 구체적인 사실에 착안하여 그 기초인 사회적 사실관계가 기본적인 점에서 동일한 것을 말한다.**

대법원 2011. 5. 26. 선고 2010두28106 판결

행정처분이 적법한지는 특별한 사정이 없는 한 처분 당시 사유를 기준으로 판단하면 되고, 처분청이 처분 당시 적시한 구체적 사실을 변경하지 아니하는 범위 내에서 단지 처분의 근거 법령만을 추가·변경하는 것은 새로운 처분사유의 추가라고 볼 수 없으므로 이와 같은 경우에는 처분청이 처분 당시 적시한 구체적 사실에 대하여 처분 후 추가·변경한 법령을 적용하여 처분의 적법 여부를 판단하여도 무방하다. 그러나 처분의 근거 법령을 변경하는 것이 종전 처분과 동일성을 인정할 수 없는 별개의 처분을 하는 것과 다름없는 경우에는 허용될 수 없다.

05 취소소송의 판결

1) 판결의 종류

판결이란 법률상 쟁송을 해결하기 위하여 법원이 원칙적으로 변론을 거쳐 내리는 결정을 말한다.

취소소송의 종국판결에는

- ① 소송요건의 결여로 본안심리를 거부하는 판결인 **각하판결**,
- ② 원고의 청구가 이유 없다고 판단되는 경우에 원고의 청구를 배척하는 **기각판결**,
- ③ 원고의 청구가 이유 있음을 인정하여 처분등을 취소·변경하는 **인용판결**이 있다.

2) 사정판결 [★★★]

(1) 의의

사정판결이란 원고의 청구가 이유 있다고 인정하는 경우에도 처분등을 취소하는 것이 **현저히 공공복리에 적합하지 아니하다고 인정하는 경우에** 법원이 원고의 청구를 기각하는 판결을 말한다. 사정판결은 법률적합성의 원칙의 예외로서 판례는 공공복리를 위해 엄격한 요건 하에서 제한적으로 인정되어야 한다고 본다.

[행정소송법] 제28조 (사정판결)

- ① 원고의 청구가 이유 있다고 인정하는 경우에도 처분등을 취소하는 것이 현저히 공공복리에 적합하지 아니하다고 인정하는 때에는 법원은 원고의 청구를 기각할 수 있다. 이 경우 법원은 그 판결의 주문에서 그 처분등이 위법함을 명시하여야 한다.

※ 사정판결은 무효등확인소송과 부작위위법확인소송에서는 허용되지 않는다.

(2) 요건

사정판결의 요건으로는 ① 원고의 청구가 이유 있다고 인정될 것, ② 처분등을 취소하는 것이 현저히 공공복리에 적합하지 않을 것이 있다. 판례는 ‘현저히 공공복리에 적합하지 아니한가 여부’는 위법·부당한 행정처분을 취소·변경하여야 할 필요와 그 취소·변경으로 발생할 수 있는 공공복리에 반하는 사태 등을 비교·교량하여 그 적용 여부를 판단하여야 한다고 본다.

대법원 2009. 12. 10. 선고 2009두8359 판결

행정처분이 위법한 때에는 이를 취소함이 원칙이고 그 위법한 처분을 취소·변경함이 도리어 현저히 공공의 복리에 적합하지 않은 경우에 극히 예외적으로 위법한 행정처분의 취소를 허용하지 않는다는 사정판결을 할 수 있으므로 사정판결의 적용은 극히 엄격한 요건 아래 제한적으로 하여야 하고, 그 요건인 현저히 공공복리에 적합하지 아니한가의 여부를 판단함에 있어서는 위법·부당한 행정처분을 취소·변경하여야 할 필요와 그 취소·변경으로 인하여 발생할 수 있는 공공복리에 반하는 사태 등을 비교·교량하여 그 적용 여부를 판단하여야 한다.

(3) 심리

사정판결은 법률적합성의 원칙의 예외이므로 피고인인 행정청이 주장 및 입증책임을 부담한다고 보는 견해가 있으나, 판례는 행정소송법 제26조를 근거로 당사자의 주장이 없더라도 **직권으로 사정판결이 가능하다고** 본다. 또한, 처분의 위법성 여부는 <처분시설>에 따라 처분시를 기준으로 판단하고, 공공복리를 위한 사정판결의 필요성은 사실심 변론종결시(판결시)를 기준으로 판단한다.

[법원이 직권으로 사정판결을 할 수 있는지 여부]

1. 문제점

피고(행정청)의 신청이 있어야만 사정판결이 가능한지 아니면 법원이 직권으로 사정판결을 할 수 있는지에 대해 견해가 대립한다.

2. 학설

- ① 행정소송법이 제26조를 규정하고 있더라도, 동법 제8조 제2항에 따라 민사소송법상의 변론주의에 의해 당사자의 주장·항변이 없다면 법원이 직권으로 사정판결을 할 수 없다고 보는 <부정설>과
- ② 행정소송법 제26조를 근거로 하여 당사자의 신청이 없더라도 사정판결을 할 수 있다고 보는 <긍정설> 등 견해가 대립한다.

3. 판례

판례는 당사자의 명백한 주장이 없더라도 기록에 나타난 여러 사정을 기초로 법원이 직권으로 사정판결을 할 수 있다고하여 <긍정설>의 입장을 취한다.

대법원 2006. 9. 22. 선고 2005두2506 판결

사정판결은 당사자의 명백한 주장이 없는 경우에도 기록에 나타난 여러 사정을 기초로 직권으로 할 수 있는 것이나, 그 요건인 현저히 공공복리에 적합하지 아니한지 여부는 위법한 행정처분을 취소·변경하여야 할 필요와 그 취소·변경으로 인하여 발생할 수 있는 공공복리에 반하는 사태 등을 비교·교량하여 판단하여야 한다.

4. 소결

행정소송법 제26조에서 법원은 당사자가 주장하지 않은 사실에 대해서도 판단할 수 있다고 규정하고 있고, 동법 제28조에서 당사자의 신청을 사정판결의 요건으로 규정하고 있지 않으므로 당사자의 신청이 없더라도 법원이 직권으로 사정판결을 할 수 있다고 보는 <긍정설>이 타당하다.

(4) 효과

- ① 법원은 판결의 주문에 위법함을 명시하여야 하고(행정소송법 제28조 제1항 단서),
- ② 미리 원고가 그로 인하여 입게 될 손해의 정도와 배상방법 그 밖의 사정을 조사하여야 하며(제2항),
- ③ 원고는 피고인 행정청이 속하는 국가 또는 공공단체를 상대로 손해배상, 제해시설의 설치 그 밖에 적당한 구제방법의 청구를 당해 취소소송등이 계속된 법원에 병합하여 제기할 수 있다(제3항).

3) 일부취소의 가능성 [★★]

(1) 문제점

행정소송법 제4조의 1호에서 취소소송을 '행정청의 위법한 처분등을 취소 또는 변경하는 소송'이라고 정의하고 있다. 이에 '변경'의 해석과 관련하여 법원이 일부취소판결을 할 수 있는지가 문제 된다.

(2) 행정소송법 제4조 1호의 '변경'의 의미

학설은

- ① 행정소송법 제4조 1호의 '변경'을 적극적 변경으로 보아 법원이 위법한 처분등을 취소하고 새로운 처분을 내용으로 하는 판결을 할 수 있다고 보는 <적극적 변경설>과
- ② 행정소송법에서 의무이행소송을 규정하고 있지 않으므로 행정소송법상 '변경'은 일부취소만을 의미한다고 보는 <소극적 변경설>이 대립하고,

판례는 위 변경을 소극적 변경(일부취소)이라고 보는 입장을 취한다.

생각건대, 적극적 변경설은 법원이 행정청의 처분권한을 행사하는 것과 같은 결과를 가져오므로 권력분립의 원칙에 반하여 타당하지 않고, 현행 행정소송법이 의무이행소송을 인정하고 있지 않으므로, 행정소송법상 '변경'을 소극적 변경으로서 일부취소를 의미한다고 보는 것이 타당하다.

(3) 일부취소의 가능성 (요건 및 한계)

외형상 하나의 행정처분이라도 처분의 일부에만 위법이 있는 경우에

- ① 가분성이 있거나,
- ② 일부취소되는 부분이 특정(특정성)될 수 있다면 그 일부만의 취소도 가능하다.

다만, 판례는 영업정지처분과 같이 재량행위인 경우에는 처분청의 재량권을 존중하여야 하므로 법원이 직접 처분을 하는 것은 인정되지 않는다고 본다. 따라서 일부취소판결을 할 수 없고 전부를 취소하여야 한다고 판시한다.

대법원 2000. 2. 11. 선고 99두7210 판결

외형상 하나의 행정처분이라고 하더라도 가분성이 있거나 그 처분대상의 일부가 특정될 수 있다면 그 일부만의 취소가 가능하다.

대법원 1982. 9. 28. 선고 82누2 판결

행정청이 영업정지처분을 함에 있어서 그 정지기간을 어느 정도로 할 것인지는 행정청의 재량권에 속하는 사항인 것이며, 다만 그것이 공익의 원칙이나 평등의 원칙 또는 비례의 원칙등에 위반하여 재량권의 한계를 벗어난 재량권 남용에 해당하는 경우에만 위법한 처분으로서 사법심사의 대상이 되는 것이나, 법원으로서 영업정지처분이 재량권 남용이라고 판단될 때에는 위법한 처분으로서 그 처분의 취소를 명할 수 있을 뿐이고, 재량권의 한계내에서 어느 정도가 적절한 영업정지 기간인지를 가리는 일은 사법심사의 범위를 벗어난다.

06 취소판결의 효력 [★★★]

1) 형성력 [★]

판결의 형성력이란 처분등에 대한 취소판결이 확정되면 처분청의 별도의 취소를 기다릴 것 없이 처분등이 당연히 효력을 상실하게 되는 것을 말한다. 행정소송법 제29조 제1항의 해석에 의해 인정된다고 보며, 형성력은 제3자에게도 미친다.

[행정소송법] 제29조 (취소판결등의 효력)

① 처분등을 취소하는 확정판결은 제3자에 대하여도 효력이 있다.

2) 불가변력

판결이 일단 확정되면 법원 자신도 이를 취소·변경할 수 없게 되는데, 이를 판결의 자박력 또는 불가변력이라 한다.

3) 불가쟁력 (형식적 확정력)

불가쟁력이란 당사자가 상소를 포기하거나, 상소제기기간의 경과 등으로 인해 판결에 불복하는 자가 더 이상 판결을 다룰 수 없게 되는 구속력을 의미한다. 불가쟁력은 소송 당사자와 이해관계자에 대한 효력이다.

4) 기판력 (실질적 확정력) [★★★]

(1) 의의 및 취지

기판력이란 소송물에 관하여 판결이 확정되면 이후 동일한 사항이 문제되는 경우에 당사자(승계인 포함)는 그에 반하는 주장을 할 수 없고(반복금지), 법원은 그에 반하는 판단을 할 수 없는(모순금지) 구속력을 말한다. 기판력은 인용판결뿐만 아니라 기각판결에도 인정되며, 재판간 모순방지와 분쟁의 종국적인 해결에 그 취지가 인정된다.

(2) 범위

a. 주관적 범위

기판력은 당해 소송의 당사자 및 당사자와 동일시할 수 있는 승계인과 후소법원에게만 미치고, 제3자에게는 미치지 않는다.

b. 시간적 범위

기판력은 사실심 변론종결시를 기준으로 발생한다.

c. 객관적 범위

기판력은 판결의 주문에 나타난 판단에만 미치며, 판결이유에서 실시된 그 전제가 되는 법률관계에까지는 미치지 않는다. 즉, 판결이유 중에 적시된 구체적인 위법사유에 관한 판단에는 미치지 않는다.

대법원 2000. 2. 25. 선고 99다55472 판결

확정판결의 기판력은 그 판결의 주문에 포함된 것, 즉 소송물로 주장된 법률관계의 존부에 관한 판단의 결론 그 자체에만 미치는 것이고 판결이유에서 설시된 그 전제가 되는 법률관계의 존부까지 미치는 것은 아니다.

대법원 2001. 1. 16. 선고 2000다41349 판결

기판력이라 함은 기판력 있는 전소판결의 소송물과 동일한 후소를 허용하지 않는 것임은 물론, 후소의 소송물이 전소의 소송물과 동일하지 않다고 하더라도 전소의 소송물에 관한 판단이 후소의 선결문제가 되거나 모순관계에 있을 때에는 후소에서 전소판결의 판단과 다른 주장을 하는 것을 허용하지 않는 작용을 하는 것이다.

[기판력과 국가배상청구소송]

1. 문제점

취소소송의 소송물은 처분의 위법성이고, 취소소송의 기판력은 처분등의 위법성 그 자체에만 미치므로 소송물을 달리하는 경우에는 확정판결의 기판력이 미치지 않는 것이 원칙이다. 그러나 국가배상청구소송에서 취소소송의 소송물(위법성)이 국가배상청구소송의 선결문제가 되는 경우에 취소소송의 기판력이 국가배상청구소송에 영향을 미치는지가 문제 된다. 이는 위 소송에서 위법의 개념이 동일한 것인지에 대한 논의와 연결된다.

2. 학설

- ① 취소소송의 위법과 국가배상청구소송의 위법을 동일한 개념이라고 보아 취소소송의 확정판결(인용·기각판결)의 기판력이 국가배상청구소송에 미친다고 보는 <기판력 긍정설>.
- ② 취소소송의 위법과 국가배상청구소송의 위법을 다른 개념으로 보고, 양자의 소송물이 달라 기판력이 미치지 않는다고 보는 <기판력 부정설> 및
- ③ 국가배상청구소송의 위법의 범위가 취소소송의 위법 보다 넓다고 보아 인용판결의 기판력은 국가배상청구소송에 미치나, 기각판결의 기판력은 미치지 않는다고 보는 <제한적 긍정설>이 있다.

3. 판례

판례는 ‘국가배상책임에 있어 공무원의 가해행위는 법령을 위반한 것이어야 하고, 법령을 위반하였다 함은 엄격한 의미의 법령 위반뿐 아니라 인권존중, 권력남용금지, 신의성실과 같이 공무원으로서 마땅히 지켜야 할 준칙이나 규범을 지키지 아니하고 위반한 경우를 포함하여 널리 그 행위가 객관적인 정당성을 결여하고 있음을 뜻하는 것’(대판 2008.6.12 2007다64365)이라고 하거나, ‘어떠한 행정처분이 후에 항고소송에서 취소되었다고 할지라도 그 기판력에 의하여 당해 행정처분이 곧바로 공무원의 고의 또는 과실로 인한 것으로서 불법행위를 구성한다고 단정할 수는 없는 것’(대판 2000.5.12. 99다70600)이라고 판시하는 바, 기판력에 관한 입장이 불분명하다.

4. 소결

취소소송과 국가배상청구소송의 위법의 개념을 어떻게 보느냐에 따라 취소판결의 기판력이 미치는지 여부가 달라진다. 국가배상청구소송의 위법을 취소소송의 위법보다 더 넓게 보는 광의의 행위위법설이 통설이며 이 견해에 따라 인용판결의 기판력만이 국가배상청구소송에 미친다고 보는 <제한적 긍정설>이 일반적인 견해이다.

5) 기속력 [★★★]

(1) 의의

기속력이란 처분등을 취소하는 확정판결이 있으면 그 사건의 당사자인 행정청과 그 밖의 관계행정청은 확정판결의 취지에 따라야 하는 의무를 발생시키는 효력(구속력)을 말한다.

[행정소송법] 제30조 (취소판결등의 기속력)

① 처분등을 취소하는 확정판결은 그 사건에 관하여 당사자인 행정청과 그 밖의 관계행정청을 기속한다.

(2) 법적성질

기속력의 법적성질을

① 기판력과 동일하다고 보는 <기판력설>이 있으나,

② 기속력은 취소판결의 실효성을 확보하기 위해

행정소송법에서 특별히 인정하는 효력이라고 보는 <특수효력설>이 통설 및 판례의 입장이다.

생각건대, 기판력은 모든 본안판결의 효력이며 소송법상 효력이나, 기속력은 취소판결(인용판결)에서의 효력이며 실체법상 효력이므로 양자를 다르게 보는 <특수효력설>이 타당하다.

(3) 범위

a. 주관적 범위

기속력은 그 사건에 관하여 당사자인 행정청과 그 밖의 관계 행정청을 기속한다(행정소송법 제30조 제1항). 여기서 '관계 행정청'이란 당해 판결에 의해 취소되는 처분등을 기초로 하여 그와 관련되는 처분이나 부수되는 행위를 할 수 있는 모든 행정청을 말한다.

b. 시간적 범위

기속력의 시간적 범위는 처분의 위법성 판단의 기준시점을 처분시로 보는 처분시설에 따라 처분시에 존재 하던 사유에만 기속력이 미친다고 보는 것이 통설 및 판례의 태도이다. 따라서 처분의 취소판결이 있을 후 새로운 처분사유(법령 및 사실상태)에 의해 동일한 내용의 처분을 하더라도 이는 기속력에 반하지 않는다.

대법원 1998. 1. 7.자 97두22 결정

행정처분의 적법 여부는 그 행정처분이 행하여 진 때의 법령과 사실을 기준으로 하여 판단하는 것이므로 거부처분 후에 법령이 개정·시행된 경우에는 개정된 법령 및 허가기준을 새로운 사유로 들어 다시 이전의 신청에 대한 거부처분을 할 수 있으며 그러한 처분도 행정소송법 제30조 제2항에 규정된 재처분에 해당된다.

c. 객관적 범위

기속력은 판결주문 및 그 전제가 된 처분의 구체적인 위법사유에 관한 이유 중의 판단에 대하여 인정되며 판결의 결론과 직접 관계없는 방론이나 간접사실에 미치지 않는다는 것이 통설과 판례의 태도이다.

또한, 판례는 절차나 형식의 위법을 이유로 처분등이 취소되는 판결이 확정된 경우에는 행정청이 판결에 적시된 절차나 형식의 위법사유를 보완하여 다시 새로운 처분을 하더라도 이는 기속력에 저촉되지 않는다고 본다.

대법원 2001. 3. 23. 선고 99두5238 판결

행정소송법 제30조 제1항에 의하여 인정되는 취소소송에서 처분 등을 취소하는 확정판결의 기속력은 주로 판결의 실효성 확보를 위하여 인정되는 효력으로서 판결의 주문뿐만 아니라 그 전제가 되는 처분 등의 구체적 위법사유에 관한 이유 중의 판단에 대하여도 인정된다.

[기본적 사실관계의 동일성 판단기준]

1. 기본적 사실관계의 동일성 유무

기본적 사실관계의 동일성 유무는 처분사유를 법률적으로 평가하기 이전의 구체적인 사실에 착안하여 그 기초인 사회적 사실관계가 기본적인 점에서 동일한지에 따라 결정된다. [대법원 2011. 10. 27. 선고 2011두14401 판결]

2. 구체적인 판단

기본적 사실관계의 동일성에 관해 구체적인 판단은 시간적·장소적 근접성, 행위의 태양·결과 등의 제반사정을 종합적으로 고려하여야 한다.

(4) 내용

[행정소송법] 제30조 (취소판결등의 기속력)

- ① 처분등을 취소하는 확정판결은 그 사건에 관하여 당사자인 행정청과 그 밖의 관계행정청을 기속한다.
- ② 판결에 의하여 취소되는 처분이 당사자의 신청을 거부하는 것을 내용으로 하는 경우에는 그 처분을 행한 행정청은 판결의 취지에 따라 다시 이전의 신청에 대한 처분을 하여야 한다.
- ③ 제2항의 규정은 신청에 따른 처분이 절차의 위법을 이유로 취소되는 경우에 준용한다.

a. 반복금지의무 (「행정소송법」 제30조 제1항)

취소판결이 확정되면 당사자인 행정청과 관계 행정청은 확정판결에 반하는 처분을 하여서는 안 된다. 즉, 행정청은 동일한 사실관계 하에서 동일한 당사자에 대하여 동일한 내용의 처분등을 반복해서는 안 되며, 이를 위반한 처분은 하자가 중대하고 명백하여 당연무효가 된다.

1. 새로운 사유로 하는 동일한 처분 (반복금지의무 위반 X)

행정소송법 제30조 제2항에 의하면, 행정청의 거부처분을 취소하는 판결이 확정된 경우에는 처분을 행한 행정청이 판결의 취지에 따라 이전 신청에 대하여 재처분을 할 의무가 있다. 행정처분의 적법 여부는 행정처분이 행하여진 때의 법령과 사실을 기준으로 판단하는 것이므로 확정판결의 당사자인 처분 행정청은 종전 처분 후에 발생한 새로운 사유를 내세워 다시 거부처분을 할 수 있고, 그러한 처분도 위 조항에 규정된 재처분에 해당한다. 여기서 ‘새로운 사유’인지는 종전 처분에 관하여 위법한 것으로 판결에서 판단된 사유와 기본적 사실관계의 동일성이 인정되는 사유인지에 따라 판단되어야 한다. [대법원 2011. 10. 27. 선고 2011두14401 판결]

2. 절차나 형식의 하자로 취소된 후 이를 보완하여한 동일한 처분 (반복금지의무 위반 X)

과세처분시 납세고지서에 과세표준, 세율, 세액의 산출근거등이 누락되어 있어 이러한 절차 내지 형식의 위법을 이유로 과세처분을 취소하는 판결이 확정된 경우에 그 확정판결의 기속력은 확정판결에 적시된 절차 내지 형식의 위법사유에 한하여 미친다고 할 것이므로 과세처분권자가 그 확정판결에 적시된 위법사유를 보완하여 행한 새로운 과세처분은 확정판결에 의하여 취소된 종전의 과세처분과는 별개의 처분으로서 확정판결의 기속력에 저촉되는 것은 아니다. [대법원 1986. 11. 11. 선고 85누231 판결]

b. 재처분의무 (「행정소송법」 제30조 제2항)

행정소송법 제30조 제2항에 의거 판결에 의하여 취소되는 처분이 당사자의 신청을 거부하는 것을 내용으로 하는 경우에는 그 처분을 행한 행정청은 판결의 취지에 따라 다시 이전의 신청에 대한 처분을 하여야 한다. 재처분의무는 판결의 취지를 존중하면 되는 것이므로 반드시 원고가 신청한 내용대로 재처분을 해야 하는 것은 아니다. 재처분의무는 신청에 따른 처분이 절차의 위법을 이유로 취소되는 경우에 준용한다(동조 제3항).

대법원 2009. 3. 26. 선고 2009두416 판결

임용기간이 만료된 교원의 재임용이 거부되었다가 그 재임용거부처분이 법원의 판결에 의하여 취소되었다고 하더라도 임용권자는 다시 재임용 심의를 하여 재임용 여부를 결정할 의무를 부담할 뿐, 위와 같은 취소 판결로 인하여 당연히 그 교원이 재임용거부처분 당시로 소급하여 신분관계를 회복한다고 볼 수는 없다.

대법원 2005. 1. 14. 선고 2003두13045 판결

행정소송법 제30조 제2항의 규정에 의하면 행정청의 거부처분을 취소하는 판결이 확정된 경우에는 그 처분을 행한 행정청이 판결의 취지에 따라 이전의 신청에 대하여 재처분할 의무가 있다고 할 것이나, 그 취소사유가 행정처분의 절차, 방법의 위법으로 인한 것이라면 그 처분 행정청은 그 확정판결의 취지에 따라 그 위법사유를 보완하여 다시 종전의 신청에 대한 거부처분을 할 수 있고, 그러한 처분도 위 조항에 규정된 재처분에 해당한다.

c. 결과제거의무 (원상회복의무)

취소판결이 확정되면 행정청은 취소된 처분으로 인해 초래된 위법상태를 제거해야 할 결과제거의무(원상회복의무)를 진다. 결과제거의무에 대한 명문의 규정은 없지만 일반적으로 행정소송법 제30조 제1항의 해석상 인정된다고 보며, 행정소송법 개정안에는 이를 명문화하고 있다.

대법원 2019. 10. 17. 선고 2018두104 판결

어떤 행정처분을 위법하다고 판단하여 취소하는 판결이 확정되면 행정청은 취소판결의 기속력에 따라 그 판결에서 확인된 위법사유를 배제한 상태에서 다시 처분을 하거나 그 밖에 위법한 결과를 제거하는 조치를 할 의무가 있다 (행정소송법 제30조).

[행정소송법] 제34조 (거부처분취소판결의 간접강제)

- ① 행정청이 제30조제2항의 규정에 의한 처분을 하지 아니하는 때에는 제1심수소법원은 당사자의 신청에 의하여 결정으로써 상당한 기간을 정하고 행정청이 그 기간내에 이행하지 아니하는 때에는 그 지연기간에 따라 일정한 배상을 할 것을 명하거나 즉시 손해배상을 할 것을 명할 수 있다.
- ② 제33조와 민사집행법 제262조의 규정은 제1항의 경우에 준용한다. <개정 2002. 1. 26.>

1) 의의 및 취지

간접강제란 행정청이 행정소송법 제30조 제2항에 따른 재처분의무를 이행하지 않을 때, 법원이 일정한 절차에 따라 행정청에게 배상을 명하는 제도를 말한다. 간접강제는 판결의 실효성 확보에 그 취지가 인정된다.

2) 요건

간접강제의 요건으로는

- ① 거부처분에 대한 취소판결이 확정될 것과
- ② 처분청이 거부처분취소판결의 취지에 따른 재처분을 하지 않을 것이 있다.

여기에서 '재처분을 하지 않은 것'에는 아무런 재처분을 하지 않은 것뿐만 아니라, 재처분이 기속력에 반하여 당연무효가 된 것도 포함된다.

3) 절차

간접강제는

- ① 당사자가 제1심 수소법원에 간접강제를 신청하고,
- ② 법원은 간접강제의 신청이 이유 있다고 인정함으로써 간접강제결정을 한다.

간접강제결정으로써 법원은 상당 기간을 정하고 그 기간 내에 이행하지 아니하면 지연기간에 따라 일정한 배상을 명하거나, 즉시 손해배상 할 것을 명할 수 있다.

4) 배상금의 성질 (심리적 강제수단)

판례는 간접강제는 행정청으로 하여금 확정판결의 취지에 따른 재처분의무의 이행을 확실히 담보하기 위한 것으로서 재처분 지연에 대한 제재나 손해배상은 아니고 재처분의 이행에 관한 심리적 강제수단에 불과한 것이라고 보았다. 따라서 간접강제결정에서 정한 의무이행기한이 경과한 후에라도 확정판결의 취지에 따른 재처분의 이행이 있으면 더 이상 배상금을 추심하는 것은 허용되지 않는다고 본다.

대법원 2004. 1. 15. 선고 2002두2444 판결

행정소송법 제34조 소정의 간접강제결정에 기한 배상금은 거부처분취소판결이 확정된 경우 그 처분을 행한 행정청으로 하여금 확정판결의 취지에 따른 재처분의무의 이행을 확실히 담보하기 위한 것으로서, …(중략)… 이는 확정판결의 취지에 따른 재처분의 지연에 대한 제재나 손해배상이 아니고 재처분의 이행에 관한 심리적 강제수단에 불과한 것으로 보아야 하므로, 특별한 사정이 없는 한 간접강제결정에서 정한 의무이행기한이 경과한 후에라도 확정판결의 취지에 따른 재처분의 이행이 있으면 배상금을 추심함으로써 심리적 강제를 피할 목적이 상실되어 처분상대방이 더 이상 배상금을 추심하는 것은 허용되지 않는다.

5) 적용범위 (무효등확인판결)

(1) 문제점

행정소송법 제34조에서는 거부처분취소판결에 따른 재처분의무를 이행하지 않을 때에 대한 실효성 확보수단으로 간접강제를 규정하고 있고, 동법 제38조 제2항에서 이를 준용하고 있어 부작위위법확인판결에도 간접강제가 적용된다. 그러나 무효등확인판결의 경우 간접강제를 준용하는 규정이 없어 간접강제가 적용될 수 있는지가 문제 된다.

(2) 학설

- ① 간접강제를 준용하는 규정이 없으므로 부정하는 <부정설>과
- ② 행정소송법 제34조 제1항에서 '제30조제2항의 규정에 의한 처분을 하지 아니하는 때'라고 규정하고 있음을 근거로 거부처분이 당연무효인 경우에도 간접강제가 허용된다고 보는 <긍정설>이 있다.

(3) 판례

판례는 무효등확인판결이 간접강제를 준용하지 않으므로 부정하는 입장에 있다.

대법원 1998. 12. 24.자 98무37 결정

행정소송법 제34조는 취소판결의 간접강제에 관하여 규정하면서 제1항에서 행정청이 같은 법 제30조 제2항의 규정에 의한 처분을 하지 아니한 때에 간접강제를 할 수 있도록 규정하고 있고, 같은 법 제30조 제2항은 "판결에 의하여 취소되는 처분이 당사자의 신청을 거부하는 것을 내용으로 하는 경우에는 그 처분을 행한 행정청은 판결의 취지에 따라 다시 이전의 신청에 대한 처분을 하여야 한다."라고 규정함으로써 취소판결에 따라 취소된 행정처분이 거부처분인 경우에 행정청에 다시 처분을 할 의무가 있음을 명시하고 있으므로, 결국 같은 법상 간접강제가 허용되는 것은 취소판결에 의하여 취소된 행정처분이 거부처분인 경우라야 할 것이다.

(4) 소결

행정소송법 제38조 제1항에서는 무효등확인소송이 동법 제30조를 준용한다고 규정하고 있어, 무효등확인판결이 있으면 행정청에게 재처분의무가 발생한다. 따라서 무효등확인소송에서도 행정청의 재처분의무 위반에 대한 실효성 확보를 위해 간접강제가 적용될 수 있다고 보는 것이 타당하다.

1) 청구의 병합 [★]

[행정소송법] 제10조 (관련청구소송의 이송 및 병합)

- ① 취소소송과 다음 각호의 1에 해당하는 소송(이하 “**關聯請求訴訟**”이라 한다)이 각각 다른 법원에 계속되고 있는 경우에 관련청구소송이 계속된 법원이 상당하다고 인정하는 때에는 당사자의 신청 또는 직권에 의하여 이를 취소소송이 계속된 법원으로 이송할 수 있다.
1. 당해 처분등과 관련되는 손해배상·부당이득반환·원상회복등 청구소송
 2. 당해 처분등과 관련되는 취소소송
- ② 취소소송에는 사실심의 변론종결시까지 관련청구소송을 병합하거나 피고외의 자를 상대로 한 관련청구소송을 취소소송이 계속된 법원에 병합하여 제기할 수 있다.

(1) 의의 및 취지

청구의 병합이란 하나의 소송절차에서 여러 개의 청구를 하는 것(객관적 병합) 또는 **소송당사자가 수인**이 되는 것(주관적 병합)을 말한다. 청구의 병합은 **소송경제** 도모와 **판결간 모순방지** 등에 취지가 있으며, 행정소송법 제10조 제2항, 민사소송법 제253조 등에 근거가 있다.

(2) 종류

청구의 병합의 종류에는

- ① 양립하는 여러 개의 청구를 병렬적으로 병합하는 **단순병합**(모든 청구에 대해 법원의 판결이 필요),
- ② 여러 개의 청구 가운데 어느 하나가 인용되면 다른 청구에 대해서는 심판을 바라지 않은 형태의 **선택적 병합**,
- ③ 양립되지 않는 청구를 **주위적·예비적**으로 병합하는 **예비적 병합**이 있다.

(3) 요건

청구의 병합의 요건으로는

- ① **주된 청구인 행정사건에 관련** 청구를 병합할 것,
- ② **각 청구가 적법요건을 갖출 것**,
- ③ 청구 사이에 **기초되는 사실의 관련성(견련성)**이 있어야 한다. 다만, 피고가 같을 필요는 없다.

※ 예비적 병합의 예 [대법원 2014. 4. 24. 선고 2012두6773 판결]

잔여지의 수용청구와 잔여지의 가격감소로 인한 손실보상청구는 서로 양립할 수 없는 관계에 있어 선택적 병합이 불가능한데 원심이 위 두 청구의 선택적 병합 청구를 허가한 것 또한 잘못이다.

2) 소송참가

소송참가란 타인간 소송 계속 중 당사자가 아닌 **제3자가 소송의 결과에 따라 자신의 법률상 지위에 영향**이 미치게 될 경우, 자신의 이익을 위하여 **소송절차에 참가**하는 것을 말한다.

(1) 제3자의 소송참가 [★★]**[행정소송법] 제16조 (제3자의 소송참가)**

- ① 법원은 소송의 결과에 따라 권리 또는 이익의 침해를 받을 제3자가 있는 경우에는 당사자 또는 제3자의 신청 또는 직권에 의하여 결정으로써 그 제3자를 소송에 참가시킬 수 있다.

a. 의의 및 취지

제3자의 소송참가란 소송의 결과에 의해 권익의 침해를 받을 제3자가 있는 경우에 당사자 또는 제3자의 신청 또는 직권에 의하여 그 제3자를 소송에 참가시키는 제도를 말한다. 제3자의 권익을 보호에 그 취지가 인정된다.

b. 요건과 절차

제3자의 소송참가의 요건으로는

- ① 타인간의 취소소송 등이 계속 중일 것,
- ② 소송결과에 따라 법률상 이익의 침해를 받을 제3자일 것이 있다.

여기에서 '제3자'란 소송당사자 이외의 자를 말하고, '이익의 침해'는 법률상 이익을 말하며, 단순한 사실상의 이익이나 경제상의 이익은 포함되지 않는다.

법원은 소송의 당사자 또는 제3자의 신청 또는 직권에 의해 참가결정을 하고, 법원이 결정을 하는 때에는 미리 당사자 및 제3자의 의견을 들어야 한다.

제3자는 각하결정에 대해 즉시항고를 할 수 있다.

c. 소송참가인의 지위

소송참가는 민사소송법 제67조가 준용되므로 소송참가인의 필수적 공동소송에서의 공동소송인에 준하는 지위에 서게 되나, 당사자적격은 없으므로 공동소송적 보조참가인의 지위와 유사하다고 보는 것이 통설이다.

(2) 행정청의 소송참가

[행정소송법] 제17조 (행정청의 소송참가)

- ① 법원은 다른 행정청을 소송에 참가시킬 필요가 있다고 인정할 때에는 당사자 또는 당해 행정청의 신청 또는 직권에 의하여 결정으로써 그 행정청을 소송에 참가시킬 수 있다.

a. 의의 및 취지

행정청의 소송참가란 관계 행정청이 다른 행정청의 행정소송에 참가하는 것을 말한다.

행정소송법 제17조에서 법원은 다른 행정청을 소송에 참가시킬 필요가 있다고 인정할 때에는 당사자 또는 당해 행정청의 신청 또는 직권에 의해 결정으로써 그 행정청을 소송에 참가시킬 수 있고 규정하고 있다.

처분청 외에 관계 행정청을 소송에 참여시켜 공격·방어방법을 제출할 수 있도록 함으로서 적정한 재판을 도모하는데 그 취지가 있다.

b. 요건과 절차

행정청의 소송참가의 요건으로는

- ① 타인의 취소소송이 계속 중일 것,
- ② 처분청과 관계있는 다른 행정청일 것 및
- ③ 참가의 필요성이 있다.

행정청의 소송참가는 법원의 직권, 당사자 또는 당해 행정청의 신청에 의하여, 법원은 참가 여부를 결정하기 전에 당사자 및 행정청의 의견을 들어야 한다.

c. 참가인의 지위

행정청은 소송참가는 민사소송법 제76조가 준용되므로 참가행정청은 보조참가인에 준하는 지위에 서며, 일체의 소송행위를 할 수 있다. 다만, 참가행정청은 피참가인의 소송행위와 저촉되는 소송행위는 할 수 없다.

[행정소송법] 제4조 (항고소송)

2. 무효등 확인소송 : 행정청의 처분등의 효력 유무 또는 존재여부를 확인하는 소송

01 의의 및 성질

무효등확인소송이란 행정청의 처분 등의 효력 유무 또는 존재 여부를 확인하는 소송을 말한다.

여기에는 무효확인소송, 처분등의 존재확인소송, 부존재확인소송, 유효확인소송, 실효확인소송이 포함된다.

무효등확인소송은 주관적 소송으로서 당해 처분등이 처음부터 무효임을 확인 선언하는 확인소송의 성질을 가진다.

※ 무효등확인소송에서 준용되지 않는 취소소송의 규정

제소기간(행정소송법 제20조), 사정판결(행정소송법 제28조), 간접강제(행정소송법 제34조)

02 사정판결 가능성 [★]**(1) 문제점**

행정소송법 제38조 제1항은 무효등확인소송의 준용규정을 나열하고 있는데, 동법 제28조의 사정판결을 준용하고 있지 않다. 따라서 무효등확인소송에서 사정판결이 가능한지가 문제 된다.

(2) 학설

- ① 무효나 취소는 하자의 정도의 차이에 불과하고 그 구별이 상대적이므로 공익성을 존중하여 사정판결을 인정하여야 한다고 보는 <긍정설>과
- ② 법문언상 준용규정이 없으므로 인정될 수 없다고 보는 <부정설>이 대립한다.

(3) 판례

판례는 ‘당연무효의 행정처분을 소송목적물로 하는 행정소송에서는 존치시킬 효력이 있는 행정행위가 없기 때문에 행정소송법 제28조 소정의 사정판결을 할 수 없다(대법원 1996. 3. 22. 선고 95누5509)’고 하여 <부정설>의 입장을 취한다.

(4) 소결

사정판결은 법치주의의 예외적 조치에 해당하므로 그 해석에 있어 엄격성이 요구된다. 따라서 준용 규정이 없음을 근거로 판례의 태도와 같이 무효등확인소송에서 사정판결은 부정함이 타당하다.

03 확인소송의 보충성 (즉시확정 이익의 필요 여부) [★★]

1) 문제점

행정소송법 제35조은 무효등확인소송은 '처분등의 효력 유무 또는 존재 여부의 확인을 구할 법률상 이익이 있는 자가 제기할 수 있다'고 규정하고 있다. 여기에서 '확인을 구할 법률상 이익'과 관련하여 민사소송법상의 확인의 이익이 무효등확인소송에서도 요구되는지가 문제 된다.

2) 학설

- ① 무효등확인소송에서 취소판결의 기속력(행정소송법 제30조) 규정을 준용하고 있으므로 무효확인판결 자체 만으로도 판결의 실효성을 확보할 수 있어 확인의 소의 보충성은 요구되지 않는다고 보는 <보충성 불요설>과
- ② 무효등확인소송은 확인소송의 성질을 가지고 있으므로 확인의 소의 보충성이 필요하다고 보는 <보충성 필요설>이 대립한다.

※ 확인소송의 보충성이란?

현존하는 원고의 불안이나 위험을 제거하기 위하여 확인판결을 받는 것이 유효적절한 수단인 경우에만 확인소송이 인정될 수 있고, 보다 실효적인 권리구제 수단이 있다면 확인소송이 인정될 수 없는 것을 의미한다.

3) 판례

종래에는 무효등확인소송에서 확인의 소의 보충성이 필요하다고 보았으나, 이를 변경하여 무효확인소송의 보충성이 요구되는 것이 아니라고 판시하였다.

대법원 2008. 3. 20. 선고 2007두6342 전원합의체 판결

행정소송은 행정청의 위법한 처분 등을 취소·변경하거나 그 효력 유무 또는 존재 여부를 확인함으로써 국민의 권리 또는 이익의 침해를 구제하고 공법상의 권리관계 또는 법 적용에 관한 다툼을 적정하게 해결함을 목적으로 하므로, 대등한 주체 사이의 사법상 생활관계에 관한 분쟁을 심판대상으로 하는 민사소송과는 목적, 취지 및 기능 등을 달리한다. 또한 행정소송법 제4조에서는 무효확인소송을 항고소송의 일종으로 규정하고 있고, 행정소송법 제38조 제1항에서는 처분 등을 취소하는 확정판결의 기속력 및 행정청의 재처분의무에 관한 행정소송법 제30조를 무효확인소송에도 준용하고 있으므로 무효확인판결 자체만으로도 실효성을 확보할 수 있다. 그리고 무효확인소송의 보충성을 규정하고 있는 외국의 일부 입법례와는 달리 우리나라 행정소송법에는 명문의 규정이 없어 이로 인한 명시적 제한이 존재하지 않는다. 이와 같은 사정을 비롯하여 행정에 대한 사법통제, 권익구제의 확대와 같은 행정소송의 기능 등을 종합하여 보면, 행정처분의 근거 법률에 의하여 보호되는 직접적이고 구체적인 이익이 있는 경우에는 행정소송법 제35조에 규정된 '무효확인을 구할 법률상 이익'이 있다고 보아야 하고, 이와 별도로 무효확인소송의 보충성이 요구되는 것은 아니므로 행정처분의 무효를 전제로 한 이행소송 등과 같은 직접적인 구제수단이 있는지 여부를 따질 필요가 없다고 해석함이 상당하다.

4) 소결

무효등확인소송은 행정소송법 제30조를 준용하므로 무효확인판결의 기속력에 따라 무효판결만으로도 판결의 실효성을 확보할 수 있다. 따라서 확인소의 보충성이 요구되지 않는다고 보는 <보충성 불요설>이 타당하다.

04 취소소송과의 관계 [★]

1) 양립불가 관계

취소사유의 하자과 무효사유의 하자는 상호 양립할 수 없는 관계이다.

따라서 취소소송과 무효확인소송의 병합은 주위적·예비적 병합이어야 하며, 선택적 병합은 허용되지 않는다.

2) 상호포용 관계

취소소송과 무효등확인소송은 모두 행정처분에 위법한 하자가 있음을 이유로 그 효력의 배제를 구하는 점에서 유사하고 그 사유도 하자의 정도 등에 따른 상대적 차이에 불과하므로 상호 포용성 관계에 있다고 볼 수 있다.

[취소소송에서 위법성의 정도가 무효사유인 경우]

통설·판례는 무효선언적 의미의 취소판결을 할 수 있다고 보며, 이 경우에도 취소소송의 제소기간 준수 등 취소소송의 소송요건이 충족되어야 한다고 본다.

[무효등확인소송에서 위법성의 정도가 취소사유인 경우]

1. 학설

- ① 무효확인청구에 취소청구가 당연히 포함되어 있다고 볼 수는 없다고 하여 원고의 청구를 기각해야 한다고 보는 <청구기각판결설>.
- ② 판결은 소송상 청구에 대해 내려지는 것이므로 법원은 석명권을 행사하여 무효확인소송을 취소소송으로 변경하도록 한 후 취소소송요건을 충족한 경우 취소판결을 해야 한다고 보는 <소변경필요설> 및
- ③ 무효확인청구에는 원고의 명시적인 반대의사표시가 없는 한 취소청구도 당연히 포함된다고 보아 법원은 취소판결을 할 수 있다고 보는 <취소판결설>이 있다.

2. 판례

판례는 '일반적으로 행정처분의 무효확인을 구하는 소에는 원고가 그 처분의 취소를 구하지 아니한다고 밝히지 아니한 이상 그 처분이 만약 당연무효가 아니라면 그 취소를 구하는 취지도 포함되어 있는 것으로 보아야 한다 (94누477 판결)' 고하여 <취소판결설>의 입장을 취한다.

3. 소결

처분이 무효라는 주장에는 취소를 구하는 뜻도 포함되어 있다고 볼 수 있으므로 판례와 같이 처분을 취소하는 판결을 할 수 있다고 보는 <취소판결설>이 타당하다.

[행정소송법] 제4조 (항고소송)

3. 부작위위법확인소송 : 행정청의 부작위가 위법하다는 것을 확인하는 소송

01 의의 및 성질

부작위위법확인소송이란 행정청이 상대방의 신청에 대하여 상당한 기간 내에 일정한 처분을 해야 할 의무가 있음에도 불구하고 이를 이행하지 않는 경우 이러한 부작위가 위법한 것임을 확인하는 소송을 말한다. 부작위위법확인소송은 부작위의 위법에 대한 확인을 구하는 소송으로 확인소송의 성질을 가지며, 공권력에 대한 소송이므로 항고소송에 해당한다.

※ 부작위위법확인소송에서 준용되지 않는 취소소송의 규정

처분변경으로 인한 소의 변경(행정소송법 제22조), 집행정지(행정소송법 제23조 제2항), 사정판결(행정소송법 제28조)

02 소송요건 [★★★]

1) 대상적격 (부작위)

(1) 의의

부작위라 함은 행정청이 당사자의 신청에 대하여 상당한 기간 내에 일정한 처분을 하여야 할 법률상의 의무가 있음에도 불구하고 이를 하지 아니하는 것을 말한다(행정소송법 제2조 2호).

(2) 부작위 성립 요건

① 당사자의 신청

부작위가 성립하기 위해서는 당사자의 신청이 있어야 하며, 이러한 신청이 반드시 적법할 필요는 없다. 신청권이 필요한지에 관해서는 견해가 대립하나, 판례는 당사자에게 법규상·조리상 신청권이 없는 경우 부작위위법확인소송은 부적법하다고 판시한바 있다.

대법원 1995. 9. 15. 선고 95누7345 판결

부작위위법확인소송은 처분의 신청을 한 자로서 부작위의 위법의 확인을 구할 법률상의 이익이 있는 자만이 제기할 수 있다 할 것이며, 이를 통하여 구하는 행정청의 응답행위는 행정소송법 제2조 제1항 제1호 소정의 처분에 관한 것이라야 하므로, 당사자가 행정청에 대하여 어떠한 행정행위를 하여 줄 것을 신청하지 아니하거나 그러한 신청을 하였더라도 당사자가 행정청에 대하여 그러한 행정행위를 하여 줄 것을 요구할 수 있는 법규상 또는 조리상의 권리를 갖고 있지 아니하든지 또는 행정청이 당사자의 신청에 대하여 거부처분을 한 경우에는 원고적격이 없거나 항고소송의 대상인 위법한 부작위가 있다고 볼 수 없어 그 부작위위법확인소의 소는 부적법하다.

② 상당한 기간의 경과

부작위가 위법한 것이 되려면 당사자의 신청 후 상당한 기간이 경과하도록 행정청이 아무런 처분을 하지 않은 경우이어야 한다. 여기에서 '상당한 기간'이란 처분을 하기 위해서 통상 요구되는 기간을 의미하며, 처분의 성질·내용 등을 고려하여 판단하여야 한다.

③ 일정한 처분을 할 법률상 의무가 있을 것

부작위가 되려면 행정청에게 일정한 처분을 할 법률상 의무가 있어야 한다.

‘법률상 의무’에는 명문 규정에 의해 인정되는 경우뿐만 아니라, 조리상 인정되는 경우도 포함된다.

대법원 1991. 2. 12. 선고 90누5825 판결

법령상 검사임용 신청 및 그 처리의 제도에 관한 명문 규정이 없다고 하여도 조리상 임용권자는 임용신청자들에게 전형의 결과인 임용 여부의 응답을 해줄 의무가 있다.

④ 아무런 처분을 하지 않을 것

부작위가 되려면 행정청이 아무런 처분도 하지 않아야 한다. 즉, 행정청이 거부처분을 하였다면 이는 취소소송을 제기하여야 하므로 부작위위법확인소송을 제기할 수 없다. 또한, 법령에서 일정기간 동안 아무런 처분이 없는 경우에 거부처분을 한 것으로 보는 간주거부조항이 있는 경우에도 부작위위법확인소송은 허용되지 않는다.

대법원 1998. 1. 23. 선고 96누12641 판결

행정청이 당사자의 신청에 대하여 거부처분을 한 경우에는 항고소송의 대상인 위법한 부작위가 있다고 볼 수 없어 그 부작위위법확인 소는 부적법하다.

2) 원고적격

[행정소송법] 제36조 (부작위위법확인소송의 원고적격)

부작위위법확인소송은 처분의 신청을 한 자로서 부작위의 위법의 확인을 구할 법률상 이익이 있는 자만이 제기할 수 있다.

(1) 의의

행정소송법 제36조에서 ‘부작위위법확인소송은 처분의 신청을 한 자로서 부작위의 위법의 확인을 구할 법률상 이익이 있는 자만이 제기할 수 있다’고 규정하고 있다. 여기서 ‘법률상 이익’은 취소소송의 그것과 같으며, ‘처분의 신청을 한 자’의 의미가 무엇인지가 문제 된다.

(2) 처분의 신청을 한 자

원고적격이 인정되기 위해서는 처분을 신청한 것으로 족하다는 견해와 법규상 또는 조리상 신청권이 있어야 한다는 견해가 대립한다. 통설 및 판례는 부작위의 성립 요건으로 신청권을 요구하고 있으므로, 처분을 신청한 자로서 부작위의 위법의 확인을 구할 법률상 이익이 있는 한 원고적격이 인정된다고 본다.

대법원 1989. 5. 23. 선고 88누8135 판결

행정소송법상 취소소송이나 부작위위법확인소송에 있어서는 당해 행정처분 또는 부작위의 직접상대방이 아닌 제3자라 하더라도 그 처분의 취소 또는 부작위위법확인을 받을 법률상의 이익이 있는 경우에는 원고적격이 인정되나 여기서 말하는 법률상의 이익은 그 처분 또는 부작위의 근거법률에 의하여 보호되는 직접적이고 구체적인 이익을 말하고, 간접적이거나 사실적, 경제적 관계를 가지는데 불과한 경우는 포함되지 않는다.

3) 제소기간

(1) 문제점

행정소송법 제38조 제2항에서 부작위위법확인소송이 동법 제20조(제소기간)를 준용한다고 규정하고 있다. 그러나 행정심판을 거치지 않은 경우에는 명시적인 처분등이 없으므로 행정소송법 제20조를 어떻게 적용하여야 하는지가 문제 된다.

(2) 학설

- ① 상당기간이 경과하면 처분이 있었던 것으로 보아, 행정소송법 제20조 제2항을 적용해 그날로부터 1년 이내에 제소하여야 한다고 보는 견해와
- ② 부작위는 처분등이 없었던 것이므로 제소기간의 제한이 없다고 보는 견해가 대립한다.

(3) 판례

판례는 부작위가 계속되는 한 그 위법의 확인을 구할 이익이 있다고 보아 원칙적으로 제소기간의 제한을 받지 않는다고 본다.

대법원 2009. 7. 23. 선고 2008두10560 판결

부작위위법확인소송의 소는 부작위상태가 계속되는 한 그 위법의 확인을 구할 이익이 있다고 보아야 하므로 원칙적으로 제소기간의 제한을 받지 않는다. 그러나 행정소송법 제38조 제2항이 제소기간을 규정한 같은 법 제20조를 부작위 위법확인소송에 준용하고 있는 점에 비추어 보면, 행정심판 등 전심절차를 거친 경우에는 행정소송법 제20조가 정한 제소기간 내에 부작위위법확인소송의 소를 제기하여야 한다.

(4) 소결

행정심판법상 부작위에 대한 의무이행심판에 심판청구기간의 제한을 두고 있지 않고, 상당한 기간도 불확정적인 것으로 부작위의 종료시점을 정하기가 어려운 점을 고려하여 ②설 및 판례와 같이 제소기간의 제한이 없다고 보는 것이 타당하다.

03 심리의 범위 [★★]

1) 문제점

부작위위법확인소송의 심리범위와 관련하여 부작위의 위법 여부만을 심리 할 수 있는지, 아니면 처분의무가 있는지도 심리할 수 있는지가 문제 된다.

2) 학설

- ① 부작위위법확인소송은 행정청의 부작위가 위법한 것임을 확인하는 소송이므로, 수소법원은 부작위의 위법 여부만을 심사할 수 있다고 보는 <절차적 심리설>과
- ② 무용한 소송의 반복을 피하고 당사자의 실효적인 권리구제를 위해 신청에 따른 처분의무가 있는지와 같은 실체적 내용도 심리할 수 있다고 보는 <실체적 심리설>이 대립한다.

3) 판례

판례는 부작위위법확인소송은 부작위의 위법을 확인하여 부작위 내지 무응답이라는 소극적인 위법상태를 제거하는 것을 목적으로 한다고 하여 <절차적 심리설>의 입장을 취한다.

부작위의 위법을 확인함으로써 행정청의 응답을 신속하게 하여 부작위 내지 무응답이라고 하는 소극적인 위법상태를 제거하는 것을 목적으로 하는 것이고, 나아가 당해 판결의 구속력에 의하여 행정청에게 처분 등을 하게 하고 다시 당해 처분 등에 대하여 불복이 있는 때에는 그 처분 등을 다투게 함으로써 최종적으로는 국민의 권리아익을 보호하려는 제도이므로, 소제기의 전후를 통하여 판결시까지 행정청이 그 신청에 대하여 적극 또는 소극의 처분을 함으로써 부작위상태가 해소된 때에는 소의 이익을 상실하게 되어 당해 소는 각하를 면할 수가 없는 것이다.

4) 소결

부작위위법확인소송은 부작위의 위법성을 확인하여 소극적인 위법상태를 제거하는 것을 목적으로 하는 확인 소송인 점에서 판례와 같이 부작위의 위법한 여부만을 심리하는 <절차적 심리설>이 타당하다.

04 위법성 판단의 기준시점

부작위위법확인소송은 처분이 존재하지 않으므로, 위법성 판단은 <판결시>를 기준으로 하여야 한다.

05 거부처분취소소송으로 소변경 가능성

1) 문제점

부작위위법확인소송을 제기한 후 행정청의 거부처분을 한 경우에 행정소송법 제22조에 따라 처분변경으로 인한 소변경을 하여야함이 타당하다. 그러나 행정소송법 제37조에서 동법 제21조는 준용하나 제22조에 대한 준용규정이 없어 거부처분취소소송으로 소송을 변경할 수 있는지가 문제 된다.

2) 학설

- ① 행정소송법 제22조의 처분변경에 의한 소의 변경에 대한 준용규정을 두지 않은 것은 입법의 불비에 해당하므로, 행정소송법 제21조를 적용하여 소변경을 인정하여야 한다고 보는 <긍정설>과
- ② 행정소송법 제21조는 행정소송의 종류를 잘못할 선택한 경우에 위험을 방지함에 그 취지가 있는 것이고, 행정소송법 제22조를 준용하지 않으므로 처분변경으로 인한 소의 변경을 할 수 없다고 보는 <부정설>이 대립한다.

3) 소결

부작위위법확인소송과 거부처분취소소송은 모두 일정한 처분을 받는 것을 목적으로 한다. 이에 양자의 청구의 기초에 변경이 없으므로 행정소송법 제21조를 준용하여 소의 변경이 가능하다고 보는 것이 타당하다.

[행정소송법] 제3조 (행정소송의 종류)

2. 당사자소송 : 행정청의 처분등을 원인으로 하는 법률관계에 관한 소송 그 밖에 공법상의 법률관계에 관한 소송으로서 그 법률관계의 한쪽 당사자를 피고로 하는 소송

01 의미

행정소송법 제3조 2호에서 당사자소송을 ‘행정청의 처분등을 원인으로 하는 법률관계에 관한 소송 그 밖에 공법상의 법률관계에 관한 소송으로서 그 법률관계의 한쪽 당사자를 피고로 하는 소송’이라고 정의하고 있다. 당사자소송은 공법상의 법률관계에 관하여 의문이나 다툼이 있는 경우에 그 법률관계의 당사자가 원고 또는 피고가 되어 법률관계를 다투는 소송을 의미한다. 항고소송과는 소송의 성질, 피고적격, 제소기간 등에서 구별된다.

02 소송의 대상

당사자소송은 처분등을 대상으로 하는 것이 아니라

- ① 행정청의 처분등에 의해 발생·변경·소멸된 공법상의 법률관계와
- ② 공법이 규율하는 법률관계가 소송의 대상이 된다.

전자의 예로는 재개발조합을 상대로 조합원자격 유무에 관한 확인을 구하는 소송이 있고, 후자는 토지보상법상 주거이전비 청구소송이 있다.

03 종류**1) 실질적 당사자소송**

실질적 당사자소송이란 공법상의 법률관계에 관한 소송으로서 그 법률관계의 한쪽 당사자를 피고로 하는 소송을 말한다. 일반적으로 당사자소송이라함은 실질적 당사자소송을 의미한다.

2) 형식적 당사자소송

형식적 당사자소송이란 실질적으로는 행정청의 처분등을 다투는 것이나 형식적으로는 처분등으로 인해 형성된 법률관계를 다투기 위해 관련 법률관계의 일방 당사자를 피고로 하여 제기하는 당사자소송을 말한다. 토지보상법 제85조 제2항의 보상금증액청구소송이 이에 해당 한다.

01 의무이행소송 [★]

1) 의의

의무이행소송이란 사인이 신청에 대해 행정청이 처분을 하여야 할 의무가 있음에도 불구하고 거부 또는 부작위로 방치한 경우 행정청에 대하여 일정한 행정처분을 해 줄 것을 청구하는 행정소송을 말한다. 독일 행정법에는 의무이행소송이 명문으로 규정되어 있으나, 우리 행정소송법에는 명문의 규정이 없어 의무이행소송의 인정 여부가 문제 된다.

2) 인정 여부

(1) 학설

- ① 행정소송법 제4조를 예시적 규정으로 보고, 권력분립의 원칙을 기능적으로 이해하여 의무이행소송을 통해 개인의 권리구제의 실효성을 높여야 한다고 보는 <긍정설>,
- ② 권력분립의 원칙상 법원은 행정청의 1차적 판단권을 존중해야 하고, 행정소송법 제4조는 소송의 유형을 제한적으로 나열한 열거적 규정이므로 의무이행소송을 부정하는 <부정설> 및
- ③ 부작위위법확인소송으로 실효적 권리구제가 가능하지 않은 경우에 한하여 일정한 요건 하에서 보충적으로 의무이행소송을 인정하여야 한다고 보는 <절충설>이 있다.

(2) 판례

판례는 행정소송법 제4조를 제한적 규정으로 보는 입장에서 일관되게 의무이행소송을 부정하고 있다.

대법원 1995. 3. 10. 선고 94누14018 판결

검사에게 압수물 환부를 이행하라는 청구는 행정청의 부작위에 대하여 일정한 처분을 하도록 하는 의무이행소송으로 현행 행정소송법상 허용되지 아니한다.

(3) 소결

법원이 판결시에 행정청에게 충분한 변론 기회를 준다면 이는 행정청의 1차적 판단권을 침해한다고 볼 수 없으므로, 국민의 실효적인 권리구제를 위해 의무이행소송을 인정함이 타당하다. 행정소송법 개정안에는 의무이행소송이 포함되어 있다.

02 예방적 부작위소송

1) 의의

예방적 부작위소송이란 행정청의 처분으로 장래에 개인의 법률상 이익이 침해될 것이 예상되는 경우, 행정청이 침익적 처분을 하지 못하도록 부작위를 청구하는 소송을 말한다.

2) 인정여부

(1) 학설

- ① 행정소송법 제4조를 예시적 규정으로 보아,
국민의 권리구제를 위하여 인정하여야 한다고 보는 <긍정설>,
- ② 행정소송법 제4조를 열거적 규정으로 보아,
예방적 부작위소송을 인정하는 것은 권력분립에 반한다고 보는 <부정설> 및
- ③ 관계법상 처분요건이 일의적이고 사전에 구제하지 않으면 회복하기 어려운 손해가 발생할 우려가 있고,
다른 구제방법이 없는 경우에만 인정될 수 있다고 보는 <절충설> 등이 있다.

(2) 판례

판례는 '건축건물의 준공처분을 하여서는 아니된다는 내용의 부작위를 구하는 청구는 행정소송에서 허용되지 아니하는 것이므로 부적법하다(86누182)'고 하여 예방적 부작위소송을 부정하는 입장을 취한다.

(3) 소결

행정소송은 사후구제에 불가하므로 보다 실효적인 국민의 권리구제를 위해 긍정함이 타당하다.

행정상 손해전보란 국가 등의 행정작용으로 인해 사인에게 발생한 손해 또는 손실을 보전하는 제도를 말한다.
그 원인행위의 형태에 따라 행정상 손해배상(국가배상)과 행정상 손실보상으로 구분할 수 있고,
전통적인 행정상 손해전보를 보완하기 위한 수단으로 결과제거청구권이 있다.

구분	손해배상	손실보상
정의	공무원의 고의·과실로 인한 위법한 직무행위로 인하여 발생한 손해에 대하여 국가 등이 하는 배상	국가 등이 공공필요에 의해 행한 적법한 공권력의 행사로 인해 가해진 특별한 희생에 대하여 행정주체가 행하는 보상
원인	위법한 행정작용	적법한 행정작용
근거법령	「헌법」 제29조 「국가배상법」	「헌법」 제23조 제3항, 「토지보상법」
전보의 대상	재산적·비재산적 손해	재산적 손실
책임의 성질	과실책임주의	무과실책임주의
전보의 책임자	국가 또는 지방자치단체	사업시행자

제1절 행정상 손해배상 [★★★]

01 의의 및 유형

행정상 손해배상이란 공무원의 고의·과실로 인한 위법한 직무행위 또는 영조물의 하자로 인하여 발생한 손해에 대하여 국가 또는 지방자치단체 등이 배상을 해주는 제도를 말한다.

행정상 손해배상은 국가배상이라고도 하며, 국가배상법에서는 국가배상책임의 유형으로

- ① 공무원의 위법행위로 인한 배상책임(국가배상법 제2조)과
- ② 영조물의 설치·관리상의 하자로 인한 배상책임(동법 제5조)을 규정하고 있다.

02 법적성질 [★]

1) 공권과 사권

국가배상책임의 법적 성격에 대해

- ① 국가배상책임은 일반불법행위 책임의 한 유형에 불과한 것으로서,
국가배상법을 민법의 특별법으로 보는 <사권설>과

② 국가배상책임은 공법적 원인에 의해 발생한 것이며,

국가배상을 받을 권리는 양도나 압류의 대상이 되지 않는다고 규정(국가배상법 제4조)하고 있는 점을 근거로 공권으로 보는 <공권설>이 대립한다.

판례는 국가배상법을 민법의 특별법으로 보는 입장이다(70다2955).

생각건대, 국가배상책임은 공법적 원인에 의하여 발생한 손해에 대한 전보이므로 국가배상법을 공법으로 보고, 국가배상청구권의 법적 성격은 공권으로 보는 것이 타당하다.

2) 대위책임과 자기책임

(1) 학설

① 위법한 공무원의 행위는 국가등의 행위로 볼 수 없으므로, 공무원 자신이 배상책임을 져야 하나,

피해자 구제를 위하여 국가가 대신하여 책임을 지는 것으로 보는 <대위책임설>,

② 공무원의 행위의 효과는 국가등의 행위로 귀속되므로 배상책임은 국가등의 자기책임이라고 보는 <자기책임설> 및

③ 공무원의 위법행위가 경과실인 경우에는 공무원의 행위는 국가 행위이므로 국가가 자기책임으로서 배상책임을 지지만, 고의 또는 중과실에 의한 것일 때에는 기관의 행위로서 품격을 상실하므로 원칙적으로 공무원 개인의 책임이나, 피해자 구제를 위해 국가가 대신하여 책임지는 것이라고 보는 <절충설>이 있다.

(2) 판례

판례는 공무원의 위법행위가 경과실인 경우에는 여전히 기관의 행위로 보아 전적으로 국가등에게 배상책임을 귀속시키고, 고의 또는 중과실에 기한 경우에는 기관행위로서 품격을 상실하므로 공무원에게 손해배상책임을 부담시키되, 국민의 권리보호를 위해 국가와 공무원이 중첩적으로 배상책임을 부담하게 한다고 하여 <절충설>의 입장을 취한다.

대법원 1996. 2. 15. 선고 95다38677 전원합의체 판결

공무원이 직무를 수행함에 있어 경과실로 타인에게 손해를 입힌 경우에는 그 직무수행상 통상 예기할 수 있는 흠이 있는 것에 불과하므로, 이러한 공무원의 행위는 여전히 국가 등의 기관의 행위로 보아 그로 인하여 발생한 손해에 대한 배상책임도 전적으로 국가 등에만 귀속시키고 공무원 개인에게는 그로 인한 책임을 부담시키지 아니하여 공무원의 직무집행의 안정성을 확보하고, 반면에 공무원의 위법행위가 고의·중과실에 기한 경우에는 비록 그 행위가 그의 직무와 관련된 것이라고 하더라도 그와 같은 행위는 그 본질에 있어서 기관행위로서의 품격을 상실하여 국가 등에게 그 책임을 귀속시킬 수 없으므로 공무원 개인에게 불법행위로 인한 손해배상책임을 부담시키되, 다만 이러한 경우에도 그 행위의 외관을 객관적으로 관찰하여 공무원의 직무집행으로 보여질 때에는 피해자인 국민을 두텁게 보호하기 위하여 국가 등이 공무원 개인과 중첩적으로 배상책임을 부담하되 국가 등이 배상책임을 지는 경우에는 공무원 개인에게 구상할 수 있도록 함으로써 궁극적으로 그 책임이 공무원 개인에게 귀속되도록 하려는 것이라고 봄이 합당하다.

(3) 소결

위법행위가 공무원의 고의 또는 중과실에 기한 경우에 그 행위는 기관행위로서 품격을 상실하게 된다.

그러나 그 행위의 외관이 여전히 공무원의 직무행위로 보여진다면 피해자와의 관계에서는 기관의 행위로 인정하여야 하며, 피해자인 국민을 두텁게 보호하기 위해 국가가 자기책임으로 배상하는 것이 타당하다.

[국가배상법] 제2조 (배상책임)

- ① 국가나 지방자치단체는 공무원 또는 공무를 위탁받은 사인(이하 “공무원”이라 한다)이 직무를 집행하면서 고의 또는 과실로 법령을 위반하여 타인에게 손해를 입히거나, 「자동차손해배상 보장법」에 따라 손해배상의 책임이 있을 때에는 이 법에 따라 그 손해를 배상하여야 한다. 다만, 군인·군무원·경찰공무원 또는 예비군대원이 전투·훈련 등 직무 집행과 관련하여 전사(戰死)·순직(殉職)하거나 공상(公傷)을 입은 경우에 본인이나 그 유족이 다른 법령에 따라 재해보상금·유족연금·상이연금 등의 보상을 지급받을 수 있을 때에는 이 법 및 「민법」에 따른 손해배상을 청구할 수 없다.

1) 공무원

국가배상법 제2조는 ‘공무원 또는 공무를 위탁받은 사인’을 공무원으로 규정하고 있다.

여기에서 공무원은 행정부, 입법부, 사법부 소속의 공무원 및 지방자치단체의 공무원을 포함하며, 실질적으로 공무를 수행하는 **기능적 의미의 공무원**을 말한다. 판례는 공무를 위탁받은 사인인 공무수탁사인 경우 공무의 위탁이 일시적이고 한정적인 경우에도 공무원에 해당한다고 판시한 바 있다.

대법원 2001. 1. 5. 선고 98다39060 판결

국가배상법 제2조 소정의 ‘공무원’이라 함은 국가공무원법이나 지방공무원법에 의하여 공무원으로서의 신분을 가진 자에 국한하지 않고, 널리 공무를 위탁받아 실질적으로 공무에 종사하고 있는 일체의 자를 가리키는 것으로서, 공무의 위탁이 일시적이고 한정적인 사항에 관한 활동을 위한 것이어도 달리 볼 것은 아니다.

2) 직무행위

직무행위의 범위에 대해 협의설, 광의설 등 견해 대립이 있으나, 판례는 ‘국가배상청구의 요건인 ‘공무원의 직무’에는 **권력적 작용만이 아니라 비권력적 작용도 포함되며** 단지 행정주체가 사경제주체로서 하는 활동만 제외된다(98다39060)’고 하여 **광의설**의 입장을 취한다. 즉, 직무행위에는 **공법상의 권력작용**, **비권력 작용** 등 모든 공행정 작용이 해당 되며, **입법작용**과 **사법작용**도 포함된다.

[사익보호성의 필요성]**1. 문제점**

국가배상책임이 인정되기 위하여 공무원에게 부여된 **직무상의 의무**가 국민의 **사익을 보호하기** 위해 부과된 **것이어야 하는지**에 대해 견해가 대립한다.

2. 학설

- ① 국가배상책임이 인정되기 위한 요건으로 **법령상 직무의 위반만 있으면 된다고 보고**, 직무의 사익보호성은 개별적인 관계에서의 원고적격의 문제라고 보는 <불요설>과
- ② 직무상의 의무는 국가의 국민에 대한 일반적인 직무수행의무와 구별되는 **사익보호를 목적으로 하는 것**이어야 한다고 보는 <필요설> 등이 있다.

3. 판례

공무원에게 부과된 직무상 의무의 내용이 단순히 공공 일반의 이익을 위한 것이거나 행정기관 내부의 질서를 규율하기 위한 것이 아니고 전적으로 또는 부수적으로 사회구성원 개인의 안전과 이익을 보호하기 위하여 설정된 것이라면, 공무원이 그와 같은 직무상 의무를 위반함으로써 인하여 피해자가 입은 손해에 대하여는 상당인과관계가 인정되는 범위 내에서 국가가 배상책임을 진다. [대법원 2017. 11. 9. 선고 2017다228083 판결]

4. 소결

국가배상법은 위법한 행정작용으로 손해를 입은 국민의 권리구제에 입법목적이 있으므로, 직무상 의무가 전적으로 또는 부수적으로 개인의 안전과 이익을 위해 설정된 것인 경우에 한하여 국가배상책임을 인정하는 <필요설>이 타당하다.

[사법(司法)작용과 국가배상]

1. 문제점

국가배상법 제2조의 '공무원'에 법관도 포함되고, 재판행위도 직무에 해당한다. 그러나 법관의 재판행위의 결과인 확정판결이 있으면 기판력이 발생 되므로 재판행위에 대해 국가배상청구가 가능한지가 문제 된다.

2. 학설

- ① 국가배상책임을 인정하여도 확정판결의 기판력을 침해하는 것은 아니라는 <국가배상청구 긍정설>,
- ② 국가배상책임을 인정하는 것이 확정판결의 효력을 부정하는 것은 아니지만, 판결의 위법성이 인정되어야 하고, 이는 기판력을 침해하는 것이므로 부정하는 <국가배상청구 부정설> 및
- ③ 재판행위의 특수성을 고려하여 법적 안정성과 국민의 권리구제를 적절히 조화시켜 제한적으로 인정하여야 한다고 보는 <제한적 긍정설>이 있다.

3. 판례

판례는 법관의 재판행위에 국가배상책임을 인정하려면 당해 법관이 위법 또는 부당한 목적을 가지고 재판을 하였다거나 법관이 그에게 부여된 권한의 취지에 명백히 어긋나게 이를 행사하였다고 인정할 만한 특별한 사정이 있어야 한다고 하여 제한적으로 인정하고 있다.

대법원 2003. 7. 11. 선고 99다24218 판결

법관의 재판에 법령의 규정을 따르지 아니한 잘못이 있다 하더라도 이로써 바로 그 재판상 직무행위가 국가배상법 제2조 제1항에서 말하는 위법한 행위로 되어 국가의 손해배상책임을 발생하는 것은 아니고, 그 국가배상책임을 인정하려면 당해 법관이 위법 또는 부당한 목적을 가지고 재판을 하였다거나 법이 법관의 직무수행상 준수할 것을 요구하고 있는 기준을 현저하게 위반하는 등 법관이 그에게 부여된 권한의 취지에 명백히 어긋나게 이를 행사하였다고 인정할 만한 특별한 사정이 있어야 한다.

4. 소결

재판행위의 특수성은 국가배상의 성립요건인 위법성 또는 고의·과실의 판단과정에서 고려될 수 있으며, 법관도 공무원이고 재판행위도 직무에 포함되므로 <국가배상청구 긍정설>에 따라 위법한 재판행위에 대해 국가배상청구가 가능하다고 보는 것이 타당하다.

3) 집행하면서 (직무 관련성)

직무를 '집행하면서'는 단순한 직무 집행행위뿐만 아니라 널리 외형상 직무집행과 관련 있는 행위를 포함한다고 보는 것이 통설·판례의 태도이다(외형설). 즉, 비록 실질적으로 직무행위가 아니거나 주관적으로 공무집행 의사가 없다고 하더라도 외관상 공무원의 집행행위로 보여진다면 '직무를 집행하면서'에 포함되는 것으로 보아야 한다.

대법원 2005. 1. 14. 선고 2004다26805 판결

국가배상법 제2조 제1항의 '직무를 집행함에 당하여'라 함은 직접 공무원의 직무집행행위이거나 그와 밀접한 관련이 있는 행위를 포함하고, 이를 판단함에 있어서는 행위 자체의 외관을 객관적으로 관찰하여 공무원의 직무행위로 보여질 때에는 비록 그것이 실질적으로 직무행위가 아니거나 또는 행위자로서는 주관적으로 공무집행의 의사가 없었다고 하더라도 그 행위는 공무원이 '직무를 집행함에 당하여' 한 것으로 보아야 한다.

4) 고의 또는 과실

고의란 위법행위의 발생 가능성을 인식하고도 그 결과를 용인하는 것을 말하고, 과실이란 통상적으로 갖추어야 할 주의의무를 해태 하여 위법한 결과의 가능성을 인식하지 못하는 것을 의미한다.

① 입증책임

고의·과실의 입증책임은 원고가 부담한다.

② 판단기준

고의·과실의 유무는 직무를 행하는 평균적인 공무원을 기준으로 판단한다.

③ 법령의 해석 및 적용

판례는 원칙적으로 공무원이 관계 법규를 알지 못하거나 필요한 지식을 갖추지 못해 법규의 해석을 그르친 경우에는 과실이 있다고 본다. 그러나 법령에 대한 해석이 명백하지 않은 등의 이유로 관계 공무원이 그 나름대로 신중을 다하여 합리적인 근거를 찾아 그 중 어느 한 견해를 따라 내린 해석이 후에 대법원의 입장과 달라 결과적으로 위법하게 된 경우까지 공무원의 과실을 인정할 수는 없다고 판시한 바 있다.

대법원 2001. 2. 9. 선고 98다52988 판결

법령에 대한 해석이 복잡, 미묘하여 워낙 어렵고, 이에 대한 학설, 판례조차 귀일되어 있지 않는 등의 특별한 사정이 없는 한 일반적으로 공무원이 관계 법규를 알지 못하거나 필요한 지식을 갖추지 못하고 법규의 해석을 그르쳐 행정처분을 하였다면 그가 법률전문가가 아닌 행정직 공무원이라고 하여 과실이 없다고는 할 수 없다.

대법원 2010. 4. 29. 선고 2009다97925 판결

법령에 대한 해석이 그 문언 자체만으로는 명백하지 아니하여 여러 견해가 있을 수 있는 데다가 이에 대한 선례나 학설, 판례 등도 귀일된 바 없어 의의(疑義)가 없을 수 없는 경우에 관계 공무원이 그 나름대로 신중을 다하여 합리적인 근거를 찾아 그 중 어느 한 견해를 따라 내린 해석이 후에 대법원이 내린 입장과 같지 않아 결과적으로 잘못된 해석에 돌아가고, 이에 따른 처리가 역시 결과적으로 위법하게 되어 그 법령의 부당집행이라는 결과를 가져오게 되었다고 하더라도 그와 같은 처리방법 이상의 것을 성실한 평균적 공무원에게 기대하기는 어려운 일이고, 따라서 이러한 경우에도 공무원의 과실을 인정할 수는 없다.

④ 재량준칙에 따른 처분

판례는 ‘재량의 경우에 한 처분에 있어 관계공무원이 공익성, 합목적성의 인정, 판단을 잘못하여 그 재량권의 범위를 넘어서 행정행위를 한 경우가 있다 하더라도 공익성 및 합목적성의 적절여부의 판단기준은 구체적 사안에 따라 각각 동일하다 할 수 없을 뿐만 아니라 구체적인 경우 어느 행정처분을 할 것인가에 관하여 행정청 내부에 일응의 기준을 정해 둔 경우 그 기준에 따른 행정처분을 하였다면 이에 관여한 공무원에게 그 직무상의 과실이 있다고 할 수 없다’고 판시한 바 있다.

5) 법령의 위반

국가배상법은 배상책임의 요건으로 ‘법령의 위반’을 요구한다. 여기에서 ‘법령’은 ‘법 일반’을 의미한다고 보는 것이 일반적인 견해(행위위법설 입장)이고, 법 일반에는 성문법뿐만 아니라 관습법, 법의 일반원칙, 조리 등 불문법도 포함된다.

‘위반’의 의미에 대해서는 행위위법설, 결과위법설 등 견해 대립이 있는데, 손해배상은 위법행위에 대한 손해전보 수단이며, 취소소송에서 위법의 본질이 법규 위반인 점을 고려할 때 국가배상도 위법에 개념을 ‘법질서 위반’이라는 단일한 가치판단을 기준으로 보아야 하며, 국민의 권리구제 확대를 위해 <광의의 행위위법설>의 입장이 타당하다.

[국가배상법의 위법의 개념]

1. 학설

- ① 국가배상법상의 위법은 공무원의 직무행위가 ‘법 규범’에 적합한지를 기준으로 판단하여야 한다고 보는 <협의의 행위위법설>,
- ② ‘법령 위반’ 뿐만 아니라 인권존중·권력남용 금지의 원칙·신의성실의 원칙의 위반도 포함된다고 보는 <광의의 행위위법설>
- ③ 가해행위의 결과로 국민이 받은 손해를 국민이 수인하여야 하는가를 기준으로 판단하는 <결과불법설> 및
- ④ 직무행위의 적법·위법뿐만 아니라, 피침해이익의 성격과 침해의 정도, 가해행위의 태양 등을 종합 고려하여야 한다고 보는 <상대적 위법성설>이 있다.

2. 판례

시위자들의 화염병으로 인해 발생한 약국화재 사건에서 결과불법설을 배제하고 국가배상의 위법을 법령의 위반을 기준으로 판시한 바 있다. 이 판례와 같이 <행위위법설>이 주류적인 입장이다. 다만, 상대적 위법성설 입장에서 피침해이익의 종류 및 성질, 침해행위가 되는 행정처분의 태양 및 그 원인, 행정처분의 발동에 대한 피해자측의 관여의 유무, 정도 및 손해의 정도 등 제반 사정을 종합하여 손해의 전보책임을 판단하여야 한다고 보는 판례도 있다.

대법원 1997. 7. 25. 선고 94다2480 판결

국가배상책임은 공무원의 직무집행이 법령에 위반한 것임을 요건으로 하는 것으로서, 공무원의 직무집행이 법령이 정한 요건과 절차에 따라 이루어진 것이라면 특별한 사정이 없는 한 이는 법령에 적합한 것이고 그 과정에서 개인의 권리가 침해되는 일이 생긴다고 하여 그 법령 적합성이 곧바로 부정되는 것은 아니라고 할 것인바, 불법시위를 진압하는 경찰관들의 직무집행이 법령에 위반한 것이라고 하기 위하여는 그 시위진압이 불필요하거나 또는 불법시위의 태양 및 시위 장소의 상황 등에서 예측되는 피해 발생의 구체적 위험성의 내용에 비추어 시위진압의 계속 수행 내지 그 방법 등이 현저히 합리성을 결하여 이를 위법하다고 평가할 수 있는 경우이어야 한다.

3. 소결

손해배상은 위법행위에 대한 전보수단으로, 적법행위로 발생한 손실에 대한 전보수단인 손실보상과 구별되고, 취소소송에서 위법의 본질이 법규 위반인 점을 고려할 때 국가배상도 위법의 개념을 '법질서 위반'이라는 단일한 가치판단 기준으로 보아야 하며, 국민의 권리구제 확대를 위해 <광의의 행위위법설>의 입장이 타당하다.

6) 손해 및 인과관계

국가배상책임이 인정되기 위해서는 공무원의 불법행위로 인해 손해가 발생 되어야 한다. '손해'는 가해행위로 인해 발생한 일체의 손해로서 법률상 이익의 침해를 말하며, 반사적 이익의 침해는 해당 되지 않는다. 손해는 적극적·소극적 손해를 불문하고, 생명·신체·정신상의 손해도 포함된다. 또한, 가해행위와 손해 사이에 상당인과관계가 있어야 하는데, '상당인과관계'의 유무는 일반적인 결과 발생의 개연성은 물론 직무상 의무를 부과하는 법령을 비롯한 행동규범의 목적, 가해행위의 양태와 피해의 정도 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(2017다 286874).

04 공무원의 배상책임 [★★]

1) 문제점

헌법 제29조 제1항 단서는 공무원 개인의 책임은 면제되지 않는다고 규정하고 있는데, 이와 관련하여 국가배상책임에서 가해 공무원 개인도 피해자에 대해서 배상책임을 지는지가 문제 된다.

2) 학설

- ① 국가배상책임을 자기책임으로 보는 입장에서 국가와 공무원 개인의 책임은 독립해서 성립되고, 피해자의 권리구제를 폭넓게 보장하기 위하여 선택적 청구권 행사를 긍정하는 <긍정설>.
- ② 국가배상책임을 대위책임으로 보는 입장에서 공무원의 직접책임을 인정하는 것은 공무원의 직무집행을 위축시킬 우려가 있으므로 선택적 청구권 행사를 부정하는 <부정설> 및
- ③ 경과실에 기한 것인 경우는 여전히 기관행위이므로 국가만이 책임을 지고, 고의·중과실인 경우에는 공무원 개인의 불법행위로 보아 선택적 청구권을 긍정하는 <제한적 긍정설>이 있다.

3) 판례

판례는 공무원이 직무를 수행함에 있어 경과실로 타인에게 손해를 입힌 경우에는 여전히 국가 등의 기관의 행위로 보아 그로 인하여 발생한 손해에 대한 배상책임도 전적으로 국가 등에만 귀속시키고, 반면에 공무원의 위법행위가 고의·중과실에 기한 경우에는 기관행위로서의 품격을 상실하여 국가 등에게 그 책임을 귀속시킬 수 없으므로 공무원 개인에게 불법행위로 인한 손해배상책임을 부담시켜야 한다고 하여 <제한적 긍정설>의 입장을 취한다.

4) 소결

헌법 제29조 제1항 단서에서 공무원의 책임이 면제되지 않는다고 규정하고 있으나 구체적인 손해배상책임의 범위까지 규정하고 있지는 않고, 국가배상법은 공무원의 내부적 책임만 규정하고 있을 뿐 외부적 책임에 대해서는 규정한 바 없다. 따라서 양자를 조화롭게 해석하고 공무원의 직무집행행위를 위축시키지 않기 위해서 고의·중과실의 경우에만 공무원 개인의 책임을 인정하는 <제한적 긍정설>이 타당하다.

행정상 손실보상은 국가 등이 공공필요에 의해 행한 **적법한 공권력의 행사**로 인해 가해진 **특별한 희생**에 대하여 **사유 재산권 보장**과 **공평부담의 견지**에서 행정주체가 행하는 보상을 말한다.

01 의미 및 성질

결과제거청구권이란 행정청의 공행정작용으로 야기된 **위법한 결과의 제거**를 청구하는 일종의 **원상회복청구권**을 말한다. 즉, 위법한 상태로 인하여 권익을 침해받고 있는 자가 위법한 상태를 제거하고, 원상회복 시켜줄 것을 청구하는 권리이다. 헌법상의 **법치행정의 원리** 등에서 근거를 찾을 수 있으며, **개인적 공권**으로 볼 수 있다.

02 요건

- ① 권익의 침해는 **공행정작용**에 의한 것이어야 한다.
공행정작용에는 **권력작용뿐만 아니라 비권력적작용(사실행위)**도 포함되며, **부작위에 의한 침해**도 가능하다.
- ② 공행정작용으로 **개인의 권리 또는 법적 이익이 침해**되고 있어야 한다.
여기서 권익은 재산상 권익뿐만 아니라 명예, 신용 등 **정신적인 것**도 포함된다.
- ③ 결과제거청구권이 인정되려면 **위법한 상태가 계속**되고 있어야 하며,
위법한 상태의 유무는 **사실심 변론종결시**를 기준으로 판단한다.
- ④ 결과제거청구는 **원상회복이 사실상 가능**하고, **법적으로 허용**되며,
의무자에게 그것이 **기대 가능한 것(수인가능성)**이어야 한다.

03 결과제거청구권의 내용

결과제거청구권은

- ① **위법한 공행정작용으로 야기된 직접적인 결과의 제거**와
- ② 그 제거를 통한 **원상회복** 또는 **동등한 가치 있는 상태로의 회복**을 내용으로 한다.

PART 05

도시 및 주거환경 정비법

Chapter 01 개설

제1절 의의 및 종류

정비사업이란 도시기능을 회복하기 위하여 정비구역에서 정비기반시설을 정비하거나 주택 등 건축물을 개량 또는 건설하는 다음 각 목의 사업을 말한다. 도시정비법에 따른 정비사업에는 주거환경개선사업, 재개발사업 및 재건축사업이 있다.

[도시정비법] 제1조 (목적)

이 법은 도시기능의 회복이 필요하거나 주거환경이 불량한 지역을 계획적으로 정비하고 노후·불량건축물을 효율적으로 개량하기 위하여 필요한 사항을 규정함으로써 도시환경을 개선하고 주거생활의 질을 높이는 데 이바지함을 목적으로 한다.

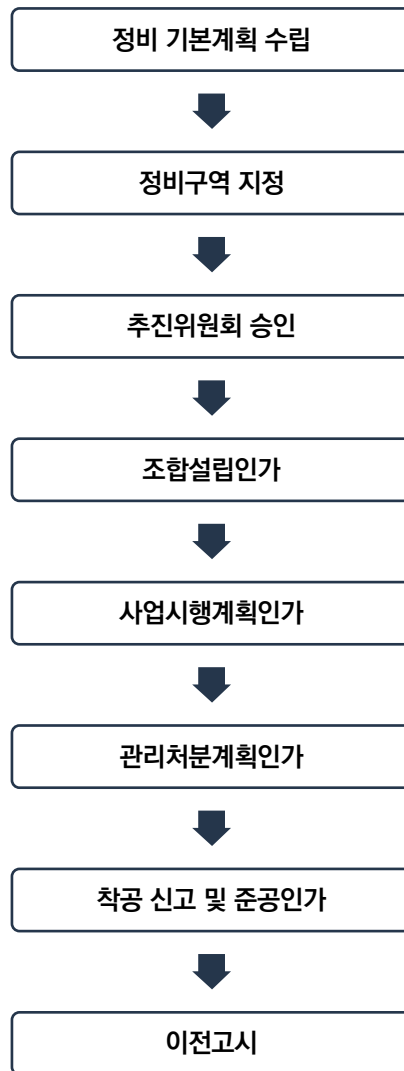
제2절 재개발사업과 재건축사업의 차이

재개발사업은 '정비기반시설이 열악하고 노후·불량건축물이 밀집한 지역에서 주거환경을 개선하기 위하여 시행하는 사업(도시 및 주거환경정비법 2조 2호 나목)'을 말하고, 재건축사업은 '정비기반시설은 양호하나 노후·불량건축물이 밀집한 지역에서 주거환경을 개선하기 위하여 시행하는 사업(법 2조 2호 다목)'을 말한다.

재개발사업과 재건축사업은 노후·불량건축물이 밀집한 지역에서 주거환경을 개선하기 위해 시행하는 사업으로 그 목적은 유사하나, 판례는 재개발사업은 공공성이 높다고 인정하여 공익사업에 해당한다고 보지만, 재건축사업은 공공성 및 공익성이 미약하여 토지보상법상 수용권 등이 부여되는 공익사업이라고 볼 수 없다고 본다. 이에 토지보상법의 적용에 있어 차이가 있다.

대법원 2014. 7. 24. 선고 2012다62561,62578 판결

구 도시정비법 제49조 제6항 단서는 도시정비법 제38조에 따라 사업시행자에게 '공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률'(이하 '공익사업법'이라 한다)상 정비구역 안의 토지 등을 수용 또는 사용할 권한이 부여된 정비사업에 제한적으로 적용되고, 그 권한이 부여되지 아니한 주택재건축사업에는 적용될 수 없다.



01 개설

도시정비법 제35조 제1항에서는 시장·군수등, 토지주택공사등 또는 지정개발자가 아닌 자가 정비사업을 시행하려는 경우에는 토지등소유자로 구성된 조합을 설립하여야 한다고 규정하고 있다. 즉, 정비사업을 추진하기 위해서는 추진위원회를 구성하여 시장등의 승인을 받고 이후 도시정비법에 따라 조합을 설립하여 시장등으로부터 조합설립인가를 받아야 한다. 조합은 법인격을 가지며, 사업시행자로서 관할 행정청의 감독 아래 공적 사무를 담당하는 행정주체의 지위를 가진다.

02 법적성질 [★★]

1) 학설

조합설립인가의 법적성질에 대해

- ① 조합설립행위를 기본행위로 보고,
인가는 이를 보충하여 법률상의 효과를 완성시키는 보충행위로서 <강학상 인가>로 보는 견해와
- ② 조합설립행위를 조합설립인가를 받기 위한 필요 요건으로 보고,
인가는 조합을 행정주체로 설정하는 행위로서 <강학상 특허>로 보는 견해가 있다.

2) 판례

(1) 종래 판례 (강학상 인가)

종래에는 조합설립인가를 제3자의 법률행위를 보충하여 그 법률상의 효과를 완성시키는 보충행위라고 보았다. 즉, 조합설립행위는 사법행위로서 기본행위이고, 시장등의 조합설립인가는 기본행위의 효력을 완성시켜주는 보충행위로서 <강학상 인가>로 보는 입장을 취했다.

대법원 2000. 9. 5. 선고 99두1854 판결

주택건설촉진법에서 규정한 바에 따른 관할시장 등의 재건축조합설립인가는 불량·노후한 주택의 소유자들이 재건축을 위하여 한 재건축조합설립행위를 보충하여 그 법률상 효력을 완성시키는 보충행위이다.

(2) 최근 판례 (설권적 처분)

최근에는 판례를 변경하여 조합설립인가처분을 도시정비법상 재건축사업을 시행할 수 있는 권한을 갖는 행정주체로서의 지위를 부여하는 설권적 처분으로 보고, 조합설립행위는 인가처분을 위한 요건 중에 하나라고 판시한 바 있다.

대법원 2009. 9. 24. 선고 2008다60568 판결

행정청이 도시 및 주거환경정비법 등 관련 법령에 근거하여 행하는 조합설립인가처분은 단순히 사인들의 조합설립행위에 대한 보충행위로서의 성질을 갖는 것에 그치는 것이 아니라 법령상 요건을 갖추 경우 도시 및 주거환경정비법상 주택재건축사업을 시행할 수 있는 권한을 갖는 행정주체(공법인)로서의 지위를 부여하는 일종의 설권적 처분의 성격을 갖는다고 보아야 한다. 그리고 그와 같이 보는 이상 조합설립결의는 조합설립인가처분이라는 행정처분을 하는 데 필요한 요건 중 하나이다.

03 쟁송수단 [★★]

1) 문제점

조합설립행위에 하자가 있는 경우 조합설립행위에 대한 효력을 다투는 소송을 제기하여야 하는지, 설립행위의 하자를 이유로 조합설립인가처분의 효력을 다투는 소송을 제기하여야 하는지가 문제 된다.

2) 판례

종래에는 조합설립인가를 강학상 인가로 보아 기본행위인 조합설립에 하자가 있는 경우에는 민사쟁송으로써 따로 그 기본행위의 취소 또는 무효확인 등을 구하는 것은 별론으로 하고 기본행위의 불성립 또는 무효를 내세워 바로 그에 대한 감독청의 인가처분의 취소 또는 무효확인을 소구할 법률상 이익이 있다고 할 수 없다고 판시하였으나, 최근에는 조합설립인가를 강학상 특허로 보는 입장에서 조합설립결의에 하자가 있다면 그 하자를 이유로 직접 항고소송의 방법으로 조합설립인가처분의 취소 또는 무효확인을 구하여야 한다고 판시한다.

종래 판례 : 대법원 2000. 9. 5. 선고 99두1854 판결

조합설립행위에 하자가 있을 때에는 그에 대한 인가가 있다 하더라도 기본행위인 조합설립이 유효한 것으로 될 수 없고, 따라서 그 기본행위는 적법유효하나 보충행위인 인가처분에만 하자가 있는 경우에는 그 인가처분의 취소나 무효확인을 구할 수 있을 것이지만 기본행위인 조합설립에 하자가 있는 경우에는 민사쟁송으로써 따로 그 기본행위의 취소 또는 무효확인 등을 구하는 것은 별론으로 하고 기본행위의 불성립 또는 무효를 내세워 바로 그에 대한 감독청의 인가처분의 취소 또는 무효확인을 소구할 법률상 이익이 있다고 할 수 없다.

최근 판례 : 대법원 2009. 9. 24. 선고 2008다60568 판결

조합설립결의는 조합설립인가처분이라는 행정처분을 하는 데 필요한 요건 중 하나에 불과한 것이어서, 조합설립결의에 하자가 있다면 그 하자를 이유로 직접 항고소송의 방법으로 조합설립인가처분의 취소 또는 무효확인을 구하여야 하고, 이와는 별도로 조합설립결의 부분만을 따로 떼어내어 그 효력 유무를 다투는 확인의 소를 제기하는 것은 원고의 권리 또는 법률상의 지위에 현존하는 불안 위험을 제거하는 데 가장 유효·적절한 수단이라 할 수 없어 특별한 사정이 없는 한 확인의 이익은 인정되지 아니한다.

3) 소결

조합설립인가가 있으면 조합은 사업을 시행할 수 있는 권한을 갖는 행정주체의 지위를 갖게 되므로 조합설립인가를 특허로 보는 것이 타당하다. 따라서 조합설립행위에 하자가 있다면 이는 인가처분의 요건에 하자가 있는 것이므로 그 하자를 이유로 인가처분을 직접대상으로하여 항고쟁송을 제기하여 다투는 것이 타당하다.

	조합설립 법적성질	조합설립인가 법적성질	쟁송수단 (조합설립행위의 하자)
종래	사법행위로서 기본행위	강학상 인가	민사소송으로 기본행위의 무효확인 소 제기
최근	공법행위로서 인가를 위한 절차요건	설권적 처분	항고소송으로 조합설립인가의 취소 또는 무효확인 소 제기

01 개설

도시정비법 제50조에 의거 사업시행자는 정비사업을 시행하려는 경우에는 사업시행계획서에 정관등 서류를 첨부하여 시장·군수등에게 제출하고 사업시행계획인가를 받아야 한다. 또한 인가받은 사항을 변경하거나 정비사업을 중지 또는 폐지하려는 경우에도 같으며, 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하는 경우에는 시장·군수등에게 신고하여야 한다.

02 법적성질 [★★]

1) 사업시행계획 (행정계획)

사업시행계획은 공법인으로서 행정주체의 지위를 가지는 사업시행자가 수립하는 것으로 행정계획의 성격을 가진다. 또한 사업시행계획이 인가·고시를 통해 확정되면 이해관계인에 대한 구속적 행정계획으로서 독립된 행정처분이 된다.

2) 사업시행인가

(1) 조합이 시행하는 사업의 경우 (강학상 인가)

판례는 '조합이 수립한 사업시행계획은 그것이 인가·고시를 통해 확정되면 이해관계인에 대한 구속적 행정계획으로서 독립된 행정처분에 해당하므로 사업시행계획을 인가하는 행정청의 행위는 조합의 사업시행계획에 대한 법률상의 효력을 완성시키는 보충행위에 해당한다'고 하여 사업시행인가의 법적성질을 강학상 인가로 본다.

[대법원 2010. 12. 9. 선고 2010두1248 판결]

(2) 토지 등 소유자들이 조합 설립하지 아니하고 시행하는 사업의 경우 (설권적 처분)

판례는 '토지 등 소유자들이 그 사업을 위한 조합을 따로 설립하지 아니하고 직접 사업을 시행하는 경우에는 사업시행인가를 받은 토지 등 소유자들은 관할 행정청의 감독 아래 정비구역 안에서 구 도시정비법상의 도시환경정비사업을 시행하는 목적 범위 내에서 법령이 정하는 바에 따라 일정한 행정작용을 행하는 행정주체로서의 지위를 가진다. 그렇다면 토지 등 소유자들이 직접 시행하는 도시환경정비사업에서 토지 등 소유자에 대한 사업시행인가 처분은 단순히 사업시행계획에 대한 보충행위로서의 성질을 가지는 것이 아니라 구 도시정비법상 정비사업을 시행할 수 있는 권한을 가지는 행정주체로서의 지위를 부여하는 일종의 설권적 처분의 성격을 가진다'고 판시한 바 있다. [대법원 2013. 6. 13. 선고 2011두19994 판결]

03 쟁송수단 [★★]

대법원은 '인가처분에는 고유한 하자가 없는데 사업시행계획에 하자가 있다면 사업시행계획의 무효확인이나 취소를 구하여야 할 것이지 사업시행계획의 무효를 주장하면서 곧바로 그에 대한 인가처분의 무효확인이나 취소를 구하여서는 아니 된다'고 하여 사업시행계획에 대한 취소 또는 무효확인소송을 항고소송으로 제기하도록 하고 있다.

대법원 2021. 2. 10. 선고 2020두48031 판결

구 도시 및 주거환경정비법에 기초하여 주택재개발정비사업조합이 수립한 사업시행계획은 관할 행정청의 인가·고시가 이루어지면 이해관계인들에게 구속력이 발생하는 독립된 행정처분에 해당하고, 관할 행정청의 사업시행계획 인가 처분은 사업시행계획의 법률상 효력을 완성시키는 보충행위에 해당한다. 따라서 기본행위인 사업시행계획에는 하자가 없는데 보충행위인 인가처분에 고유한 하자가 있다면 그 인가처분의 무효확인이나 취소를 구하여야 할 것이지만,

인가처분에는 고유한 하자가 없는데 사업시행계획에 하자가 있다면 사업시행계획의 무효확인이나 취소를 구하여야 할 것이지 사업시행계획의 무효를 주장하면서 곧바로 그에 대한 인가처분의 무효확인이나 취소를 구하여서는 아니 된다.

01 개설

사업시행자는 도시정비법 제74조에 의거 분양신청기간이 종료된 때에는 **분양신청의 현황을 기초로 관리처분계획을 수립**하여 시장·군수등의 **인가**를 받아야 하며, 관리처분계획을 변경·중지 또는 폐지하려는 경우에도 또한 같다. 관리처분계획은 분양대상자별 종전의 토지 또는 건축물 등을 정비사업으로 조성한 토지와 건축시설에 대한 권리로 변화하여 배분하는 것을 주된 내용으로 하며, 정비사업의 추산액 및 비용분담 등에 관한 사항과 현금청산 내용을 포함한다. 조합은 관리처분계획에 대한 총회결의를 거쳐 관리처분계획인가를 신청하여야 한다.

02 법적성질 [★★]

1) 관리처분계획 (행정계획)

관리처분계획은 '주택재개발사업에서 사업시행자가 작성하는 포괄적 **행정계획**(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005두 11951 판결)'이라고 판시하고 있다.

대법원 2007. 9. 6. 선고 2005두11951 판결

도시 및 주거환경정비법상 주택재건축정비사업조합이 같은 법 제48조에 따라 수립한 관리처분계획에 대하여 관할 행정청의 **인가·고시**까지 있게 되면 관리처분계획은 **행정처분**으로서 효력이 발생하게 되므로, 총회결의의 하자를 이유로 하여 행정처분의 효력을 다투는 항고소송의 방법으로 관리처분계획의 취소 또는 무효확인을 구하여야 하고, 그와 별도로 행정처분에 이르는 절차적 요건 중 하나에 불과한 총회결의 부분만을 따로 떼어내어 효력 유무를 다투는 **확인**의 소를 제기하는 것은 특별한 사정이 없는 한 허용되지 않는다.

2) 관리처분인가 (강학상 인가)

관리처분인가는 관리처분계획에 대한 법률상의 효력을 완성시키는 **보충행위**로서 **강학상 인가**에 해당한다.

관리처분계획은 사업시행계획과 마찬가지로 **인가·고시**가 있게 되면 이해관계인에 대한 **구속적 행정계획**으로서 인가와는 별개의 독립한 행정처분이 된다.

대법원 2016. 12. 15. 선고 2015두51347 판결

도시정비법에 기초하여 주택재개발정비사업조합(이하 '조합'이라 한다)이 수립한 관리처분계획은 그것이 **인가·고시**를 통해 확정되면 이해관계인에 대한 **구속적 행정계획**으로서 독립적인 행정처분에 해당한다. 이러한 관리처분계획을 **인가**하는 행정청의 행위는 **조합의 관리처분계획에 대한 법률상의 효력을 완성시키는 보충행위**이다. 따라서 기본행위가 적법·유효하고 보충행위인 인가처분 자체에 흠이 있다면 그 인가처분의 무효나 취소를 주장할 수 있다. 그러나 인가처분에 흠이 없다면 **기본행위에 흠이 있다고 하더라도 따로 기본행위의 흠을 다투는 것은 별론으로 하고 기본행위의 흠을 내세워 바로 그에 대한 인가처분의 무효확인 또는 취소를 구할 수는 없으므로**, 그 당부에 관하여 판단할 필요 없이 해당 부분 청구를 **기각**하여야 한다.

03 쟁송수단 [★★]

대법원은 '행정청의 인가·고시까지 있게 되면 관리처분계획은 행정처분으로서 효력이 발생하게 되므로, 총회결의의 하자를 이유로 하여 행정처분의 효력을 다투는 항고소송의 방법으로 관리처분계획의 취소 또는 무효확인을 구하여야 하고, 그와 별도로 행정처분에 이르는 절차적 요건 중 하나에 불과한 총회결의의 부분만을 따로 떼어내어 효력 유무를 다투는 확인의 소를 제기하는 것은 특별한 사정이 없는 한 허용되지 않는다.'고 판시하고 있다.

대법원 2009. 10. 29. 선고 2008다97737 판결

행정주체인 재건축조합을 상대로 관리처분계획안에 대한 조합 총회결의의 효력 등을 다투는 소송은 행정처분에 이르는 절차적 요건의 존부나 효력 유무에 관한 소송으로서 그 소송결과에 따라 행정처분의 위법 여부에 직접 영향을 미치는 공법상 법률관계에 관한 것이므로, 이는 행정소송법상의 당사자소송에 해당한다.

그리고 이러한 소송은, 관리처분계획이 인가·고시되기 전이라면 위법한 총회결의에 대해 무효확인 판결을 받아 이를 관할 행정청에 자료로 제출하거나 재건축조합으로 하여금 새로이 적법한 관리처분계획안을 마련하여 다시 총회결의를 거치도록 함으로써 하자 있는 관리처분계획이 인가·고시되어 행정처분으로서 효력이 발생하는 단계에까지 나아가지 못하도록 저지할 수 있고, 또 총회결의에 대한 무효확인판결에도 불구하고 관리처분계획이 인가·고시되는 경우에도 관리처분계획의 효력을 다투는 항고소송에서 총회결의 무효확인소송의 판결과 증거들을 소송자료로 활용함으로써 신속하게 분쟁을 해결할 수 있으므로, 관리처분계획에 대한 인가·고시가 있기 전에는 허용할 필요가 있다.

그러나 나아가 관리처분계획에 대한 관할 행정청의 인가·고시까지 있게 되면 관리처분계획은 행정처분으로서 효력이 발생하게 되므로, 총회결의의 하자를 이유로 하여 행정처분의 효력을 다투는 항고소송의 방법으로 관리처분계획의 취소 또는 무효확인을 구하여야 하고, 그와 별도로 행정처분에 이르는 절차적 요건 중 하나에 불과한 총회결의의 부분만을 따로 떼어내어 효력 유무를 다투는 확인의 소를 제기하는 것은 특별한 사정이 없는 한 허용되지 않는다고 보아야 한다.

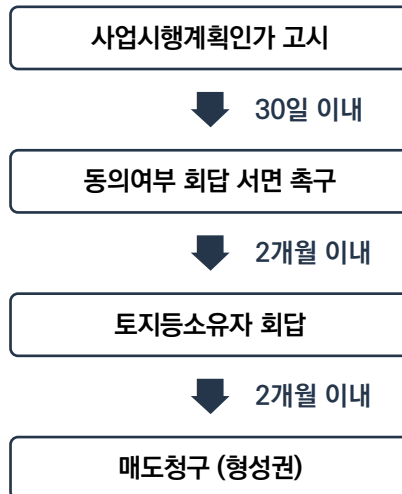
대법원 2007. 9. 6. 선고 2005두11951 판결

구 도시재개발법(2002. 12. 30. 법률 제6852호로 폐지되기 전의 것) 제34조, 제35조, 제42조, 제43조의 각 규정에 의하면, 관리처분계획은 주택재개발사업에서 사업시행자가 작성하는 포괄적 행정계획으로서 사업시행의 결과 설치되는 대지를 포함한 각종 시설물의 권리귀속에 관한 사항과 그 비용 부담에 관한 사항을 정하는 행정처분이고, 청산금부과처분은 관리처분계획에서 정한 비용 부담에 관한 사항에 근거하여 대지 또는 건축시설의 수분양자에게 청산금납부의무를 발생시키는 구체적인 행정처분으로서, 청산금부과처분이 선행처분인 관리처분계획을 전제로 하는 것이기는 하나 위 두 처분은 각각 단계적으로 별개의 법률효과를 발생시키는 독립된 행정처분이라고 할 것이므로, 관리처분계획에 불가쟁력이 생겨 그 효력을 다투 수 없게 된 경우에는 그 관리처분계획에 위법사유가 있다 할지라도 그것이 당연무효의 사유가 아닌 한 관리처분계획상의 하자를 이유로 후행처분인 청산금부과처분의 위법을 주장할 수는 없다.

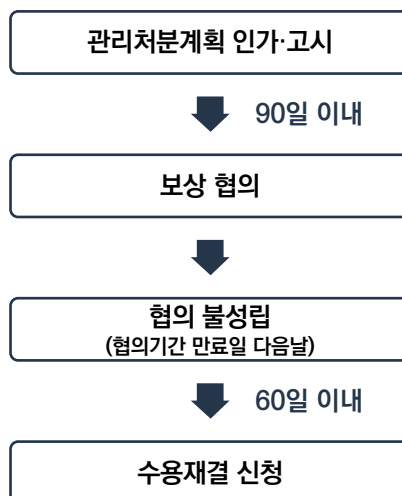
사업시행계획 관리처분계획 법적성질	인가	쟁송수단 (총회결의의 하자)	
		인가 전	인가 후
구속적 행정계획	강학상 인가	당사자소송으로 총회결의의 무효확인 소 제기	항고소송으로 사업시행계획 (관리처분계획)의 취소 또는 무효확인 소 제기

01 재건축사업의 매도청구 (『도시정비법』 제64조, 제73조)

매도청구권은 사업시행자가 조합설립이나 사업시행자 지정에 동의 않은 **토지등소유자**를 상대로 토지의 소유권과 그 밖의 권리를 **매도할 것을 청구할 수 있는 권리**를 말하며(제64조), 분양신청을 하지 아니한 경우에도(현금청산자) 매도청구를 할 수 있다. 매도청구권은 형성권으로 청구권 행사시 매매계약이 성립한 것으로 본다.

**02** 재개발사업의 수용재결 (『도시정비법』 제73조 제2항)

사업시행자는 관리처분계획이 인가·고시된 다음 날부터 90일 이내 **분양신청을 하지 않은 자 등**(현금청산자)에 대해 토지, 건축물 또는 그 밖의 권리의 손실보상에 관한 **협의를 하여야** 하고, **협약이 성립되지 아니하면** 토지보상법에 따른 **수용재결을 신청**할 수 있다.



03 매도청구소송과 토지보상법상 보상금을 다투는 쟁송절차의 차이점 [★★]

도시 및 주거환경정비법 제47조 위헌소원 [지정재판부 2011헌바224, 2012. 11. 29.]

주택재건축사업의 경우 사업시행자는 분양대상에서 제외된 조합원과의 사이에 청산에 관한 협의가 이루어지지 않을 경우 매도청구권을 행사할 수 있는데, 이 때 현금청산대상자에게는 개발이익이 포함된 시가에 따른 보상이 이루어지므로, 수용절차를 통해 개발이익이 제외된 보상을 받는 주택재개발사업의 경우에 비해 불합리한 차별이 있다고 볼 수 없고, 주택재개발사업의 경우와 달리 현금청산대상자에 대한 이주대책 등을 마련하지 않았다 하더라도 이는 사업 성격의 차이를 반영한 합리적인 차별이므로 평등원칙에 반하지 않는다.

1) 소송형태 및 관할법원

- ① 매도청구를 둘러싼 법률관계는 사법상의 법률관계로서 그 매도청구권 행사에 따른 소유권이전등기의무의 존부를 다투는 소송인 매도청구소송은 민사소송이다. 따라서 관할 법원은 민사법원이 된다. 반면에,
- ② 토지보상법 제85조 제2항에 따라 제기하는 보상금증감청구소송은 공법상 당사자소송이며, 사업시행자와 피수용자가 각각 피고 또는 원고가 되어 보상금을 다투는 소송이므로 형식적 당사자소송에 해당한다. 따라서 행정법원이 관할 법원이 된다.

대법원 2010. 4. 8. 선고 2009다93923 판결

구 도시 및 주거환경정비법상 주택재건축정비사업조합이 공법인이라는 사정만으로 조합 설립에 동의하지 않은 자의 토지 및 건축물에 대한 주택재건축정비사업조합의 매도청구권을 둘러싼 법률관계가 공법상의 법률관계에 해당한다거나 그 매도청구권 행사에 따른 소유권이전등기절차 이행을 구하는 소송이 당연히 공법상 당사자소송에 해당한다고 볼 수는 없고, 위 법률의 규정들이 주택재건축정비사업조합과 조합 설립에 동의하지 않은 자와의 사이에 매도청구를 둘러싼 법률관계를 특별히 공법상의 법률관계로 설정하고 있다고 볼 수도 없으므로, 주택재건축정비사업조합과 조합 설립에 동의하지 않은 자 사이의 매도청구를 둘러싼 법률관계는 사법상의 법률관계로서 그 매도청구권 행사에 따른 소유권이전등기의무의 존부를 다투는 소송은 민사소송에 의하여야 할 것이다.

대법원 1991. 11. 26. 선고 91누285 판결

토지수용법 제75조의2 제2항의 규정은 그 제1항에 의하여 이의재결에 대하여 불복하는 행정소송을 제기하는 경우, 이것이 보상금의 증감에 관한 소송인 때에는 이의재결에서 정한 보상금이 증액 변경될 것을 전제로 하여 기업자를 상대로 보상금의 지급을 구하는 공법상의 당사자소송을 규정한 것으로 볼 것이다.

2) 절차 및 제소기간

- ① 매도청구권의 경우 사업시행계획인가의 고시가 있는 날부터 30일 이내에 미동의자에게 동의 여부를 회답할 것을 촉구하고, 미동의자가 2개월 이내에 회답하지 않으면 부동의하는 것으로 보고 2개월 이내에 매도를 청구할 수 있다. 반면에,
- ② 보상금증감청구소송은 토지보상법 제85조 제1항의 제소기간이 적용되어 재결서 정본 송달일로부터 90일, 이의재결서 정본 송달일로부터 60일 이내 각각 소송을 제기할 수 있다.

3) 원고와 피고

- ① 매도청구소송의 원고는 재건축조합이 되고 피고는 조합설립에 동의하지 아니한 자가 된다. 반면에,
- ② 보상금증상청구소송은 사업시행자와 피수용자가 각각 원고와 피고가 된다.

4) 감정평가 기준 및 방법

(1) 기준시점 (가격시점)

- ① 매도청구에 따른 감정평가는 도시정비법 제64조에 따라 매매계약 성립일을 기준으로 하고,
- ② 수용재결의 경우 토지보상법 제67조 제1항에 따라 수용재결일이 가격시점이 된다.

(2) 개발이익

- ① 매도청구에 따른 감정평가는 보상평가가 아니고 일반 시가평가이다.
여기에서 '시가'란 시가란 매도청구권이 행사된 당시의 토지나 건물의 객관적 거래가격으로서 재건축으로 인하여 발생할 것으로 예상되는 개발이익이 포함된 가격을 말한다. 반면에,
- ② 수용재결을 위한 보상평가는 해당 공익사업으로 인하여 토지등의 가격이 변동되었을 때에는 이를 고려하지 아니한다고 규정하고 있는 토지보상법 제67조 제2항에 따라 개발이익을 포함하지 않는다.

대법원 2009. 3. 26. 선고 2008다21549,21556,21563 판결

사업시행자가 주택재건축사업에 참가하지 않은 자에 대하여 도정법 제39조에 의한 매도청구권을 행사하면, 그 매도청구권 행사의 의사표시가 도달함과 동시에 주택재건축사업에 참가하지 않은 자의 토지나 건축물에 관하여 시가에 의한 매매계약이 성립되는 것인바, 이때의 시가란 매도청구권이 행사된 당시의 토지나 건물의 객관적 거래가격으로서, 노후되어 철거될 상태를 전제로 하거나 주택재건축사업이 시행되지 않은 현재의 현황을 전제로 한 거래가격이 아니라 그 토지나 건축물에 관하여 주택재건축사업이 시행된다는 것을 전제로 하여 토지나 건축물을 평가한 가격, 즉 재건축으로 인하여 발생할 것으로 예상되는 개발이익이 포함된 가격을 말한다.

(3) 사실상 사도

- ① 매도청구권 행사에 따른 평가는 시가평가이며 판례는 '토지의 현황이 도로일지라도 재건축사업이 시행될 것을 전제로 할 경우의 인근 대지 시가와 동일하게 평가하되, 각 토지의 형태, 주요 간선도로와의 접근성, 획지조건 등 개별요인을 고려하여 감액 평가하는 방법으로 산정하는 것이 타당하다'고 판시하고 있다. 반면에,
- ② 수용재결을 위한 보상평가는 토지보상법 시행규칙 제26조 제1항 2호에 의거 인근토지에 대한 평가액의 1/3 이내로 평가하여야 한다.

대법원 2014. 12. 11. 선고 2014다41698 판결

도시 및 주거환경정비법에 의한 주택재건축사업의 시행자가 같은 법 제39조 제2호에 따라 乙 등이 소유한 토지에 대하여 매도청구권을 행사하였는데, 토지 현황이 인근 주민의 통행에 제공된 도로 등인 사안에서, 토지의 현황이 도로일지라도 주택재건축사업이 추진되면 공동주택의 일부가 되는 이상 시가는 재건축사업이 시행될 것을 전제로 할 경우의 인근 대지 시가와 동일하게 평가하되, 각 토지의 형태, 주요 간선도로와의 접근성, 획지조건 등 개별요인을 고려하여 감액 평가하는 방법으로 산정하는 것이 타당한데도, 현황이 도로라는 사정만으로 인근 대지 가격의 1/3로 감액한 평가액을 기준으로 시가를 산정한 원심판결에 법리오해의 잘못이 있다고 한 사례.

대법원 2012. 3. 22. 선고 2011두6400 전원합의체 판결

[판시사항]

도시 및 주거환경정비법상 이전고시가 효력을 발생한 이후에도 조합원 등이 관리처분계획의 취소 또는 무효확인을 구할 법률상 이익이 있는지 여부(소극)

[판결요지]

이전고시의 효력 발생으로 이미 대다수 조합원 등에 대하여 확실히·일률적으로 처리된 권리귀속 관계를 모두 무효화하고 다시 처음부터 관리처분계획을 수립하여 이전고시 절차를 거치도록 하는 것은 정비사업의 공익적·단체법적 성격에 배치되므로, 이전고시가 효력을 발생하게 된 이후에는 조합원 등이 관리처분계획의 취소 또는 무효확인을 구할 법률상 이익이 없다고 봄이 타당하다.